StuDocu.com

Diritto costituzionale martines 24

DIRITTO COSTITUZIONALE (Università degli Studi di Bari)



Parte prima- Capitolo I –Comunità e diritto

1-I gruppi e gli interessi sociali ed il loro principio ordinatore. Fenomeno giuridico e fenomeno associativo.-L'uomo non può vivere isolato, ma è in continua relazione con i suoi simili, assieme ai quali costituisce dei gruppi sociali, dei quali entra a far parte o necessariamente, senza alcuna determinazione di volontà (ciascuno di noi fa parte del gruppo sociale Stato per il solo fatto di essere nato da padre o madre italiani); o volontariamente, quando, per libera determinazione, ci si associa a un gruppo già costituito, ovvero lo si costituisce insieme ad altri. La ragione prima per cui l'uomo tende ad unirsi ad altri uomini deve rinvenirsi nell'esistenza di bisogni ed esigenze che per loro natura non possono essere soddisfatti dall'uomo isolato, ma solo collettivamente. Gli interessi si distinguono in *individuali* e *collettivi*; i primi possono essere puramente egoistici; i secondi, invece, sono quegli interessi che non possono essere soddisfatti se non prevalentemente o esclusivamente in forma associata. Se poi ci si astrae dall'interesse individuale, considerando il gruppo come entità a sé stante, si avrà l'*interesse generale*, che non è proprio dei singoli ma li trascende, anche se ha pur sempre come riferimento l'uomo e la dimensione in cui vive e agisce. Negli ordinamenti contemporanei con il moltiplicarsi delle esigenze collettive, nascono gli *interessi diffusi*, alcuni dei quali hanno ad oggetto beni, quali il paesaggio, l'ambiente, la salute, che sono direttamente tutelati dalla Costituzione e dagli Statuti delle Regioni di diritto comune. Si pensi al progressivo restringersi e all'inquinamento di alcune risorse come l'acqua e l'aria, che sono da considerare più beni economici che comuni. L'interesse alla conservazione e alla fruizione di tali beni non può propriamente dirsi collettivo, giacché non attiene all'individuo in quanto membro di un gruppo e perché per la sua tutela l'uomo non ha bisogno di associarsi ad altri uomini. Gli interessi diffusi non hanno un centro di riferimento ed appartengono ad una categoria indeterminata e aperta di soggetti non collegati tra loro da alcun vincolo associativo (ad es. i consumatori, i malati, etc.). Possiamo dunque delineare un graduazione degli interessi umani che dall'interesse individuale egoistico giunge, attraverso l'interesse collettivo, sino a quello generale, che tutti li racchiude. Gli interessi umani appaiono ordinati secondo un principio di confliggenza composizione, vigente sia fra interessi dello stesso gruppo che tra interessi di grado diverso. Un gruppo sociale in cui lo svolgimento di detto principio fosse affidato esclusivamente agli istinti irrazionali e all'egoismo dei singoli non è neanche pensabile, in quanto non saprebbe neppure assicurare la sua stessa sopravvivenza. Un gruppo sociale può dirsi costituito quando al principio di confliggenza-composizione degli interessi umani se ne contrappone un altro, il *principio ordinatore* che, senza annullarlo, lo disciplina assicurando la coesione

This document is available free of charge on StuDocu.com

interna del gruppo. Questo principio rappresenta la condicio sine qua non del gruppo, ne esprime l'essenza. Esso può operare, nel gruppo, facendo coincidere l'interesse di uno solo (tirannia), di un ristretto numero (oligarchia) degli associati con l'interesse del gruppo; ovvero assicurando la salvaguardia ed il proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i consociati (democrazia). L'interesse generale, che racchiude gli altri interessi, è e non può non essere proprio di gruppi sociali a fini (potenzialmente) generali, di quelle società che si usa definire politiche. Un gruppo sociale viene ad esistere ancor prima che si dia delle regole atte a preordinarne le strutture. Affinchè queste regole siano espresse è necessario che vi sia la volontà di esprimerle e di comporre gli interessi in conflitto. Procedure e strutture sociali sono un posterius rispetto alla formazione del gruppo. Esse,tuttavia, assolvono ad un'essenziale funzione, detta *organizzativa*, diretta a dare al gruppo il carattere della continuità e della stabilità nel tempo. Le regole organizzative specificano e fissano il vincolo associativo. La stabilità e la continuità nel tempo del gruppo, derivante dalla organizzazione, vale a distinguere il gruppo sociale da ogni forma episodica di aggregazione umana. Un gruppo sociale senza organizzazione è una contraddizione in termini. Esaminiamo, ad esempio, la famiglia che l'art. 29 Cost. definisce società naturale e che rappresenta il gruppo sociale primigenio. L'organizzazione della famiglia è determinata da un duplice ordine di norme: quelle poste da un'autorità esterna alla famiglia e contenute nella Cost. e nel c. c. e quelle poste all'interno di questa società naturale. Quindi avremo un'organizzazione tipo della famiglia predisposta dall'ordinamento giuridico italiano ed una organizzazione spontanea, che può corrispondere o meno con quella predisposta dallo Stato. Nell'ipotesi in cui le regole organizzative siano eteronome, il gruppo sociale verrà ad esistenza ed acquisterà i caratteri della stabilità e della continuità quando sarà presente l'altro elemento essenziale per la sua costituzione, cioè il fatto razionale creatore del vincolo associativo e queste regole avranno ottenuto l'assenso espresso o tacito dei componenti il gruppo e siano osservate o fatte osservare. Non è dunque sufficiente prevedere in astratto che il gruppo abbia un'organizzazione, perché venga ad esistenza. È necessario che l'organizzazione sia operante, che le regole vengano osservate spontaneamente o fatte osservare coattivamente e che, in caso di loro violazione, si provochi una reazione sociale, con conseguente applicazione di una sanzione. È necessario, insomma, che le regole, oltre che poste, siano effettivamente vigenti e perché siano effettivamente vigenti occorre che continuino ad essere sorrette e legittimate dal fatto razionale che ha originato il gruppo. Segno esteriore di codesta legittimazione sarà l'osservanza delle regole da parte del maggior numero di coloro ai quali si indirizzano, osservanza dovuta non tanto alla minaccia della sanzione ma al diffuso convincimento che tali regole assicurano la sussistenza del gruppo sociale.

Ritornando alla famiglia, essa esisterà come società naturale fino a quando avrà un'organizzazione autonoma vigente, cioè sino a quando i suoi componenti obbediranno alle regole che la famiglia si sarà date. Altrimenti si disgregherà e continuerà ad esistere solo come istituto giuridico, regolato dalle norme di Costituzione e c. c. . Tutto ciò vale anche per quei gruppi sociali che non ricevono da norme statali una disciplina particolare (associazioni non riconosciute, come partiti politici e sindacati). L'associazione partito o sindacato resterà in vita fino a quando la sua organizzazione sarà legittimata dalla volontà degli associati di osservarne e farne osservare le regole. A fondamento di ogni gruppo sociale possiamo porre un principio ordinatore ed un complesso di regole che, insieme alla struttura, ne costituiscono l'organizzazione. Questi due elementi, principio ordinatore ed organizzazione, valgono ad imprimere al gruppo il carattere della *giuridicità*. Il fenomeno giuridico è connaturato al fenomeno associativo (ubi societas ibi ius). Il diritto ha due componenti, una formale ed una materiale, connesse e inscindibili. Il diritto non si esaurisce nella forma, perché in tal caso si avrebbe pura astrazione. Le regole organizzative non assumono alcuna qualificazione, sono fini a se stesse e dirette a determinare strutture e procedure per la composizione e il soddisfacimento degli interessi. Ad es. l'art. 70 Cost. che statuisce "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere", si limita ad attribuire la funzione legislativa alle due Camere e a stabilire la procedura per l'esercizio della detta funzione. Le regole organizzative, insomma, non esprimono giudizi di valore ma costituiscono modelli di composizione e soddisfacimento degli interessi. Un giudizio di valore viene espresso nelle regole con le quali, a seconda dei casi, il gruppo o parte di esso stabiliscono che determinati interessi assumono rilevanza rispetto ad altri e vanno tutelati a preferenza di altri. Il fenomeno giuridico non si esaurisce nel fenomeno associativo, poiché accanto alle regole organizzative devono porsi altre regole, che fissino i vari tipi di interesse attorno ai quali il gruppo si è costituito. Appartengono a questo tipo di regole, ad es. , quelle che stabiliscono quali diritti sono attribuiti ai soggetti dell'ordinamento. Le *regole istituzionali* proprio perché esprimono gli interessi intorno ai quali il gruppo si è costituito, potranno dirsi tali in quanto trovino corrispondenza nella realtà sociale. Potremmo porci il problema del linguaggio del legislatore, essendo talvolta ambiguo il testo delle leggi. Le regole istituzionali sono strettamente connesse ai valori del gruppo e come questi ultimi risentono dell'evoluzione spaziale e temporale e delle ideologie che animano il gruppo. Il diritto, perché sia veramente tale e non si riduca a una serie di pure formulazioni verbali, dovrà essere il prodotto, l'espressione, la vita stessa di una data comunità sociale in un dato momento storico, colta in uno dei momenti più alti della condizione umana, che è quello associativo organizzativo.

This document is available free of charge on StuDocu.com

2-La teoria istituzionale del Romano e la dottrina pure del diritto di Kelsen. La concezione istituzionale del diritto nel pensiero del Mortati.- La teoria istituzionale del diritto è quella che collega il fenomeno giuridico al gruppo sociale, ad ogni gruppo sociale, escludendo di conseguenza che vi sia un solo ordinamento, quello statale. Secondo questa concezione, ogni gruppo sociale crea un proprio ordinamento giuridico autonomo da quello dello Stato. Gierke, ad esempio, afferma che è capace di produrre diritto ogni comunità organica, aggiungendo che abilitato a produrre diritto è soprattutto lo Stato come comunità popolare organizzata, ma anche la Chiesa, il Comune ed ogni collettività. Santi Romano ha da un lato giuridicizzato il concetto di "istituzione" ed ha sostituito questo concetto a quello di comunità, dall'altro ha affermato che il diritto non si esaurisce in un complesso di norme ma è l'istituzione stessa. Dal principio per cui "ubi societas ibi ius" e viceversa, il Romano trae il corollario che il concetto del diritto deve contenere l'idea dell'ordine sociale. In quanto fenomeno sociale, l'ordinamento giuridico presuppone necessariamente l'organizzazione e la struttura. Il *concetto di istituzione* è quello che per il Romano meglio esprime la simbiosi esistente tra norma, organizzazione e pluralità dei soggetti e interessi coinvolti nella società. Ordinamento giuridico ed istituzione sono pertanto la stessa cosa; il diritto nasce e vive nella concretezza dell'istituzione. Merito indiscusso della teoria istituzionale del Romano è quello di aver sottolineato che il fenomeno giuridico non si esaurisce nel fenomeno normativo, il fatto stesso dell'organizzazione imprime ad un gruppo sociale il carattere della giuridicità. Tuttavia, la teoria istituzionale non riesce a superare un vuoto logico. Infatti, il Romano individua con precisione i caratteri esteriori della istituzione, ma ne dà per presupposta l'intima essenza che è data dal fenomeno associativo. Secondo la *teoria pura del diritto*, invece, il diritto si esaurirebbe nelle norme intese come comandi, imperativi. Kelsen, illustre rappresentante di questa teoria, sostiene che il giurista deve limitarsi a chiarire cosa sia il diritto e come si presenti. Il diritto è un sistema di norme che regolano comportamenti umani e la norma è uno schema qualificativo di un fatto esteriore. Tutte le norme traggono fondamento da una norma fondamentale, da cui si deduce la validità di tutte le altre. Per K. il diritto è un sistema di norme regolanti o superiori e regolate o inferiori, secondo una costruzione a gradi. Ciascuna norma è condizione di validità di un'altra e condizionata da una norma superiore. Tale ricerca finisce con una norma suprema, che è presupposta con riferimento ad una costituzione statuita ed efficace. La teoria pura del diritto è stata oggetto di critiche. Alla concezione istituzionale si rifà *Mortati,* che sostiene che la sola considerazione della serie delle norme da una visione monca del fenomeno giuridico. Da qui la necessità di risalire dalle norme alla istituzione, che risulta dalla intima struttura associativa impressa al gruppo dalla distribuzione di forze e controforze.

Così intesa l'istituzione appare come sinonimo di costituzione, nel significato più proprio di fondamentale legge di vita.

3. Il diritto e gli altri fenomeni sociali- Il Romano, il Kelsen ed il Mortati si riferiscono ad un assetto fondamentale, individuato dal Romano nella istituzione, dal Kelsen nella norma fondamentale, dal Mortati nel gruppo sociale. La tesi della socialità del diritto trova, dunque, ulteriore conferma. Kelsen stesso afferma che le norme giuridiche regolano comportamenti umani e pertanto l'ordinamento giuridico è un ordinamento sociale e, per la sua natura coercitiva, è diretto ad assicurare la sicurezza collettiva. Siffatta conclusione, tuttavia, non vale ad isolare il fenomeno giuridico dagli altri fenomeni sociali. Dalle norme del c.c., del c. p., si evince come spesso un fatto economico, morale e religioso è assunto a contenuto di una norma giuridica. Le regole economiche, morali o religiose non valgono di per se stesse ad assicurare la sicurezza sociale. Sono regole sociali, ma presuppongono l'esistenza del gruppo e non valgono a costituirlo. Solo il diritto vale a creare il gruppo sociale e a conferirgli stabilità e continuità nel tempo, mediante norme coattive. Le società umane nascono da un fatto razionale di composizione degli interessi configgenti e l'organizzazione stabilizza il fattore di coesione, dato dalla forza e dal consenso. Il diritto è un fatto razionale di composizione di interessi (elemento materiale), composizione stabilizzata nel tempo da norme di organizzazione (elemento formale).Essenza del diritto, a differenza delle altre regole sociali, è quella di comporre il pluralismo e mantenere uniti gli uomini tra loro.

4. La costituzione in senso formale e materiale. La costituzione come processo- Il problema della fonte prima e suprema dell'ordinamento è stato preso in esame dal Mortati con la teoria della costituzione materiale, intendendo con essa " quel nucleo essenziale di fini e di forze che regge ogni singolo ordinamento positivo". L'elemento strumentale che compone il contenuto della costituzione materiale è dato dalle forze politiche. L'elemento materiale è dato dallo scopo unificatore che aggrega i vari interessi intorno allo stato. La costituzione in senso materiale si identifica nelle forze politiche che in un dato momento storico interpretano attivamente l'interesse della comunità politica. A quanti criticano questa teoria, per la natura sociologica dei fenomeni considerati (forze politiche e scopo unificatore), Mortati risponde che si tratta pur sempre di una ricerca squisitamente giuridica. A chi, invece, sottolinea il pericolo del dualismo con la cost. formale, Mortati risponde che bisogna riportare la validità della costituzione alla sua effettività. Il diritto non è l'insieme di norme contenute in un testo di legge, ma è il complesso di situazioni e rapporti che si coagula in un centro di autorità e va a costituire il diritto "vivente", valido come tale anche se contrastante con quello legale. Ed è qui che la cost. materiale mostra il suo

This document is available free of charge on StuDocu.com

maggior valore, ove, cioè, si metta a confronto con la costituzione formale (data dal documento contenente le norme costituzionali). Le due costituzioni possono, in tutto o in parte divergere. Si tratta allora di eliminare le ragioni del contrasto o modificando la costituzione formale per adeguarla a quella materiale, laddove sia sorto un diverso modo di intendere l'assetto dello Stato; o di affermare la forza della costituzione formale, laddove le sue prescrizioni conservino tutta la loro vigenza. Costituzione formale e materiale possono non collidere quando, assimilando la prima al progetto di un edificio da costruire e la seconda all'edificio in costruzione, si dimostri che la costruzione ha rispettato le linee fondamentali del progetto. La costituzione materiale non è che la cost. formale nel suo farsi e nel suo divenire. Non bisogna identificare la cost. materiale con la mera effettività della forza. L'innovazione dei principi, i contesti nazionali e sopranazionali, la giurisprudenza, la prassi etc, fanno sì che la costituzione si crei e ricrei continuamente. Non bisogna considerarla in modo statico, ma come un processo. È come se si formasse una catena formata da molti anelli, il primo dei quali è la costituzione formale e l'ultimo la costituzione materiale. La differenza tra le due è naturale, ma si può sempre risalire dall'ultimo anello al primo. La Costituzione italiana di oggi è ben diversa da quella votata dall'Assemblea Costituente nel1947, così come quella attuale degli Stati Uniti è diversa dalla Dichiarazione di Filadelfia del 1787. Resta però possibile risalire dall'una all'altra. La stessa operazione non sarebbe possibile tra la Costituzione repubblicana e lo Statuto Albertino: il fascismo, la guerra e i nuovi valori hanno introdotto una radicale discontinuità tra i due sistemi costituzionali. La costituzione come processo rappresenta la chiave di lettura dell'evoluzione costituzionale.

5. La dottrina del diritto naturale. La pluralità degli ordinamenti giuridici. Socialità e storicità del diritto.- Il fenomeno giuridico è un fenomeno sociale, proprio delle società umane. Non si rinviene in natura come quei fenomeni detti naturali. A meno che non lo si intenda tale perché intimamente legato all'uomo, che fa anch'esso parte del creato. Riferimento alla natura è stato fatto da parte della dottrina del diritto naturale, di cui nel tempo sono state date due fondamentali accezioni. Secondo una prima, il diritto naturale possiede i caratteri dell'assolutezza, certezza, oggettività, eternità: sarebbe dunque il solo vero e giusto diritto. La seconda, più recente, considera che anche il diritto naturale dovrebbe essere ricondotto alla relatività e storicità della condizione umana. La dottrina del diritto naturale sembra rispondere ad un'esigenza sempre avvertita: sottrarre il diritto alla mutevolezza del divenire quotidiano. Oggi noi uomini dell'occidente abbiamo alcuni punti fermi, primo fra tutti il bisogno di mettere dei limiti ben netti ai poteri dello Stato. Lo Stato di diritto non è che un prodotto del diritto naturale così come la garanzia internazionale dei

diritti dell'uomo ne è una moderna applicazione. Molti articoli della Cost. italiana sono riportati al diritto naturale: l'art.3, l'art. 2 e molti artt. della *Parte I Diritti e doveri dei cittadini.* Il pluralismo giuridico trova il suo antecedente nel pluralismo sociologico ed entrambi riflettono l'opposizione alla statualità del diritto, allo Stato come unico centro del sistema. Da qui il riconoscimento a gruppi sociali stanziati sul territorio della potestà di darsi un proprio ordinamento le cui norme sono equiparate a quelle dello Stato (autonomia), si pensi a Regioni, Province, Comuni. La nostra Cost., riconosce alle confessioni religiose diverse dalla cattolica il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Essa non si limita a garantire le *formazioni sociali* ma riconosce ordinamenti giuridici diversi dallo Stato. La molteplicità e varietà dei gruppi sociali deve essere ricondotta ad'unità e armonia e ciò è possibile solo attraverso lo Stato, l'unica società cui si possano attribuire interessi veramente generali. Per Stato oggi dobbiamo intendere lo *Stato costituzionale* che è dato dall'unione di popolo, autorità e valori posti a fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato in senso stretto non è che una componente della Repubblica. Ciò appare più chiaro dalla lettura degli artt. 114 e 117 Cost., dopo la riforma del titolo V della Parte II con legge cost. n 3 del 2001. Il fenomeno giuridico è strettamente connesso a quello associativo. Quindi si afferma la storicità e socialità del diritto. Non bisogna dimenticare che la fonte prima del diritto risiede nell'esigenza dell'uomo di associarsi ad altri uomini per soddisfare alcuni suoi interessi.

6. Diritto pubblico e diritto privato. – Il fine proprio del diritto può essere perseguito direttamente perseguendo fini pubblici o indirettamente perseguendo fini individuali. Questa distinzione risale al giureconsulto romano Ulpiano e da qui deriva la tradizionale bipartizione del diritto in pubblico e privato. Oggi bisogna tener presente che questa distinzione va, per certi versi, sfumando. Si pensi alla pubblicizzazione del diritto privato (la disciplina dei rapporti di dir.privato va sempre più diventando di interesse generale). Inoltre, esistono zone dell'ordinamento dove confluiscono interessi pubblici e privati. Si pensi al diritto tributario, al diritto del lavoro, al diritto della navigazione. Spesso gli interessi tutelati non sono né pubblici, né individuali ma collettivi (i lavoratori iscritti a un sindacato, i cittadini iscritti a un partito). A meno che non si voglia far prevalere il momento terminale della tutela che attiene ad un interesse individuale. Una tesi opposta assegna preminenza sempre e comunque all'interesse pubblico. Appartengono al diritto pubblico le norme del diritto costituzionale, regionale, penale, parlamentare, processuale civile e penale, internazionale, tributario, ecclesiastico, ecc. Mentre fanno capo al d. privato le norme contenute nel codice civile che disciplinano i rapporti tra privati. Rilievo particolare assumono le norme del diritto costituzionale. Più che un ramo dell'ordinamento, il diritto costituzionale ne rappresenta lo stesso tronco.

This document is available free of charge on StuDocu.com

Capitolo 2- Le fonti del diritto

1. Delimitazione dell'indagine- Vi sono una serie di valori che assicurano la vigenza del sistema nel suo complesso; una serie di regole in cui questi valori vengono fissati in una formulazione linguistica; una serie di regole che stabiliscono organi e procedure per la produzione delle regole stesse e, infine, una serie di regole volte a coordinare il sistema nel suo complesso. La nostra Costituzione esprime dei valori fondamentali, tra cui quello dell'uguaglianza. Occorre che questo valore trovi applicazione, che sia operante. L'atto mediante il quale si raggiunge questo risultato è la legge e, quindi, la legge non potrà operare discriminazioni tra i cittadini basate su sesso, razza, lingua, religione etc.. Sappiamo che l'organo cui è affidata la funzione legislativa è il Parlamento, che, prendendo in considerazione il discorso sul valore uguaglianza, dovrà rispettare questo valore e non potrà emanare leggi contrarie a questo principio, pena la dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale. Il diritto positivo è il diritto effettivamente vigente, posto in essere dagli organi deputati a tale scopo dall'ordinamento.

2. La norma giuridica- La giuridicità di una norma si misura dalla sua attitudine a garantire nel tempo continuità e stabilità al gruppo sociale. Questo dimostra l'intima connessione tra fenomeno sociale e fenomeno giuridico. Le norme giuridiche, qualora la fonte sia scritta, sono enucleate da formulazioni linguistiche che: evidenziano gli interessi propri del gruppo; prescrivono modi e limiti con cui i soggetti possono o devono perseguire tali interessi; stabiliscono gli organi e le procedure per accertare e dichiarare l'inosservanza delle prescrizioni; stabiliscono la sanzione da applicare ai trasgressori. Destinatari delle norme giuridiche sono o tutti i consociati (si pensi all'art.24 "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi") o alcuni di essi individuabili sulla base del possesso di determinate caratteristiche (art.34 che riconosce il diritto di accedere ai gradi più alti dell'istruzione ai capaci e ai meritevoli che non abbiano mezzi sufficienti). Le norme possono avere come destinatari singoli individui (si pensi alla legge che attribuisce il diritto alla pensione alla vedova di un'illustre personalità) o anche soggetti dello Stato-apparato o non avere alcun destinatario e limitarsi a esprimere principi cardine dell'ordinamento (art.13 inviolabilità della libertà personale). I caratteri ricorrenti delle norme giuridiche sono: **positività, generalità, astrattezza, coattività, esteriorità.** *Positività-* la norma giuridica deve essere positiva, vale a dire deve enunciare un interesse effettivamente vigente nella società e predisporre gli strumenti per la sua soddisfazione e tutela. Il carattere della positività è strettamente connesso a quello della **effettività**, la concreta efficacia della norma. Una norma è effettiva quando ottiene un'obbedienza media da parte dei suoi destinatari, cioè è rispettata dalla maggior parte dei soggetti cui si indirizza. L'effettività- positività considera la norma anche per come si applica nelle aule giudiziarie, negli uffici amministrativi e

nei rapporti tra privati. *Coattività*- la norma giuridica è coattiva, nel senso che, qualora l'interesse della comunità richieda la sua puntuale osservanza, l'ordinamento appresta gli strumenti (sanzioni) affinchè il precetto sia eseguito anche contro o in assenza della volontà del destinatario. Coattività e sanzione vanno di pari passo. Tuttavia, non tutte le norme giuridiche esprimono un precetto assistito da una sanzione, perché accanto alle norme coattive vi sono quelle che coattive non sono. Si pensi alle norme istituzionali, definitorie, programmatiche, a quelle che attribuiscono situazioni attive in genere, a quelle promozionali e d'incentivazione. Questo non significa che queste norme possono venire violate. Esse sono positive, cioè esprimono un valore proprio del gruppo sociale. Si pensi all'art. 1 comma 1 della Costituzione: la natura democratica e repubblicana del nostro Stato deve essere rispettata sia a livello di stato apparato che di comunità sociale. Si faccia riferimento al comma I dell'art. 4 Cost., in cui la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendano effettivo. Gli organi di indirizzo politico, Parlamento e Governo, dovranno adoperarsi per perseguire questo fine e in caso contrario potranno applicarsi sanzioni di natura politica a loro carico (voto di sfiducia, scioglimento di una o di ambedue le Camere, mancata rielezione dei parlamentari). *Esteriorità*- il carattere dell'esteriorità della norma giuridica risiede nel fatto che disciplina la vita di relazione e ne organizza i modi di svolgimento a differenza di quelle regole sociali che ciascuno formula per se stesso e non incidono sulla vita associata. *Generalità e astrattezza*- la norma giuridica per essere tale deve possedere i requisiti della generalità e dell'astrattezza. La generalità consiste nell'attitudine della norma a regolare una serie di fatti o comportamenti senza riferimento a situazioni o soggetti determinati (es. art.53 "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"). L'astrattezza risiede nell'attitudine della norma a disporre in via ipotetica e secondo uno schema logico per cui se si verifica l'evento A deve verificarsi l'evento B. Questo carattere è, però, ormai controverso poiché la società attuale è frammentata in gruppi che richiedono trattamenti normativi differenziati. Questo va a discapito della certezza del diritto. Le leggi speciali individuano una species rispetto a un genus. Le leggi eccezionali individuano una deroga rispetto a una norma generale, come nel caso della sospensione del decorso dei termini processuali dal I agosto al 15 settembre. Dubbi possono sorgere sull'ammissibilità delle cd **leggi personali,** quelle leggi che hanno per destinatari soggetti singoli e determinati e con le quali vengono assunti provvedimenti concreti, le **leggi provvedimento.** Questi atti hanno la forza propria della legge ma non anche natura normativa, cioè non introducono nell'ordinamento norme giuridiche. Si consideri l'atto amministrativo con cui il comune o lo Stato dispongono l'espropriazione per pubblica utilità di un bene e la legge con cui il Parlamento a

This document is available free of charge on StuDocu.com

norma dell'art. 43 Cost. espropria un'impresa che si riferisca a servizi pubblici essenziali. Gli effetti sono i medesimi: il trasferimento di proprietà dall'espropriato all'espropriante. Ma avverso l'atto amministrativo l'espropriato potrà esperire i normali ricorsi in via amministrativa e giudiziaria; mentre, contro la legge espropriatrice non potrà che impugnarla per illegittimità costituzionale per vizi formali o sostanziali dell'atto. Le leggi provvedimento costituiscono un caso di deroga al principio della divisione dei poteri, non potendo il legislatore ordinario emanare atti a contenuto concreto, questo compito essendo proprio delle autorità amministrative. La legge provvedimento è uno strumento per raggiungere in via diretta e immediata i fini dello Stato sociale. Ma la sua ammissibilità ci pare incidere non sui caratteri di generalità ed astrattezza, ma sul fatto che la legge debba avere un contenuto tipico. Concezione peraltro ampiamente superata. **La norma giuridica è una prescrizione generale ed astratta che identifica gli interessi vigenti in un gruppo sociale ed appresta gli strumenti per la loro tutela e il loro soddisfacimento. Di essa va, pertanto, garantita l'osservanza.**

3. Fonti di produzione e fonti sulla produzione; fonti atti e fonti fatti; fonti dirette e fonti indirette; fonti di cognizione- le norme giuridiche sono desumibili, generalmente, da una formulazione linguistica scritta (che assume la forma tipica ed il *nomen iuris* degli atti normativi: legge, decreto legge, regolamento etc). Ciò al fine di conferire loro un certo grado di certezza e stabilità. Testo scritto e norma costituiscono due entità distinte che non vanno confuse, in quanto la norma è esterna all'atto che l'ha posta e non si identifica con la statuizione legislativa o **formula normativa o disposizione** risultante da uno o più articoli di un testo normativo. È l'interprete che deve enucleare la norma dalla statuizione legislativa. In presenza di una fonte del diritto è dato distinguere: **-l'aspetto formale,** vale a dire l'atto in quanto posto in essere secondo una data procedura (legge, decreto legge, regolamento); **- l'aspetto sostanziale o formula normativa o disposizione,** ciò che con l'atto viene disposto; **- la norma giuridica desumibile, in via interpretativa, dall'atto e dalla relativa disposizione.** La norma può essere desunta anche da un comportamento che assuma determinate caratteristiche **(consuetudine).** Le ***fonti normative*** sono, dunque, quegli atti e quei fatti mediante i quali sono poste le norme giuridiche. La fonte è lo strumento tecnico predisposto dall'ordinamento per produrre il diritto oggettivo. Per questo sono dette **fonti di produzione.** Ma le fonti di produzione sono a loro volta predisposte dall'ordinamento, che disciplina organi e procedure necessarie alla produzione delle norme. Ad es. l'art. 70 Cost. "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere", stabilisce quali organi sono deputati a formare le leggi, mentre l'art. 72 determina la procedura. Queste sono fonti di produzione che

sono, al tempo stesso, **fonti sulla produzione.** Esse sono, di regola, contenute nella Costituzione, per il loro rilievo formale e sostanziale. Le fonti si distinguono in *fonti fatti e fonti atti. Le fonti atti* sono costituite da manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato soggetto o di altro ente a ciò legittimato dalla Costituzione e trovano la loro formulazione in un testo scritto **(fonti scritte).** Le *fonti-fatti* consistono in un comportamento oggettivo **(consuetudine o uso)** o in atti giuridici esterni al nostro ordinamento (si pensi ad un trattato internazionale reso esecutivo in Italia) gli uni e gli altri riconducibili alla categoria delle **fonti non scritte.** La distinzione tra fonti fatti e fonti atti assume rilievo ove si osservi che vale a determinare la competenza della Corte Cost. che, a norma dell'art.134 comma II Cost., può sindacare la conformità alla Cost. delle fonti atti e non già delle fonti fatti e, più in particolare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge di Stato e Regioni. Si distingue inoltre tra *fonti dirette e indirette.* Si hanno le prime quando la fonte è prevista nello stesso ordinamento, le seconde quando essa è disciplinata in un ordinamento esterno a quello dello Stato. In questo ultimo caso è necessario che la norma sia recepita o resa efficace nell'ordinamento in cui la si vuole applicare. Fra le fonti del diritto viene annoverata anche la *necessità*, intesa come elemento intrinseco di un'attività che senza si esso sarebbe contraria al sistema legale delle fonti. Qui non si intende quello stato di necessità previsto quale condizione per l'emanazione di un atto o il compimento di un'attività in deroga all'ordine prestabilito delle competenze , come nel caso dei decreti legge ai sensi dell'art.77 Cost. c'è chi nega che la necessità operi come fonte, in quanto la valutazione sulla sua sussistenza è sempre politica e contingente. Dalle fonti di e sulla produzione vanno distinte le fonti **di cognizione,** locuzione impropria che sta ad indicare i documenti ufficiali nei quali sono racchiuse le disposizioni normative (La Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, la Raccolta degli usi vigenti in una determinata Provincia stilata dalle camere di commercio, ecc).

4. Le fonti sulla produzione nell'ordinamento italiano- l'ordinamento giuridico italiano è il prodotto sia di fonti fatti che di fonti atti, sia di fonti dirette che indirette. Le fonti sulla produzione nella Costituzione sono indicate agli articoli: 138 legge costituzionale; 70 legge ordinaria; 76 decreto legislativo; 77 decreto legge; 87 regolamenti governativi; 39 contratto collettivo di lavoro; 64 regolamenti parlamentari; 137 regolamenti Corte Cost.; 116 Statuti regionali speciali; 123 Statuti regioni ordinarie; 10 adattamento automatico; 80 legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali contenenti ordine di esecuzione. La Costituzione è preordinata a tutte le altre fonti, è la fonte delle fonti. Secondo una diversa tesi essa sarebbe inserita nell'ordine delle fonti, al primo posto. Il procedimento di formazione

This document is available free of charge on StuDocu.com

delle fonti indicate nella Costituzione è spesso disciplinato in altri testi normativi. Per i regolamenti governativi l'art.87, che li disciplina nella fase finale, rimanda per le altre fasi alla legge 400 del 1988; per i referendum abrogativi delle leggi delle Regioni l'art.123 rinvia agli Statuti. Altre fonti non sono neppure previste nella Cost., pur dovendo in essa trovare legittimazione. Si pensi ai bandi militari, il cui fondamento si fa risalire all'art.78 Cost., a norma del quale, in caso di guerra, le Camere conferiscono al Governo i poteri necessari; alle fonti dell'UE il cui fondamento si rinviene nell'art'11, in quella parte in cui dispone che l'Italia acconsente alle limitazioni alla sua sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo; gli statuti e i regolamenti degli enti pubblici non territoriali (cd enti parastatali, camere di commercio) la cui legittimità risiede nel principio di autonomia e decentramento di cui all'art.5. La Cost. non menziona la consuetudine e si limita a legittimare come fatti normativi le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art.10) così come non menziona il procedimento per l'immissione nell'ordinamento giuridico italiani di norme poste in ordinamenti giuridici stranieri (rinvio). L'ordinamento giuridico italiano contempla una varietà e pluralità di fonti, ma tutte sono ricondotte ad armonia dalla Costituzione.

Fonti atti: Statali: leggi costituzionali, leggi ordinarie, atti aventi forza di legge (decreti legge, leggi delegati, decreti attuativi degli Statuti speciali, referendum abrogativo).

Fonti atti Non statali: regionali : statuti ordinari, leggi regionali, referendum abrogativo regolamenti regionali. Provinciali: leggi e regolamenti delle province di Trento e Bolzano, statuti e regolamenti provinciali. Statuti e regolamenti comunali. Regolamenti di enti non territoriali.

Fonti atti esterne all'ordinamento statale: fonti comunitarie.

Fonti fatti: consuetudine, necessità, norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, accordi internazionali, fonti straniere richiamate nell'ordinamento italiano.

5. La delegificazione, la semplificazione normativa ed il meccanismo cd taglia-leggi. La complessità e varietà delle fonti, la difficoltà di comporre le antinomie che tra esse possono verificarsi, le numerose fonti extra ordinem e l'eccessiva produzione legislativa hanno posto all'attenzione di dottrina ed organi di governo il problema della **delegificazione.** Si tratta di esaminare se è possibile porre un freno

all'inflazione delle leggi (secondo una stima prudenziale in Italia sarebbero in vigore circa 50000 leggi) sottraendo al legislatore il potere di disciplinare una materia che non sia legislativa, giungendo a delegificare intere materie o settori di esse per attribuirli alla competenza dell'esecutivo. Siffatto problema sarebbe, almeno in parte, risolto se si accogliesse la tesi di chi ritiene che l'organizzazione dei pubblici uffici è attribuita, dall'art.97 comma I Cost., proprio all'esecutivo e non al legislatore ordinario e che l'esecutivo gode in materia di una vera e propria riserva di regolamento. L'emanazione di una legge in una materia sostanzialmente non legislativa si rende alle volte necessaria perché detta materia è già disciplinata da una legge, cosicché il regolamento (atto gerarchicamente subordinato) non può intervenire a modificare le norme in essa contenute. Per non incorrere in un processo infinito, non resta che delegificare la materia. La delegificazione in senso tecnico consiste nel decongestionare il Parlamento da attività superflue, non consone alle funzioni che esso dovrebbe svolgere in una moderna democrazia, mediante una legge che trasferisca certe discipline dalla sede legislativa a quella regolamentare. L'art. 17 della legge n.400 del 1988 dispone che con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per le materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Cost., per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le leggi generali regolatrici della materia disponendo l'abrogazione delle norme vigenti, a partire dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con questo tipo di regolamenti, così nasce la riserva di regolamento in materia di organizzazione e funzionamento della P.A. . Con questo tipo di regolamenti il Governo autorizza l'attuazione delle direttive comunitarie. Nell'ultimo decennio si è assistito ad una successione di interventi volti a delegificare interi settori normativi e a semplificare i procedimenti amministrativi, da ultimo si pensi al codice del processo amministrativo. Sempre nell'obiettivo della semplificazione rientra la legge 246 del 2005, modificata nel 2009, che ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali, anteriori al 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Tutte le disposizioni non comprese nei suddetti decreti sono abrogate. Si è realizzato un meccanismo cd taglialeggi. Sono state escluse dalla sua applicazione le disposizioni legislative indispensabili: i codici, i testi unici, le disposizioni regolanti l'ordinamento degli organi costituzionali, delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, le disposizioni tributarie, ecc. Dalla delegificazione vanno distinte: la deregulation, che consiste nella riduzione dell'intervento dei poteri pubblici belle

This document is available free of charge on StuDocu.com

attività economiche, nel presupposto che tale intervento non è riuscito a migliorare l'allocazione delle risorse e la distribuzione del reddito; la denazionalizzazione o privatizzazione, che si ha quando lo Stato, già titolare di un'impresa o di un'attività, si ritira da tali campi e affida per intero a privati la relativa disciplina, che obbedirà, ove si tratti di attività economiche, alle regole del libero mercato ; la de burocratizzazione, tendente a rendere più agevole la P.A. mediante norme che snelliscano attività e procedimenti amministrativi.

6. I criteri per comporre le fonti in sistema- la varietà e molteplicità di fonti richiedono un criterio per il loro coordinamento in sistema. I criteri comunemente adottati sono: **gerarchico,** che consiste nell'ordinare le fonti secondo l'efficacia loro attribuita dall'ordinamento (la fonte di grado superiore prevale su quella di grado inferiore); **cronologico,** secondo il quale lex posterior derogat priori; **della separazione delle competenze,** in base al quale l'efficacia delle fonti viene distinta a seconda della sfera, territoriale o materiale, in cui essa opera. Il termine efficacia può essere inteso in senso formale e sostanziale. Se ci si riferisce alle fonti come atti o fatti mediante i quali vengono prodotte le norme giuridiche, esso acquista natura sostanziale ed indica l'attitudine della fonte a creare norme giuridiche; se ci si riferisce alle fonti come atti emanati da determinati organi secondo procedure prefissate, acquista natura puramente formale. Una legge provvedimento avrà efficacia solamente formale, ma la gran parte delle leggi e delle altre fonti avranno efficacia sia formale che sostanziale. Ciascuna fonte ha una sua misura di efficacia, che è data dall'ambito entro il quale essa può produrre diritto e tale ambito viene stabilito dall'ordinamento, che attribuisce a ciascuna fonte una sua forza (efficacia formale). Nella scala gerarchica delle fonti, la preminenza è assegnata alla legge del parlamento **(fonte primaria o di primo grado).** Ragioni storico-politiche stanno alla base di questa preminenza. Il passaggio dallo Stato assoluto a quello moderno o di diritto è segnato dalla sottrazione al monarca del potere di dettare norme costitutive dell'ordinamento per affidarlo ad assemblee istituite ad hoc, ritenendo che un organo collegiale meglio potesse effettuare l'identificazione degli interessi fondamentali.

Queste ragioni ancora oggi giustificano la preminenza della legge formale sulle altre fonti, anche se in alcuni ordinamenti a codesta preminenza non corrisponde la preminenza del Parlamento sul Governo. A quest'ultimo era originariamente riservata una limitata potestà normativa (regolamenti). Col tempo, l'intervento dello Stato in campi solitamente lasciati all'iniziativa privata e il rafforzarsi dei poteri dell'esecutivo hanno portato al riconoscimento al Governo del potere di emanare atti aventi la stessa efficacia della legge formale (decreti legge e decreti legislativi). La Costituzione non contiene un'elencazione esaustiva delle fonti, tuttavia esistono dei

punti fermi. La legge costituzionale sta in posizione di supremazia rispetto a tutte le altre fonti. Mediante tale fonte si può procedere, entro certi limiti, alla revisione o alla deroga della Cost. Le fonti in contrasto con la Cost. o con legge cost. possono essere dichiarate costituzionalmente illegittime e perdere ogni efficacia. Questa supremazia è causa ed effetto della procedura aggravata per l'approvazione di detta legge, cui può partecipare anche il corpo elettorale, mediante referendum. Tra tutte le altre fonti, la preferenza è assegnata alla legge del Parlamento, alla quale la Cost. espressamente riserva la disciplina di alcune materie. L'esercizio della funzione legislativa è affidato collettivamente alle due Camere (art. 70). Gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) sono disciplinati dalla Cost., con la previsione di limiti relativi all'oggetto e alla modalità di esercizio dei poteri normativi del Governo (artt. 76, 77). Efficacia sostanziale pari a quella della legge del Parlamento sembra doversi riconoscere anche al referendum abrogativo di una legge o di un atto avente valore di legge. Se è vero che mediante il referendum non si crea direttamente e immediatamente diritto, è pur vero che l'abrogazione di una o più norme non si esaurisce nel momento in cui il referendum spiega la sua efficacia, giacché provoca nell'ordinamento delle reazioni a catena. Il primo effetto è il venire a mancare di una norma e così una determinata fattispecie cessa di essere giuridicamente disciplinata. Questo modifica certamente l'ordinamento preesistente e può suscitare la necessità di colmare il vuoto normativo creatosi. Per questo, al referendum abrogativo può essere riconosciuta efficacia sostanziale pari a quella delle leggi di primo grado. *Controversa è l'ammissibilità tra le fonti dei bandi militari, atti emanati dal comandante supremo delle forze armate. Sembra trovino fondamento nell'art. 78 Cost., seppure si tratterebbe di una legittimazione indiretta. Pure controversa è l'efficacia dei decreti con cui il P.D.R. provvede all'attuazione degli Statuti di Friuli, Valle d'Aosta, Trentino. Non possono assimilarsi ai decreti legislativi e né occupare una posizione intermedia tra legge e Costituzione. Hanno carattere eccezionale.*

Tra la legge ed alcune fonti ad essa equiparate non esiste rapporto di pari ordinazione bensì di separazione. Si pensi alle leggi regionali che, a norma dell'art.117 Cost. , possono essere emanate nelle materie ivi indicate, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato. Lo Stato stabilisce i principi fondamentali e le Regioni legiferano nei limiti di detti principi. Lo Stato non può dettare norme di sviluppo e di dettaglio e le Regioni non possono porre norme di principio. Altre fonti separate sono i contratti collettivi di lavoro ed i regolamenti delle Camere. Tra la legge del Parlamento e gli atti governativi aventi la stessa efficacia, la Cost. assegna la preferenza alla prima, condizionando l'esercizio della funzione legislativa del Governo alla emanazione, da parte del Parlamento, di una legge che determini il tempo entro il quale il Governo potrà legiferare e l'oggetto della delega e i principi e i

This document is available free of charge on StuDocu.com

criteri direttivi, sia subordinando l'efficacia dei decreti legge alla conversione in legge formale entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

7. Le fonti aventi un'efficacia subordinata a quella della legge formale- Efficacia formale e sostanziale subordinata a quella della legge formale hanno, nella gerarchia delle fonti, i regolamenti governativi e di altre autorità. Un regolamento potrà immettere nuove norme nell'ordinamento in quanto queste norme non siano in contrasto con quelle contenute in leggi formali e in atti aventi eguale forza. L'art. 4 delle "Disposizioni sulla legge in generale" statuisce che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi ed aggiunge che i regolamenti delle autorità diverse dal Governo non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti governativi. Il rispetto del principio della supremazia della legge non esclude che esigenze pratiche giustifichino che una legge possa disporre l'abrogazione di norme vigenti, a partire dall'entrata in vigore di norme regolamentari con esse in contrasto *(regolamenti autorizzati)* o che un regolamento possa disciplinare una materia non disciplinata dalla legge, ponendosi in tal caso come unica fonte regolatrice. Sia nell'una che nell'altra ipotesi, la misura dell'efficacia sostanziale del regolamento è pari a quella della legge; ma ad essa non corrisponde una uguale efficacia formale, essendo i regolamenti considerati come fonti inferiori alla legge e, come tali, non sottoponibili al giudizio di legittimità costituzionale e soggetti solo al giudizio di legittimità da parte degli organi della giustizia amministrativa. Regolamenti statali non governativi (ministeriali e interministeriali) La subordinazione del regolamento alla legge appare ormai meramente superata: alcuni regolamenti possono operare deroghe alla legge primaria o dettare norme in materie riservate (non in via assoluta) alla legge. Però l'efficacia formale di questi regolamenti non è equiparata a quella della legge ai fini della loro impugnabilità innanzi alla Corte Cost. Secondo una tesi, ad essi andrebbe riconosciuta l'efficacia formale della legge e l'impugnabilità innanzi alla Corte Cost. Diversamente, la tesi opposta ritiene che essi siano ineluttabilmente subordinati alla legge.

8. I regolamenti degli organi costituzionali e degli organi a rilevanza costituzionale- Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale possono darsi, in virtù della posizione che assumono nell'ordinamento, regolamenti atti a disciplinare la loro organizzazione interna, lo stato giuridico ed economico del personale e il modo di esercizio delle funzioni. Si tratta dei **regolamenti delle Camere, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica, del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio dei ministri, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.** I regolamenti delle Camere non sono regolamenti in senso tecnico bensì delle fonti subordinate solo alla Costituzione, che danno

esecuzione a norme in essa contenute. Ponendo la Cost. una riserva di regolamento parlamentare, detti regolamenti non possono essere ordinati gerarchicamente bensì secondo il criterio della separazione delle competenze, di modo che la legge formale non può disciplinare la materia loro propria. La Corte costituzionale può emanare regolamenti per disciplinare l'esercizio delle sue funzioni. Il P.D.R. approva il regolamento interno alla presidenza e stabilisce con suo decreto lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla presidenza. Il Consiglio superiore della magistratura può disciplinare con regolamento interno il suo funzionamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può adottare propri regolamenti limitatamente ad alcune materie approvati con D.P.R. Anche il Consiglio dei ministri può darsi un regolamento interno per disciplinare i propri lavoro e le modalità di informazione sui lavori del consiglio.

9. La consuetudine- nel sistema gradualistico delle fonti, fonte subordinata sia alle leggi che ai regolamenti è la consuetudine (fonte di terzo grado) o uso. L'art. 8 delle "Disposizioni sulla legge in generale" stabilisce che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. Non sono ammesse nel nostro ordinamento consuetudini contrarie a leggi o regolamenti *(contra legem)*, ma soltanto consuetudini che integrano o specificano il dettato legislativo *(secundum legem)* o disciplinano materie non regolate da legge *(praeter legem o introduttive)*. Sembra, tuttavia, ammessa nel nostro ordinamento l'abrogazione di una norma mediante **desuetudine** che si ha quando i destinatari della norma pongono in essere un reiterato e diffuso comportamento omissivo; non osservano il precetto. Non si tratta di una consuetudine contra legem, ma di un semplice comportamento di inosservanza del precetto. Poiché l'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" dispone che le leggi non ono abrogate che da leggi posteriori, si pongono delicati problemi circa la desuetudine e l'accertamento del comportamento omissivo. La consuetudine, non prevista dalla Cost. come fonte, è una fonte non scritta e una fonte fatto. È un fatto produttivo di diritto e in ciò sta la sua peculiarità. Non è una manifestazione di volontà normativa da parte di un organo dell'apparato autoritario a ciò tenuto, ma un comportamento uniformemente e costantemente diffuso nel tempo e nello spazio, posto in essere da gruppi sociali. Si tratta di un diritto prodotto dagli stessi destinatari della norma. Il ripetersi uniforme e costante di un dato comportamento non basta a qualificarlo come giuridico. Non tutti i comportamenti costanti e diffusi nel gruppo sociale producono norme giuridiche : si pensi allo scambiarsi gli auguri, alle regole religiose. Perché si abbia una norma consuetudinaria, oltre al ripetersi costante e uniforme nel tempo di un comportamento, è necessaria la presenza di un altro elemento, individuato nella cd

This document is available free of charge on StuDocu.com

opinio iuris ac necessitatis (motivazione psicologica del comportamento). Questo elemento consiste nella convinzione da parte degli appartenenti al gruppo sociale che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Contro questo elemento sono state mosse diverse critiche. La più nota ritiene che, se si considera essenziale l'opinio iuris ac necessitatis, la norma consuetudinaria non esiste finchè non interviene la motivazione psicologica. E se si intende con essa la credenza di assolvere ad una norma giuridica, si cade in un circolo vizioso perché una norma giuridica ancora non esiste. Può sostenersi, invece, che l'elemento psicologico consista nel convincimento che un dato comportamento sia conforme ai fini primari del gruppo stesso. La norma consuetudinaria è una norma che scaturisce di fatto dai modi in cui si perseguono i fini del gruppo. Questo la differenzia dai semplici comportamenti che, di volta in volta, possono essere dettati dall'opportunità, dall'educazione, dall'abitudine, ecc. Quando una norma consuetudinaria viene violata, è chiamato ad accertare la violazione il giudice, un organo dello stato. La consuetudine è fonte non scritta, perciò occorre provarne l'esistenza. Ecco perché si ricorre alla redazione scritta delle norme consuetudinarie, affidata per ogni provincia alle camere di commercio e in sede nazionale al ministero per l'industria e il commercio, che sottopongono queste raccolte a periodiche revisioni.

10. La consuetudine costituzionale- Mentre la consuetudine di diritto comune disciplina i rapporti tra privati, quella costituzionale disciplina i rapporti tra gli organi costituzionali o istituti costituzionali. Sono diversi i soggetti che pongono in essere il comportamento, che qui sono organi dell'apparato autoritario dello stato. Diverse sono anche le modalità sia per quanto riguarda la diffusione che la ripetizione nel tempo del comportamento. Quanto alla diffusione, il comportamento è posto in essere da un numero molto limitato di soggetti o anche da un solo soggetto. Quanto alla ripetizione nel tempo, può essere limitato a pochi casi. Peculiarità presenta anche l'elemento psicologico, perché possono aversi anche consuetudini cost. contra constitutionem, che derogano a norme costituzionali scritte. Si può fare l'esempio dell'introduzione in Italia del regime parlamentare che sarebbe avvenuta in via consuetudinaria, mediante una serie di comportamenti da parte degli organi costituzionali contrari allo Statuto del 1848; o, nell'attuale ordinamento, della controfirma di alcuni atti del P.D.R. da parte del ministro competente anziché di quello proponente come prescrive l'art.89 Cost; ed ancora della sottrazione dei tesorieri degli organi costituzionali al controllo contabile. Casi più frequenti di consuetudine costituzionale si hanno quando organi costituzionali pongono in essere atti mediante i quali vengono creati nuovi istituti. Si pensi all'istituto della luogotenenza regia non previsto nello Statuto o, nell'attuale ordinamento, alla nomina

di uno o più vicepresidenti del Consiglio o dei ministri senza portafoglio (gli uni e gli altri non previsti dalla Cost.). Per riconoscere una consuetudine cost., bisogna verificarne la conformità alla costituzione materiale.

11. Le convenzioni costituzionali; le norme di correttezza costituzionale; la prassi ed il precedente- Dalla consuetudine costituzionale vanno distinte le convenzioni costituzionali, le norme di correttezza costituzionale, la prassi ed i precedenti. Esse sono fonti extra ordinem, contrapposte alle fonti legali, che sono le fonti ordinate in sistema. Le **convenzioni costituzionali** sono regole di condotta che disciplinano l'esercizio delle competenze degli organi costituzionali o un temporaneo assetto dell'ordine costituzionale, stabilite in seguito ad un accordo, espresso o tacito, stipulato a livello costituzionale dagli operatori politici. Esse intervengono negli spazi lasciati liberi dalle norme scritte che disciplinano l'esercizio delle competenze. Sono vincolanti fin quando gli operatori politici che hanno stipulato l'accordo lo ritengono opportuno. Si pensi al procedimento di nomina del Governo. La Cost. all'art. 92 si limita a statuire che il P.D.R. nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta di questo i ministri. La nomina del Presidente del Consiglio è preceduta da consultazioni che il Capo dello Stato svolge per compiere una scelta che garantisca la formazione di un Governo stabile. Quindi, la fase appunto delle consultazioni è disciplinata in via convenzionale. Le convenzioni possono trasformarsi in consuetudini ove si stabilizzino nel tempo. La consuetudine è una convenzione stabilizzata nel tempo. **Le regole della correttezza costituzionale** riguardano il comportamento o di singoli individui operanti nell'ambito costituzionale, tenuti al rispetto del galateo parlamentare, o il comportamento degli organi costituzionali nei loro reciproci rapporti, che devono essere improntati alla lealtà, alla cortesia, a un certo cerimoniale (si pensi alle dimissioni presentate dal Governo in segno di correttezza al neo eletto Capo dello Stato, che, sempre per correttezza, le rifiuta). La violazione di dette regole può dar luogo ad un generico biasimo. **La prassi** assume rilevanza soprattutto in campo amministrativo. Consiste in una serie di atti o fatti posti in essere da organi costituzionali e indicativi del modo in cui essi intendono l'esercizio delle loro funzioni. La prassi si distingue dalla consuetudine perché manca del carattere della continuità. Esempi di prassi in campo costituzionale sono dati dalla partecipazione alla elezione del P.D.R. di 3 delegati per ogni regione e di 1 per la Valle d'Aosta; dalla sospensione dell'attività legislativa ed ispettiva delle Camere durante le consultazioni per la risoluzione delle crisi e le discussioni sulla fiducia iniziale. Anche le convenzioni cost. possono costituire una prassi e trasformarsi, se consolidate, in consuetudine. **Il precedente** è costituito da un fatto o un atto singolo cui si uniforma, in presenza delle medesime circostanze, l'organo che lo ha posto in

This document is available free of charge on StuDocu.com

essere o un organo diverso. Si tratta di un modello di comportamento non vincolante. Un esempio è dato dalla procedura con cui, nel 1964, si è accertato l'impedimento del P.D.R. e si è affidato l'esercizio delle sue funzioni al Presidente del Senato. O ancora dalla costituzione nel Governo Craxi di un Consiglio di Gabinetto col compito di assistere il Presidente del Consiglio nel lavoro politico. Se nel nostro ordinamento, fondato sul diritto scritto, il precedente non acquista particolare rilevanza, negli ordinamenti di tipo anglosassone, dove prevale il diritto non scritto, i giudici sono tenuti allo stare decisis, vale a dire ad applicare la stessa massima applicata nella stessa fattispecie da altri giudici. Consuetudini, convenzioni, norme di correttezza, prassi e precedente trovano applicazione all'interno delle assemblee legislative e vanno a costituire quel diritto parlamentare che si vuole, in parte, lasciare duttile, affidandolo alla creatività delle assemblee.

12. La giurisprudenza- le decisioni dei giudici assumono rilevanza in quanto traggono la norma dalla sfera astratta in cui essa è collocata per applicarla ad un caso concreto. Ancora più rilevante è la funzione del giudice quando è chiamato a sciogliere il nodo derivante dalla compresenza di più leggi che disciplinano una stessa materia; o ad applicare ad una realtà mutata leggi vecchie; o a trarre la norma da formule contenenti i cd concetti valvola, polisensi. L'ordinamento giuridico non è quello che risulta dai codici e dalle leggi bensì, almeno in parte, quello che risulta dalle sentenze della magistratura. In questo senso, si può riconoscere alla giurisprudenza valore di fonte del diritto. Ciò vale anche per gli atti della P.A. che presuppongono pure l'interpretazione di un testo e la sua applicazione ad un caso concreto e per l'attività dei privati che, nello svolgere attività negoziale, di continuo applicano norme giuridiche. La sentenza del giudice ha un più spiccato senso normativo perché essa diviene obbligatoria, fa stato tra le parto, i loro eredi o gli aventi causa, può essere opposta a terzi. Non va dimenticata l'importante funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di Cassazione dall'art.65 della legge sull'ordinamento giudiziario, che la definisce organo supremo della giustizia che assicura l'uniforme e corretta interpretazione della legge. *L'equità- se nell'ordinamento italiano, il giudice nel pronunciare sulla causa deve seguire le norme del diritto, la legge può in via eccezionale attribuirgli il potere di decidere il merito della causa, sia in primo grado che in appello, secondo equità quando riguardi diritti disponibili dalle parti e queste gliene facciano richiesta. Il giudice di pace, se il valore della causa non eccede i millecento euro, decide sempre secondo equità. Ciò significa che, nei casi previsti, il giudice può creare egli stesso la regola da applicare, seguendo criteri di giustizia e ragionevolezza.*

13. Contratti collettivi di lavoro- Fonti del diritto, sebbene non ancora operanti, sono i **contratti collettivi di lavoro** giacchè, qualora siano stipulati da sindacati registrati (cd contratti collettivi di diritto pubblico) acquistano, a norma dell'art.39 Cost., efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Si tratta di fonti del diritto non statali, la cui formazione è riservata dalla Costituzione alla determinazione autonoma delle associazioni contrapposte di lavoratori e datori di lavoro. Se da un lato i contratti non possono contenere clausole in contrasto con leggi e regolamenti generale, dall'altro ci sembra che si inseriscano nel sistema delle fonti anche secondo il criterio della separazione delle competenze, ove si osservi che, al fine di riservare un certo margine di determinazione alla autonomia sindacale, leggi e regolamenti non possono disciplinare nei dettagli la materia oggetto della contrattazione collettiva. Attualmente, non esistendo sindacati registrati, i contratti stipulati dalle contrapposte associazioni dovrebbero acquistare la normale efficacia dei contratti e valere solo tra le parti. Di fatto, invece, i contratti di lavoro individuali, stipulati dai datori di lavoro e dai lavoratori non iscritti ad un sindacato, riproducono le clausole dei contratti collettivi dirette ad assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, ricollegandosi la validità erga omnes dei contratti collettivi all'art.36 Cost. A tutt'oggi, non essendo ancora stata emanata la cd legge sindacale non esistono sindacati persone giuridiche e, quindi, contratti collettivi di diritto pubblico (fonti del diritto). *Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è regolato da contratti collettivi stipulati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle PP.AA. (ARAN) e dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti possono essere annoverati tra le fonti del diritto.* Non va annoverata tra le fonti del diritto l'interpretazione delle norme compiuta, a fini scientifici, dagli studiosi del diritto, la cd dottrina, a differenza di quanto accadeva in epoche ormai lontane. Tuttavia, essa assume un importante ruolo di stimolo, di chiarimento e critica.

14. Fonti poste in ordinamenti esterni a quello italiano e loro efficacia nell'ordinamento italiano mediante: a) per le norme di diritto internazionale, l'adattamento automatico e l'ordine di esecuzione- Gli ordinamenti esterni a quello dello stato possono essere di 2 tipi: *generali e particolari.* Ordinamento generale per eccellenza è quello della *comunità internazionale*, ordinamenti particolari sono quelli dei singoli Stati o di istituzioni (come la Chiesa cattolica) non assimilabili ad uno Stato. Vi è un terzo tipo di ordinamento, dato dall'unione di più Stati, che si può definire *intermedio* tra quello dei singoli stati e quello della comunità internazionale. Con riferimento a questi tre tipi di ordinamento e alle fonti loro proprie aventi

This document is available free of charge on StuDocu.com

efficacia nell'ordinamento italiano, hanno rilievo: per la Comunità internazionale, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e le norme pattizie; per gli ordinamenti particolari, la presupposizione ed il rinvio; per gli ordinamenti intermedi, le norme comunitarie. La comunità internazionale è costituita da tutti gli Stati sovrani e si fa storicamente risalire alla *Respubblica Christiana* che collegò in unità di interessi e principi i popoli dell'Europa occidentale successivamente all'anno mille. Tale comunità è dal Trattato di Westfalia del 1648 una comunità fra eguali. La formazione del diritto che da essa emana, il diritto internazionale, avviene prevalentemente in via consuetudinaria e convenzionale, mentre per quanto riguarda l'osservanza delle singole regole, essa è affidata ai singoli Stati sulla base di due principi fondamentali: *pacta sunt servanda e consuetudo est servanda.* Pur mancando nella Comunità internazionale un apparato autoritario istituzionalizzato, è sempre presente, nondimeno, un'autorità, che non prende corpo in un apparato sovraordinato, a meno che non lo si voglia individuare nell'ONU. Il principio secondo il quale quella internazionale è una comunità fra eguali è puramente teorico, giacché, di fatto, gli Stati economicamente e politicamente più forti influenzano, se non determinano, la volontà di quelli più deboli. Una tendenza che va affermandosi è quella a porre nelle costituzioni dei singoli Stati norme che assicurino nei loro ordinamenti l'osservanza delle norme di diritto internazionale. Forme di collegamento tra il diritto interno e quello internazionale nell'ordinamento italiano sono **l'adattamento automatico (art.10) e l'ordine di esecuzione.** L'art. 10 Cost. dispone che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", intendendo con queste ultime quelle che rispondono alle esigenze e agli interessi di tutti gli stati. Si pensi proprio ai principi *pacta sunt servanda e consuetudo est servanda,* al principio della libertà dei mari, alle norme in materia di immunità diplomatiche e al principio di non ingerenza negli affari degli altri Stati. In virtù dell'art.10, il legislatore ordinario non può emanare norme contrastanti con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Se ciò facesse, la legge sarebbe impugnabile innanzi alla Corte Cost. Più incerto appare il rapporto tra le norme di d. internazionale generalmente riconosciute e le norme costituzionali; dovendosi ritenere che queste ultime prevalgano sulle prime, con la conseguenza che una legge ordinaria in contrasto con una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, ma conforme ad una norma costituzionale, sarebbe da considerare costituzionalmente legittima. La cosa cambia quando sia intervenuta una modifica in una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta. In questo caso a cedere dovrebbe essere la norma costituzionale, che dovrebbe anzi essere adeguata alla modifica stessa. Infatti, alla modifica del principio non può non aver partecipato anche lo Stato italiano, quale componente della

comunità internazionale. L'**ordine di esecuzione** riguarda il cd diritto internazionale pattizio, vale a dire le norme di diritto internazionale prodotte dall'accordo (o trattato o convenzione o dichiarazione) fra due o più stati, diretto a regolare i loro rapporti in campo politico, commerciale, economico, ecc. Con la stipulazione dello stesso, gli Stati contraenti sono tenuti, in virtù del principio *pacta sunt servanda*, ad adottare nel loro ordinamento le misure necessarie a darvi esecuzione, ciò può avvenire mediante due procedure: l'emanazione di una legge o di un atto di eguale forza, con cui vengono prodotte nell'ordinamento interno le norme esecutive dell'accordo; con **l'ordine di esecuzione,** che è il procedimento di regola adottato. Quest'ordine è, di solito, contenuto in una legge e consiste nella formula "piena ed intera esecuzione è data al trattato" di cui è annesso il testo integrale. Nel primo caso, è il legislatore interno a porre le norme esecutive del trattato; nel secondo caso, il legislatore statale si limita ad operare un rinvio al trattato. Secondo una prassi frequente in Italia, quando la ratifica dei trattati internazionali da parte del P.D.R. deve essere preceduta, a norma dell'art. 80, da una legge di autorizzazione, le Camere nella stessa legge impegnano il Governo (con la formula "piena ed intera esecuzione sia data al trattato") ad emanare le norme necessarie ad adattare il diritto interno al trattato. Sono stati posti dubbi sulla legittimità di tale prassi, che eluderebbe il principio di cui all'art. 76 che prevede una delega con l'indicazione di principi, tempo e oggetto. Diversamente sostiene il Quadri, per il quale il Parlamento è chiamato solo ad autorizzare il Governo e non vi è necessità di un atto ad hoc.

15. b) per le norme di altri ordinamenti statali, la presupposizione ed il rinvio- Si ha la **presupposizione** quando per applicare una norma dell'ordinamento statale si rende necessario il riferimento da una norma di un ordinamento straniero. Così, ad es, quando l'art. 295 cod. pen. punisce chiunque nel territorio dello Stato attenti alla vita, alla libertà o all'incolumità del Capo di uno Stato estero, poiché nessuna norma nell'ordinamento giuridico italiano disciplina questa figura, occorrerà riferirsi all'ordinamento dello Stato di cui è capo il soggetto passivo del reato. Allo stesso modo, poiché l'art.10 comma III, attribuisce allo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Cost. italiana, il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, sarà necessario, perché la norma possa essere applicata, stabilire la qualità di cittadino straniero, mediante riferimento all'ordinamento dello stato di cui chi chiede diritto di asilo asserisce di essere cittadino. Si ha il **rinvio** quando, in virtù di una norma posta nell'ordinamento interno, una norma, di un altro ordinamento, viene applicata nello Stato. Tale tipo di rinvio è possibile anche fra norme di uno stesso ordinamento (ad es. tra una legge e un regolamento). Si distingue tra rinvio *formale o non ricettizio* e rinvio *materiale o*

This document is available free of charge on StuDocu.com

ricettizio. Si ha il primo quando lo Stato pone, nel suo ordinamento, una norma che rinvia a quella di un ordinamento straniero, stabilendo i criteri per individuarla; il secondo quando la norma posta nell'ordinamento statale rinvia a quella di un ordinamento straniero per farne proprio il contenuto o nazionalizzarla. Nel primo caso, la norma non entra a far parte dell'ordinamento italiano; nel secondo, la norma viene fatta propria. I casi di rinvio ricettizio sono rari. Un es. è dato dalle norme della Costituzione albanese che, in seguito al sorgere dell'Unione reale italo-albanese, rinviavano allo Statuto del Regno. Si fa rientrare nei casi di rinvio ricettizio anche quello della norma interna che contiene l'ordine di esecuzione di un trattato internazionale. Più frequenti sono i casi di rinvio formale. Essi si hanno quando è necessario disciplinare, nell'ordinamento, fatti che presentano rispetto allo Stato elementi di estraneità. Le norme di diritto interno che rinviano ad un ordinamento straniero per la disciplina dei fatti che presentano, rispetto allo Stato, elementi di estraneità costituiscono il *diritto internazionale privato*. Si tratta sempre di norme di diritto interno, ma disciplinano fatti collegati con uno o più stati stranieri.

16. c) per le norme comunitarie, i trattati istitutivi delle Comunità- Particolare considerazione meritano le norme comunitarie, vale a dire le norme emanate dagli organi dell'UE ed originariamente dagli organi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che ha cessato di esistere nel 2002, della Comunità economica europea e della Comunità europea per l'energia atomica, istituite la prima con il Trattato di Parigi del 1951 e le altre con i trattati di Roma del 1957. Il trattato di Maastricht del 1992, che ha istituito l'UE, ha ribattezzato la CEE in CE. Questo quadro normativo è stato poi modificato dai trattati di Amsterdam, Nizza e infine Lisbona, entrato in vigore nel 2009. Fanno parte dell'UE 27 stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Gli atti delle istituzioni comunitarie che hanno la funzione di disciplinare aspetti interni delle vita degli ordinamenti nazionali sono molteplici e sono accomunati sotto la definizione di diritto comunitario ma non tutti possono essere considerati fonti del diritto, limitandosi alcuni ad essere meri atti amministrativi. I principali tipi di fonte comunitaria sono dati dai **regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni**, ma soprattutto dai primi, anche se gli stati membri sono tenuti a dare attuazione a tutte queste fonti nei loro ordinamenti. L'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario è disciplinato dalla legge n.11 del 2005, che dispone che il Parlamento approva ogni anno una legge cd comunitaria, che assicuri l'adeguamento mediante disposizioni modificative o abrogative di norme in contrasto con gli obblighi

derivanti dall'appartenenza all'UE; mediante disposizioni attuative o applicative di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni. Nelle materie non riservate alla legge, le direttive possono essere applicate con regolamento. A norma dell' ex art. 249 del TCE, oggi art. 288 TFUE, il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente obbligatorio in ogni stato membro, mentre la direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il fine, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Mentre destinatario della direttiva è lo stato membro, il regolamento può indirizzarsi ad uno qualsiasi dei soggetti di diritto interno. Il regolamento è interamente obbligatorio. La direttiva dà norme di scopo, che lasciano libero il destinatario in ordine alla forma e ai mezzi per perseguirlo. I caratteri dei regolamenti sono:*portata generale, applicabilità diretta, obbligatorietà.* Portata generale in quanto si dirigono ad una o più categorie di destinatari direttamente e nel loro complesso. La obbligatorietà caratterizza i regolamenti rispetto a quegli atti comunitari non vincolanti (pareri e raccomandazioni) e rispetto ad atti vincolanti ma non in tutti gli elementi (direttive). L'applicabilità diretta rende efficace il regolamento negli ordinamenti degli stati membri per il solo fatto della sua emanazione. Da qui discende l'idoneità del regolamento a derogare persino alle leggi formali, il cd principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno. Principio peraltro riconosciuto dalla stessa Corte Cost. Il fondamento dell'applicazione nell'ordinamento italiano delle fonti comunitarie risiede nell'art. 11 Cost. : "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo." La Corte Cost. ha stabilito che un regolamento comunitario va sempre applicato, sia esso precedente o successivo ad una legge ordinaria con esso incompatibile. La compatibilità fra regolamento comunitario e norma interna è una questione lasciata alla cognizione del giudice comune. La Corte ha, tuttavia, confermato l'inapplicabilità di regolamenti comunitari in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana. L'applicazione diretta delle norme comunitarie in luogo di quelle interne non può aversi nel caso delle direttive, che richiedono per la loro attuazione specifici atti normativi, salvo che sia così dettagliata da consentirne l'immediata applicazione. Quando una legge dello Stato fosse in contrasto con una direttiva, si ricorrerebbe alla Corte cost. al fine di ottenerne l'annullamento per violazione dell'art.11. Dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, con legge costituzionale n. 3 del 2001, il I comma dell'art.117 dispone che "La potestà legislativa è esercitata dallo

This document is available free of charge on StuDocu.com

Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.". Questa norma va intesa in simbiosi con quella espressa all'art.11, andando così a costituire il fondamento della conformità del diritto interno a quello comunitario. La disciplina dell'appartenenza dell'Italia all'UE è regolata dai principi di sussidiarietà, trasparenza, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica.

17. Le cd fonti atipiche e le leggi rinforzate- Il nostro ordinamento costituzionale prevede una pluralità e varietà di fonti. Esistono fonti di pari forza della legge formale emanate da organi diversi dal Parlamento o il cui procedimento di formazione è più complesso (aggravato) rispetto a quello ordinario; fonti la cui forza è depotenziata o potenziata e fonti per la cui formazione sono previsti alcuni adempimenti. Questo ha condotto la dottrina a costruire la figura delle fonti atipiche e rinforzate, presupponendo quindi che vi sia una fonte la cui forza ed efficacia siano tipiche. Alcune fonti, decreti legge e decreti legislativi, sono atti del potere esecutivo con eguale forza della legge formale; ad altre (regolamenti parlamentari) la Cost. riserva la disciplina dell'organizzazione delle funzioni delle assemblee legislative; nelle materie assegnate alla competenza legislativa ripartita di Stato e Regioni fonti statali e regionali concorrono a disciplinare dette materie secondo il criterio di separazione delle competenze; alcuni tipi di regolamento hanno un'efficacia sostanziale pari alla legge formale. Talune fonti si distinguono perché sono sottratte all'abrogazione mediante referendum (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali) ed hanno cioè una forza o efficacia formale potenziata; mentre, di converso, la fonte referendum abrogativo ha un'efficacia depotenziata. Sotto il profilo procedimentale, esistono differenze tra fonti di pari grado, consistenti in un diverso procedimento di formazione, al quale sono chiamati a partecipare organi o enti estranei agli organi cui il procedimento è in via normale è affidato o in un procedimento aggravato (LEGGI RINFORZATE es. art.132 Cost. prevede che per disporre la fusione di Regioni esistenti o creare nuove Regioni occorre una legge di revisione cost. e che la richiesta venga da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni delle regioni interessate, che la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione e che siano sentiti i relativi Consigli regionali. Altro es. è dato dalle leggi di amnistia e indulto che devono essere deliberate con la maggioranza qualificata di ciascuna Camera). Si tratta, in realtà, di procedimenti che vedono in una partecipazione dal basso mediante atti di partecipazione o consultivi degli enti o popolazioni interessati. Per cui a rinforzarsi non è tanto la fonte, quanto il momento partecipativo. Allo stesso modo, nella disciplina di cui all'art. 8 Cost., a norma del

quale i rapporti tra stato e confessioni acattoliche sono regolati da intese con le relative rappresentanze, si avrebbe un rafforzamento non del procedimento formativo, ma del momento partecipativo.

18. L'interpretazione dei testi normativi- L'interpretazione di un testo normativo consiste in un'operazione intellettiva che vale a cogliere la portata,il significato della norma stessa nel contesto dell'ordinamento giuridico. Chi non ha le nozioni tecniche necessarie non riuscirà a cogliere il significato di un testo normativo, a trarre la norma da questo testo. Chi conosce le tecniche giuridiche potrà compiere l'operazione dell'interpretazione diretta a individuare la norma; chi è chiamato ad applicare il diritto, oltre ad interpretare il testo, renderà viva e operante la norma. Nel primo caso, l'interpretazione è fine a se stessa, mira a conoscere la norma. Nel secondo caso è funzionalizzata all'applicazione della norma al caso concreto. Si pensi all'interpretazione compiuta a fini di studio da un avvocato che debba predisporre un atto di citazione e, diversamente, a un giudice chiamato a risolvere una controversia.
L'attività dell'interprete dovrà svolgersi nei limiti dell'ordinamento giuridico,affinchè sia assicurata l'armonicità e la coerenza dello stesso. Ciò significa che l'interpretazione non può mai essere arbitraria,nel senso che non potrà trarre dal testo una norma che non si coordini in sistema con le altre: ciò non vuol dire che l'interpretazione non possa essere soggettiva e determinata dalla cultura giuridica o dalla forma mentis dell'interprete,oppure ancora che dallo stesso testo non possano trarsi norme in tutto o in parte diverse. Quello che conta è che,soprattutto nella fase attuativa del diritto,la norma ricavata dal testo si inserisca armonicamente nel sistema e trovi in esso la sua coerente collocazione. Proprio perché non può essere arbitraria,l'interpretazione dei testi normativi,soprattutto nella fase attuativa,deve svolgersi secondo regole predeterminate o ricavabili dal sistema. A tal proposito,l'art.12 comma I delle "Disposizioni sulla legge in generale" stabilisce che "nell'applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore": ciò significa che l'interprete deve tener conto del significato tecnico-grammaticale del testo normativo e della parole secondo la loro connessione sintattica(INTERPRETAZIONE LETTERALE),nonché dell'intenzione del legislatore(mens o ratio legis). L'intenzione del legislatore in particolare è un elemento obiettivo,non va cioè riferita alla volontà di coloro che hanno formulato il testo: la formula legislativa infatti,una volta approvata,e quindi la norma da essa desumibile,vivono di vita propria,per cui la ratio o mens legis si obiettivizza positivamente nell'ordinamento. L'interpretazione letterale e la ricerca della mens legis vanno integrate con l'INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: non essendo infatti la norma isolata,ma inserita in un sistema unitario e concluso,essa va colta nelle connessioni con le altre norme e in particolare deve armonizzarsi con i principi fondamentali che assicurano l'intima coerenza dell'ordinamento. Secondo questo criterio l'interprete,una volta tratta la norma dal testo sulla base dell'interpretazione letterale e della mens legis,dovrà "calare" la stessa nell'ordinamento; potrà perciò

This document is available free of charge on StuDocu.com

avvenire che, non più considerata isolatamente,la norma si arricchisca(INTERPRETAZIONE ESTENSIVA)o si restringa(INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA). Abbiamo detto che da uno stesso testo possono trarsi,in diversi periodi,norme in tutto o in parte diverse;ciò appare essenzialmente dovuto al fatto che,pur restando immutato il testo,vengono a mutare i principi che reggono l'ordinamento. In questa ipotesi il significato della norma dovrà essere adeguato a questi nuovi principi (INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE). Particolare importanza assume l'interpretazione adeguatrice nel campo del diritto costituzionale (anche per l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte cost.,che fa carico al giudice di ricercare un'interpretazione delle disposizioni legislative conforme a Costituzione e solo in caso di esito infruttuoso rimette la questione alla Corte stessa). Si tratta chiaramente di un fenomeno fisiologico,giacchè proprio il trascorrere del tempo determina un distacco sempre crescente fra il significato originario del testo e quello che l'interprete gli attribuisce in via d'attuazione:si parla in questo caso di INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA. L'interpretazione di un testo,anche se compiuta in sede giurisdizionale,non vincola mai l'interprete successivo, se non in un rapporto interno di gerarchia o allorquando la Cassazione, accogliendo il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enunci il principio al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi. Proprio perché un testo normativo può ricevere varie e talora contrastanti interpretazioni,in alcuni casi il legislatore può intervenire a chiare o precisare con legge o con atto ad essa equiparato il significato del testo,vincolando in tal modo gli interpreti non solo ad attribuire quello stesso significato e ad applicarlo,ma anche ad applicarlo RETROATTIVAMENTE,e cioè sin dalla sua formulazione (tranne che,in caso di legge penale,si tratti di una legge più sfavorevole al reo):INTERPRETAZIONE AUTENTICA (che, come ha stabilito la Corte cost. non può incidere sulle sentenze passate in giudicato).

Può avvenire poi che l'interprete,pur ricorrendo a questi criteri,non trovi una norma che espressamente definisca e disciplini quella particolare fattispecie: soccorre a questo riguardo l'art.12 delle Preleggi stabilendo che se una controversia non può essere decisa da una precisa disposizione,si ha riguardo alle disposizioni che regolano materie analoghe o casi simili o, se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato(INTERPRETAZIONE ANALOGICA). Per cui la norma da attuare è sempre contenuta se non espressamente,implicitamente nel sistema. Sarà compito dell'interprete ricavarla o dalle disposizioni che disciplinano materie analoghe o casi simili(ANALOGIA LEGIS) o,qualora non sia possibile rinvenire con certezza il secondo termine dell'analogia,mediante il ricorso a principi generali dell'ordinamento giuridico(ANALOGIA IURIS),principi fondamentali,di struttura,istituzionali,quali ad esempio il principio di eguaglianza,della separazione dei poteri,del decentramento ecc. L'interpretazione analogica non è consentita in materia penale,laddove vige il "favor libertatis",per cui un fatto,per essere punto penalmente come reato,deve essere espressamente previsto come illecito da una legge. Se ricorrendo all'analogia legis e iuris l'interprete non arriva comunque a ricavare una norma da applicare al caso concreto,questi dovrebbe(secondo alcuni autori) prendere atto che nell'ordinamento è

presente una lacuna normativa. Secondo altri invece non esisterebbero lacune,sia perché tutto ciò che non è disciplinato (imposto o vietato) dal diritto è giuridicamente consentito e sia perché,qualora non si riesca a rinvenire una norma o principio da applicare ad una determinata fattispecie,essa va semplicemente ritenuta giuridicamente irrilevante,almeno da quell'ordinamento in quel particolare momento storico. Ad es. non è previsto alcun obbligo di mangiare o meno un determinato cibo, di fare o meno una passeggiata, essendo comportamenti socialmente irrilevanti. Tuttavia, può accadere che, in determinate circostanze, gli interessi ad essi collegati entrino in conflitto con altri: si pensi al razionamento del cibo o al coprifuoco nei periodi di guerra. Si è parlato anche di *lacune istituzionali*,laddove un istituto normativamente previsto non sia stato costituito in concreto: è il caso della Corte costituzionale,del CSM ,del CNEL, la cui istituzione è avvenuta in un secondo momento rispetto all'entrata in vigore della Costituzione(anni '50 e '60). Si trattò in quel caso di ipotesi di inattuazione della Costituzione, la cui responsabilità ricade sulle forze politiche dell'epoca,cui spettava il compito di rendere la Costituzione operante in ogni suo aspetto. D'altronde la nostra Cost., ancora oggi, non può dirsi completamente attuata: si pensi all'art. 39.

19. L'interpretazione delle disposizioni costituzionali- Particolare rilievo assume poi l'interpretazione delle norme costituzionali,in virtù della natura di tali stesse disposizioni rispetto alle altre,che si connotano per una più elevata carica di politicità in quanto espressione dei principi e dei valori fondamentali attorno ai quali la comunità sociale si è organizzata, andando a formare lo Stato. Molte disposizioni costituzionali contengono concetti valvola,suscettibili come tali di diverse interpretazioni a seconda anche del momento storico-politico in cui ad esse viene data attuazione e delle forze politiche chiamate a renderle concretamente operanti(come i concetti di "utilità sociale" e "fini sociali"). Proprio in ragione della sua delicatezza,quest'interpretazione è stata affidata in Italia ad un organo apposito,la Corte costituzionale che, per la sua composizione e l'estrazione dei suoi componenti, è in grado di meglio cogliere il significato delle disposizioni della Costituzione formale. Chiamati a interpretare (indirettamente) la Costituzione sono anche i cittadini(tenuti ad osservarla),il legislatore(che nella formulazione delle leggi non può produrne di non conformi alla Costituzione),i giudici(che sono tenuti a non applicare la legge qualora non siano certi della sua conformità alla Costituzione), i pubblici amministratori e gli organi di indirizzo politico. Ecco, dunque, un'altra peculiarità dell'interpretazione dei testi costituzionali,che è appunto data da una molteplicità e varietà di soggetti. La Costituzione si rivolge all'intero corpo sociale e ciò spiega come, di fatto, la sua interpretazione possa essere e di fatto sia influenzata da fattori politici, rischiando di piegarsi alla cura di interessi di parte. Anche se la creazione di un organo deputato a dichiarare l'illegittimità delle norme contrarie alla Cost. (appunto la Corte) attenua non poco quest'influenza. Tuttavia, capita che, in alcuni casi, la Corte scelga, tra quelle possibili, l'interpretazione più idonea a conservare l'equilibrio politico.

This document is available free of charge on StuDocu.com

19. L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio- Per efficacia si intende l'idoneità di un fatto o un atto a produrre effetti giuridici,e cioè a costituire,modificare o estinguere determinate situazioni giuridiche. L'applicabilità delle norme giuridiche ha una sua dimensione,temporale e spaziale. Quanto alla prima,l'art.11 delle Preleggi statuisce che "La legge non dispone che per l'avvenire:essa non ha effetto retroattivo",volendo indicare quindi che una norma non può essere applicata a situazioni di fatto o a rapporti giuridici sorti e conclusisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Tale principio(IRRETROATTIVITA' degli atti normativi:dispongono unicamente per il futuro,e non hanno effetti per il passato)è previsto nella Costituzione(art.25, II comma),limitatamente però al campo del diritto penale ("Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"),cosicchè la Corte costituzionale(sentenza n.118 del 1957 ed altre successive),pur riconoscendo che il principio generale dell'irretroattività delle leggi rappresenta un'antica conquista della nostra civiltà giuridica,ha statuito che esso non è mai assurto nel nostro ordinamento alla dignità di norma costituzionale se non per la materia penale e limitatamente alle norme più sfavorevoli al reo. Un problema più complesso è quello di stabilire fino a qual punto la norma possa disporre per il passato. Non dovrebbero esservi dubbi che una legge non possa applicarsi a rapporti giuridici che al momento della sua entrata in vigore abbiano esaurito i loro effetti in virtù di una sentenza passata in giudicato, di una transazione , di un arbitrato. Diversamente, la legge si applicherà alle situazioni e ai rapporti che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, al momento della sua entrata in vigore e, quando si tratti di atti su procedimento, a quelle fasi non ancora compiute. Per il resto occorrerà affidarsi alla "prudente valutazione del legislatore" tenuto ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici. La deroga al principio generale della irretroattività non è consentita da parte dei regolamenti, che non possono derogare al principio contenuto in una fonte primaria. La legge spiega la sua efficacia nel tempo fino a quando una legge successiva o una fonte di pari grado non la abroghi. L'art. 15 delle Preleggi statuisce che l'abrogazione può essere *espressa o tacita.* È espressa quando la legge successiva espressamente stabilisce che una legge precedente o alcuni articoli di essa sono abrogati. È tacita quando le disposizioni di una nuova legge siano incompatibili con quelle della legge precedente o quando la nuova legge regoli l'intera materia già regolata da una legge anteriore. L'abrogazione totale o parziale di una legge può avvenire anche mediante referendum (art. 75 Cost.) ed in tal caso sarà espressa. Possono aversi leggi a termine, che fissano la durata della loro efficacia o ad efficacia predeterminata dall'ordinamento (es. legge di bilancio, la cui efficacia a norma dell'art. 81 dura un anno; il decreto legge che, a norma dell'art. 77, se non convertito in legge cessa di essere efficace trascorsi 60 giorni); leggi la cui

vigenza è condizionata dalla permanenza di alcuni stati di fatto o di diritto (ad es. leggi emanate in periodo di guerra) o la cui vigenza cessa con l'entrata in vigore di un'altra legge. La regola dell'abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale o eccezionale e quella successiva generale (*legi speciali per generalem non derogatur*), ritenendosi che la disciplina generale non abbia ragione di mutare quella dettata dal legislatore precedente. Nel nostro ordinamento si ha un caso di *disapplicazione* delle leggi allorquando la Corte cost. ne dichiari l'illegittimità costituzionale. Infatti, l'art. 136 Cost. dispone che, quando la Corte dichiara l'illegittimità di una legge o atto ad essa equiparato, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La pronuncia della Corte rende la legge inapplicabile. Ogni costituzione nasce ed è posta per durare nel tempo: la sua vigenza non può avere limiti temporali prefissati. Se prevedesse tali limiti, sarebbe una contraddizione logica. Ciò non significa che le costituzioni debbano essere eterne, ma certamente esse tendono a maggiore durevolezza e intangibilità rispetto alle altre leggi. Una costituzione non può nascere, senza contraddire se stessa, né come provvisoria né come eterna. La sua durata è indeterminata, dipendendo dalla persistenza dei valori in essa obiettivizzati e dalla capacità delle forze politiche di attuarli. Essa può contenere delle disposizioni che fissano i modi e i termini temporali della sua attuazione, come le 18 "Disposizioni transitorie e finali" che completano il dettato della nostra Cost. L'applicabilità delle norme, secondo una dimensione spaziale, viene ricollegata al principio della *territorialità della legge*, secondo il quale l'efficacia delle norme vige nell'ambito territoriale entro il quale lo Stato esercita la sua sovranità. Detto principio appare ovvio, ma non è esclusivo in quanto rapporti e situazioni sorti nel territorio dello Stato possono essere disciplinati da norme di altri ordinamenti e rapporti e situazioni sorti in un altro Stato possono essere disciplinati da norme del nostro ordinamento. Il primo caso si ha quando l'ordinamento italiano rinvia ad un ordinamento straniero; il secondo quando l'ordinamento straniero rinvia a quello italiano. Si pensi all'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno degli Stati membri. Il principio della territorialità della legge va integrato avendo riguardo ai destinatari delle norme, giacché se è vero che tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato (cittadini, stranieri, apolidi) sono soggetti alle sue leggi (regola assoluta per le leggi penali), è altrettanto vero che la legge italiana si applica anche se il suo destinatario si trova al di fuori dello stato italiano: si pensi all'obbligo di pagare le imposte grava sui cittadini anche se residenti all'estero o ancora agli atti e ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile che si trovino in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero, tali fatti sono disciplinati dalle leggi italiane in tutti i casi in cui dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto è avvenuto (art. 5 cod. nav). In un ordinamento con una pluralità di fonti, come quello italiano, si hanno tre livelli di applicabilità delle leggi: statale, regionale e provinciale(limitatamente alle Province di Trento e Bolzano).

This document is available free of charge on StuDocu.com

Capitolo Terzo IL SOGGETTO DI DIRITTO E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. La soggettività giuridica; capacità giuridica e capacità di agire; persone fisiche e persone giuridiche; i diritti senza soggetto- le norme giuridiche considerano ogni uomo centro di imputazione di interessi, socialmente e giuridicamente rilevanti. L'uomo è, ad un tempo, destinatario della norma giuridica e centro di imputazione di interessi giuridici. Il riconoscimento di interessi operati dal diritto in capo ad ogni uomo comporta l'attribuzione di una serie di situazioni attive e passive, che nel loro complesso vanno a costituire quella che tecnicamente è detta **soggettività giuridica** ed il loro titolare diviene **soggetto di diritto.** La capacità delle persone fisiche- soggetti di diritto di essere potenzialmente destinatari delle norme che attribuiscono situazioni attive e passive viene definita **capacità giuridica** e si acquista, a norma dell'art. 1 cod. civ., al momento della nascita. Può avvenire che la legge riconosca dei diritti ai concepiti, in questo caso il loro acquisto è subordinato all'evento della nascita. Si pensi alla legge n. 40 del 2004 in materia di fecondazione medicalmente assistita, che si impegna al riconoscimento dei diritti del concepito. La capacità giuridica acquista rilievo nel diritto pubblico, dove possono sorgere dubbi relativamente al riconoscimento di alcuni diritti ad alcuni soggetti. Si discute se gli stranieri e gli apolidi siano titolari di quei diritti che la Cost. sembrerebbe riservare ai cittadini e se il riconoscimento e la tutela di alcuni diritti di libertà si estenda anche ai minorenni. Il riconoscimento formale della capacità giuridica può non coincidere con l'effettiva attribuzione in capo ai soggetti di situazioni giuridiche attive, allorquando ciò sia impedito da ostacoli di ordine economico e sociale. Si pensi all'art. 4 Cost. che riconosce a tutti i cittadine il diritto al lavoro; sappiamo che ostacoli economico-sociali impediscono il raggiungimento della piena occupazione. Diversa dalla capacità giuridica è la **capacità di agire** che consiste nell'attitudine di un soggetto a porre in essere direttamente atti produttivi di effetti giuridici e che si acquista al 18esimo anno di età, ai sensi dell'art. 2 cod. civ. Oltre che alle *persone fisiche* l'ordinamento attribuisce la soggettività giuridica anche ad entità composte o da un'unione di persone costituitasi in vista di un interesse comune (associazioni o corporazioni) ovvero ad una struttura organizzativa idonea a soddisfare gli interessi di persone determinate o determinabili (fondazioni o istituzioni). Tali entità sono definite persone giuridiche per sottolineare che esse sono una creazione del diritto, non esistono nel mondo reale. Le persone giuridiche, a differenza di quelle fisiche, possono essere pubbliche o private, in base alla natura dei fini che perseguono. La distinzione non è sempre facile, perché possono aversi enti a struttura privatistica che perseguono interessi pubblici e perché la natura del fine non è sempre determinata o

determinabile. Destinatari delle norme giuridiche possono essere anche entità cui l'ordinamento non ricollega la soggettività giuridica. Il fenomeno è rilevante sia in dir. pubblico che privato. Si pensi alle associazioni non riconosciute, a quelle cioè che non hanno chiesto o ottenuto il riconoscimento o che sono in attesa di ottenerlo; alla comunione legale tra coniugi, al condominio negli edifici, all'eredità giacente, al fallimento, all'impresa. La nostra Cost., oltre uno specifico riferimento alle formazioni sociali quali sedi ove l'uomo svolge la sua personalità, contiene norme che hanno per destinatari entità non soggettivizzate o non soggettivizzabili. Fra queste: il popolo, la famiglia legittima, i partiti politici, i sindacati non registrati. Si tratta di figure che non possono qualificarsi come veri e propri soggetti di diritto, ma come entità alle quali, ciò nonostante, l'ordinamento attribuisce situazioni giuridiche attive e passive, forme di tutela, legittimazioni processuali,

2. Le situazioni giuridiche attive: il potere giuridico; il diritto soggettivo; l'interesse legittimo- Alla posizione di coloro che sono titolari interessi (posizione attiva) si contrappone quella di coloro ai quali l'ordinamento impone di collaborare e non opporsi (posizione passiva) al soddisfacimento degli stesso. Ogni qualvolta si realizza un interesse ne viene, di regola, compresso un altro. Ad es. all'interesse della comunità di disporre di denaro per perseguire i suoi fini, corrisponde la posizione dei cittadini tenuti a concorrere alle spese pubbliche. Le situazioni giuridiche attive sono essenzialmente tre: **potere, diritto soggettivo, interesse legittimo. Potere giuridico** è una situazione giuridica astratta riconosciuta dall'ordinamento a tutti i soggetti o a determinate categorie di soggetto in ordine al soddisfacimento di un interesse giuridicamente rilevante, proprio o altrui. Situazione astratta perché non collegata ad un interesse nel campo di azione già presente nel soggetto e che abbisogna di una specificazione nel momento in cui il soggetto titolare intenda perseguire il suo interesse. Il potere o potestà attiene sia al diritto privato che a quello pubblico. Quanto al primo si pensi alla potestà dei genitori sui figli minori e alla potestà di testare; quanto al secondo, al potere dei cittadini di eleggere i loro rappresentanti o di agire in giudizio. Dall'astrattezza del potere giuridico (potenziale) si passa poi alla concretezza del diritto soggettivo (attuale). Così dall'astratta potestà di eleggere i rappresentanti si passa al diritto di elettorato attivo; dal potere di agire in giudizio al diritto di azione. Perché la situazione divenga attuale, è necessario che l'ordinamento riconosca ad un soggetto la titolarità di un interesse, con la connessa capacità di farlo valere e tutelarlo nei confronti degli altri soggetto, tenuti a un comportamento omissivo o commissivo. **Il diritto soggettivo** presuppone una relazione tra due o più soggetti (rapporto giuridico) che vede da una parte il titolare/i della situazione attiva e dall'altra il titolare/i della situazione passiva. Il rapporto giuridico può essere di

This document is available free of charge on StuDocu.com

diritto pubblico o di diritto privato: è di dir. Pubblico quando ambedue i soggetti o uno di essi sono soggetti pubblici (ad es. il rapporto tra lo stato e un ente pubblico o fra lo Stato e un cittadino); è di dir. privato quando ambedue i soggetti sono privati o quando, pur se uno dei soggetti è di diritto pubblico, quel determinato rapporto è disciplinato da norme di dir. privato (ad es. il rapporto tra creditore e debitore o fra un privato proprietario di un alloggio e una p.a. cui l'alloggio è stato dato in locazione). **L'interesse legittimo** si ha quando l'interesse protetto in capo ad un soggetto è inscindibilmente connesso alla tutela di un interesse altrui, generalmente pubblico. L'ordinamento tutela l'interesse del singolo non direttamente, come accade per i diritto soggettivi, ma solo di riflesso e se e in quanto si connetta ad interessi prevalenti. L'esempio è quello del concorso pubblico. Tutti i cittadini, di ambo i sessi, possono accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. I cittadini hanno il diritto soggettivo di partecipare al concorso e il diritto soggettivo di ricoprire il pubblico ufficio, se vincitori. Quindi abbiamo: il potere giuridico di accedere ai pubblici uffici e i due diritti soggettivi sopra menzionati, oltre all'interesse legittimi di chi vi partecipa al regolare svolgimento del concorso. Chi ha partecipato allo stesso e ritiene che vi siano state irregolarità può ricorrere avverso i risultati del concorso innanzi al Giudice amministrativo. L'interesse legittimo del ricorrente è l'annullamento delle prove del concorso. L'interesse legittimo può essere definito come interesse qualificato alla legittimità dell'attività amministrativa, da ciò il collegamento con l'art. 97 che prescriva che i pubblici uffici devono essere organizzati in modo da garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e con l'art. 98 a norma del quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Buon andamento ed imparzialità sono i canoni cui deve uniformarsi l'attività amministrativa. Il ***diritto affievolito*** sarebbe dato da quei diritti, pieni e azionabili giudizialmente, che all'insorgere di un pubblico interesse possono essere sacrificati o convertiti in diritti di altra natura. Ad es. nel caso in cui una P.A. decidesse, per ragioni di pubblica utilità, di sopprimere un ufficio, il diritto del titolare al mantenimento dello stesso verrebbe meno, senza che egli possa avanzare pretese; o se espropriasse per le stesse ragioni una proprietà privata, il diritto verrebbe meno, pur sorgendo un diritto all'indennizzo. L'interesse pubblico finisce col prevalere. I diritti affievoliti sono uguali agli altri fino a quando le esigenze del pubblico interesse non divengono attuali. La Cost. si occupa delle situazioni giuridiche attive sia sotto il profilo sostanziale che processuale. Nel primo caso, riconoscendo e garantendo alcuni diritti soggettivi; nel secondo, disponendo la tutela in giudizio dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

3. L'effettività dei diritti soggettivi- il riconoscimento o disconoscimento delle situazioni giuridiche soggettive è affidato alle forze politiche dominanti. Si pensi alle vicende storiche dei diritti di libertà, all'evoluzione dello Stato moderno in Stato sociale. Nelle democrazie liberali, è stata riconosciuta ai cittadini, con una posizione di eguaglianza formale, una loro sfera di autonomia nei confronti dei pubblici poteri (*libertà dallo Stato o negativa*). Non è sufficiente il riconoscimento di alcuni diritti, se esistono ostacoli che ne impediscono il concreto esercizio. In una società politica perfetta, tutti i cittadini dovrebbero ottenere dall'ordinamento le medesime opportunità di partecipazione attiva alla vita della comunità, secondo canoni di giustizia ed eguaglianza (*libertà nello Stato o positiva*). La Repubblica si impegna a promuovere le condizioni per passare dal piano formale a quello dell'effettivo esercizio: es. art. 4, art. 24, art.32, etc.

4. Le situazioni giuridiche passive: dovere ed obbligo- correlative alle situazioni giuridiche di vantaggio sono, di regola, quelle passive o di svantaggio che sono: **dovere ed obbligo.** Il dovere è una situazione giuridica imputabile non a soggetti determinati ma ad una generalità di soggetti, successivamente determinabili. L'obbligo è una situazione soggettiva in forza della quale un determinato soggetto è tenuto ad osservare un comportamento commissivo o omissivo, attivo o passivo verso un altri soggetto, cui l'ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretenderne l'osservanza. Fin quando la situazione di svantaggio non si specifica, si ha la figura del dovere; mentre, quando si ha un rapporto tra due o più sogg., si ha l'obbligo. Si pensi al dovere di ogni cittadino di svolgere un'attività che concorra al progressi materiale o spirituale della società (art.4); al dovere dei genitori di educare i figli; alla difesa della Patria.

This document is available free of charge on StuDocu.com

Capitolo Quarto LO STATO

Sezione I Stato-Istituzione, Stato-apparato; Comunità statale.

1. Lo Stato-istituzione- Come già osservato, al fine di assicurare un ordinato svolgimento della vita sociale è necessario che la pluralità e la varietà degli ordinamenti giuridici sia ricondotta alla sintesi,all'armonia, rispettando le individualità dei singoli ordinamenti ma al contempo subordinandoli tutti ad una visione unitaria dell'interesse generale. Questo risultato si è storicamente e materialmente ottenuto assegnando al maggiore fra i gruppi sociali,che li comprende tutti ed esprime e tutela gli interessi della collettività,una posizione di preminenza sugli altri,al fine di consentirgli di regolare in modo autoritario sia i rapporti intersoggettivi e sia i rapporti con le collettività comprese nel suo ambito. Questo compito attiene quindi all'ordinamento giuridico dello Stato. Una prima condizione affinchè un ordinamento venga qualificato come statale è che esso non dipenda,per la predisposizione delle regole istituzionali ed organizzative che lo compongono,da un altro ordinamento;che sia cioè **originario**. Se un ordinamento giuridico deriva in tutto o in parte la sua validità da un altro ordinamento non si è in presenza di uno Stato nel significato che oggi si assegna a questo termine,bensì di un altro tipo di società(ad es.una Regione,una Provincia,un Comune). Perché si abbia uno Stato,accanto alla condizione che il suo ordinamento sia indipendente nei confronti di tutti gli altri(originario) se ne pone una seconda,e cioè che esso sia dotato di un **apparato autoritario preminente**, idoneo a individuare e selezionare gli interessi e ad assicurare la composizione degli interessi configgenti e la pacifica convivenza dei consociati. Occorre, inoltre, che l'ordinamento sia su base territoriale, cioè è necessario un elemento materiale quale centro di riferimento degli interessi. Uno Stato senza territorio non è pensabile perché mancherebbe di un elemento indispensabile, che è un fattore di coesione e stabilità. È da escludere che possano considerarsi stati sia quei gruppi sociali non stanziati su un territorio sia quelli stanziati su un territorio le cui dimensioni non siano sufficienti ad attribuirgli interessi generali. Questi ultimi, se pure sono designati col termine Stato, non ne posseggono la condizione materiale e giuridica. Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, i cd stati esigui, sono il primo il frutto di un compromesso politico diretto ad assicurare alla Chiesa una sfera di sovranità territoriale e gli altri residui storici di antiche posizioni di indipendenza. Possiamo quindi definire lo Stato(in una prima approssimazione) come un ordinamento giuridico originario a fini generali dotato di un apparato autoritario posto in posizione di supremazia(preminenza). Lo Stato quindi si distingue e differenzia nettamente da ogni altro ordinamento particolare perché persegue fini generali,mentre gli altri ordinamenti si propongono il conseguimento di fini particolari; allo stesso modo,l'ordinamento statale si distingue dagli altri ordinamenti territoriali in esso compresi perché questi ultimi non hanno il carattere dell'originarietà, dal momento che dipendono,per la loro validità,dal primo. Le circoscrizioni territoriali minori in cui lo Stato può suddividersi infatti possono esercitare la potestà di costituire

autonomamente il loro ordinamento soltanto nei limiti preventivamente stabiliti dallo Stato. (Attualmente si è posta l'esigenza di creare circoscrizioni territoriali più ampie(la città-regione,le aree metropolitane,l'accorpamento dei cosiddetti "comuni polvere" al fine di adeguare la realtà giuridica alla realtà di fatto e di dotare questi nuovi ordinamenti degli strumenti giuridici e finanziari necessari per programmare il loro sviluppo economico-sociale.A tale esigenza è stata data una risposta incisiva con la riforma del Titolo V della II Parte della Costituzione operata con la legge costituzionale n.3 del 2001,che ha introdotto,negli art.114,117,118,119 e 120 espliciti riferimenti alle "Città metropolitane",dando nuova fisionomia alle autonomie locali. D'altra parte,si riscontra la diversa tendenza degli Stati a costituire fra loro unioni sovranazionali con l'intento precipuo di superare,anche se gradualmente,le barriere dei confini e della sovranità di ogni singolo componente per giungere alla creazione di un sistema interstatale di economia integrata e per stipulare convenzioni dirette a tutelare alcuni interessi politico-sociali ad essi comuni.)

2. Lo Stato istituzione e la sua evoluzione storica (le forme di Stato)

La definizione dello Stato come ordinamento a fini generali non può e non deve condurci nell'errore di ritenere che,per ciò solo,tutti gli Stati siano delle società politiche perfette,ed è anzi estremamente difficile che un ordinamento riesca a garantire compiutamente l'effettiva partecipazione di tutte le componenti sociali alla gestione dello Stato stesso,a comporre i conflitti tra i gruppi e a selezionare obiettivamente gli interessi da tutelare e gli scopi da perseguire. Molto spesso anzi è accaduto che lo Stato divenisse strumento per perseguire fini non generali,ad esempio di una classe,di un partito,di un gruppo di cittadini che abbiano conquistato il potere e siano riusciti ad imporsi sugli altri gruppi sociali. Per **forma di stato** si intende *il rapporto che intercorre tra le autorità dotate di potestà d'imperio e la società civile,nonché l'insieme dei principi e dei valori cui lo Stato ispira la propria azione.*

In merito all'esame delle varie forme di Stato che si sono succedute nel tempo,si usa solitamente distinguere tra STATO FEUDALE, ASSOLUTO, MODERNO e SOCIALE,distinzione fondata appunto sulla diversa misura in cui,in ciascuna di queste forme di Stato,si è storicamente assicurata la partecipazione dei governati alla direzione politica dello Stato medesimo,e quindi sulla diversa misura in cui è stato tutelato l'interesse generale. STATO FEUDALE: Nel Medioevo i rapporti di potere avevano carattere esclusivamente privato,che si incarnavano ad es. nel rapporto di dominazione privata che veniva ad instaurarsi tra feudatario e vassallo. Nello Stato feudale quindi,in cui non esisteva una netta linea di demarcazione fra diritto pubblico e diritto privato,il territorio era patrimonio del sovrano e dei vari feudatari e il primo si limitava a impersonare l'unità dei rapporti di vassallaggio in un ordinamento che si reggeva su una pluralità di comunità autonome non coordinate fra loro. In questa forma di Stato chiaramente non esisteva un interesse generale,né tantomeno una "voluntas omnium"(come la intendevano i giuristi romani),ma appunto tante società particolari,tanti interessi localizzati nel feudo e impersonati dal feudatario(al punto che Calasso ha sostenuto che in questa fase lo Stato fosse stato pienamente esautorato e in via di progressiva disintegrazione). STATO ASSOLUTO: Lo Stato assoluto

This document is available free of charge on StuDocu.com

costituì la reazione al particolarismo feudale,sostituendo l'accentramento rigido alla pluralità di centri di potere medievale. Ciò richiese appunto la creazione di un apparato statale autoritario,con al vertice il monarca, quale fonte di ogni altro potere politico. Nacque in Europa tra il '400 e il '500 e si affermò nei due secoli successivi;si caratterizzò per l'affermazione di un potere sovrano attribuito interamente al Re,la cui volontà costituiva la fonte primaria del diritto,e quindi ciò che il sovrano voleva aveva efficacia di legge. Il suo potere assoluto non incontrava limiti legali(il re era "*legibus solutus"). Lo Stato di Polizia* costituisce una forma razionalizzata dello Stato assoluto ed è così definito perché tende a promuovere il benessere dei sudditi("polizia" va dunque etimologicamente ricollegata a polis e a ius politiae). STATO MODERNO o DI DIRITTO: Il superamento dello Stato assoluto si ha alla fine del 1700, quando il potere viene assunto da una classe sociale,la borghesia,che ha ormai acquistato(anche in seguito alla sua ascesa economica)una forza politica tale da consentirle di governare lo Stato da sola(come in America del Nord,dove le colonie inglesi si svincolano dalla madrepatria). Nasce così lo Stato moderno o di diritto, inteso come l'ordinamento giuridico che centralizza il potere politico autoassoggettandosi a delle leggi. Il detentore del potere politico,in questa forma di Stato,non può auto attribuirsi tale potere,che deve invece essere previamente stabilito da atti normativi(Costituzione,leggi). I principi su cui si basa questa forma si Stato sono in buona parte contenuti nei bills of rights che i coloni inglesi del Nord America anteposero alle costituzioni che si dettero quando proclamarono l'indipendenza dalla madrepatria(1776),nella "Dichiarazione di indipendenza" emanata dal Congresso di Filadelfia dello stesso anno e nella "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino"redatta dall'Assemblea nazionale francese nel 1789. Nella dichiarazione di indipendenza nordamericana si legge che tutti gli uomini sono stati creati uguali,che essi sono stati dotati dal creatore di diritti inalienabili e che fra questi vi sono in primo luogo,la vita,la libertà e la ricerca della felicità. Inoltre,si afferma che per assicurare il godimento di tali stessi diritti,gli uomini hanno stabilito dei governi la cui autorità emana dal consenso dei governati. Lo Stato moderno assume quindi come propri i principi dell'uguaglianza formale,della tutela dei diritti inalienabili,dell'autorità legittimata dal consenso dei governati,e si da costituzioni scritte in cui questi principi sono solennemente proclamati. Con l'espressione "STATO DI DIRITTO"(teorizzato da Montesquieu nel suo L'esprit des lois del 1748) si indica quindi la soggezione di tutti i pubblici poteri alle norme giuridiche, che segna il tramonto definitivo del Sovrano *legibus solutus.* Si tratta di una svolta alla quale contribuirono in maniera decisiva le dottrine liberali del XVIII e XIX secolo,miranti a delimitare la sfera d'azione dello Stato nei confronti dell'individuo singolo e a distribuire il potere fra i vari organi dell'apparato autoritario in modo da evitare gli arbitri dei governanti(sempre possibili quando l'autorità è accentrata in un solo organo). Proprio in seno al nascente Stato di diritto si individua quindi il principio della divisione dei tre poteri(legislativo,esecutivo e giudiziario). Tuttavia questa prima incarnazione dello Stato moderno appare strutturata su basi oligarchiche, in quanto essa realizzò storicamente quella che è stata definita la dittatura della borhesia,escludendo dalla partecipazione al governo dello

Stato chi non facesse parte di tale classe. Ne consegue che seppure la sfera degli interessi giuridicamente tutelati risultasse notevolmente ampliata rispetto al passato,aveva comunque natura settoriale. L'evoluzione dello Stato moderno è caratterizzata,sul piano giuridico,dalla progressiva estensione del suffragio(fino a giungere poi al suffragio universale,che in Italia è stato introdotto solo a partire dalle elezioni del '46) e dalla costituzione,accanto ai partiti politici di élites,dei "partiti di massa". Questo fenomeno trova il suo fondamento nella realtà economico-sociale a cavallo tra 800 e 900,basti pensare al rapido processo di industrializzazione cui si ricollega la formazione del proletariato urbano. STATO SOCIALISTA e STATO AUTORITARIO: Alla fine della prima guerra mondiale lo Stato di tipo liberale-ottocentesco entra quindi in crisi e ad esso si contrappone lo STATO SOCIALISTA nel quale tutto il potere appartiene ai lavoratori delle città e delle campagne, e lo STATO AUTORITARIO,nel quale da un lato viene esaltata la collettività nazionale mentre dall'altro non la si ritiene capace di autogovernarsi politicamente, sì da rendersi necessaria la figura di un capo carismatico che la rappresenti e la guidi. STATO SOCIALE: Il secondo dopoguerra segna il passaggio dallo Stato moderno allo Stato sociale. Quest'ultima forma di Stato si caratterizza per l'azione dei pubblici poteri diretta a promuovere il benessere dei cittadini(WELFARE STATE)mediante un intervento programmato e sempre più esteso nelle attività economico-sociali e nel campo della protezione sociale. A differenza però del paternalistico Stato di polizia,lo Stato sociale esalta le sue varie componenti per sollecitarne la partecipazione ed il consenso. Esso quindi non fa leva soltanto sulle libertà civili e politiche e sull'uguaglianza formale,ma anche su una più equa distribuzione dei redditi,presupposto essenziale per il raggiungimento di un'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE di tutti i governati. Un'ulteriore forma di Stato,propria,fino a qualche tempo fa,soprattutto dei paesi dell'Est europeo,era data dallo "Stato socialista" o "del socialismo reale", che si ispira alla dottrina marxista-leninista e si distingue per la collettivizzazione dei mezzi di produzione(con la conseguente limitazione del diritto di proprietà),l'esistenza di un partito unico(il partito comunista),tutt'al più fiancheggiato da partiti satelliti,la prevalenza assegnata al principio di uguaglianza sostanziale rispetto a quello delle libertà civili e politiche. (Attualmente questa forma di Stato è presente unicamente nella Repubblica popolare cinese,nella Corea del Nord,a Cuba,nel Vietnam e nel Laos).

3. Stati unitari e Stati composti-Secondo un criterio di classificazione secondario,le forme di Stato si distinguono in unitarie e composte. Si ha uno Stato **unitario** quando il potere sovrano è attribuito ad un unico ente dall'ordinamento; lo Stato **composto** quando detto potere è invece suddiviso fra uno Stato centrale e più enti che hanno la caratteristica di Stati. La forma più diffusa di Stato composto è lo **stato federale**,che si ha quando più Stati,pur conservando la loro identità,si uniscono per dar vita ad un ordinamento statale ad essi sovrapposto(Stato centrale) al quale conferiscono determinati poteri sovrani relativi alle relazioni internazionali,alle forze armate,alle comunicazioni,allo sviluppo economico;di modo che i rapporti fra lo Stato centrale e gli Stati membri che compongono lo Stato federale,se da un lato risultano improntati

This document is available free of charge on StuDocu.com

al rispetto di quella parziale sfera di sovranità di cui questi ultimi sono titolari, dall'altra vedono lo Stato centrale in una posizione assolutamente preminente,al fine di consentire che questo,soprattutto nei campi sopracitati della politica economica,delle relazioni internazionali e della legislazione,adotti un indirizzo unitario. (Esempi di Stati federali sono gli Usa,la Germania,la Svizzera,ecc.)

*4.**Stati accentrati e Stati decentrati-*** A sua volta,lo Stato unitario tende ad acquisire la fisionomia o di Stato rigidamente **accentrato**,in cui le tre funzioni fondamentali sono esercitate in via esclusiva da organi dello Stato soggetto, oppure **decentrato** in cui si attua un'ulteriore e più intensa forma di decentramento mediante la creazione di enti territoriali ai quali vengono conferite la potestà di legiferare in determinate materie e la corrispondente potestà amministrativa(ma non la funzione giurisdizionale che resta di esclusiva spettanza dello Stato).Il decentramento può andare da un massimo,che si ha nello Stato federale (che attribuisce ai singoli Stati membri una sfera di potere sovrano), ad una forma intermedia,propria degli Stati regionali,nei quali le Regioni svolgono le funzioni legislativa e amministrativa nei limiti dell'ordinamento unitario dello Stato, fino ad un minimo,negli Stati che concedono soltanto ristretti ambiti di autonomia agli enti territoriali minori. Da questa forma di decentramento che definiamo *istituzionale* e che trasferisce dallo Stato-soggetto ad enti diversi la titolarità di parte delle funzioni sovrane ed il connesso potere decisionale, va distinto il *decentramento organico o burocratico, che* si ha quando la funzione amministrativa viene distribuita,sempre all'interno dell'apparato autoritario dello Stato,fra organi centrali e organi periferici,assegnando a questi ultimi oltre che funzioni meramente esecutive anche un potere decisionale in merito alle questioni locali.Se poi nel tipo di centramento detto "burocratico" gli organi statali periferici vengono formati con la partecipazione delle popolazioni locali,si avrà(secondo il modello tradizionale della Gran Bretagna)l'auto-governo(*self-government).* La nostra Costituzione,conformemente ai principi di democrazia sostanziale cui si ispira,dopo aver ribadito all'art.5 l'unitarietà dello Stato("La Repubblica,una e indivisibile…"),impegna il legislatore non solo a riconoscere e a promuovere le autonomie locali(decentramento istituzionale),ma anche ad attuare il più ampio decentramento amministrativo(vale a dire il decentramento organico)e anzi ad adeguare i principi e i metodi della legislazione alle esigenze delle autonomie e del decentramento. Forti ostacoli sono stati in realtà posti dall'apparato politico-burocratico dello Stato all'attuazione di questa disposizione;solo di recente infatti alle autonomie locali è stato dato un nuovo ordinamento attraverso il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali(D.Lgs n.267 del 2000).Non si è ancora provveduto invece ad adeguare il sistema della finanza locale ai principi contenuti nell'art.119 della Costituzione, tranne che con una legge-delega sul "federalismo fiscale",con la conseguenza che viene ad essere ostacolata la piena realizzazione di quel ruolo promozionale che le comunità locali chiedono agli enti territoriali di assolvere.

5. Le unioni di Stati- Più Stati possono unirsi fra loro,pur conservando la propria sovranità,per dar vita ad una unione di Stati. La più importante di tali unioni è ad oggi l'Organizzazione delle Nazioni Unite(ONU),nata a seguito della Conferenza di San Francisco(1945),i cui organi principali sono l'Assemblea,il Consiglio di Sicurezza(composto da 15 membri,di cui 5 permanenti:USA,Russia,Repubblica popolare cinese,Gran Bretagna,Francia),il Segretariato generale,il Consiglio economico e sociale e la Corte internazionale di giustizia. L'ONU persegue il mantenimento della sicurezza internazionale,il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della collaborazione fra Stati. Di tale unione(che ha il potere di intervenire a tutela della pace e della sicurezza internazionale anche ricorrendo all'uso della forza)fanno oggi parte quasi tutti gli Stati del mondo. La Svizzera è uscita dal suo tradizionale neutralismo, aderendovi nel 2002- Altre unioni di rilievo sono le riunioni a carattere politico-economico:la CECA(che è stata estinta nel 2002)e che aveva per fine la realizzazione di un mercato comune di carbone e acciaio in Europa;la Comunità/Unione europea,diretta,tra l'altro,alla formazione di un mercato comune unico europeo;la Comunità europea dell'energia atomica(CEEA)ecc. Queste sono organizzazioni sovranazionali.

6. Trattato di Maastricht - Con il Trattato sull'Unione europea(firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 dagli Stati aderenti alla CEE)si è dato concreto avvio all'integrazione politica ed economica dell'Europa,con il fine di costituire un mercato economico europeo unico,un'Unione economica e monetaria ed una vera e propria cittadinanza europea(con i connessi diritti e doveri)attribuita ai cittadini degli Stati membri. Per quel che riguarda in particolare l'ordinamento costituzionale italiano,va detto che in principio erano stati avanzati dubbi circa la compatibilità di singole clausole del Trattato con alcune disposizioni costituzionali(ad es.,il conferimento del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione che sembrava non compatibile con l'art.48,che attribuisce invece il diritto di voto ai soli cittadini italiani,e con l'art.51,che egualmente attribuisce ai soli cittadini il diritto di accedere alle cariche elettive). In sede di lavori parlamentari del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato è prevalsa, però, l'opinione secondo cui l'art.11 della Costituzione valga a legittimare l'immissione nell'ordinamento italiano delle disposizioni del Trattato,anche se apparentemente non compatibili con il testo della Costituzione. Ed è così stato possibile attribuire(con il D.Lgs 197 del '96)ai cittadini dell'Unione europea l'elettorato attivo per il rinnovo degli organi del Comune e della circoscrizioni in cui sono residenti;agli stessi è riconosciuto inoltre l'elettorato passivo,limitatamente alle cariche di consigliere comunale e componente della Giunta,con esclusione della carica di vicesindaco.
Particolare rilievo ha assunto l'elezione a suffragio universale e diretto dei membri del Parlamento europeo che,già prevista dai trattati istitutivi delle Comunità e

This document is available free of charge on StuDocu.com

continuamente rinviata,si è poi svolta il 10 giugno 1979:fino a tale data,il Parlamento era composto da delegati dei Parlamenti nazionali designati fra i propri membri.

7. Trattato di Amsterdam - I Trattati istitutivi delle Comunità europee e il Trattato di Maastricht sono stati modificati dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997. Le novità più importanti di tale Trattato sono:l'enunciazione di alcuni principi fondamentali(democraticità,tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,regole basilari dello Stato di diritto),la cui violazione può portare a gravi sanzioni a carico degli Stati responsabili; un ampliamento dei poteri del Parlamento europeo nel processo di formazione delle normative comunitarie; l'importanza centrale del tema dell'occupazione.

8. Trattato di Nizza – Nel 2001 è stato approvato il Trattato di Nizza, che ha introdotto modifiche di rilievo tra cui: rafforzamento dei poteri del Presidente della Commissione; l'aumento dei parlamentari europei da 626 a 732 ecc.

9. Trattato costituzionale e Trattato di Lisbona – I rappresentanti di tutti gli Stati dell'UE avevano sottoscritto, a Roma, nel 2004 un trattato istitutivo di una Costituzione per l'Europa. Tuttavia, il processo verso un'istituzionalizzazione in senso costituzionale europeo ha subito una battuta d'arresto, con l'esito negativo dei referendum in Francia ed Olanda. Il 13 dicembre 2007 è stato sottoscritto il Trattato di Lisbona,che modifica sia il Trattato istitutivo dell'UE sia il Trattato istitutivo della Comunità europea,senza sostituirsi agli stessi. Le novità salienti sono: l'introduzione della "iniziativa dei cittadini",in base alla quale 1.000.000 di cittadini dell'Unione,appartenenti ad un certo numero di Stati membri,può invitare la Commissione a presentare una proposta; distinzione delle competenze per categorie; riconoscimento esplicito della facoltà degli Stati di recedere dall'Unione europea; introduzione della figura del Presidente del Consiglio europeo,con un mandato di 2 anni e mezzo;attribuzione di validità ed efficacia giuridica alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(CEDU)approvata a Nizza nel 2000;istituzione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;conferimento all'Unione della personalità giuridica unica; rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo; maggiore applicazione del principio di sussidiarietà. Il Trattato è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è entrato in vigore il 1 dicembre 2009.

10. La Confederazione di Stati - Una forma particolare di unione di stati è data infine dalla **confederazione**,costituita,in base ad un trattato,da Stati per lo più contigui che conservano la loro sovranità e che si associano al fine di meglio provvedere alla loro difesa verso l'esterno. Le Confederazioni si danno normalmente degli organi comuni,il più importante dei quali è l'assemblea confederale(costituita dai rappresentanti dei vari Stati)cui è affidato il potere legislativo nei limiti e nelle maniere indicati dal trattato istitutivo. Un esempio è costituito dalla NATO e dalla Lega degli Stati arabi.

11. Gli elementi costitutivi dello stato – istituzione; osservazioni generali- Elementi imprescindibili dello Stato- istituzione sono quindi: l' **originarietà** intesa come indipendenza dell'ordinamento giuridico statale da ogni altro; la **territorialità** dell'ordinamento stesso,nel senso che il territorio costituisce l'ambito spaziale di riferimento degli interessi generali di cui l'ordinamento appresta la tutela;la **natura dei fini** che lo Stato persegue,che sono generali perché propri dell'intera collettività;la **preminenza** dell'apparato autoritario statale rispetto a quello degli altri gruppi sociali. La compresenza e la combinazione di questi quattro elementi ci da il gruppo sociale Stato;vale quindi che essi sono ugualmente coessenziali allo Stato stesso e pertanto,mancando anche uno solo di essi,non si ha uno Stato bensì un diverso gruppo sociale. Questi stessi elementi valgono ad individuare il gruppo sociale Stato come entità astratta,ideale; storicamente, però, uno Stato di questo tipo è esistito soltanto nel periodo(relativamente limitato)delle monarchie assolute,quando ciascuno degli elementi essenziali venne fortemente esaltato come reazione al particolarismo feudale. Ad oggi,lo Stato contemporaneo non si identifica più completamente nel modello astratto,che è stato profondamente modificato dalla realtà giuridica e di fatto in cui esso svolge la sua azione. Assistiamo, infatti, ad un fenomeno che può apparire per certi versi contraddittorio:da un lato lo Stato estende nel suo interno i suoi interventi a campi sempre più vasti,dall'altro acconsente a limitazioni esterne della propria sovranità sempre maggiori per effetto della partecipazione a organismi sovranazionali(UE). Sempre con riferimento ai mutamenti intervenuti negli elementi costitutivi dello Stato,c'è da notare che lo Stato contemporaneo(a differenza dello Stato ottocentesco) non persegue più soltanto fini generali(difesa verso l'esterno,il mantenimento dell'ordine pubblico,la pubblica istruzione ecc.)bensì anche fini settoriali,propri di una parte della collettività(per es. la pianificazione dello sviluppo industriale del Mezzogiorno nel nostro ordinamento).

12. I singoli elementi costitutivi dello Stato: a) il territorio - Il territorio,come elemento essenziale dello Stato,è costituito in via esclusiva da quella parte del globo terrestre sulla quale lo Stato è legittimato ad esercitare la propria sovranità. La precisa delimitazione dello stesso ,pertanto,è condizione essenziale per garantire allo Stato l'esercizio della sovranità,e per assicurare agli Stati l'indipendenza reciproca. Il territorio dello Stato è perciò costituito dalla terraferma e dalle acque interne(fiumi,laghi,mari interni)comprese entro i confini e inoltre,dallo spazio aereo sovrastante,dal sottosuolo e da quel tratto di mare adiacente alle coste(e che comprende anche le profondità subacquee)che è detto "*mare territoriale*". Il territorio è delimitato da confini che possono essere *naturali*(es.,la catena delle Alpi),nel senso che le convenzioni internazionali possono decidere di assumere elementi naturali per porli come linea di demarcazione fra Stati,oppure *artificiali*,quando la linea di confine è fissata non avvalendosi di elementi naturali, ma di opere dell'uomo(un reticolato,una strada ecc.) Nel caso di confini naturali,e in mancanza di particolari convenzioni fra gli Stati limitrofi,la linea di confine: 1) se si tratta di una catena di montagne,è data dalla linea che congiunge le vette più elevate; 2) nel caso di un fiume navigabile,coincide con la linea della corrente più forte e più alta(linea Talweg)

This document is available free of charge on StuDocu.com

per consentire ai due Stati la navigazione rivierasca; 3)se invece il fiume non è navigabile,con la linea mediana dello stesso; 4)nei laghi,è data dalla retta che unisce i punti terminali del confine in terraferma. L'estensione del mare territoriale è variabile da Stato in Stato,con un minimo di 3 miglia marine(la gittata massima di un cannone prima dello sviluppo della moderna tecnologia bellica) fino ad un massimo di 12-15 miglia a partire dalla linea della marea più bassa seguendo l'andamento delle coste. Il codice di navigazione italiano fissa l'estensione del mare territoriale a 12 miglia. Problemi particolari sorgono invece relativamente allo sfruttamento della *piattaforma continentale,* quella parte di fondo marino contigua al territorio continentale degli Stati,rispetto al quale l'art.76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del maew stabilisce che lo Stato rivierasco esercita i diritti sovrani su tale parte di territorio al fine di esplorazione dello stesso e dell'utilizzazione delle sue risorse naturali. In Italia,un'apposita legge('67,n.613)disciplina la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi sia nel mare territoriale sia nella piattaforma continentale. L'importanza dell'elemento territoriale come elemento fondamentale dello Stato si desume anche all'art.241 del c.p.,che fa rientrare nei delitti lesivi della personalità dello Stato l'attentato all'integrità territoriale. Al di là del mare territoriale(nel quale lo Stato fa valere la propria sovranità)si estende il *mare libero o alto mare* non soggetto alla sovranità di alcuno Stato.
Strettamente legati al territorio, sono gli istituti della **extraterritorialità** e dell'**immunità territoriale**. L'extraterritorialità è una finzione giuridica, in base alla quale le navi e gli aeromobili militari, che si trovano nelle acque territoriali o nello spazio aereo di un altro Stato, sono soggetti alle leggi dello Stato del quale battono bandiera. A norma poi dell'art.5 del codice della navigazione,"gli atti e i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile". Oltretutto,per l'art.4,"le navi italiani in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati territorio italiano". L'immunità territoriale si ha quando una porzione del territorio statale risulta parzialmente immune o esente dalla potestà d'imperio dello Stato. I casi più frequenti di immunità territoriale sono dati dalle sedi delle rappresentanza diplomatiche straniere e da ogni luogo in cui risieda,anche solo temporaneamente,l'agente diplomatico(ad es.,una camera d'albergo);in tali luoghi lo stato,per una norma consuetudinaria di diritto internazionale,non può esercitare la sua potestà d'imperio,a meno che non vi acconsenta l'agente diplomatico stesso. (Caso specifico di immunità territoriale è quello relativo a Piazza S.Pietro che,a norma dell'art.3 del trattato fra Santa Sede e l'Italia,pur facendo parte della Città del Vaticano,resta aperta al pubblico ed è quindi soggetta ai poteri delle autorità italiane il cui esercizio si arresta,tuttavia,ai piedi della scalinata della Basilica). In merito alla natura del diritto dello stato sul proprio territorio, si discute ancora oggi in dottrina:ad oggi,nonostante svariate tesi,sembra si possa accogliere quella secondo la quale il diritto dello Stato sul territorio rientra nella categoria dei diritti sugli elementi costitutivi della propria persona(allo stesso modo del diritto al nome o all'onore)e non alla categoria dei diritti reali:il diritto reale infatti presuppone un oggetto

giuridicamente diverso dal soggetto suo titolare. Ciò non toglie che il territorio possa essere assunto anche come elemento costitutivo,oltre che dello Stato,anche di altri enti(Regioni,Province,Comuni)in esso compresi,e che vengono appunto detti "territoriali" per significare che il loro territorio rappresenta una condizione essenziale per la loro esistenza giuridica,a differenza invece di quanto avviene per gli enti "non territoriali"(enti parastatali,camere di commercio,enti pubblici economici ecc.)per i quali il territorio costituisce soltanto l'ambito entro il quale esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge.
Infine,c'è da osservare che lo Stato può possedere,a titolo di proprietà pubblica o privata,determinate parti del territorio (beni demaniali e patrimoniali; lidi,spiagge,porti,fiumi,torrenti,laghi appartengono necessariamente allo stato e sono soggetti a regime giuridico speciale). Storicamente,è avvenuto che l'intero territorio appartenesse allo Stato(come nell'ex URSS in conseguenza del regime politico-sociale allora esistente).

13. b) il popolo - L'elemento umano acquista nello Stato-istituzione una determinata qualificazione giuridica e innanzitutto un suo nomen iuris che è quello di **popolo**,che sta a designare la comunità di tutti coloro ai quali l'ordinamento giuridico statale assegna lo status di cittadino. Da detto status deriva una serie di situazioni giuridiche attive e passive, che valgono a porre i cittadini in relazione con l'apparato autoritario,laddove invece i non-cittadini (stranieri e apolidi) sono di regola esclusi dal godimento di alcuni diritti(aventi solitamente natura politica) e non sottoposti all'osservanza di alcuni doveri(aventi anch'essi natura per lo più politica). Si fa riferimento,a tal riguardo,alle norme contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione italiana,che riservano ai soli cittadini un trattamento giuridico che ne assicura la pari dignità sociale e l'uguaglianza formale e sostanziale,il diritto al lavoro e le libertà di circolazione e di soggiorno,di riunione,di associazione,consentendone l'estradizione solo ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali e non ammettendola in caso di reati politici,tranne che si tratti del reato di genocidio; riconoscono inoltre ai cittadini inabili al lavoro o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ed attribuiscono infine ai cittadini il diritto di elettorato attivo,di associarsi in partiti politici,di rivolgere petizioni alle Camere e di accedere agli uffici e alle cariche elettive. Allo stesso modo,alcuni doveri sono propri soltanto dei cittadini,e precisamente il dovere di lavorare,di difendere la patria,di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. Allo stesso modo però,l'art.2,con una formulazione che comprende sia i cittadini che i non cittadini,statuisce che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale";inoltre l'art.10 riconosce allo straniero, al quale venga impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche,il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Il legame fra popolo e territorio è, quindi, diretto: nel territorio dello Stato infatti possono esprimersi e localizzarsi interessi generali in quanto questi stessi interessi fanno capo

This document is available free of charge on StuDocu.com

ad una comunità determinata e stabilmente stanziata su di esso. Presupposto per l'acquisto della qualità di cittadino è la comunanza di certi valori ed interessi che valgono a distinguere una comunità statale da un'altra,ad imprimerle cioè una particolare fisionomia. Uno Stato esiste quindi fintanto che fra i suoi cittadini vi sia l'IDEM SENTIRE DE RE PUBBLICA,permanga cioè il vincolo associativo che li faccia sentire partecipi della comunità. La cittadinanza italiana viene acquistata, in base alla legge n.91 del 1992: con la nascita per: ius sanguinis: ossia acquista la cittadinanza il figlio(anche adottivo)di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana; ius soli: ossia acquista la cittadinanza colui che è nato in Italia da genitori ignoti o apolidi(cioè privi di qualsiasi cittadinanza) o che,nato in Italia da cittadini stranieri,non ottenga la cittadinanza dei genitori sulle basi delle leggi dello Stato cui essi appartengono. È cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica. Lo straniero nato in Italia,che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se entro un anno dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; su istanza dell'interessato(gravata dal pagamento di un contributo di 200 euro)rivolta al sindaco del Comune di residenza o all'autorità consolare,e in particolare: dal coinuge,straniero o apolide,di un cittadino o cittadina italiani qualora ricorrano determinate condizioni(che dopo il matrimonio risieda in Italia per almeno 2 anni o che siano decorsi almeno 3 anni dalla data del matrimonio e in costanza del medesimo;i termini sono dimezzati in presenza di figli); dallo straniero che possa vantare un genitore o un ascendente di secondo grado che sia cittadino italiano per nascita; dallo straniero che abbia raggiunto la maggiore età e che sia stato adottato da cittadino italiano e ivi residente da almeno 5 anni successivi all'adozione; dallo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni; dal cittadino di uno degli Stati membri dell'UE,dopo almeno 4 anni di residenza nel territorio della Repubblica; dall'apolide dopo almeno 5 anni di residenza;dallo straniero dopo almeno 10 anni di regolare residenza. Casi di perdita della cittadinanza: **per rinuncia**(il caso del cittadino che possieda,acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera,qualora risieda o abbia deciso di stabilire la propria residenza all'estero); **autonomamente,** il caso del cittadino che svolgendo funzioni alle dipendenze di uno Stato estero,intenda conservare questa posizione nonostante l'intimazione del Governo italiano a cessare tale rapporto di dipendenza. La cittadinanza italiana non può essere riacquistata quando ricorrano alcune condizioni(fissate dalla legge 91/1992). A norma dell'art.22 nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici. La qualità di cittadino e l'appartenenza allo Stato non vale tuttavia a fare del popolo di ogni Stato un'entità isolata e racchiusa entro i confini,soprattutto con l'avvio del processo di integrazione europea e la creazione di organizzazioni sovranazionali. La cittadinanza europea è stata istituita dal Trattato di Maastricht e spetta a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Essa attribuisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati ed il diritto,per i residenti in uno Stato- membro di cui non sono cittadini,di voto e di eleggibilità nelle lezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato. L'aver considerato il popolo come portatore di interessi generali

territorialmente localizzati induce ad accogliere al riguardo,la tesi secondo cui il popolo è nel nostro ordinamento una *figura giuridica soggettiva*, vale a dire un soggetto privo di personalità giuridica ma titolare di situazioni giuridiche,anche se non di veri e propri diritti soggettivi. La maggiore tra queste situazioni soggettive si identifica nella **sovranità**,ossia nel massimo potere di governo,da esercitare "nelle forme e nei limiti della Costituzione"(secondo quanto recita il secondo comma dell'art.1). Dal popolo come insieme dei cittadini va distinta la **popolazione** dello Stato,termine col quale si indica, invece, il complesso di tutti coloro(cittadini,stranieri,apolidi)che in un dato momento risiedono stabilmente sul territorio dello Stato e sono sottoposti alle sue leggi. La consistenza della popolazione viene accertata periodicamente(in Italia ogni 10 anni)mediante un censimento generale. **Stranieri** sono i cittadini di un altro Stato. Sono sottoposti alle leggi dello Stato(in particolare per quanto riguarda ingresso,soggiorno ed espulsione).In Italia gli stranieri sono titolari delle situazioni giuridiche attive e passive non riservate espressamente dalla Costituzione e dalle leggi ai cittadini(per il godimento dei diritti civili vale inoltre,a norma dell'art.16 delle preleggi,la condizione di **reciprocità** con il trattamento riservato dal loro Stato di appartenenza ai cittadini italiani). A norma dell'art.10 invece la condizione giuridica dello straniero in Italia è regolamentata dalle norme di diritto internazionale. **Apolidi** sono coloro che non hanno alcuna cittadinanza. Sono anch'essi sottoposti alle leggi dello Stato(soprattutto per quanto attiene all'esercizio dei diritti civili e all'obbligo del servizio militare). Va notato che la legge sulla cittadinanza tende ad eliminare l'apolidia,statuendo che il figlio di apolidi nato in Italia acquista la cittadinanza italiana.
Dal popolo va ancora distinta la **nazione**,che sta a designare un'entità etnico-sociale caratterizzata dalla comunione di razza,lingua,cultura,costumi,tradizione,religione ecc.fra coloro che la compongono. Quest'entità preesiste allo Stato e ne costituisce una delle basi sociologiche. Possono dunque esistere Stati i cui cittadini appartengono a più nazioni (Stati plurinazionali).L'Italia non può essere considerata uno Stato plurinazionale,data la scarsa consistenza numerica dei suoi cittadini appartenenti a gruppi etnici diversi per lingua,tradizioni,costumi(residenti soprattutto in Valle d'Aosta,provincia di Bolzano e in alcune zone del Friuli-Venezia Giulia). Tuttavia,a norma dell'art.6,la Costituzione tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ivi residenti:in esecuzione a quest'articolo,gli Statuti speciali della Valle d'Aosta,del Trentino e del Friuli prevedono particolari misure per assicurare la parità di diritti e di trattamento e la salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali di tali minoranze. A norma dell'art. 51 Cost., "la legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica", vale a dire gli appartenenti alla nazione italiana che siano cittadini di un altro Stato.

14. c) sovranità- L'attributo della sovranità,come proprio dello Stato,può essere inteso in due diversi significati strettamente interconnessi e interdipendenti. In una prima accezione(*sovranità interna*),la sovranità consiste nella posizione di supremazia dell'ordinamento statale rispetto agli altri ordinamenti minori(che in ragione di ciò necessitano del riconoscimento statale per essere pienamente legittimi).

This document is available free of charge on StuDocu.com

In un secondo significato,per sovranità (sovranità esterna)si intende, invece, l'originarietà,e quindi,l'indipendenza,dell'ordinamento statale rispetto ad ogni altro Stato. Questi due significati sono del resto riassunti dall'art.7,che stabilisce infatti che lo Stato e la Chiesa cattolica sono,ciascuno nel proprio ordinamento, indipendenti(sovranità come indipendenza da un potere esterno) e sovrani(sovranità come supremazia interna). La supremazia dell'ordinamento statale non è soltanto un principio astratto,ma si concretizza in una serie di atti mediante i quali viene esercitato il comando e fatta valere la supremazia,atti che sono emanati dagli organi che entrano a far parte dell'apparato autoritario dello Stato,e cioè la legge, l'atto amministrativo e la sentenza. L'autorità dello Stato si oggettivizza, in tal modo,in atti formali cui l'ordinamento riconosce una specifica efficacia,e cioè la *forza* della legge,l'*esecutorietà* dell'atto amministrativo e la *cosa giudicata* della sentenza definitiva. *Così la teoria teocratica individuava nella volontà di Dio la fonte prima della sovranità(OMNIS POTESTAS A DEO). Nella civiltà medievale infatti,il re era considerato pro vice Christi. La teoria della sovranità popolare, invece,già enunciata dai giuristi romani in età repubblicana,bruscamente interrottasi durante il principato("Quod principi placuit,legis habet vigorem") è poi stata elaborata e messa appunto come teoria contrattualistica ad opera di Rousseau(patto sociale che da vita alla società politica,considerato come espressione del consenso popolare). Ancora,la Rivoluzione francese reca con sé l'idea che la sovranità corrisponda alla volontà popolare:si tratta di una prima affermazione del principio di eguaglianza,che sarà poi alla base del costituzionalismo democratico,ma come sappiamo la Rivoluzione non compì il passo successivo:di fatti la stessa volontà della maggioranza,se non sottoposta a limiti,diventa volontà dispotica;il Parlamento in tal modo assunse su di sé le caratteristiche che erano state proprie del sovrano assolutista. Pertanto si pose l'esigenza di stabilire un limite giuridico al si sopra della stessa volontà della maggioranza, la legge. Da ultimo,nella teoria nazionalsocialista,era il Fuhrer ad incarnare la volontà popolare. Secondo i teorici del nazionalsocialismo infatti,il Fuhrer possedeva non soltanto lo spirito del popolo (VOLKSGEIST) ma anche la volontà del popolo (VOLKSWILLE),per cui la sua autorità derivava dal popolo.* La sovranità,oggi,va riconosciuta non più allo Stato- soggetto, per il solo fatto che da esso emanano gli atti di autorità,bensì a quella "persona vivente",a quel complesso di persone alle quali l'ordinamento conferisce istituzionalmente il potere supremo di determinare lo Stato. Secondo il II comma dell'art.1 della Costituzione infatti "la sovranità spetta al popolo",che però la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Nell'epoca contemporanea quindi,la sovranità tende a diventare OGGETTIVA,non più quindi connotato di un soggetto(principe,partito,Stato,popolo o altro),ma di un sistema di valori, che risulta incarnato dalla Costituzione.

15. Stato – istituzione; Stato – apparato; comunità statale – Lo **Stato istituzione** , o meglio lo Stato inteso in questo senso, indica uno dei corpi sociali organizzati(anche detti ISTITUZIONI),con propri ed esclusivi elementi costitutivi,che valgono ad individuare l'ordinamento giuridico statale come comprensivo di tutti gli ordinamenti particolari e ad essi sovraordinato. È questo lo Stato che la nostra Cost. designa più spesso col termine "Repubblica", ma anche Italia, Patria, Paese. Inteso come **apparato,** il termine Stato designa l'apparato autoritario,vale a dire quel complesso di autorità cui l'ordinamento attribuisce il potere di emanare e applicare le norme e i comandi mediante i quali lo Stato stesso fa valere la propria supremazia. Allo Stato

così inteso, detto anche **Stato – governo**, l'ordinamento può conferire personalità giuridica,e allora si parla di Stato-soggetto o Stato-persona. In quest'accezione,esso sarà il massimo dei soggetti giuridici,ma non per questo non sottoposto al diritto. Nel nostro ordinamento,lo Stato apparato,in quanto titolare di situazioni giuridiche attive e passive,è persona giuridica. Nell'ordinamento inglese e in quello della Città del Vaticano allo Stato non viene riconosciuta la personalità giuridica. Inteso come **comunità,** lo Stato è l'insieme di soggetti distinti dallo Stato apparato,ossia i governati. La comunità statale,intesa come "società civile",nelle democrazie pluraliste non è solo destinataria dei comandi dello Stato apparato,ma partecipa anche alla formazione del comando,o in alcuni casi lo predispone direttamente,in un processo di integrazione reciproca fra la sfera dell'autorità con quella della libertà. Mentre lo Stato-istituzione quindi è una realtà giuridica ben determinata nei suoi elementi costitutivi,la comunità statale è una realtà in continua trasformazione.

16. Lo Stato apparato e la sua organizzazione: a) le funzioni dello Stato- l'organizzazione ed i modi di svolgimento delle attività di governo devono essere sottoposti al diritto. Ogni istituzione ha le sue leggi, i suoi atti amministrativi, le sue sentenze dichiarative, costitutive, di condanna. L'attività complessiva diretta alla produzione degli atti dell'autorità viene detta **funzione** come attività organizzata e preordinata al conseguimento di uno scopo. In questo significato, questo termine è stato adottato dalla nostra Cost. agli artt. 70 (funzione legislativa), 102 (funz. Giurisdizionale), 118 (funzioni amministrative). Sono qui indicate le attività dirette alla produzione della legge, della sentenza e dell'atto amministrativo e, per quanto riguarda la funzione giurisdizionale e quella legislativa, anche le autorità che le esercitano (Camere e magistrati ordinari). Nessuna indicazione è dato trovare in materia della funzione amministrativa. È da ritenere che l'attribuzione della detta funzione all'apparato di governo sia presupposta. Un richiamo esplicito alle funzioni amministrative di Stato ed enti pubblici territoriali si ha nell'art.118. Alcuni autori individuano oltre alle tre funzioni ora esplicate, una quarta funzione di *indirizzo politico*. La direzione politica dello Stato implica, non solo la determinazione dei fini dell'azione statale, ma anche la funzionalizzazione della volontà dei governanti e il conseguimento dei fini stessi. Più che di una funzione, sarebbe meglio parlare di un'attività di indirizzo politico.

17. b) le forme di governo- Esse indicano il modo in cui le funzioni dello Stato sono distribuite ed organizzate tra i vari organi costituzionali, avuto particolare riguardo alle attività di indirizzo politico e ai suoi modi di svolgimento. Le forme di governo dello Stato contemporaneo possono ricondursi a tre tipi: **parlamentare; presidenziale; direttoriale.** *La forma di governo parlamentare* è sorta in Inghilterra nel corso del secolo XVIII, per poi affermarsi nell'Europa continentale, assumendo diverse configurazioni. Tuttavia, questa forma di governo possiede una caratteristica fondamentale, comune a tutte le sue interpretazioni storiche, cioè **il rapporto fiduciario che lega le Camere rappresentative al Governo** per cui quest'ultimo deve ottenere la fiducia delle Camere per svolgere la sua attività, fiducia che deve

This document is available free of charge on StuDocu.com

permanere. Le conseguenze sono un potere di controllo del Parlamento sull'attività del Governo, necessario affinché il Governo possa far valere la *responsabilità politica* del Governo mediante un *voto di sfiducia;* l'obbligo del Governo di dimettersi in seguito al voto di sfiducia, essendo venuto meno il rapporto fiduciario. Lo schema del governo parlamentare prevede un'applicazione attenuata del principio della separazione dei poteri: ciascun potere esercita la funzione propriamente attribuitagli, ma anche funzioni di altri poteri (si pensi al potere di controllo del Parlamento sul Governo e all'emanazione di atti normativi da parte degli organi dell'esecutivo). *La forma di governo presidenziale* (esempio classico Stati Uniti d'America) attua una rigida separazione dei poteri. Il modello teorico prevede che le funzioni esecutiva e di indirizzo politico (affidate al Capo dello Stato e all'amministrazione), legislativa (affidata alle assemblee elettive), e giurisdizionale (affidata al corpo dei magistrati) vengano svolte senza interferenze reciproche, salve alcune eccezioni. Ad es. , negli Stati Uniti, nessun rapporto lega il Capo dello Stato e l'esecutivo alle Camere sia perché il Presidente è eletto dal popolo con elezione di II grado, sia perché i segretari di Stato (posti a capo dei vari rami dell'amministrazione e assimilabili ai nostri ministri) sono scelti discrezionalmente dal Presidente e sono responsabili esclusivamente dinanzi a lui. L'indirizzo politico è determinato prevalentemente dal Capo dello Stato. Non esiste un organo collegiale paragonabile al Governo della forma parlamentare. Le Camere non hanno alcuna ingerenza nella determinazione dell'indirizzo politico. Il Congresso (costituito dalla Camere dei rappresentanti e dal Senato) non può provocare la caduta del Presidente se non per atti gravissimi; di converso, il Presidente non può sciogliere le Camere. Il Congresso può condizionare l'indirizzo politico presidenziale, mediante la manovra finanziaria, stanziando o meno i fondi necessari al suo svolgimento. Il Presidente, oltre a poter segnalare al Congresso l'adozione di alcuni provvedimenti, ha quello di veto all'entrata in vigore delle leggi. Il Congresso ha accentuato negli ultimi anni il suo potere di controllo verso le amministrazioni federali. *La forma di governo direttoriale* (almeno secondo il modello oggi attuato in Svizzera) prevede un organo collegiale (Consiglio federale),eletto dalle Camere, al quale è affidata la suprema autorità di governo. Il Presidente della Confederazione che è pure Presidente del Consiglio federale è eletto, per la durata di un anno, fra i membri del Consiglio. Le funzioni di governo sono svolte dai singoli componenti il Consiglio, per cui il potere esecutivo appare come un'emanazione diretta di quello legislativo. Non esiste una relazione fiduciaria tra Consiglio ed Assemblea federale, ma ciò non esclude il sindacato politico delle Camere sui componenti del Consiglio. Non esistono forme di governo buone o cattive in assoluto. Il popolo di ciascuno stato si dà la forma di governo che, in un dato momento storico, meglio ritiene adattarsi alle sue peculiarità, tradizioni. Di ogni forma di governo, esistono diverse concrete applicazioni. Ad es. l'attuale forma di governo francese, pur presentando elementi di quella parlamentare, accentua o poteri del Presidente della Repubblica facendone quasi "un monarca repubblicano". Essa non può includersi strettamente né tra le forme parlamentari né fra quelle presidenziali, costituendo un tipo a sé stante detto semi-presidenziale o parlamentare a tendenza presidenziale. Un tipo di forma i governo parlamentare,

detto *assembleare* prevede la nomina diretta del Governo da parte delle assemblee legislative, la limitazione dei poteri del Capo dello Stato, l'estensione del controllo parlamentare. La forma di governo parlamentare appare non più sufficiente ad assicurare nello Stato contemporaneo una piena partecipazione dei governati alla direzione politica dello Stato. Essa si fonda su una visione formale della democrazia, ottocentesca e su una rappresentanza politica che oggi è messa in discussione (la rappresentatività dei rappresentanti in particolare). Perciò sono state introdotte forme di partecipazione dirette, come il riconoscimento del ruolo dei partiti, dei sindacato, le libertà positive e negative nonché il principio dell'eguaglianza sostanziale, di fatto. Nella stessa forma di governo presidenziale, sono stati accentuati i poteri di controllo del Congresso. *Un cenno meritano la forma di governo di Gabinetto (Gran Bretagna) e quella degli Stati socialisti. La prima, che rientra nella forma parlamentare, è così definita per la preminenza del Gabinetto (costituito dai ministri più qualificati, di regola 20) ed, in seno ad esso, al Primo Ministro cui spetta la direzione politica dello Stato. Gli stati socialisti hanno adottato nel tempo forme di governo differenziate e sono oggi in via di trasformazione verso forme democratiche di tipo occidentale.*

Sezione II, L'ORGANIZZAZIONE E GLI ATTI DEI PUBBLICI POTERI

18. Il principio della separazione dei poteri e le interferenze funzionali- Lo stato liberale ha portato al superamento della accentramento del potere in una sola persona, affermando la divisione del potere fra più organi. Il potere dello Stato, pur restando unico nella sua essenza, viene suddiviso, così da evitare il suo esercizio arbitrario. Il principio della **separazione dei poteri,** la cui teorizzazione risale a Locke e Montesquieu, è stato accolto dalla nostra Cost., che si limita ad indicare quali sono gli organi cui viene attribuito l'esercizio delle funzioni; ma non esclude, anzi, espressamente prevede che la stessa funzione possa essere esercitata da organi diversi da quelli cui è stata istituzionalmente affidata (*cd interferenze funzionali).* Il collegamento tra funzione e complesso di organi che la esercitano non ha valore assoluto. Il principio della separazione dei poteri vuole garantire "la sfera di competenza" dei diversi organi. Nell'ordinamento italiano, il potere legislativo è assegnato alle due Camere; quello esecutivo al Governo e quello giudiziario alla magistratura ordinaria. Ogni potere emana i propri atti con forma tipica: quella della legge formale (potere legislativo), del decreto (potere esecutivo) e della sentenza (potere giudiziario). Con la funzione legislativa, lo Stato pone le norme costitutive dell'ordinamento; con quella amministrativa, svolge un'attività effettiva e concreta per soddisfare i suoi fini immediati; con quella giurisdizionale, lo Stato accerta la volontà normativa da far valere in un caso concreto, interpretando la legge ed applicando le sanzioni. La magistratura ordinaria, infatti, è chiamata a risolvere i conflitti di interesse fra più soggetti. La funzione legislativa e quella amministrativa vengono, in uno Stato ad autonomie regionali come il nostro, suddivise fra Stato e Regioni. Una rigida separazione dei poteri non è in concreto attuabile. Se così fosse, non si avrebbe coordinazione fra i poteri, che garantisce un armonico svolgimento delle funzioni statali. Le **interferenze funzionali** nel nostro sistema costituzionale possono così schematizzarsi: A) il potere legislativo svolge sia *funzioni*

This document is available free of charge on StuDocu.com

materialmente amministrative (ad es. la nomina dei dipendenti delle Camere) sia funzioni *materialmente giurisdizionali* (ad es. il giudizio sulle elezioni contestate dei membri delle Camere o il porre in stato d'accusa il PDR). Esso svolge, inoltre, istituzionalmente una funzione di indirizzo politico, mediante atti legislativi, le cd *leggi di indirizzo politico,* e procedure di controllo, di indirizzo e informazione nell'ambito del rapporto fiduciario tra Camere e Governo. Infine, le Camere sono chiamati a eleggere tutti o parte dei componenti alcuni organi costituzionali (PDR, cinque giudici costituzionali, un terzo dei componenti il CSM); B) il potere esecutivo svolge *funzioni materialmente legislative* quando emana atti che possono avere un'efficacia subordinata alla legge formale (regolamenti) o ad essa equiparata (decreti legge e legislativi). Gli organi della giurisdizione amministrativa ordinaria e speciale (TAR, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, ecc) sono ancora in parte collegati al Governo nella loro composizione (i magistrati di consiglio di Stato e Corte dei Conti sono, per una data quota, nominati dal Governo) anche se i magistrati godono di garanzie di indipendenza. C) il potere giudiziario svolge funzioni *materialmente amministrative* tramite provvedimenti rientranti nella cd "volontaria giurisdizione" (autorizzazione ad acquistare o alienare beni di minori, nomina di un tutore) mentre nel nostro ordinamento, ispirato al sistema della legalità, ai magistrati è assolutamente precluso di creare la norma da applicare al caso concreto, cioè di svolgere funzioni materialmente legislative.

19. Gli organi e la loro classificazione- Essendo le persone giuridiche delle entità astratte, esse devono, per agire, avvalersi di persone fisiche. Col termine **organo** si indica la persona fisica che vuole ed agisce per la persona giuridica (il signor X, Presidente del Consiglio, il signor Y sindaco di Milano e così via). In un'accezione più ampia, l'organo è costituito, oltre che dalla persona fisica, dalla *sfera di competenza* attribuitagli dall'ordinamento e dai mezzi materiali e dalla struttura organizzativa di cui l'organo si avvale per esplicare le sue funzioni. La persona fisica indica l'elemento soggettivo dell'organo, la sfera di competenza, la struttura e i mezzi indicano quello oggettivo. Così considerato l'organo non muta, pur nel succedersi delle persone fisiche ad esso preposte. L'organo non si distingue dalla persona giuridica, ma in essa si immedesima e con essa forma un tutt'uno. Non ha una propria soggettività giuridica. L'attività esplicata dalla persona fisica titolare dell'organo viene imputata dal diritto direttamente all'ente, anche se non sempre ogni agire dell'organo è agire dell'ente. Quando il Parlamento, ad es., approva una legge, tale atto non sarà imputato al Parlamento o alle singole persone fisiche che lo compongono, bensì allo Stato. L'atto compiuto dall'organo al di fuori della sua sfera di competenza sarà sempre atto dell'ente, ancorché viziato e, quindi, annullabile. Per particolari ragioni, di solito a carattere patrimoniale, l'ordinamento può attribuire all'organo la qualità di soggetto (un esempio di organo-soggetto di diritto è il Consiglio nazionale delle ricerche). Per comprendere meglio, si confronti il concetto di organo con quello di rappresentante. Mentre il rapporto di rappresentanza si instaura tra due soggetti dove il rappresentante agisce e gli effetti ricadono nella sfera giuridica del rappresentato, nel rapporto organico l'ente e l'organo non sono

distinguibili, essendo l'organo immedesimato nella persona giuridica. Lo Stato e gli enti pubblici possono avvalersi, in via eccezionale, di rappresentanti. Regioni, province e comuni sono rappresentati in giudizio da liberi professionisti. Lo Stato può affidare la cura di alcuni servizi o di compiti suoi propri ad altri enti (di regola i minori enti territoriali), che devono sopportarne in tutto o in parte le relative spese. Si pensi ai servizi anagrafici, elettorali, di stato civile svolti dai Comuni, alla gestione dei servizi scolastici e giudiziari cui in parte sono tenuti Province e Comuni. Qualora l'assunzione di tali servizi avvenga nell'ambito di un rapporto organico, gli atti del titolare dell'organo ricadono direttamente sullo Stato. **La figura del funzionario di fatto** si ha quando il titolo di investitura della persona fisica all'organo sia irregolare, sia scaduto o venga a mancare. Valga l'es. del parlamentare la cui elezione sia annullata dalla Camera cui appartiene. Di regola, gli atti posti in essere dal funzionario di fatto sono considerati validi e continuano a esplicare la loro efficacia. Il loro annullamento causerebbe un turbamento dello stato di fatto o di diritto già instauratosi: si pensi al caos che deriverebbe dall'annullamento dei voti espressi dai parlamentari, decaduti in sede di verifica delle elezioni. **L'usurpatore di pubbliche funzioni** è, invece, chi, commettendo un reato (art.347 c.p.) svolga una pubblica funzione o le attività inerenti ad un pubblico impiego senza essere investito in alcun modo; i suoi atti sono nulli. Le persone fisiche titolari di un organo di un ente pubblico sono dette **funzionari.** Possono essere o meno collegate all'ente da un rapporto di pubblico impiego: in caso affermativo, oltre che funzionari saranno anche pubblici impiegati; in caso manchi un collegamento stabile con l'ente, si tratta di *funzionari onorari.* Inoltre, si hanno pubblici impiegati *non titolari di organi* che non manifestano la volontà dell'ente, ma svolgono un'attività tecnica (es. docenti) o materiale (conduttore di un elettrotreno). La distinzione è tenuta presente dall'art. 28 Cost., a norma del quale funzionari e dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Gli organi possono così classificarsi: IN BASE ALLA STRUTTURA-**organi individuali,** costituiti da una sola persona (PDR) e **collegiali,** costituiti da una pluralità di persone, che agiscono come un'unità (Giunta comunale, Senato); **organi semplici,** che costituiscono un'unità indivisibile e **organi complessi (o organi di organi)** che sono composti da più organi (come ad es. il Governo, formato dal Presidente del Consiglio, dai vari ministri e dal Consiglio dei ministri; il Parlamento formato da Camera e Senato).IN BASE ALLE ATTRIBUZIONI- **organi esterni,** che devono manifestare la volontà dell'ente o porlo in rapporti giuridici con altri soggetti, **organi interni,** che esauriscono la loro attività nella sfera giuridica dell'ente e non al di fuori; fra gli organi esterni, si distinguono quelli **primari,** che hanno per legge una propria competenza (come ad es. il prefetto) e **secondari,** destinati a sostituire altri organi in caso di assenza o impedimento del titolare di questi (come il vice-prefetto); **organi centrali,** se la loro competenza si estende a tutto il territorio dello Stato (ministeri) o **locali,**se è territorialmente delimitata (intendenza di finanza); **organi attivi,** che formano o manifestano la volontà dell'ente o la portano ad esecuzione (Camere), **consultivi** che non esercitano funzioni di volontà, ma solo di apprezzamento tecnico mediante pareri

This document is available free of charge on StuDocu.com

(Consiglio di Stato); **di controllo,** che accertano la conformità degli atti degli organi attivi alle norme di legge (controllo di legittimità) o anche all'opportunità e alla convenienza amministrativa (controllo di merito), oppure accertano il raggiungimento degli obiettivi di legge, valutando costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa (controllo di gestione). IN BASE ALLA LORO FORMAZIONE: **organi rappresentativi o non rappresentativi,** secondo che siano o no in collegamento diretto con il popolo attraverso l'istituto della rappresentanza politica (organi rappresentativi per eccellenza sono le Camere) o siano comunque collegati con un gruppo sociale mediante l'elezione dei loro componenti. IN BASE ALLA LORO POSIZIONE GIURIDICA: **organi direttivi,** che esercitano funzioni di amministrazione attiva e non hanno nell'ordinamento superiori gerarchici (ad es. il ministro, il sindaco) ed **organi dipendenti,** che sono gerarchicamente subordinati ai primi (ad es. il direttore generale di un ministero rispetto al ministro); **organi costituzionali,** quegli organi dello Stato che, posti al vertice dell'organizzazione statale, si trovano in posizione di indipendenza e parità giuridica fra loro. Questo non esclude che possano esservi controlli da un organo costituzionale all'altro (come quello politico-ispettivo delle Camere sul Governo). Gli organi costituzionali sono *indefettibili poiché la loro presenza nell'ordinamento caratterizza la forma di Stato o di governo* ed il loro venir meno provocherebbe un mutamento dell'assetto costituzionale dei poteri. L'Italia, ad es., è uno Stato democratico e parlamentare perché il suo ordinamento prevede un Presidente della Repubblica elettivo, due Camere elettive ed un Governo legato al Parlamento da un rapporto fiduciario. Se tali organi venissero a mancare o fosse mutato il loro modo di formazione o i rapporti tra essi intercorrenti, la forma di stato o di governo muterebbero anch'esse. Nel nostro ordinamento, sono organi costituzionali il PDR, le Camere, il Governo e la Corte cost. Vi sono, inoltre, degli organi (che non possono definirsi costituzionali perché non valgono a caratterizzare la forma di stato e di governo) che, per le funzioni esercitate e la posizione di indipendenza dei loro componenti, assumono **rilevanza costituzionale.** Siffatta qualifica viene attribuita nel nostro ordinamento a: Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti e, secondo la tesi prevalente, al CSM. Le funzioni svolte dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, vanno assumendo maggior valore perché atte a garantire il corretto funzionamento delle PA. Non tutti gli organi elencati nella Cost. possono definirsi costituzionali (ad es. non sono o. costituzionali il Consiglio di Stato, il Consiglio Supremo di difesa, la Corte dei Conti, la Cassazione, ecc).

20. Gli atti giuridici e la loro classificazione- nell'ambito della distinzione tra *fatti naturali e fatti umani,* fra i fatti umani si individua un'ulteriore distinzione tra *meri fatti ed atti in senso proprio.* Questi ultimi si caratterizzano per la presenza dell'elemento della volontà, della partecipazione cosciente di chi li pone in essere o al loro compimento (volizione dell'atto) o alla determinazione dell'effetto (volizione dell'effetto). Lo Stato e gli enti pubblici svolgono le loro funzioni prevalentemente mediante atti di diritto pubblico, che per gli atti dello Stato assumono una forma tipica (legge, decreto, sentenza). Oltre che in tali forme, l'attività dei pubblici poteri

si esplica mediante atti preparatori all'emanazione dell'atto definitivo. Quindi, la funzione è l'attività complessiva diretta alla produzione degli atti dello Stato, l'attività è costituita da una serie di atti omogenei posti in essere nell'esercizio di una funzione. Nel diritto amministrativo si sono distinti gli atti in provvedimenti amministrativi (l'atto mediante il quale l'autorità amministrativa dispone in ordine all'interesse pubblico attribuitole, incidendo in situazioni soggettive del privato, come espropriazioni, concessioni, autorizzazioni) ed atti amministrativi strumentali (atti al servizio del provvedimento, come certificazioni, pareri, ecc). Ricollegandosi alla classificazione degli organi, gli atti dei pubblici poteri possono così classificarsi: **atti semplici (individuali e collegiali); atti composti (reiterati e complessi); atti collettivi.** Sono semplici quegli atti posti in essere o da un solo soggetto o da un solo organo, qualora questo sia individuale o collegiali (da qui la loro distinzione in individuali e collegiali). Gli atti composti si distinguono in reiterati e complessi. Sono atti reiterati o continuati quelli per la cui formazione si richiede più di una manifestazione di volontà da parte dello stesso organo (ad es. la legge costituzionale, che richiede una doppia approvazione da ambedue le Camere). Sono complessi gli atti risultanti dalla fusione della volontà di più organi, che può essere espressa mediante un atto individuale o collegiale. Si pensi alla legge formale, atto formato dalla fusione delle volontà espresse con due distinte deliberazioni dei due rami del Parlamento. La complessità dell'atto può essere eguale o diseguale, a seconda che le volontà che lo formano abbiano o meno lo stesso valore giuridico (ad es. la legge formale è atto a complessità eguale, perché le due deliberazioni delle Camere sono giuridicamente poste sullo stesso piano; i decreti del PDR sono, di regola, atti a complessità diseguale perché in essi è giuridicamente prevalente la volontà del Capo dello Stato o del ministro o del Presidente del Consiglio controfirmanti). Dagli atti complessi, bisogna distinguere quelli collettivi, che risultano anch'essi dalla fusione di più volontà. Mentre nell'atto complesso le volontà si fondono (con la conseguenza che il vizio di una di esse inficia l'atto), nell'atto collettivo restano distinte, essendo unica solo la manifestazione (il vizio di una non inficia l'atto). Esempi di atto collettivo sono le circolari interministeriali. La maggior parte degli atti giuridici vengono a formazione in seguito ad un procedimento, che indica il modo della formazione di un atto quando questa risulti preceduta da una serie (procedimentale appunto) di atti ed attività funzionalmente collegati, con rilevanza esterna. I procedimenti constano di tre fasi: quella dell'iniziativa, quella costitutiva, quella integrativa dell'efficacia. Si pensi al procedimento elettorale, a quello di formazione della legge, ai processi, ecc. *La formazione della volontà degli organi collegiali è complessa. I modi di computare la maggioranza: normalmente la volontà del collegio è espressa dalla maggioranza, secondo il principio maggioritario che si contrappone a quello dell'unanimità. Maggioranza semplice o relativa = metà + 1 dei presenti.*

21. Atti giuridici: a) perfezione, validità, efficacia; b)vizi- l'atto giuridico si dice perfetto quando è completo di tutti i suoi elementi intrinseci, strutturali e funzionali (la legge è perfetta quando è completo il suo iter formativo e sono presenti tutti i suoi elementi costitutivi). La perfezione attiene all'esistenza dell'atto. La mancanza di un

This document is available free of charge on StuDocu.com

requisito essenziale dell'atto ne provoca l'inesistenza (nullità): si pensi all'atto posto in essere da un usurpatore di pubbliche funzioni. Un atto giuridico si dice valido quando i suoi elementi costitutivi oltre che presenti, sono regolari, non viziati. I **vizi degli atti** (limitatamente agli atti di diritto pubblico)possono essere di due tipi: di *legittimità* (nel dir. privato illegalità ed illiceità) e di *merito*. I vizi di *legittimità* si hanno quando l'atto non è conforme al suo modello legale e sono : ***incompetenza,*** quando l'atto è posto in essere da un soggetto diverso da quello previsto nel modello legale, ad es. il prefetto che emana un atto che secondo la legge dovrebbe emanare il ministro dell'interno; l'incompetenza può essere di due gradi, assoluta quando il soggetto appartiene a un grado diverso dell'amministrazione, come il provveditore agli studi che espropria un terreno per costruire una scuola, e relativa quando il soggetto agente appartiene allo stesso ramo di amministrazione (intendente di finanza che emana un atto di competenza del ministro delle finanze), il vizio di incompetenza si ha anche quando l'atto è emanato da un organo di un ente diverso da quello legittimato (la Regione che legifera su una materia riservata allo Stato)*;* ***eccesso di potere****,* attiene alla funzione tipica dell'atto e si ha quando l'atto è posto per perseguire un fine differente da quello previsto o comunque inidoneo a perseguirlo e si articola in contraddittorietà di provvedimenti (si contraddice un provvedimento già emanato), manifesta illogicità o ingiustizia, disparità di trattamento(situazioni analoghe sono trattate in maniera diversa e viceversa), sviamento di potere (si persegue un interesse privato anziché pubblico), errore o travisamento dei fatti (il provvedimento è motivato sulla base di un travisamento dei fatti) ***violazione di legge,*** si ha quando l'atto è contrario alla legge sia nell'aspetto formale (come l'irregolare composizione dell'organo agente, il mancato rispetto del procedimento di formazione, *vizio in procedendo*) sia nel contenuto (ad es. una legge che contenga una norma contraria alla Cost*.) e, più in generale, quando il vizio non attenga né all'incompetenza né all'eccesso di potere.* I **vizi di merito** attengono all'opportunità e convenienza dell'atto e si hanno quando questo, ancorché legittimo,appare non congruo, non conveniente, non opportuno, non idoneo a perseguire il pubblico interesse. Il controllo sui vizi di merito può gravemente limitare l'autonomia di alcuni soggetti. L'atto è **efficace** quando può spiegare i suoi effetti. Un atto può essere perfetto ed efficace anche se invalido; esso spiegherà la sua efficacia finché non sarà annullato (una legge costituzionalmente illegittima dovrà essere osservata finché la Corte cost. non ne dichiari l'illegittimità). Un atto può essere perfetto, valido ma non ancora efficace, ad esempio quando è sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale o perché, nel caso di una legge, non è ancora trascorso il periodo di *vacatio.*

Sezione III – LA COSTITUZIONE DELLO STATO

22. Concetto e tipi di costituzione - Prendendo in considerazione un qualsiasi gruppo sociale,possiamo facilmente isolare un complesso di norme,scritte o anche non scritte,ed una struttura sociale che valgono a tracciare le linee maestre dell'organizzazione del gruppo. In queste norme e in questa struttura trovano espressione i valori e le esigenze del gruppo,il fine (o i fini) che il gruppo si propone

di raggiungere e l'apparato autoritario che esso si è dato per il conseguimento del fine stesso e per garantire l'osservanza delle regole sociali. Rispetto a queste norme e a questa struttura,la restante organizzazione appare come complementare anche se necessaria ad un loro più completo svolgimento. In questo senso,secondo Crisafulli,"qualsiasi ente o gruppo sociale,in quanto esiste secondo un suo ordine,ha e non può non avere,una costituzione". Anche lo Stato pertanto,in quanto gruppo sociale organizzato,ha e non può non avere una costituzione. Bisogna tener presente che la "costituzione" di uno Stato è il frutto dell'ideologia dominante in un dato momento storico. Non esiste un concetto ideale di costituzione, ma un concetto che, di volta in volta, deve essere determinato storicamente. Premesso questo,va però detto che è possibile individuare in determinate epoche storiche un concetto di costituzione che sia valido per più Stati,fra loro accumunati dalla medesima ideologia:così ad esempio possiamo parlare di un gruppo di costituzioni ispirate all'ideologia liberaldemocratica(quelle dei Paesi dell'Occidente) e (ormai in misura molto ridotta) di un gruppo di costituzioni ispirate all'ideologia marxista-leninista(quelle dei residui Paesi socialisti). La traduzione in termini normativi della costituzione quindi,intesa come assetto fondamentale,è necessaria per assicurare la stabilità e la certezza dei valori,dei fini istituzionali e della struttura organizzativa dello Stato:la traduzione in norme dell'assetto fondamentale ha in altri termini una funzione garantista, riconoscendo,in particolare,l'esercizio delle libertà democratiche. Essa avviene di regola in forma scritta,riunendo e coordinando in un unico testo le norme in esame,ma può anche avvenire in forma consuetudinaria,seppure in quest'ultimo caso esiste sempre e comunque un corpo di norme scritte in funzione anch'esse garantiste(ad esempio la costituzione della Gran Bretagna,fondata in massima parte su regole consuetudinarie ma anche su norme scritte,quali quelle contenute nei Parliament Acts del 1911 e del 1949 e nello Human Rights Act del 1988).Quindi, la Costituzione di uno stato,intesa come complesso di regole che esprimono in un sistema unitario ed armonico i principi e gli istituti fondamentali dell'assetto di uno Stato,può essere **scritta o non scritta(consuetudinaria**). Si ha una costituzione **scritta** quando tali principi ed istituti vengono consacrati in un documento(definito appunto Costituzione,o Statuto,o Carta fondamentale) di guisa che possano essere facilmente individuabili e differenziarsi dalle altre regole giuridiche. Si ha, invece, una costituzione **consuetudinaria** quando non esiste un documento organico in cui vengono racchiuse norme materialmente costituzionali, cosicchè l'assetto costituzionale dello Stato viene ordinandosi in buona misura attraverso norme consuetudinarie e di costume,espresse spontaneamente dalla collettività nel corso del tempo, e viene garantito da un esteso e duraturo consenso popolare. Esempio emblematico la Gran Bretagna. Le costituzioni si distinguono anche in **rigide e flessibili,** a seconda che per modificare o abrogare le disposizioni in esse contenute sia necessario ricorrere o ad un procedimento diverso(aggravato) rispetto a quello proprio delle leggi ordinarie oppure sia sufficiente il procedimento ordinario di formazione delle leggi. Una costituzione si dice perciò flessibile se modificabile con un processo analogo a quello previsto per la formazione delle leggi ordinarie(come nel caso dello Statuto albertino,che sebbene si fosse

This document is available free of charge on StuDocu.com

proclamato"immodificabile e perfetto",nella realtà pratica era modificabile da una qualsiasi legge ordinaria). Una costituzione si dice invece rigida se modificabile con un procedimento di revisione aggravato(che per la Costituzione italiana viene disciplinato e regolato dall'art.138,Titolo VI,parte II Cost.).Pertanto,le costituzioni rigide assumono,nella gerarchia delle fonti,un grado superiore a quello delle leggi ordinarie,derivante dalla loro particolare forza formale;mentre le costituzioni flessibili sono di pari grado delle leggi formali(hanno quindi stessa forza passiva della legge ordinaria).Ne consegue che le leggi ordinarie(e gli atti ad essa equiparati)che siano in contrasto con una norma contenuta in una costituzione rigida sono costituzionalmente illegittime e, come tali, dovranno essere sottoposte ad un controllo di costituzionalità(da parte della Corte costituzionale)diretto a dichiararne l'invalidità. Al contrario,qualora una legge(o un atto avente pari efficacia) sia in contrasto con una norma contenuta in una costituzione flessibile,a cedere sarà quest'ultima,trattandosi di una comune successione di norme aventi la stessa forza formale. Le costituzioni non scritte sono di regola,per loro stessa natura,flessibili. Anche una costituzione scritta può però essere flessibile,come il caso dello Statuto albertino,se non contiene alcuna norma che aggravi il procedimento per la sua revisione. L'attuale costituzione repubblicana italiana invece è rigida per la presenza in essa dell'art.138 che disciplina,aggravandolo rispetto a quello ordinario,il procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Le costituzioni si distinguono ancora in **corte e lunghe,** a seconda che si limitino a disciplinare la materia strettamente costituzionale(l'organizzazione dello Stato,i rapporti fra poteri,i diritti e i doveri dei cittadini)o anche materie diverse. Una costituzione breve si limita pertanto a disciplinare la forma di governo(i rapporti fra poteri) e le norme sulla formazione(ossia le norme che riguardano il processo di formazione delle leggi),che rappresenta il contenuto costituzionale minimo. Una costituzione di tal tipo tralascia quindi di occuparsi dei diversi ambiti della vita associata,disciplinando unicamente lo stato apparato. Una costituzione lunga invece pone anche una disciplina di principio della vita associata. Come esempi di costituzioni corte possiamo tener presente la Costituzione federale degli Stati Uniti e lo Statuto albertino del '48(che conteneva solo 84 articoli). Le costituzioni scritte si dicono anche **formali o in senso formale.**
Le costituzioni si distinguono anche in costituzioni **bilancio** e costituzioni-**programma**,a seconda che siano rivolte al presente e abbiano come loro fine quello di dare forma giuridica ad una realtà sociale già esistente(costituzioni bilancio),oppure(come nel caso della Costituzione italiana)si propongano anche di promuovere la trasformazione di tale realtà,indicando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti idonei a tale scopo(c-programma).
Le costituzioni si distinguono in **ottriate**(concesse) e **votate**(o di emanazione popolare):si hanno le prime in regime monarchico,allorquando il sovrano,prima assoluto,concede una costituzione scritta ai suoi sudditi(molto spesso costrettovi dalla pressione popolare,come è accaduto in Italia nel 1848 con la concessione dello Statuto al Regno di Sardegna da parte di re Carlo Alberto).Si hanno invece le seconde quando la costituzione è espressione della volontà popolare e viene redatta e

approvata dai rappresentanti del popolo,riuniti in Assemblea costituente(attuale Costituzione italiana).

23. La Costituzione italiana e le sue origini **-**La Costituzione repubblicana italiana del '47 è: **scritta**, perché i principi e gli istituti fondamentali dell'organizzazione statale sono consacrati in un documento(il testo costituzionale)e perché è espressamente prevista(art.138)la forma scritta per le leggi che regolano la materia costituzionale; **rigida**, perché alle norme in essa contenute è stata assegnata un'efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie,di modo che le leggi che modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento di formazione delle leggi ordinarie ma con una procedura aggravata(art.138); **votata**, perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti dall'Assemblea costituente; **convenzionale**, perché le forze politiche che l'hanno redatta ed approvata erano fra loro in contrasto(basti pensare alle profonde divisioni ideologiche fra le forze politiche cattoliche,comuniste e liberali,tutte rappresentate nell'assemblea),per cui è stato necessario,al fine di dare un nuovo assetto costituzionale allo Stato,che queste stesse forze procedessero a delle reciproche concessioni. Una costituzione si dice invece *ordinativa* quando promana da un'unica forza politica che detiene il potere o perché è storicamente sola in quel dato periodo o perché ha sopraffatto le altre forze,eliminandole(come spiega Giannini). La nostra Costituzione rappresenta la conclusione di un travagliato periodo della nostra storia recente,che affonda le sue radici nella crisi dello Stato liberale-ottocentesco,crisi che trova la punta massima della sua espressione all'indomani della fine della prima guerra mondiale. Possiamo fissare convenzionalmente l'inizio di questo periodo nella notte fra il 24 e il 25 luglio 1943,allorquando il Gran Consiglio de fascismo votò una mozione di sfiducia nei confronti dell'allora Capo del Governo,Benito Mussolini. Il re revocò Mussolini e nominò al suo posto il maresciallo Badoglio, che presiedette un governo tecnico. Venne soppresso il partito fascista (1943). Con l'emanazione del decreto-legge luogotenenziale del 25 giugno 1944,lo Stato italiano si dette "un ordinamento provvisorio caratterizzato dalla funzione di preparare la formazione di un rinnovato e stabile assetto costituzionale,in radicale opposizione al precendente"(Mortati). All'art.1 di questo decreto,venne infatti stabilito che dopo la liberazione del territorio nazionale,le forme istituzionali sarebbero state scelte dal popolo italiano,che a tal fine avrebbe eletto,a suffragio universale diretto e segreto,un'Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato. Con un altro decreto,emanato in un secondo momento,la decisione sulla forma istituzionale dello Stato(repubblica o monarchia)fu sottratta all'Assemblea costituente e attribuita invece al popolo,che avrebbe espresso la sua volontà mediante un referendum. Il referendum istituzionale si svolse il 2 giugno del 1946,contemporaneamente alle elezioni dei deputati all'Assemblea costituente,che si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e nella seduta del 28 giugno elesse Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato. Successivamente,l'Assemblea decise la nomina di una commissione di 75 membri(designati con il criterio della proporzionalità politica)incaricata di elaborare e proporre il progetto della

This document is available free of charge on StuDocu.com

Costituzione. La Commissione(che per assicurare una maggiore speditezza nei lavori fu suddivisa in tre sottocommissioni)presentò il progetto il 31 gennaio 1947 all'Assemblea costituente,insieme ad una relazione redatta dal Presidente di commissione, Meuccio Ruini.La discussione sul progetto si protrae fino al 22 dicembre del '47,con la votazione finale dell'intera Costituzione a scrutinio segreto. La nuova Costituzione fu promulgata da Enrico De Nicola il 27 dicembre del '47 ed è entrata formalmente in vigore a partire dal 1° gennaio 1948. Anche dopo l'approvazione della Costituzione,l'Assemblea continuò a funzionare fino al 31 gennaio '48 per deliberare la legge per l'elezione del Senato della Repubblica,gli statuti delle Regioni ed una legge contenente "disposizioni sulla stampa".

24. Caratteristiche dello Stato italiano secondo la Costituzione: *repubblicano, democratico, fondato sul lavoro, interventista, parlamentare, decentrato, non confessionale, aperto alla comunità internazionale.*

25. Lo stato repubblicano- La Cost. all'art. 1 comma I definisce l'Italia una Repubblica, qualificandola come democratica e fondata sul lavoro; individuando, quindi, un "tipo" specifico di Repubblica. L'art. 139 cd "norma di chiusura" stabilisce che "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". La repubblica come forma di governo si contrappone alla monarchia. Fra le differenze, il carattere rappresentativo del Capo dello Stato, derivante gli dal continuo collegamento con la comunità sociale (espressamente previsto nella Cost. all'art. 87).

26. Lo Stato democratico – Nel suo significato etimologico, democrazia significa "governo di popolo". In ogni società, è dato distinguere governanti e governati. Secondo l'ideale democratico, tale distinzione dovrebbe essere abolita, nel senso di rendere possibile un pieno ed assoluto autogoverno, giungendo all'identificazione tra governanti e governati. Questa è un'utopia. Il concetto realistico di democrazia mantiene la distinzione tra governanti e governati, ponendoli, però, in continuo collegamento di modo che l'azione governativa si conformi alle istanze sociali. Inoltre, in alcuni ordinamenti, i governati hanno a disposizione strumenti per poter manifestare direttamente la loro volontà anche in contrasto con le decisioni politiche dei governanti (si pensi al referendum abrogativo di leggi). Si contrapponga lo stato autoritario a quello democratico. Nel primo i collegamenti tra governanti e governati sono troncati, nel convincimento che solo coloro che hanno assunto la direzione politica dello stato possano interpretare la volontà del popolo, al quale non si riconosce capacità politica alcuna. Di qui l'eliminazione dei procedimenti elettorali per la scelta dei governanti, dei controlli su di essi e di libertà politiche e civili. Nello stato democratico, invece, esistono istituti giuridici che mirano a immettere il popolo nel governo dello stato: *indirettamente,* attraverso i suoi rappresentanti designati dal corpo elettorale (**democrazia rappresentativa**); *direttamente,* attribuendo al corpo elettorale poteri di decisione o impulso dell'attività di governo (**democrazia diretta**); o anche in maniera *decentrata* consentendo che le società intermedie a carattere politico ed i singoli possano concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico

dello Stato e ad evidenziare gli interessi collettivi degni di tutela (democrazia **decentrata o pluralista**). Tutte e tre queste forme di partecipazione del popolo al governo dello Stato sono disciplinate e garantite dalla nostra Cost., innanzitutto all'art. 1 ("La sovranità appartiene al popolo"). Il collegamento tra governanti e governati vengono assicurati: -per quanto riguarda la democrazia *rappresentativa*, rendendo elettivi da parte di tutti i cittadini maggiorenni gli organi del potere legislativo (solo per l'elettorato attivo del Senato è richiesta l'età di 25 anni) e collegando il Governo ai rappresentanti del popolo tramite la *fiducia;* è assicurata la tutela delle minoranze e al PDR è attribuito il potere di sciogliere le Camere, qualora non siano in grado di garantire una stabile ed ordinata attività di governo; - per quanto riguarda la democrazia *diretta,* attraverso gli istituti del referendum abrogativo delle leggi e degli atti aventi forza di legge (art. 75), del referendum costituzionale, del referendum in materia di fusione di Regioni, Comuni ecc, con gli istituti dell'iniziativa popolare delle leggi e della petizione; - per quanto riguarda la democrazia *decentrata,* mediante l'attribuzione ai cittadini associati in partiti politici del potere di concorrere a determinare la politica nazionale e ai cittadini uniti nei sindacati del potere di auto tutelare gli interessi della categoria di appartenenza. Meritano attenzione le società cd *intermedie* fra Stato e cittadino: famiglia, associazioni culturali, politiche, insomma tutte le formazioni sociali dove l'uomo svolge la sua personalità. Da non sottovalutare, i fenomeni di associazionismo spontaneo, espressione di uno stato d'insoddisfazione (es. no global). L'inserzione nelle attività di governo delle esigenze popolari è resa possibile dall'esercizio di quei diritti inviolabili che la Repubblica riconosce all'art. 2. Fra questi, il diritto di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero. Il carattere democratico del nostro Stato è completato dalla formulazione del principio di eguaglianza, sia formale che sostanziale (art. 3).

27. Lo Stato fondato sul lavoro- La norma contenuta all'art. 1 "L'Italia è una Rep. democratica fondata sul lavoro" va letta in concordanza con quella espressa all'art.4, che enuncia il diritto- dovere al lavoro e ad esso attribuisce rilevanza costituzionale. Il lavoro è valore-base dell'ordinamento, valore informativo dell'ordinamento.

28. Lo Stato sociale – Lo Stato sociale configurato dalla nostra Cost.è uno Stato che, pur conservando gli istituti della proprietà privata e della libera iniziativa economica privata, ritiene necessario intervenire nelle attività economiche per coordinarle e indirizzarle verso il benessere comune. In particolare, gli artt. 41, 43 e 44 individuano un sistema di economia regolata. Fermo restando che l'uomo (art.2) è posto in piena evidenza nella Cost., quest'ultima prevede tre strumenti per realizzare il processo di sviluppo: **programmazione** (funzione di coordinamento e indirizzo dell'attività economica) **(art.41); espropriazione di imprese** e categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o situazioni di monopolio a preminente carattere generale e il loro trasferimento allo Stato, enti pubblici o comunità di lavoratori o utenti (**art.43**); **la riforma agraria (art. 44).** Sino a qualche tempo fa, lo Stato interveniva direttamente nell'economia con una miriade di enti

This document is available free of charge on StuDocu.com

pubblici economici, sistema modificato grazie alla trasformazione di alcuni di essi (come ENI, ENEL ecc) in S.P.A. e come tali sottoposte al dir. privato. la tendenza attuale è quella di una progressiva privatizzazione delle imprese pubbliche, in vista di una loro gestione efficiente ed economica contro quella, spesso, assistenzialistica e burocratica.

29. Lo Stato Parlamentare- La norma costituzionale che caratterizza la nostra forma di governo come parlamentare è contenuta nell'art. 94 comma I che dispone che "il Governo deve avere la fiducia delle due Camere". I commi successivi disciplinano le modalità per la concessione o la revoca della fiducia. Come conseguenza del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, l'art. 95 prevede la responsabilità politica davanti alle Camere del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri. La mancata attribuzione al PDR dei poteri di indirizzo politico fa sì che tali poteri vengano accentrati nel raccordo Parlamento-Governo. Il PDR, tuttavia, può condizionare in vario modo l'attività di indirizzo politico mediante l'esercizio dei suoi poteri di impulso, controllo che ne fanno un garante della legittimità costituzionale e come tale un organo imparziale. Il tipo di governo parlamentare delineato dalla Cost. è stabilizzato o *a tendenza equilibratrice*, che si ha quando nessuno degli organi di indirizzo ha assegnata la prevalenza, essendo in posizione di parità. Il Parlamento occupa una posizione centrale nel nostro sistema ed, essendo il nostro uno Stato decentrato, costituisce la massima sede rappresentativa in cui operare la sintesi delle istanze comunitarie e le scelte definitive.

30. Lo Stato decentrato- All'opposto dello Stato accentrato quale quello monarchico, la "Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" art 5 Cost. La Cost. prevede i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni (art.114). Alle Regioni è stato attribuito il potere di emanare norme legislative entro certi limiti. Ai Comuni è stata assegnata la competenza generale a svolgere le funzioni amministrative, salvo quelle conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato secondo i principi di differenziazione, sussidiarietà e adeguatezza (art.118 Cost).

31. Lo Stato non confessionale- Il carattere non confessionale dello Stato italiano discende da quelle norme cost. che riconoscono la più ampia libertà di religione e l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose ed escludono che la professione di una certa religione possa costituire un elemento discriminante tra i cittadini e che le istituzioni e associazioni a carattere religioso o di culto possano essere oggetto di un trattamento normativo differenziato. Per l'art. 8 Cost., infatti, *Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.* Per l'art. 19 *Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.* L'art. 3 dispone che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali dinanzi alla legge senza distinzione di religione e l'art. 20 che *Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni*

legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Lo Stato italiano è laico nel senso che riconosce l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge e la più ampia libertà di coscienza e culto.

32. Lo Stato aperto alla comunità internazionale- Il nostro Stato ha una vocazione internazionalistica, espressa in diverse norme costituzionali e più in particolare agli artt. 10 ed 11 : *L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*. È disciplinata la posizione dello straniero, oltre che il diritto di asilo. L'Italia ripudia la guerra e promuove le limitazioni alla sua sovranità, che garantiscano la pace e la giustizia tra le nazioni.

33. Le disposizioni costituzionali- Possono essere di tre tipi: *istitutive o organizzative, precettive, programmatiche.* Sono poste sullo stesso piano e sono tutte disposizioni costituzionali. Quelle istitutive danno le linee generali dell'ordinamento, istituiscono i vari organi costituzionali e a rilevanza costituzionale e ne stabiliscono l'organizzazione. Quelle precettive attribuiscono al cittadino un diritto nei confronti dello Stato o sempre verso lo Stato gli impongono un dovere. Quelle programmatiche individuano i fini che lo Stato deve perseguire per realizzare l'assetto sociale voluto dal Costituente.

34. La Costituzione vigente- Se si volesse tracciare un sommario bilancio dell'attuazione della Costituzione, i risultati potrebbero apparire sconfortanti. Infatti, è stata attuata, non per intero, la parte organizzativa ma non quella programmatica. L'affermarsi di prassi contra constitutionem, il permanere di leggi costituzionalmente illegittime, inadempienze varie hanno portato ad una costituzione vigente in netta antitesi, per certi versi, con quella scritta. Le divergenze tra le due non possono sempre risolversi a favore di quella effettivamente vigente. Se sono salve la natura repubblicana e la tendenza internazionalistica del nostro Stato, altri suoi caratteri appaiono perplessi: dubbi sorgono sull'attuazione dell'eguaglianza sostanziale di cui al comma II dell'art. 3; sul perseguimento dell'obiettivo del lavoro di cui all'art. 4 per l'esistenza di larghe sacche di disoccupazione e di squilibri Nord- Sud. Inoltre, resta da dimostrare la natura parlamentare, cioè che il potere risieda nel raccordo Parlamento-Governo e non in entità sociale, come partiti e gruppi di interesse. Il decentramento dello Stato si è attuato con la creazione delle Regioni di diritto comune ma non può dirsi lo stesso del decentramento burocratico. La piena attuazione del carattere non confessionale richiederebbe l'eliminazione di quella posizione di privilegio assegnata nell'ordinamento alla religione cattolica rispetto alle altre confessioni.

This document is available free of charge on StuDocu.com

PARTE II, L'ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO

Capitolo I – Il potere legislativo

1. Il bicameralismo- Il potere legislativo è attribuito in Italia al Parlamento che,a norma dell'art.55 Cost.,si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; cosicchè il Parlamento è nel nostro ordinamento un organo complesso,perché formato da due organi collegiali. La Cost. ha adottato il sistema bicamerale,con due camere elettive,che hanno fra l'altro gli stessi poteri e svolgono identiche funzioni,realizzando così una forma di bicameralismo cosiddetto **perfetto**. (Diversi Stati,fra cui la Gran Bretagna e,in misura minore,la Francia e la Spagna,hanno invece adottato forme di bicameralismo cosiddetto imperfetto o limitato: si hanno queste forme quando le due Camere non sono in posizione di parità funzionale e in particolare la volontà legislativa di una delle due prevale su quella dell'altra,di modo che a quest'ultima restano riservate funzioni di semplice controllo sospensivo). A favore del bicameralismo perfetto militano diverse ragioni,prima fra tutte la considerazione che le leggi,dovendo essere sottoposte all'approvazione di due assemblee distinte,risultato elaborate con una maggiore accuratezza e riflessione. L'identità di funzioni delle due Camere può però ritardare oltre misura lo svolgimento della loto attività(in particolare legislativa),così come sostenuto da una parte della dottrina,per cui sotto quest'aspetto sarebbe forse preferibile una forma di bicameralismo imperfetto,ma la scelta resta opinabile.

2. Il Parlamento in seduta comune- Dal Parlamento come organo complesso va distinto il Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere,che è un organo collegiale, i cui componenti sono appunto i deputati e i senatori(integrati in alcuni casi dai delegati delle Regioni,e specificamente al momento delle elezioni del Presidente della Repubblica). Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei casi: di elezione e giuramento del Presidente della Repubblica; di messa in stato di accusa del Presidente;di elezione di 1/3 dei componenti del Consiglio superiore della magistratura(CSM);di elezione di 5 dei 15 giudici costituzionali; di compilazione,ogni nove anni,di un elenco di persone fra le quali sono sorteggiati,in caso di necessità,i 16 giudici aggregati alla Corte costituzionale per i giudizi in materia penale. A norma dell'art.63 Cost.,il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. Nelle riunioni in seduta comune, viene applicato il regolamento della Camera dei deputati ma l'art.65 del regolamento del Senato specifica che è sempre fatta salva la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse in proposito. Il Parlamento in seduta comune potrebbe pertanto darsi un proprio autonomo regolamento: il silenzio della Costituzione a tal proposito quindi non preclude la possibilità di un'autonoma potestà regolamentare del Parlamento riunito in seduta comune sia attraverso la formulazione di un organico complesso di norme e sia di volta in volta,per l'esercizio di funzioni particolari alle quali non potrebbero adattarsi le regole presenti nei regolamenti delle due Camere.

Sezione I, LA FORMAZIONE DELLE CAMERE

3. Elezioni ed ordinamento democratico- Un concetto realistico di democrazia richiede che,posta la distinzione fra governanti e governati,i primi vengano posti in continuo collegamento con i secondi,di modo che l'azione governativa risulti conforme alle effettive esigenze della comunità. In una società democratica, quindi, i governanti devono essere necessariamente indicati dai governati ed il governo dovrà essere di estrazione popolare. Proprio per questo motivo, nella nostra Costituzione,in ossequio al principio democratico che regge e sottende il nostro Stato,si è dato posto al sistema selettivo dei governanti mediante elezione,in particolare per la formazione degli organi costituzionali (o di rilevanza costituzionale,come il CNEL)dello Stato-apparato. Nell'ordinamento italiano,soltanto i componenti della Camera dei deputati e del Senato(nella sua massima parte)sono direttamente designati dal corpo elettorale tra gli organi che esercitano funzioni di governo: si è in tal modo attuata una delle regole dei sistemi democratici moderni,fondati sui meccanismi elettivi. Nei moderni Stati di partiti,la scelta degli elettori viene influenzata però non soltanto dalle persone dei candidati,ma anche dal loro orientamento politico o,più precisamente,dall'orientamento politico del partito al quale esse sono iscritte; ne consegue che il voto di ogni elettore adempie ad una duplice funzione: di designazione dei candidato e di approvazione del programma politico del partito di cui questi fa parte. Le uniche eccezioni al modo di designazione mediante elezioni sono previste dalla Costituzione per i componenti del Senato,alcuni dei quali vengono nominati dal Presidente della Repubblica (i cosiddetti "senatori a vita") o designati dalla stessa norma costituzionale (come nel caso degli ex Presidenti della Repubblica,che una volta esauriti il mandato diventano di diritto senatori a vita,salvo eventuale rinuncia). A norma dell'art.59 II comma infatti,il Presidente può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale,scientifico,artistico e letterario. Una prima questione che si pone al riguardo è se ciascun Presidente possa nominare cinque senatori a vita oppure fino a cinque senatori,di modo che il numero complessivo dei senatori non possa mai essere superiore a questa cifra. La dottrina prevalente è a favore della seconda ipotesi,adottata anche dai vari Presidenti nel corso di trentasei anni,ma ci sono state nel tempo delle eccezioni,per es.la nomina da parte del presidente Pertini,nell'84,di altri due senatori a vita oltre il numero di 5,con il consenso preventivo del Presidente del Senato e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Allo stesso modo,il Presidente Cossiga ha nominato altri cinque senatori a vita;mentre i presidenti Scalfaro,Ciampi e Napolitano si sono attenuti all'interpretazione restrittiva. Quanto poi ai requisiti della nomina,il Presidente gode di un ampio margine di discrezionalità in proposito,fermo restando che nella scelta non deve essere guidato da criteri politici o di parte. E', inoltre, ovviamente richiesto il requisito della cittadinanza italiana(cui si accompagna quello del godimento dei diritti civili e politici ad essa connessi,fondamentali per l'accesso a tutti gli uffici pubblici),mentre il requisito del raggiungimento del 40esimo anno di età molto spesso viene derogato per la prevalenza del criterio degli altissimi meriti in campo

This document is available free of charge on StuDocu.com

sociale,scientifico,artistico e letterario.Per quel che riguarda i sistemi elettorali per la formazione delle due Camere,di essi non vi è menzione nella Costituzione,in quanto l'Assemblea costituente non volle deliberatamente prendere posizione al riguardo;implicitamente si ricava tuttavia che è esclusa qualsiasi forma di rappresentanza della sola maggioranza e che al contrario deve essere adottato un sistema elettorale che garantisca la rappresentanza delle minoranze.

4. La rappresentanza politica- L'elezione,come modo democratico di selezione dei governanti,conferisce a questi la qualità di rappresentanti: la stessa Costituzione dispone del resto che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione(art.67). Affermare che gli organi elettivi rappresentino per ciò solo la volontà popolare tuttavia appare mistificante:alle volte,essi non rappresentano coloro dai quali sono stati eletti(come nel caso del Presidente della Repubblica,che rappresenta unicamente l'unità nazionale,e non i parlamentari dai quali è stato eletto). Si è perciò ancora oggi alla ricerca di un sistema elettorale "perfetto",che consenta cioè una rappresentanza senza residui alcuni.

5. Elettorato attivo ed elettorato passivo- Le Camere sono elette dai cittadini che godono del diritto di elettorato attivo; in particolare,sono elettori della Camera dei deputati i cittadini maggiorenni,mentre possono partecipare alle elezioni per il Senato i cittadini che abbiano superato i venticinque anni d'età. Sono invece eleggibili(cosiddetto "elettorato passivo")alla Camera tutti i cittadini maggiorenni,al Senato gli elettori che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. La legge costituzionale del 2000, n.1, ha previsto l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero,con l'istituzione della circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere; con la legge cost. del 2001 n.1 sono stati invece attribuiti 12 deputati alla circoscrizione Estero e 6 senatori alla corrispondente circoscrizione del Senato. A queste due disposizioni costituzionali è stata data attuazione con la legge del 27 dicembre 2001 n.459,recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. L'art.48 II comma Cost. dispone che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Non hanno quindi diritto al voto: a) coloro che,ritenuti persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità,siano stati sottoposti a misure di prevenzione; b) i sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province; c) i condannati a pena che comporta l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici(se temporanea,per tutto il tempo della sua durata).

6. I sistemi elettorali- Per sistema elettorale si intende ogni complesso di norme che regola e determina la ripartizione dei seggi per la rappresentanza di un determinato corpo elettorale. La distinzione fondamentale di questi sistemi è basata sul carattere "maggioritario" o "non maggioritario" che essi possono presentare: qualifiche con le quali si vuole designare il criterio assunto,rivolto o ad accertare soltanto quale sia la volontà espressa dalla maggioranza dei votanti,oppure a tenere conto anche della

volontà degli altri votanti rimasti in minoranza. Con i sistemi **maggioritari** si assegnano ai candidati che abbiano ottenuto la maggioranza (relativa,assoluta o qualificata) i seggi attribuiti al collegio. Questo sistema presenta innegabili vantaggi,soprattutto evita l'eccessivo frazionamento del sistema partitico;al tempo stesso però la sua adozione può dare luogo ad alcuni inconvenienti,favorendo la polarizzazione fra i due partiti maggiori e sottorappresentando i partiti minori. Il sistema **proporzionale,** invece, si propone di assicurare alle diverse parti politiche un numero di seggi in proporzione ai voti ottenuti; di modo che il Parlamento eletto con questo sistema finisce col rispecchiare più fedelmente la volontà degli elettori di quanto non avvenga nei paesi che scelgono di adottare il sistema maggioritario. Tuttavia,qualora il corpo elettorale sia politicamente poco omogeneo,i sistemi proporzionali favoriscono il suo frazionamento fra diversi partiti,con la conseguenza che si potrebbe rendere difficile la formazione di una stabile maggioranza di governo(così come è avvenuto durante la prima repubblica).
In sintesi, si può dire che tendenzialmente i sistemi maggioritari,sollecitando gli elettori a dividersi in due schieramenti partitici contrapposti che si alternano alla guida del governo,in modo da dar luogo al cosiddetto "*bipartismo*" o "*bipolarismo*",privilegiano la stabilità politica rispetto alla rappresentatività,al contrario di quanto accade invece nei sistemi proporzionali. Ovviamente non è possibile determinare con certezza quale dei due sistemi sia preferibile in assoluto e, anzi, la scelta risulta assolutamente relativa ed opinabile a seconda delle necessità politiche contingenti. Inoltre il rendimento di un sistema elettorale dipende in buona parte anche da fattori ad esso esterni,quali l'influenza che possono esercitare sugli elettori i grandi mezzi di comunicazione di massa(stampa,televisione),le regole della propaganda,la maturità politica degli elettori, ecc.ecc.

7. I caratteri del voto- Secondo la dizione dell'art.**48** II comma,il voto è: **personale**, in quanto deve essere esercitato personalmente,a meno che non si tratti di elettori fisicamente impediti,come nel caso di persone non vedenti,affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità,che solitamente esercitano il diritto elettorale con l'ausilio di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. Non è ammesso il voto "per procura"; **eguale**, nel senso che ciascun voto,quale che sia la persona dell'elettore,ha lo stesso valore di tutti gli altri voti. Non sono pertanto ammessi il *voto plurimo*,che si ha quando al voto dell'elettore che si trova in determinate condizioni personali o sociali(capi-famiglia,proprietari di immobili,laureati,professionisti ecc.)viene attribuito un valore superiore alla semplice unità,e il *voto multiplo*, che si ha quando invece un elettore è ammesso a votare in più collegi; **libero**, nel senso che non solo le leggi elettorali ma l'intero ordinamento devono impedire che l'elettore subisca qualsivoglia forma di pressione o di coazione a favore di un partito o di un candidato. (Appare tuttavia evidente che la legge può garantire la libertà del voto nelle sue condizioni esterne,ma non può di fatto impedire che la volontà dell'elettore venga condizionata da altri fattori); **segreto**, proprio al fine di assicurarne la libertà. La segretezza del voto viene assicurata dalla

This document is available free of charge on StuDocu.com

predisposizione di schede elettorali uguali per tutti gli elettori e quindi,di fatto,irriconoscibili le une dalle altre,e delle cabine elettorali in cui l'elettore deve appunto isolarsi per esprimere il voto. L'esercizio del voto, infine, è,sempre a norma dell'art.48 II comma,un **dovere civico** :non è, quindi, giuridicamente obbligatorio,tant'è che manca in Costituzione la previsione di sanzioni concrete in caso di inadempimento. (La partecipazione alle elezioni raggiungeva fino a pochi anni fa in Italia percentuali maggiori;in questi ultimi anni invece è venuto progressivamente in evidenza il fenomeno dell'*astensionismo*).

8. Il procedimento elettorale e l'assegnazione dei seggi- Le elezioni del Senato e della Camera sono disciplinate rispettivamente dal D.Lgs del 93 n.233 e dal D.P.R. 1957 n.361,come modificati dalla legge del 21 dicembre 2005 n.270. Con questa legge elettorale è stato reintrodotto in Italia il sistema proporzionale,abbandonato dieci anni prima in favore del sistema maggioritario. La nuova forma prevede tuttavia una correzione del proporzionalismo mediante "**premi di maggioranza**" da assegnarsi con metodi diversi per la Camera e per il Senato. Il nuovo sistema elettorale vigente è, inoltre, a "**liste bloccate**",nel senso che l'elettore può votare solo per le liste dei candidati senza poter esprimere alcuna preferenza (come invece avviene per le elezioni europee,regionali,sia pure con l'eccezione della regione Toscana,provinciali e comunali). L'elezione dei parlamentari, quindi, è rimessa totalmente alle scelte e all'ordine di presentazione nella lista, stabiliti dai partiti. Nei confronti di alcune disposizioni delle leggi elettorali di Camera e Senato sono stati indetti tre referendum abrogativi: i primi due miravano a modificare le disposizioni attribuendo il premio di maggioranza alla lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti anziché alla coalizione vincente; con il terzo quesito invece si chiedeva di eliminare la possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura più di una circoscrizione. Tali referendum,inizialmente fissati per il 18 maggio 2008,sono stati poi rinviati a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere del 6 febbraio 2008 al 21 giugno 2009: in tutti e tre i referendum tuttavia non si è raggiunto il quorum strutturale necessario a rendere valida la consultazione. Il procedimento elettorale per le due Camere si apre con il decreto del Presidente della Repubblica,che indice le elezioni su deliberazione del Consiglio dei ministri. A norma dell'art.61 Cost., le elezioni devono avere luogo entro settanta giorni dalla fine della legislatura. La seconda fase del procedimento riguarda la formazione e la presentazione delle liste dei candidati;queste ultime sono presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati, che devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito. I partiti possono poi effettuare il collegamento in una coalizione di liste da essi rispettivamente presentate. Contestualmente al deposito del contrassegno,i partiti o gruppi politici devono depositare il programma elettorale nel quale dichiarano nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica o,nel caso di collegamento fra più liste,come unico capo della coalizione. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi della

Camera dei deputati con metodo proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti(da 1000 fino a 1500 elettori per il Senato nelle Regioni); da almeno 2500 fino a 3000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti fino a 1.000.000 (da 1.750 fino a 2.500 per il Senato nelle Regioni); da almeno 4.000 e da non più di 4500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (da 3.500 fino a 5.000 per il Senato nelle Regioni). In caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni questi numeri di sottoscrizione vengono ridotti della metà. Nessuna sottoscrizione è poi richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento dell'indizione delle elezioni; allo stesso modo,nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato dichiarazioni di coalizione con almeno 2 partiti con le caratteristiche sopra dette e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. In questi casi,la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo.
Ogni lista,all'atto della presentazione,è composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. A pena di nullità dell'elezione,nessun candidato può decidere di candidarsi contestualmente alla Camera e al Senato.
Con la presentazione e la pubblicazione delle candidature si apre la campagna elettorale,che dura fino al giorno precedente la votazione e che è adesso regolata da alcune leggi(10 dicembre 1993 n.515 e 22 febbraio 2000 n.28)che hanno l'intento di assicurare la **par condicio** fra i candidati e fra i partiti per quel che riguarda la propaganda elettorale,in modo che siano assicurate la parità di trattamento,la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
Le elezioni si svolgono in due giorni(domenica e lunedì fino alle 15:00)presso le varie sezioni nelle quali sono stati ripartiti gli elettori. In ciascuna sezione viene costituito un seggio elettorale composto da un presidente,quattro scrutatori(di cui uno,a scelta del presidente,svolge le mansioni di vicepresidente) e da un segretario.
L'elezione del Senato avviene su base regionale(art.57 Cost.),nel senso che le Regioni costituiscono le maggiori circoscrizioni nel cui ambito si svolgono le operazioni elettorali. Con riferimento alla Camera, invece,partecipato al riparto dei seggi solo le coalizioni che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi,a condizione che almeno una delle liste in coalizione abbia ottenuto almeno il 2% dei voti o che sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in Regioni in cui le dette minoranze risultano tutelate e abbia conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione.
All'interno delle singole coalizioni sono ammesse alla distribuzione dei seggi solo le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2% dei voti validi espressi.
Partecipano alla ripartizione anche le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 4%dei voti validi espressi e le singole liste rappresentative di minoranze linguistiche che abbiano le caratteristiche già viste,nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato il 10% ma che hanno conseguito sul piano

This document is available free of charge on StuDocu.com

nazionale il 4% dei voti o siano rappresentative di minoranze.
Il premio di maggioranza viene attribuito alla coalizione o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi espressi e che non abbiano già conseguito almeno 340 seggi. Alla coalizione o alla lista vincitrice viene in tal modo attribuito il numero di seggi necessario a raggiungere quota 340 seggi.
A questo punto,si divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista vincitrice per 340,ottenendo così il *quoziente elettorale nazionale di maggioranza.* Si divide poi per 277 il totale delle cifre elettorali nazionali delle altre coalizioni o liste,ottenendo così *il quoziente elettorale nazionale di minoranza*. Sulla base di questi quozienti,si procede infine alla ripartizione attribuendo gli eventuali seggi residui alle liste che hanno ottenuto i resti maggiori o,in caso di parità,a quelle che hanno ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale. A parità di quest'ultima,si procede per sorteggio.
I candidati vengono eletti secondo l'ordine di presentazione nella lista. Il sistema elettorale previsto per il senato è simile a quello della Camera,con l'importante differenza che il premio di maggioranza viene assegnato su scala regionale alla coalizione o alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti,ma che non abbia raggiunto il 55%dei seggi. Viene quindi assegnato alla lista o alla coalizione il numero di seggi necessari a raggiungere il 55%: la differenza non è di poco conto,in quanto può condurre ad un divario di risultati notevole tra le due Camere in termini di seggi(come è avvenuto nelle elezioni politiche del 2006).
I candidati eletti deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione(secondo l'art.1 del regolamento della Camera). Allo stesso modo,i senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni dal momento della proclamazione,se eletti,o dalla comunicazione della nomina,se nominati(art.1 del regolamento del Senato).
Sia alla Camera che al Senato,il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa viene attribuito nell'ambito della medesima lista al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

9. Differenziazione tra le due Camere-I tratti distintivi tra le due Camere possono così schematizzarsi: è richiesta di un'età diversa per l'acquisto del diritto di elettorato attivo e passivo; la Camera è composta da 630 membri,il Senato da 315(più i senatori di diritto e a vita);sono parzialmente diversi i sistemi elettorali per l'elezione delle due Camere; il rapporto rappresentativo (num. di abitanti corrispondente a ogni seggio) è più elevato per il Senato; la Camera dei deputati è interamente elettiva mentre del Senato fanno parte anche i senatori di diritto e a vita. Con la revisione costituzionale del 1963 è stato eliminato,parificando a 5 anni la durata in carica delle due Camere,un ulteriore elemento di distinzione:precedentemente, infatti, la durata in carica era fissata a 5 anni per la Camera e a 6 anni per il Senato. Altri tratti distintivi relativi all'organizzazione interna e al modo di esercizio delle funzioni sono poi contenuti nei rispetti regolamenti parlamentari:così ad esempio il regolamento della Camera dispone che un progetto di legge può essere assegnato ad una commissione in sede deliberante per questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale;

nulla è invece previsto al riguardo nel regolamento del Senato. La formula adottata dall'art.57,comma I,definisce il Senato come organo eletto a base regionale,tant'è che lo stesso articolo,al III comma,stabilisce che nessuna regione può avere un numero di senatori interiore a 7,ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta,che ne hanno rispettivamente 2 e 1. Ora,poiché il bicameralismo ha portato a giudizio di molti a diversi aspetti negativi("il Senato inutile doppione della Camera),in special modo la sovrapposizione dei lavori parlamentari,la lentezza e la relatività di procedure e il blocco delle stesse in seguito al voto contrario di una delle Camere,da più parti sono state avanzate proposte dirette a porvi riparo ricorrendo a modifiche sia strutturali(il Senato come "Camera delle Regioni",secondo un'idea originariamente formulata in Assemblea costituente)sia funzionali(ad esempio affidando alla Camera la funzione legislativa e al Senato quella di controllo sull'amministrazione),ovvero instaurando un sistema unicamerale. Contro queste proposte si è osservato che conta assicurare che il procedimento di deliberazione parlamentare sia contrassegnato dalla dialettica fra due autonomi poteri decisionali. Non si intende che la soluzione vada ricercata nella trasformazione del Senato in una Camera delle Regioni mediante l'elezione dei suoi membri ad opera dei Consigli regionali,ma soltanto che la completa attuazione dell'ordinamento regionale richiede una più diretta rappresentanza delle Regioni in Parlamento. Sono previsti nella Costituzione vari modi per consentire l'ingresso in Parlamento delle Regioni(l'iniziativa legislativa e i voti,la partecipazione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica,l'approvazione da parte delle Camere degli Statuti deliberati dai Consigli regionali):si tratterebbe quindi di instaurare mediante elezioni un effettivo collegamento fra la base regionale e il Senato,di modo che possano ridursi gli svantaggi,lamentati a gran voce dalle Regioni,derivanti dalla mancata previsione di una sede istituzionale nella quale possa operarsi il raccordo fra le Regioni complessivamente considerate e l'organo legislativo dello Stato-istituzione. Periodicamente viene inoltre avanza,fra le varie proposte di riforme istituzionali,quella di ridurre il numero dei seggi delle due Camere;un Parlamento memo numeroso avrebbe forse maggiore autorità e potrebbe funzionare meglio secondo una parte della dottrina(e in effetti 945 parlamentari sono un numero abbastanza elevato,in specie se confrontato con i 435 deputati e i 100 senatori degli Stati Uniti,che hanno una popolazione ben superiore a quella italiana,300 milioni di abitanti).Ad ogni modo,l'accresciuto numero di attribuzioni di cui si fa carico alle Camere in nome della centralità del Parlamento richiede una congrua disponibilità di parlamentari:la riduzione del numero dei parlamentari non contribuirebbe pertanto ad assicurare una migliore funzionalità del Parlamento sino a quando deputati e senatori saranno sottoposti ad una rigida disciplina di partito o di schieramento,che anzi tanto più sarebbe fatta valere quanto più venisse ridotto il numero di parlamentari. Sembra pertanto che non sia questa la strada da seguire per assicurare una maggiore funzionalità dell'organo,bensì quello di uno snellimento delle procedure,di un freno o di un filtro alle proposte di legge e alla pratica delle "leggine"ecc.

This document is available free of charge on StuDocu.com

10. Ineleggibilità ed incompatibilità parlamentari- Ragioni di opportunità politica hanno portato il legislatore ad escludere alcune categorie di persone che ricoprono determinati uffici dall'elezione all'ufficio di deputato o senatore,ed è, inoltre, per altre categorie, stato stabilito che essi non possano ricoprire contemporaneamente l'ufficio di parlamentare ed un altro ufficio,e debbano pertanto scegliere fra i due. Nella prima ipotesi si parla di **ineleggibilità** nella seconda di**incompatibilità**. E' importante notare che le cause di ineleggibilità non incidono sulla capacità elettorale passiva;in altri termini,chi è colpito da una causa di ineleggibilità non perde il diritto ad essere eletto,ma tale diritto non può essere validamente esercitato finchè permane la causa impeditiva. Venute meno infatti tali ragioni,il diritto può essere validamente esercitato;al contrario,se un candidato viene eletto nonostante sia colpito da una causa di ineleggibilità,la sua elezione è nulla.
Le persone colpite da ineleggibilità sono distinte in tre gruppi: a) persone che ricoprono determinati uffici,avvalendosi dei quali potrebbero esercitare a loro favore pressioni su alcuni elettori(ad es. i sindaci dei comuni con una popolazione superiore ai 20.000 abitanti,il capo e vice capo della polizia,i prefetti ecc.); b) persone che abbiano impiego da governi esteri,al fine di impedire possibili interferenze straniere nello svolgimento delle elezioni; c)persone che sono legate allo Stato da particolari rapporti economici,in modo da evitare che i loro interessi personali possano interferire con lo svolgimento del mandato parlamentare(ad es.i concessionari di pubblici servizi,i dirigenti di società sussidiate dallo Stato ecc.)A queste categorie vanno aggiunti i giudici della Corte costituzionale e i magistrati,che non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte alla giurisdizione degli uffici loro assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni per un periodo compreso nei 6 mesi antecedenti la data della candidatura. Quanto alle cause di incompatibilità,alcune di esse sono previste dalla stessa Costituzione(tra deputato e senatore;tra membro del Parlamento e Presidente della Repubblica;tra membro del Parlamento e membro del CSM o della Corte);altre vengono riportate nella legge del 13 febbraio 1953 n.60 diretta in massima parte ad impedire che membri del Parlamento ricoprano cariche in enti controllati dallo Stato. I membri del Parlamento non possono infatti ricoprire cariche o esercitare funzioni di amministratore,presidente ecc.in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione(o a qualsiasi altro servizio lo Stato contribuisca direttamente o indirettamente). I membri del Parlamento inoltre non possono ricoprire cariche o uffici in enti pubblici o privati. I professori universitari di ruolo eletti al Parlamento sono collocati d'ufficio in aspettativa per la durata del mandato,e gli statuti delle maggiori confederazioni sindacali dispongono che non si possono contemporaneamente ricoprire alcune cariche sindacali e l'ufficio di parlamentare. C'è incompatibilità inoltre anche fra l'ufficio di componente del CNEL e quello di parlamentare. Gli eletti colpiti da una causa di incompatibilità dovranno pertanto scegliere fra l'ufficio di parlamentare e quello già ricoperto. Figura nuova rispetto alle elezioni della Camera e del Senato è quella della **incandidabilità,** già prevista per le elezioni regionali, provinciali e comunali, ma introdotta dal 2012 anche per le elezioni politiche. In particolare, non possono candidarsi e comunque ricoprire la

carica di deputati e senatori: coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, compiuti o tentati, previsti dall'art. 51 del c.p.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso; attività organizzate peer il traffico illecito di rifiuti; ecc.); coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti consumati o tentati, rubricati nel c.p. come *delitti contro la P.A, delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.* come ad es. peculato, concussione, corruzione; coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati per i quali sia prevista la pena reclusiva non inferiore nel massimo a 4 anni (art. 278 c.p.p). Qualora sopravvenga una causa di incandidabilità durante il mandato, la Camera di appartenenza delibera in sede di verifica dei poteri.

11. La verifica delle elezioni- Appena eletto,il parlamentare assume la qualità di deputato o senatore e può quindi esercitare le funzioni inerenti al suo ufficio;per assicurare però il rispetto della Costituzione e delle norme di legge,la sua elezione viene sottoposta ad un controllo sia sotto il profilo della sussistenza dei requisiti per la validità dell'ammissione all'ufficio(in ordine alla capacità elettorale passiva e all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità)sia sotto il profilo della regolarità delle operazioni elettorali.
Questo controllo("verifica delle elezioni" o "verifica dei poteri" o ancora "verifica dei titoli di ammissione")viene esercitato dalla Giunta delle elezioni(alla Camera)e dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari(al Senato). La verifica si svolge attraverso due fasi,una necessaria,detta controllo **di delibazione**,ed una eventuale,**giudizio di contestazione** ,laddove dovessero rinvenirsi presupposti contro la convalida. Il controllo di delibazione mira appunto ad accertare la validità della elezione sia dal punto di vista della validità dell'ammissione all'ufficio,sia sotto il profilo della regolarità delle elezioni;se la Giunta delibera la convalida ne da comunicazione all'assemblea,alla quale non resta altro che prendere atto della convalida;se la Giunta ritiene invece non regolare l'elezione la contesta nel successivo giudizio di contestazione,che si svolge in parte dinanzi alla Giunta(in una discussione pubblica alla quale sono ammessi i sottoscrittori delle proteste,il parlamentare la cui elezione è stata messa sotto accusa e i loro rispettivi rappresentanti),e si conclude infine con una deliberazione della medesima a favore o contro la convalida. L'altra parte del giudizio si svolge innanzi all'intera assemblea,che decide definitivamente,a scrutinio segreto,se convalidare o meno l'elezione. Il giudizio di contestazione implica l'esercizio di una funzione materialmente giurisdizionale,e costituisce dunque un'eccezione al principio secondo cui la funzione giurisdizionale dovrebbe essere affidata esclusivamente ai giudici ordinari,secondo l'art.102 Cost. I comma. Si è voluta in tal modo garantire l'autonomia del Parlamento,ma si è allo stesso modo compromessa l'imparzialità del giudizio,affidato allo stesso organo del quale fanno parte i parlamentari la cui elezione è stata contestata. La verifica delle elezioni nella Camera si svolge secondo le disposizioni contenute nel regolamento interno alla Giunta del '98,e al Senato a norma del regolamento per la verifica dei poteri deliberato nel '92.

This document is available free of charge on StuDocu.com

Sezione II- LO "STATUS" DI MEMBRO DEL PARLAMENTO

Per "status" di parlamentare si intende la posizione complessiva di cui deputati e senatori vengono a trovarsi in ragione della loro appartenenza alle Camere elettive. Tale status di acquista quindi dal momento dell'assunzione dell'ufficio di deputato o senatore, vale a dire con la proclamazione e,per i senatori a vita,con la comunicazione della nomina. Le guarentigie dello status di parlamentare sono previste dall'art. 68 cost. Esse sono strettamente connesse alla funzioni svolte dai parlamentari e tendono ad assicurarne il libero esercizio, tutelando in tal modo sia il parlamentare sia,al tempo stesso,le assemblee elettive contro indebite ingerenze volte a limitarne o comprimerne l'indipendenza. E' infatti evidente(come peraltro testimonia l'origine storica delle guarentigie)che le assemblee parlamentari sono realmente indipendenti se ed in quanto lo sono i loro singoli componenti.

12. L'irresponsabilità per le opinioni espresse ed i voti dati-A norma dell'art. 68 comma I cost. (come modificato dalla legge cost. 3/93), "I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Tale norma esenta quindi i parlamentari da ogni responsabilità civile,penale,amministrativa e disciplinare che potrebbe sorgere da un'opinione espressa o da un voto dato, al fine appunto di consentire la più ampia libertà di valutazione e decisione nell'esercizio del mandato. Tale irresponsabilità permane anche alla scadenza della carica di parlamentare. Essa è limitata tuttavia: ai voti e alle opinioni, per cui se viene commesso un fatto materiale il parlamentare è perseguibile penalmente; alle opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare, e non in altra sede, (es. opinioni su giornali ecc.).Le Camere, tuttavia, tendono ad estendere l'irresponsabilità anche oltre i limiti della sede parlamentare, non concedendo l'autorizzazione a procedere. Negli ultimi anni,la Corte cost. ha assunto una posizione più rigorosa in tema di insindacabilità delle opinioni espresse al di fuori della sede parlamentare ritenendo che, con sent. 58/2000, debba poter essere riscontrato un nesso funzionale fra attività parlamentari e dichiarazioni, e più precisamente questo nesso dovrà consistere nell'identificabilità della dichiarazione quale espressione dell'attività del parlamentare. Con la sent.n.137 del 2001,la Corte costituzionale,nel ribadire quanto sancito dall'art.68 I comma,ha chiarito però che la prerogativa parlamentare dell'insindacabilità non può essere estesa fino a comprendere gli insulti solo perché collegati con le posizioni sostenute da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche;esula quindi dalla guarentigia dell'insindacabilità l'uso del turpiloquio,bandito peraltro dagli stessi regolamenti parlamentari; mentre, con la sent.509 del 2002, la Corte ha riconosciuto la sindacabilità delle opinioni espresse da un deputato anche all'interno delle sedi parlamentari,laddove non sia riscontrabile un nesso con l'esercizio della funzione parlamentare(nesso tra opinioni e funzione). I regolamenti, nell'art. 58 della Camera e nell'art. 88 del Senato, statuiscono che il parlamentare che, nel corso di discussione parlamentare, sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente dell'Assemblea di nominare una commissione (il cosiddetto "giurì

d'onore") che accerti i fatti. La commissione riferirà al Presidente che prenderà atto, senza dibattito. Le guarentigie di insindacabilità sono state estese anche ai consiglieri regionali (art. 122, comma IV).

13. Le guarentigie della libertà personale e domiciliare e della libertà di comunicazione e corrispondenza- A norma dell'art. 68 comma II e III, come modificato dalla legge cost. n. 3/93, nessun parlamentare, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, può essere:sottoposto a perquisizione personale o domiciliare; arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che sia stato preso in flagranza di reato, per i quali è richiesto l'arresto obbligatorio; sottoposto ad intercettazione in qualsiasi forma di conversazione o comunicazione ed a sequestro di corrispondenza. La riforma del 93 ha abolito l'autorizzazione per sottoporre il parlamentare a processo penale, che s'era prestata a notevoli abusi (si pensi alla truffa; all'emissione di assegni a vuoto; ecc.).Resta ferma l'autorizzazione per limitare la libertà personale, salvo che siano colti nell'atto di commettere un reato (in flagranza di reato),per il quale è previsto obbligatoriamente l'arresto. Ciò a garanzia della continuità della funzione da essi svolta quali rappresentanti del popolo, oltre che per non far venire meno il numero della Camera, e per evitare che la mancanza di parlamentari stravolga le forze politiche. Con legge 140 del 2003, si sono introdotte nuove disposizioni per l'attuazione dell'art.68 Cost.,allo scopo di disciplinare in maniera più particolareggiata i rapporti tra l'Autorità giudiziaria e la Camera di appartenenza del parlamentare coinvolto in indagini o processi. La legge stessa all'art. 1 aveva stabilito che le alte cariche dello Stato (Presidente della repubblica, salvo le disposizioni dell'art. 90 cost.; Presidenti del senato e della camera; Presidente del Consiglio dei Ministri salvo quanto previsto dall'art. 96 cost.; Presidente della Corte cost.) non potevano essere sottoposti a processi penali per qualsiasi reato riguardante anche fatti antecedenti rispetto al momento dell'assunzione della carica fino alla cessazione della stessa. I processi già iniziati venivano sospesi al momento dell'entrata in vigore della legge fino alla cessazione del mandato del soggetto implicato. La nuova prerogativa di immunità fece sorgere subito forti perplessità e vivaci polemiche circa la sua compatibilità con la Costituzione. La Corte costituzionale,con la sentenza n.24 del 2004,ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma prima citata per contrasto con gli art.24 e 4 della Costituzione,in quanto incideva sul diritto di difesa dell'imputato,che avrebbe in ogni caso dovuto aspettare la cessazione della carica per potersi difendere legalmente e sul diritto di azione della parte civile,che avrebbe dovuto aspettare un tempo indeterminato per vedere accolta la propria domanda risarcitoria. La nuova prerogativa era pure in violazione del principio di eguaglianza,in quanto(a giudizio della Corte),venivano accomunata in un'unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura,ma anche per la natura delle funzioni,e perché si distinguevano per la prima volta i Presidenti degli organi costituzionali dagli altri componenti degli stessi. Con la legge 124 del 2008 è stata reintrodotta la sospensione dei processi penali(anche per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione)nei confronti dei soggetti che rivestono la

This document is available free of charge on StuDocu.com

qualità di Presidente della Repubblica,Presidente del Consiglio,Presidente del Senato e della Camera. Rispetto alle disposizioni simili contenute nella legge n.140 del 2003,era stata esclusa da questa garanzia speciale la carica di Presidente della Corte costituzionale. La sospensione operava per l'intera durata della carica e non era reiterabile,salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura,né si applicava in caso di successiva investitura in un'altra delle cariche indicate. Se il processo penale veniva sospeso,veniva automaticamente sospeso anche il decorso della prescrizione. La sospensione inoltre si applicava anche ai processi penali in corso alla data dell'entrata in vigore di questa legge,in ogni fase,stato o grado gli stessi si fossero trovati. Anche queste norme furono dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale,che con la sent.262 del 2009 ha ritenuto che le stesse violassero gli artt. 3 e 138 Cost. In particolare, la sospensione dei processi penali è stata ritenuta "derogatoria rispetto al regime processuale comune" in quanto posta "solo a favore dei titolari di quattro alte cariche dello Stato". Pertanto,secondo la Corte costituzionale,la deroga si risolveva "in un'evidente disparità di trattamento delle alte cariche rispetto a tutti gli altri cittadini".

14. Sanzioni disciplinari a carico dei parlamentari- Sono assunte dal Presidente dell'Assemblea o dall'Ufficio di Presidenza alla Camera o dal Consiglio di Presidenza al Senato, e consistono: nel richiamo all'ordine, qualora il parlamentare pronunci parole sconvenienti oppure turbi in altro modo l'andamento dei lavori; nell'esclusione dall'aula dopo il secondo richiamo all'ordine se ancora il parlamentare persiste nel turbare i lavori o nei casi più gravi(ingiurie ad uno o più colleghi,ad un mebro del Governo,oltraggio,vie di fatto,appello alla violenza ecc.); nella censura (accompagnata eventualmente dall'espulsione dall'aula) con l'interdizione a partecipare ai lavori in aula per un determinato tempo (da 2 a 15 giorni di seduta alla Camera e per un periodo non superiore ai 10 giorni al Senato).

15. Divieto di mandato imperativo- L'art. 67 Cost. dispone che "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". Ciò significa che il parlamentare,in quanto rappresentante dell'intera nazione e non già degli elettori del suo collegio,non può ricevere da questi disposizioni vincolanti circa il modo in cui deve svolgere il suo mandato(anche se,come è comprensibile,egli sarà portato a rendersi interprete anche delle esigenze e dei bisogni del suo elettorato). Dal divieto di mandato imperativo discende **l'irresponsabilità politica** dei parlamentari nel corso della loro permanenza nell'ufficio: infatti, il parlamentare eletto non può essere revocato.
Il divieto di mandato imperativo risulta di fatto attenuato in Parlamento dalla presenza dei partiti politici, dato che i parlamentari devono seguire le direttive dei partiti ai quali appartengono. Alcuni autori,come Virga, ritengono che in queste condizioni il parlamentare viene trasformato in mero portavoce di interessi del partito e,conseguentemente,il divieto di mandato imperativo viene violato. Altri, come Biscaretti, Mazziotti, Mortati ecc. hanno differentemente sostenuto che la sottoposizione dei parlamentari ai partiti non vale a far venire meno il divieto;il

parlamentare, infatti, non è tenuto all'obbedienza e può sempre orientare la sua volontà in maniera difforme alla direttive ricevute. Infatti, nel Regolamento della Camera art. 83 comma 1, e art. 116 comma 3, si dice che il parlamentare in contrasto con l'opinione del partito ha il diritto a prendere la parola sulle linee generali di un progetto di legge. Mentre al Senato, all'art. 84 reg. senato, i senatori in dissenso del gruppo hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente. Nella realtà però la disciplina dei partiti viene ad imporsi sui parlamentari, anche perché i parlamentari ribelli vengono molto spesso puniti con l'applicazione di sanzioni, che possono giungere fino all'espulsione dal partito o all'esclusione dalle liste elettorali.

16. L'indennità parlamentare- L'art. 69 Cost. dispone che "I membri del Parlamento ricevano una indennità stabilita dalla legge". L'art. 1 della legge 1261/65 stabilisce che l'indennità è costituita da quote mensili compresi i rimborsi di spese di segreteria e di rappresentanza. L'ammontare di queste quote è stabilito dall'Ufficio di Presidenza delle Camere in misura non superiore al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione. A questa indennità fissa si devono aggiungere le spese di soggiorno a Roma pagate in misura di 15 giorni al mese non superiore alle missioni dei magistrati di funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione. Ai parlamentari spetta inoltre la carta di libera circolazione sulle reti ferroviaria e sulle linee aeree ed un assistente pagato con fondi stanziati dalle camere. Ai deputati spetta anche un assegno vitalizio, per i parlamentari che hanno 65 anni e che abbiano prestato versato contributi per 5 anni.

17. I parlamentari pubblici impiegati- I parlamentari pubblici impiegati vengono collocati in aspettativa per il mandato parlamentare e,secondo quanto dispone l'art.88 Cost.,non possono fare carriera se non per anzianità.

18. Le guarentigie delle Camere nel loro complesso- Le guarentigie di cui godono le Camere, per la protezione dell'assemblea, si riflettono sui singoli componenti (Romano). Innanzitutto, speciali norme penali tutelano l'esercizio delle funzioni delle camere (art. 289 cod. pen.) nonché il vilipendio di esse (art. 290 cod. pen.). Accanto poi a questa protezione penale(comune peraltro anche al Presidente della Repubblica e al Governo)va ricordata **l'immunità della sede**: la polizia o altra forza dell'ordine o giudiziaria non può infatti entrare nelle camere, se non autorizzata dal Presidente delle Camere e solo dopo aver sospeso la seduta.
I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine all'interno dell'aula dipendono dal Presidente che li esercita o li delega ai questori, e con l'ausilio della guardia di servizio. Va menzionata infine l'autonomia contabile delle Camere, che determinano da se stesse il loro fabbisogno finanziario e gestiscono direttamente l'apposito fondo somministrato dal Tesoro dello Stato senza essere sottoposte ad alcun controllo esterno.

SEZIONE III – L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE

This document is available free of charge on StuDocu.com

19. I regolamenti parlamentari - Le norme relative all'organizzazione interna e allo svolgimento delle funzioni delle Camere sono contenute nella Costituzione(e sono quindi comuni alle due assemblee) ma anche nei cosiddetti **regolamenti parlamentari** (e allora l'organizzazione di ciascuna assemblea potrà in parte differire). Secondo quanto disposto dall'art. 64 comma 1 Cost. , "Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti". I regolamenti parlamentari possono definirsi come un complesso di disposizioni che ciascuna delle due Camere vota nell'esercizio del proprio potere di autonormazione al fine di disciplinare lo svolgimento dei suoi lavori, la sua organizzazione, i suoi rapporti con gli altri organi costituzionali e in primis con il Governo, oltre che con gli estranei che vengono ammessi nelle sedi della Camere sia per assistere alle sedute sia per accedere agli uffici o per collaborare con le stesse nell'esercizio di alcune loro funzioni. I regolamenti, benchè comunemente definiti "interni", contengono norme costitutive dell'ordinamento giuridico, alcuni delle quali provengono dalla Cost. stessa (art. 72). Sono pertanto fonti del diritto che, in virtù della *riserva di regolamento parlamentare,* prevista dalla Costituzione stessa all'art.64 I comma, sfuggono alla gerarchia delle fonti. Si tratta infatti di fonti separate, di una competenza costituzionalmente riservata a ciascuna Camera, di modo che non si può disciplinare con legge la materia dell'organizzazione interna e dello svolgimento delle funzioni camerali, proprio sulla base di questo principio *di indipendenza costituzionale di ciascuna Camera*. Un indice della natura di fonte normativa dei regolamenti parlamentari si rinviene nei regolamenti approvati dalla Camere nel 1971,che dispongono la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed un periodo di vacatio, come per le altre fonti atti. Quanto all'efficacia dei regolamenti,è indubbio che posseggano l'efficacia sostanziale propria delle fonti normative,mentre la loro efficacia formale non è certo quella del regolamento,ossia di una fonte subordinata alla legge: nel campo loro riservato, infatti,i regolamenti si pongono come **fonte esclusiva**,di primo grado,subordinata unicamente alla Costituzione e alle norme costituzionali. I regolamenti parlamentari inoltre, non essendo menzionati nell'art. 134 Cost.(che elenca le competenze della Corte) non possono essere soggetti al *sindacato di legittimità costituzionale* da parte della Corte stessa. Infatti la Corte ha ritenuto che la Costituzione ha instaurato una democrazia parlamentare,collocando il Parlamento al centro del sistema e facendone l'istituto caratterizzante dell'ordinamento: ne deriva che è nella logica del sistema che alle Camere spetti e vada perciò riconosciuta un'indipendenza nei confronti di qualsiasi altro potere. Bene potrebbe accadere, dunque, che le Camere pongano nei loro regolamenti norme in contrasto con la Costituzione senza che su di esse possa pronunciarsi la Corte costituzionale(competente a giudicare unicamente la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge). La subordinazione della fonte regolamento parlamentare alla Costituzione appare, quindi, come un'affermazione che rischia di essere confinata nel campo delle astrazioni,non esistendo di fatto alcun controllo esterno sull'osservanza delle norme costituzionali da parte delle Camere in sede di emanazione o di modifica dei loro regolamenti. Lo schema dei regolamenti della Camera e del Senato è pressoché uguale: una prima parte è dedicata

all'organizzazione e al funzionamento delle Camere; particolare rilievo assumono poi le norme relative al procedimento di formazione delle leggi, in quanto direttamente esecutivi della Cost.(e in specie dell'art.72 Cost.). Da ultimo,i regolamenti disciplinano le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione dei rapporti tra Governo e Camere (mozioni di fiducia e di sfiducia,istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza ecc.). I regolamenti approvati dalle Camere nel 1791 hanno accentuato la loro natura di fonti non solo esecutive ma anche *attuative* della Costituzione. Infatti,accanto a norme esecutive(cioè direttamente connesse ad una disposizione costituzionale,che valgono a rendere concretamente operante,come nel caso dell'art.72),questi regolamenti contengono norme che,svolgendo alcuni principi impliciti e consequenziali presenti in Costituzione,contribuiscono a comporre la stessa struttura politico-istituzionale dello Stato. Si pensi a questo riguardo alle norme che disciplinano le funzioni di indirizzo,di controllo e di informazione,ai criteri per l'assegnazione delle proposte di legge alle commissioni in sede deliberante o alle disposizioni che disciplinano i casi in cui il Governo può porre la questione di fiducia ecc. Si può quindi rilevare che i nuovi regolamenti tendono a rispecchiare fedelmente la tendenza in atto in Italia da alcuni anni a rivalutare il ruolo del Parlamento nel sistema, assicurandone una maggiore funzionalità,al punto che si è parlato "indirizzo politico" e di "scelte istituzionali" dei regolamenti parlamentari. Oltre che questi regolamenti,detti appunto "generali",ciascuna Camera emana altri regolamenti relativi ad un settore della sua attività o della sua organizzazione interna. Tali sono ad esempio per la Camera dei deputati il regolamento interno della Giunta delle elezioni,quello dei servizi e del personale; mentre per il Senato il regolamento per la verifica dei poteri,quello di amministrazione e contabilità e quello dei concorsi. Infine nel 1989 le Camere hanno approvato separatamente ma nel medesimo testo il regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

20. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza- L'art. 63 Cost. dispone che "Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza". Secondo i regolamenti,l'Ufficio di Presidenza è composto 4 vicepresidenti, 8 segretari, 3 questori. Al Senato l'Ufficio prende il nome di Consiglio di Presidenza.Il Presidente rappresenta la Camera; egli è organo super partes e a tale posizione di imparzialità deve, pertanto, ispirare l'esercizio delle proprie funzione. Come espressione dell'intera assemblea, egli acquista una posizione costituzionale che lo vede garante delle minoranze e del corretto svolgimento delle attività parlamentari nel quadro dei rapporti maggioranza-opposizione,nonché custode e interprete delle prerogative delle Camere,di modo che egli deve aver riguardo anzitutto alla tutela della Costituzione e dei principi in essa contenuti. Da qui la tesi del Manzella, secondo il quale il Presidente è uomo della Costituzione, titolare non di astratti poteri ma di precisi interessi politico- costituzionali. Spetta quindi al Presidente assicurare il corretto svolgersi dei lavori d'aula e l'applicazione del regolamento: egli dà la parola, la toglie, dirige e modera le discussioni, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle

This document is available free of charge on StuDocu.com

votazioni,chiarisce il significato del voto,ne annuncia il risultato. I regolamenti camerali distinguono i ruoli dei due Presidenti,assegnano al Presidente del Senato attribuzioni maggiori sia in ordine ai poteri di direzione dei dibattiti e di organizzazione dei lavori,sia in ordine all'esercizio delle funzioni proprie delle Camere(come nel caso dell'assegnazione dei progetti di legge ad una commissione in sede deliberante,che alla Camera è soltanto "proposta" dal Presidente e decisa dall'Assemblea,mentre al Senato viene disposta dal Presidente,che si limita a darne comunicazione all'Assemblea). Non per questo sembra si possa rinvenire una tendenza assemblearistica della presidenza della Camera di contro ad una tendenza presidenzialistica di quella del Senato,né tantomeno una maggiore democraticità della prima rispetto alla seconda. Si tratta soltanto di un diverso modo di intendere i poteri del presidente d'Assemblea in relazione ai modi di esercizio delle funzioni delle Camere,che non incide sulla posizione costituzionale dell'organo. **All'Ufficio di Presidenza** spetta di deliberare il progetto di bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo delle Camere,di nominare su proposta del Presidente il Segretario Generale,ecc. I vice-presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza.
I **segretari** sovraintendono al processo verbale delle sedute compilato dagli stenografi e ne danno lettura; procedono allo scrutinio delle votazioni e in genere coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
I **questori** sono preposti a vari servizi delle Camere e sovrintendo al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella Camera secondo le disposizioni del Presidente.

21. I gruppi parlamentari; le commissioni permanenti; le giunte; le commissioni d'inchiesta; le deputazioni- I gruppi parlamentari sono organi interni alle Camere che assicurano il collegamento fra queste ultime ed i partiti politici. L'art. 14 R.C.D dispone che "i deputati debbano dichiarare entro 2 giorni dalla prima seduta a quale gruppo appartengono", mentre l'art. 14 R.S.R. dispone che i senatori indichino entro 3 giorni di quale gruppo intendono far parte. Dal momento che,come ovvio,i parlamentari iscritti ad un partito aderiscono allo stesso gruppo,si hanno di regola tanti gruppi quanti sono i partiti politici rappresentati nelle Camere. Sorge in tal modo uno stretto collegamento fra il gruppo parlamentare,articolazione interna delle Camere,e il partito politico. Gruppi parlamentari possono essere costituiti anche da parlamentari non iscritti ad alcun partito ma uniti da un comune impegno su determinati valori o uniti da comune ideologia,e ancora da parlamentari che dichiarano di non voler appartenere ad un gruppo,che confluiscono nel cosiddetto "*gruppo misto*". I gruppi parlamentari sono, comunque, da considerare in massima parte come la proiezione dei partiti politici nelle Camere: a tal proposito,è sorta una vera e propria querelle sul fatto che il gruppo sia considerabile,oltre che organo delle Camere,anche organo del partito. Nella realtà,per quanto gli statuti del partito possano vincolare il gruppo ad osservare l'indirizzo o le direttive dello stesso,nelle Camere non c'è sempre perfetta coincidenza fra partito e il suo gruppo parlamentare: in primo luogo perché il gruppo viene in considerazione come entità distinta dal partito,e in secondo luogo per il *divieto di mandato imperativo*. L'autonomia dei gruppi dai partiti non vuole tuttavia significare contrapposizione o distacco,ma il

semplice fatto che il gruppo,pur rappresentando la proiezione del partito nella Camera,conserva sempre un certo margine di discrezionalità nelle sue scelte. Queste considerazioni inducono a non accogliere la tesi pure formulata che vede nel gruppo parlamentare un'associazione di diritto privato; se così fosse infatti bisognerebbe ammettere che le Camere si avvalgono in via istituzionale di associazioni private. Ai gruppi parlamentari invece meglio si addice la natura di associazioni(necessarie)di diritto pubblico,natura che vale ulteriormente a distinguerli dai partiti politici. Ogni gruppo parlamentare è composto da almeno 20 deputati, mentre al Senato i gruppi sono di almeno 10 senatori. Al gruppo misto aderiscono gli indipendenti ed i parlamentari la cui forza numerica sia insufficiente a formare un gruppo. Alla Camera,i deputati appartenenti al gruppo misto possono richiedere al Presidente di formare componenti politiche in seno ad esso,a condizione che ciascuna consista almeno di dieci deputati. Possono essere formate componenti anche di consistenza numerica inferiore, purchè vi aderiscano deputati in numero non minore di 3,i quali rappresentino un partito la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivocabili,e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati. Un'unica componente all'interno del gruppo misto può essere costituita anche da deputati,in numero non inferiore a 3,appartenenti a minoranze linguistiche, che siano stati eletti nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate dalla Costituzione. Ogni gruppo parlamentare si dà una propria organizzazione interna con la nomina di 1 presidente, di 1 o più vicepresidenti, di un comitato direttivo alla Camera e di 1 o più segretari al senato. Ad essi è assicurata la disponibilità di locali, mezzi e contributi a carico delle Camere stesse,differenziati a seconda della loro consistenza numerica. Fra gli organi interni delle Camere va inoltre menzionata la *Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari*, relativamente all'importanza da essa assunta in merito ad alcuni suoi compiti,quale quello di deliberare il programma dei lavori dell'Assemblea. Alla Camera,la Conferenza viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile,anche su richiesta del Governo o di un Presidente di un gruppo,per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle singole commissioni. Le **commissioni permanenti** sono organi interni delle Camere,composte di regola in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari; per cui ogni commissione riproduce, seppur in misura ridotta, la composizione politica delle Camere (la maggioranza in Assemblea lo sarà anche nella commissioni, allo stesso modo la minoranza). Ciò principalmente perché le commissioni svolgono funzioni di grande rilievo(basti pensare alla funzione legislativa)ed è quindi necessario che i loro orientamenti politici corrispondano a quelli dell'intera Assemblea.
In particolare, alla Camera,ciascun gruppo parlamentare subito dopo la costituzione designa i propri componenti nelle commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna commissione,ed il Presidente della Camera distribuisce poi fra le commissioni i deputati che non sono rientrati nella precedente ripartizione. Allo stesso modo al Senato,ciascun gruppo entro 5 giorni dalla sua costituzione,procede alla nomina dei propri rappresentanti nelle singole commissioni,ed il Presidente del Senato distribuisce poi nelle commissioni i senatori che non risultano assegnati dopo

This document is available free of charge on StuDocu.com

la prima ripartizione.
Le commissioni sono 14 sia alla Camera che al Senato,si distinguono in ragione della loro *competenza per materia* e riproducono in alcuni casa la divisione dell'amministrazione centrale in ministeri(ad es. come per la commissione programmazione e bilancio,lavoro e previdenza sociale,giustizia,finanze ecc.). Significative variazioni alle competenze delle commissioni sono state apportate dalle modifiche ai regolamenti approvate rispettivamente il 23 luglio 1987 alla Camera e il 30 luglio 1987 al Senato,con le quali si è istituita alla Camera la XIV *commissione competente per le questioni comunitarie*, mentre al Senato la preesistente *Giunta per gli affari delle Comunità europee* è stata trasformata nella XIV *Commissione permanente per le politiche dell'UE*. Alla Camera nel 1997 è stato inoltre istituito il Comitato per la legislazione,con la funzione di fornire pareri sui testi legislativi. Compiti delle commissioni sono quelli di riunirsi: in sede referente per l'esame di questioni che riferiscono in Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa o deliberante per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente per la formazione degli articoli di un progetto di legge; in sede politica per ascoltare le comunicazioni del Governo, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione e per presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte su materie di loro competenza. Le commissioni(in sede referente,consultiva,legislativa,politica)svolgono da un lato un'attività preparatoria di quella dell'Assemblea,ma dall'altro possono giungere(in sede deliberante e in sede politica)fino a sostituirsi all'Assemblea con propri poteri decisionali. Ciò ha innegabilmente portato ad uno snellimento dei lavori delle Camere,ma ha fatto sorgere al tempo stesso delicati problemi di equilibrio fra i poteri dell'Assemblea e quelli delle commissioni. Si è soliti affermare che le Camere svolgono meglio il loro lavoro in commissione(per la ristrettezza del numero dei componenti,per l'attenuarsi degli scontri fra maggioranza e opposizione,per la minore difficoltà a raggiungere un compromesso),ma non si deve neanche incoraggiare in maniera eccessiva la parcellizzazione dei lavori delle Camere facendo delle commissioni la sede effettiva delle decisioni camerali.
Anche le commissioni permanenti si danno una loro organizzazione interna con l'elezione di un presidente,due vicepresidenti e di due segretari. Dalla data della loro costituzione le commissioni vengono poi rinnovate ogni biennio,ma i loro componenti possono anche essere riconfermati. Dalle commissioni parlamentari si distinguono poi le **giunte**, che sono anch'esse organi permanenti delle Camere, i cui componenti vengono nominati dal Presidente in modo da rispecchiare sempre la proporzione dei gruppi. Alla Camera sono: *la giunta per il regolamento, quella delle elezioni, quella delle autorizzazioni richieste ai senzi dell'art. 68 Cost.*.
Al Senato sono invece: *la giunta per il regolamento e la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Oltre* alle commissioni permanenti e alle giunte sono da ricordare le cosiddette **commissioni di inchiesta** (art. 82 Cost.) e le **deputazioni** (non più previste nel nuovo regolamento della Camera),che sono organi straordinari, che vengono cioè create in caso di necessità, rispecchiando sempre la composizione della Camera stessa.

22. Gli organi bicamerali - Accanto a questi organi unicamerali esistono organi bilaterali, cioè composti pariteticamente da deputati e senatori,collegati strutturalmente e funzionalmente con l'aula. La Cost. all'art. 126 comma IV dispone solo la *Commissione per le questioni regionali* e non ne istituisce altre, ma non è escluso che si possano indire inchieste parlamentari bicamerali, anzi l'art. 26 R.S. prevede espressamente la formazione di organi bilaterali che, per consuetudine, sono stati creati anche alla Camera.
La legittimità costituzionale di questi organi è stata lungamente discussa sotto diversi profili,quali quelli del loro "distacco" dalla Camere,che li porterebbe ad assumere una posizione di "terzietà" rispetto ad esse(inconciliabile col bicameralismo).Più che sulla legittimità costituzionale della loro istituzione,sembra possano essere avanzati dubbi soprattutto in ordine ai modi della loro formazione,alle norme che ne disciplinano il funzionamento e alla stessa opportunità della loro costituzione. In un sistema bicamerale perfetto come il nostro,la regola è che ciascuna Camera opera separatamente dall'altra e a tal fine si dà un proprio regolamento contenente una distinta disciplina interna. L'operare in comune delle due Camere costituisce quindi una vera e propria deroga al principio del bicameralismo perfetto.
Anche gli organi bicamerali possono essere distinti in **permanenti e temporanei**: fra gli organi bicamerali più importanti possono ricordarsi la commissione parlamentare per le questioni regionali;la commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Fra gli organi aventi carattere temporaneo sono da menzionare le commissioni chiamate a dare pareri sui decreti legislativi del Governo.

23. La legislatura; la decadenza dei progetti di legge; la prorogatio; la convocazione - Col termine *legislatura* si intende il periodo che va dalla prima riunione dell'assemblea al giorno del loro scioglimento normale (che avviene dopo 5 anni) o al giorno dello scioglimento anticipato (ad opera del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 88 cost.). Con la fine della legislatura *decadono tutti i progetti di legge* che non sono stati ancora approvati dalle due Camere, cosicché questi progetti possono essere ripresentati alle nuove Camere(sempre che se ne ravvisi l'opportunità politica).
Tuttavia i regolamenti parlamentari hanno adottato una formula di compromesso secondo la quale se i progetti decaduti vengono ripresentati entro sei mesi dall'inizio della nuova legislatura nell'identico testo già approvato o sono sottoposti alle commissioni in sede referente nell'identico testo il cui esame sia stato già esaurito dalle commissioni stesse nella precedente legislatura,possono essere rispettivamente essere riesaminati con una procedura d'urgenza o inviati dalle commissioni all'Assemblea. Unica eccezione al principio di decadenza è quella che riguarda i progetti di legge di iniziativa popolare,per il cui riesame non è richiesta una nuova presentazione all'inizio della legislatura. A norma dell'art.61 Cost., "Finché non siano insediate le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti" (**prorogatio** art. 61). Il prolungamento senza termini è escluso dalla Costituzione, e previsto solo in caso di guerra, deve essere inoltre deliberato con legge (art. 60 Cost.) Nella

This document is available free of charge on StuDocu.com

prorogatio, le Camere devono attenersi alla normale amministrazione costituzionale(nella quale possono farsi rientrare l'attività di controllo politico sul Governo e di garanzia costituzionale); esse inoltre potranno svolgere la funzione legislativa,limitatamente ai casi in cui questa abbia i caratteri dell'*indifferibilità ed urgenza,* come nei casi dell'esame dei decreti legge per la loro conversione in legge,della approvazione della legge di bilancio,della deliberazione dello stato di guerra, del riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica. (Il riesame di una legge rinviata può,in via generale,non avere i caratteri dell'urgenza come invece la conversione in legge di un decreto legge,l'approvazione del bilancio o di altre leggi che per la loro particolare natura e in presenza di determinate condizioni richiedono che la loro approvazione non possa essere rimessa alle nuove Camere;si pensi ad es. ad una legge sull'ordine pubblico in caso di deliberazione dello stato di guerra o in una situazione di emergenza. Resta però il requisito dell'indifferibilità,e cioè dell'improrogabilità:in primo luogo perché il rinvio alle Camere investe le Camere che hanno approvato la legge e non le nuove. Soccorre a tal proposito l'art.74 Cost.,per il quale,con il rinvio,il Presidente della Repubblica richiede alle Camere una nuova deliberazione,vale a dire una seconda pronuncia,tenuto conto dei rilievi mossi dal Presidente nel messaggio motivato. Se a deliberare fossero invece le Camere neo-elette,esse si troverebbero chiamate a pronunciarsi per la prima volta sulla legge:il rinvio in tal caso non comporterebbe quindi un riesame della legge,ma una sua prima lettura. In tal modo,precludere alle Camere la possibilità di riesaminare la legge rinviata in regime di proprogatio equivarrebbe ad investire il Presidente della Repubblica di un sostanziale potere di veto: la legge infatti,non potendo essere riesaminata dalle Camere in prorogatio decadrebbe con lo scioglimento delle Camere secondo il principio di decadenza. A tal proposito si cita il caso del rinvio alle Camere operato nel febbraio del 1992 dall'allora Presidente della Repubblica Cossiga,che rinviò alle Camere in prorogatio la legge sull'obiezione di coscienza,approvata da una larghissima maggioranza in Parlamento. Nel caso in specie,la Corte costituzionale aveva già in precedenza,con la sent.468 del 1991,chiaramente affermato che ad ogni assemblea elettiva spetta la totale disponibilità delle attribuzioni costituzionalmente spettanti all'assemblea medesima e ai loro membri qualora queste attribuzioni siano ricomprendibili fra gli atti indifferibili e necessari permessi in regime di scadenza della legislatura. Nonostante ciò,la riforma dell'obiezione di coscienza è stata approvata solo molto tempo dopo,nel '98.) Le camere sono **convocate di diritto** : entro 20 giorni delle elezioni (art. 61) in una data fissata dal presidente della Repubblica che indice le elezioni; il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre (art. 62); quando una Camera si riunisce in via straordinaria è convocata di diritto anche l'altra, ciò per permettere il contemporaneo svolgimento dei lavori delle due camere (art. 62 comma 2); ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria dal suo Presidente o dal Presidente della Repubblica, o da un terzo dei componenti (art. 62 c. 2)e su **mozione di aggiornamento,** quando, sospendendo i lavori, si rinvia per la loro ripresa. Le camere cessano dal loro ufficio o per fine mandato (allo scadere dei 5 anni di normale durata della legislatura) o per scioglimento anticipato: a sciogliere anticipatamente le

Camere è il Presidente della repubblica (art. 88) sentiti i Presidenti delle Camere. Tale potere del Presidente può tuttavia essere esercitato negli ultimi 6 mesi del suo mandato (c.d. "semestre bianco"),salvo che gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale non coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura stessa.

24. Il funzionamento: la pubblicità delle sedute; il numero legale; la determinazione della maggioranza; i sistemi di votazione; l'ordine del giorno; la programmazione dei lavori - Le sedute delle Camere sono pubbliche, ma a norma dell'art. 64 Cost. ciascuna delle due Camere o il Parlamento in seduta comune può deliberare di riunirsi anche in seduta segreta. La pubblicità delle sedute si attua sia ammettendo il pubblico nelle apposite tribune, sia con la pubblicazione degli atti parlamentari,sia con la trasmissione televisiva, sia con la pubblicazione dei resoconti stenografici (ai sensi dell'art. 72 comma 3 cost.), sia con l'ammissione della stampa e del pubblico in appositi locali. Perché la seduta sia valida occorre la presenza alla seduta della maggioranza dei componenti, il c.d. "**numero legale**" (art. 64 comma 3 cost.). La rigidità di questa disposizione è stata tuttavia attenuata dai regolamenti delle due Camere, secondo i quali il numero legale è sempre *presunto*,a meno che non ne chiedano la verifica 20 deputati o 12 senatori. Le deliberazioni delle Camere devono avvenire a maggioranza dei presenti (**maggioranza semplice**) salvo che la costituzione richieda la **maggioranza assoluta** (metà + 1) o **qualificata** (2/3, 3/5 dei componenti) .Nella determinazione della maggioranza,gli astenuti hanno costituito un problema. Nella Camera dei deputati l'art. 48 R.C.D. dispone che, ai fini della determinazione della maggioranza,sono considerati presenti i deputati che esprimono voto favorevole o contrario: l'astenuto, ancorché presente, viene valutato come assente,dunque non conta; al Senato a norma dell'art. 107 R.S., essendo le decisioni prese a maggioranza dei presenti, l'astenuto fa numero legale. Sembra dunque che l'art.48 comma II del R.C.D.,disponendo che gli astenuti non vengono computati nel calcolo della maggioranza,si ponga in contrasto rispetto all'art.64 Cost.,in base al quale le deliberazioni delle Camere sono valide solo se adottate dalla maggioranza dei presenti:è quindi questo uno dei casi in cui una norma di un regolamento parlamentare costituzionalmente illegittima non può essere invalidata, infatti anche la Corte cost. con sent. 78/84 ha dichiarato l'autonomia del parlamento e dunque la sottrazione ad ogni organo dello stato sulle procedure (votazione, convocazione dell'assemblea; ecc.) sulle quali, avendo i regolamenti una riserva di legge assoluta, non è possibile operare alcun controllo. Nemmeno i pianisti, cioè deputati che votano per se stessi ed altri, possono essere perseguiti, se non all'interno dell'organo camerale stesso. Le votazioni sono **palesi o segrete**. Le prime avvengono per alzata di mano, per divisione (da una parte i favorevoli,dall'altra i contrari) per procedimento elettronico, (con registrazione dei nomi),per appello nominale (si, no, astenuto): quest'ultima forma di votazione è sempre richiesta per revocare o concedere la fiducia al Governo ai sensi dell'art.94 comma II Cost.,e alla Camera per il voto sulla questione di fiducia.
Le votazioni segrete possono invece avvenire: per schede (quando si elegge per es.il Presidente della Repubblica, i 5 membri della Corte cost.ecc.); a scrutinio segreto

This document is available free of charge on StuDocu.com

(mediante il sistema della pallina,bianca nell'urna bianca e nera nell'urna nera). La votazione segreta ha luogo normalmente,secondo i nuovi regolamenti,con procedimento elettronico utilizzando dispositivi che garantiscono la segretezza del voto. Il voto segreto offre il vantaggio di consentire la libera espressione della propria volontà da parte del votante;di contro si sostiene che la segretezza del voto offre l'opportunità di sottrarsi alla rigida disciplina di partito,mentre il voto palese sarebbe in ogni caso un elemento di chiarezza e di moralizzazione della vita politica. Le Camere non possono generalmente discutere o deliberare su materie che non siano **all'ordine del giorno** (reso noto con almeno un giorno di preavviso) e ciò in ossequio ad una regola democratica,secondo la quale bisogna conoscere gli argomenti sui quali bisogna deliberare per evitare decisioni di sorpresa. Le camere dovrebbero organizzare i propri lavori secondo il metodo della **programmazione dei lavori**, con un calendario per 3 mesi alla Camera e per 2 mesi al Senato. Il programma e il calendario dei lavori dovrebbero essere predisposti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari e votati all'unanimità (secondo i regolamenti del'71), in modo tale da rendere le minoranze compartecipi all'approvazione di atti così rilevanti per le loro evidenti implicazioni politiche. Tuttavia,in un'assemblea politicamente non omogenea, quest' unanimità risulta difficile da raggiungere, e infatti raramente la si è raggiunta, per cui il metodo della programmazione non ha dato buon esito: e infatti nel 1997 la Camera dei deputati ha sostituito l'unanimità con la maggioranza dei 3/4. Se non si raggiunge tale maggioranza, sarà il Presidente della Camera, secondo le indicazioni del Governo, a dare il programma dei lavori, inserendo anche le proposte di minoranza per 1/5 degli argomenti trattati. In caso di ulteriore scontro, il Presidente fissa per i 2 giorni successivi gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Al Senato è stato invece predisposto, in tal caso, uno schema settimanale di lavori, redatto dal Presidente sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza dei presidenti dei capigruppo parlamentari. L'ordine del giorno sarà poi formulato sulla base di tale schema.

25. Gli interna corporis - Con essi si intendono tutti gli atti e le attività compiuti all'interno delle Camere. La loro sindacabilità è esclusa sulla base della speciale indipendenza di cui le Camere dispongono. Pertanto non solo sindacabili ad es. il modo in cui è stata determinata la maggioranza, il modo o l'esito delle votazioni ecc.,che sono quindi sottratte(come le norme dei regolamenti parlamentari) al sindacato della Corte cost. La Corte stessa ha però affermato la sua competenza tutte le volte in cui si tratti di accertare l'osservanza delle norme costituzionali sul procedimento di formazione della legge. In particolare la Corte ha deciso (sent. 9/59) che spetta ad essa accertare se il testo di legge che il Presidente di una Camera nel suo messaggio di trasmissione all'altra Camera, sia effettivamente conforme a quello approvato dalla Camera stessa. La corte ha affermato che l'autonomia e l'indipendenza delle Camere copre tutte le attività poste in essere dai parlamentari stessi e riconducibili a fattispecie disciplinate dai regolamenti parlamentari, e

impedisce che i comportamenti siano presi in considerazione anche alla luce di altre norme giuridiche. (sent. 379/96).

26. L'ostruzionismo- Per ostruzionismo si intende l'uso esasperato degli strumenti procedurali a disposizione dei parlamentari, al fine di ritardare, ostacolare o impedire la formazione della volontà camerale. Da questo tipo di ostruzionismo, che è definito **tecnico** e che è sempre lecito entro certi limiti, va distinto l'ostruzionismo cosiddetto **fisico**,vale a dire quello che si manifesta mediante la violenza e che è ovviamente illecito. Dell'ostruzionismo tecnico si avvale generalmente l'opposizione per tentare di impedire che le scelte politiche della maggioranza si traducano in provvedimenti concreti. Esso viene posto in essere con la presentazione di valanghe di emendamenti, con la richiesta di verifica del numero legale, con discorsi in aula protratti per ore ed ore, con il far venir meno il numero legale abbandonando l'aula ecc. I regolamenti delle Camere prevedono vari rimedi contro l'ostruzionismo,che vanno dal contingentamento dei termini della discussione,alla votazione riassuntiva o per principi degli emendamenti,alla presentazione della questione di fiducia da parte del Governo,che determina l'automatica decadenza di tutti gli emendamenti.
Ci si è chiesti a questo punto, se l'ostruzionismo rientri o meno nelle regole del gioco democratico:anche in questo caso,la risposta al quesito non può essere data in astratto. Certamente l'ostruzionismo è legittimo quando rappresenta l'ultima spiaggia per combattere contro misure liberticide proposte dalla maggioranza:l'ostruzionismo è quindi lecito laddove si configuri come una sorta di "diritto di resistenza" contro gli abusi della maggioranza e come sintomo di un distacco del Paese reale dal Paese legale. Non è ,invece, certamente lecito quando viene condotto per fini di parte che nulla hanno a che vedere con la difesa e la salvaguardia dei principi costituzionali.
Accanto all'ostruzionismo di minoranza esiste anche un ostruzionismo di maggioranza che si è messo in atto nel nostro Parlamento nei periodi di immobilismo nell'attuazione della Costituzione da parte delle forze di Governo. Il fenomeno è stato denunciato da Calamandrei in uno scritto del '53,e ha consistito nella deliberata volontà della maggioranza a non dare attuazione ai punti più qualificanti del proprio programma di governo.

SEZIONE IV- LA FUNZIONE LEGISLATIVA DELLE CAMERE

Per il principio della separazione dei poteri, spetta alle Camere (oltre che ai Consigli regionali) il potere di legiferare, ossia di emanare le norme costitutive dell'ordinamento giuridico dello Stato complessivamente inteso. Anche il Governo può porre in essere atti contenenti norme giuridiche (decreti legislativi, decreti-legge, regolamenti), mentre a loro volta le Camere svolgono attività e funzioni che,per i contenuti e le procedure seguite,non possono essere ricondotte nell'ambito della funzione legislativa.
Le norme giuridiche poste in essere dalle Camere sono dette **leggi formali**, atti che assumono una particolare efficacia, consistente nell' idoneità di innovare l'ordine legislativo preesistente, sia integrandolo con nuove norme e sia modificandolo con

This document is available free of charge on StuDocu.com

l'abrogazione di leggi precedentemente emanate da parte di leggi successive disciplinanti la stessa materia. L'efficacia della legge formale può quindi spiegarsi o attivamente,nel senso di una "prevalenza" della legge sugli altri atti ad essa gerarchicamente subordinati, o passivamente, nel senso della "resistenza" della legge agli atti gerarchicamente subordinati che si pongano in contrasto con essa. L'efficacia viene allora detta **forza di legge**, che si distingue dal *valore di legge,* che è invece dato dal particolare regime giuridico della legge e degli atti ad essa equiparati, consistente nella loro sottoposizione al solo sindacato di legittimità della Corte costituzionale.

27. Il procedimento di formazione della legge ordinaria: a) l'iniziativa legislativa- La legge formale è un *atto complesso eguale*, alla cui formazione cioè partecipano in posizione di parità le due Camere mediante una manifestazione di volontà che si concreta nell'approvazione del medesimo testo (art. 70 cost. "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere".) Il procedimento di formazione consta di 3 fasi: iniziativa legislativa (fase introduttiva); approvazione delle Camere (fase costitutiva); promulgazione e pubblicazione (fase integrativa dell'efficacia). L'iniziativa legislativa, che consiste nella presentazione del progetto di legge ad una delle due Camere, è attribuita: -al Governo; -ai singoli membri delle Camere; -al popolo; - al CNEL; -ai Consigli Regionali. L'iniziativa governativa è la più rilevante, sia perché il Governo è l'organo meglio in grado d valutare, direttamente e attraverso le amministrazioni periferiche ad esso strutturalmente collegate, l'opportunità o la necessità di interventi nei vari campi della vita nazionale, e sia perché ad esso fa capo l'iniziativa della legge di bilancio e della legge finanziaria, oltre che in materia di rapporti internazionali e comunitari. I progetti di legge di iniziativa governativa (che assumono più tecnicamente il nome di **disegni di legge**) hanno maggiori probabilità di essere approvati, dal momento che, di regola, il Governo può contare sul voto favorevole della maggioranza dei parlamentari (della quale è appunto espressione). E'evidente invece che un Governo che goda dell'appoggio di una maggioranza non sufficientemente omogenea potrebbe incontrare difficoltà nel portare a compimento la sua linea di politica legislativa. In tal caso,esso si vede costretto a difendere in Parlamento i suoi disegni di legge mediante una serie di patteggiamenti non soltanto con le forze dell'opposizione,ma anche,talvolta,con alcuni partiti che compongono la maggioranza, e ad accogliere di conseguenza gli emendamenti proposti o a porre la questione di fiducia sull'approvazione delle disposizioni che ritiene essenziali. Per consentire al governo di attuare,entro i congrui limiti di tempo,il programma che intende perseguire,si è da più parti proposto di inserire nei regolamenti parlamentari nome idonee a sveltire il procedimento di formazione delle leggi di cui ha assunto l'iniziativa (la cosiddetta "corsia preferenziale"). Questo risultato è stato almeno in parte raggiunto: i regolamenti parlamentari infatti fissano un termine entro il quale deve essere compiuto l'esame di alcuni disegni di legge d'iniziativa governativa(bilancio,legge finanziaria,conversione dei decreti legge), e dispongono che il programma dei lavori venga redatto tenuto conto delle priorità indicate dal Governo. L'iniziativa governativa si esercita con l'approvazione da parte del

Consiglio dei Ministri di un disegno di legge,per la cui presentazione alle Camere è però necessario un decreto di autorizzazione del Presidente della Repubblica. L'iniziativa parlamentare viene invece esercitata da singoli membri delle Camere,che presentano una proposta di legge alla Camera di appartenenza. L'iniziativa popolare è esercitata mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli: si tratta,insieme a *referendum e petizione*,di uno dei tradizionali istituti della democrazia diretta,che ha trovato attuazione negli art.48 e 49 della legge n.352 del 25 maggio 1970,a norma dei quali la proposta,accompagnata da una relazione che ne illustri la finalità e le norme,deve essere presentata al Presidente di una delle due Camere. L'iniziativa del CNEL,con la nuova organizzazione dell'organo a seguito della riforma dell'86,non trova particolari difficoltà. Sembra tuttavia che,in virtù della composizione dell'organo e delle funzioni ad esso attribuite,l'iniziativa possa essere presentata soltanto nel campo economico- sociale. L'iniziativa dei Consigli regionali è esercitata invece dai singoli Consigli regionali o da più Consigli congiuntamente,e deve avere per oggetto materie che interessano la Regione. Non è da escludersi che una o più Regioni possa o possano formulare e presentino alle Camere proposte di legge che riguardano i loro rapporti con lo Stato(ad es.,le cosiddette "*leggi cornice*"),o meglio un settore dell'attività statale che attiene all'indirizzo politico da adottare nei confronti delle Regioni. In ogni caso,queste ultime non si sono sempre attenute al criterio restrittivo che vorrebbe limitato il loro potere di iniziativa legislativa alle sole materie di diretto interesse regionale. Per questo si diceva della difficoltà di individuare e circoscrivere l'ambito di tale interesse: potrebbe soccorre a riguardo la nozione autonomia politica,e la formale ripartizione delle competenze ai sensi dell'art.117 Cost. e degli Statuti speciali. Un altro tipo di iniziativa legislativa è quella attribuita dall'art.133 Cost. ai Comuni che vogliano promuovere il mutamento delle circoscrizioni provinciali o l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione. Le modalità di esercizio di questo tipo d'iniziativa trovano disciplina nell'art.21 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. Si parla di iniziativa "*vincolata*" o di iniziativa "*riservata*" (Spagna Musso); la prima si ha quando la presentazione di una proposta di legge alle Camere non ha carattere facoltativo,ma obbligatorio,come ad es. nel caso della legge di bilancio,che deve obbligatoriamente essere presentata ogni anno dal Governo ai sensi dell'art.81 Cost.; la seconda si ha quando il potere d'iniziativa è esercitato da un solo soggetto (così ad es. per i rapporti tra Stato e le confessioni acattoliche (art. 8 Cost.), che è riservata in via esclusiva al Governo,unico e solo organo che è in grado di avviare e concludere le intese con le rappresentanze di queste confessioni. La Costituzione o le leggi ordinarie possono anche prescrivere che l'iniziativa venga assunta soltanto dopo che siano stati emessi determinati pareri o raggiunti raccordi o intese. Si può pensare a questo proposito all'iniziativa di legge per la modifica dei Patti lateranensi,che ai sensi dell'art.7 Cost. deve essere preceduta dall'accordo con la Santa Sede; alle intese che stanno alla base della legge regolatrice dei rapporti fra Stato e le altre confessioni acattoliche; ancora,l'art.132 comma II Cost. richiede che la presentazione della proposta di legge per il distacco di una

This document is available free of charge on StuDocu.com

Provincia o di un Comune da una Regione e la loro aggregazione ad un'altra,sia preceduta dalla richiesta degli enti interessati,dal parere dei Consigli regionali e da un referendum. I regolamenti parlamentari infine(art.72 comma II R.C.D. e art.76 R.S.)dispongono che non possono essere assegnati alle commissioni i progetti di legge che riproducono sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi 6 mesi dalla data della reieizione.

28: b)l'approvazione delle Camere: il procedimento ordinario- L'approvazione di un progetto di legge può avvenire secondo tre procedimenti distinti: **ordinario; decentrato** (o per commissioni); **misto**. **Il procedimento ordinario:**Secondo quanto disposto dall'art. 72 comma 1 Cost., il progetto di legge viene preliminarmente esaminato e discusso da una commissione competente nella materia alla quale il progetto si riferisce(e che in questo caso si dice quindi convocata "*in sede referente*"). La commissione non si limita a svolgere una funzione istruttoria del progetto in esame, ma anzi può proporre anche modifiche al testo originario e redigere un testo unico qualora vengano presentati più progetti di legge su un medesimo oggetto. Esaurito l'esame preliminare,la commissione trasmette all'Assemblea il progetto di legge, accompagnandolo con una o più relazioni (le relazioni saranno più di una nel caso in cui anche le minoranze ritengano di dover redigere una loro relazione). Quindi il progetto di legge viene discusso nelle sue linee generali al fine di accertare se l'Assemblea sia o meno favorevole allo stesso. La discussione generale si chiude con la presentazione e la votazione di ordini del giorno(alla Camera sono ammessi soltanto ordini del giorno di non passaggio agli articoli e non,come al Senato,anche sul contenuto del progetto); soltanto nel caso in cui l'Assemblea si sia dimostrata favorevole al progetto si passa alla discussione e all'approvazione dello stesso articolo per articolo(e degli eventuali emendamenti e sub-emendamenti che siano stati presentati). Qualora invece venga approvato un ordine del giorno di non passaggio agli articoli,il procedimento si arresta. Approvati tutti gli articoli,si sottopone il progetto nel suo complesso alla votazione finale,per la quale è richiesto lo scrutinio palese(salvo che sia prescritto o richiesto lo scrutinio segreto). La votazione finale del progetto di legge nel suo complesso appare necessaria,in specie laddove si considera sia che i vari articoli potrebbero essere stati approvati da maggioranze diverse e sia che potrebbero essere stati approvati con emendamenti anche sostanziali,per cui il significato politico iniziale del progetto nell'un caso ed il suo contenuto nell'altro risulterebbero mutati.
Il procedimento ordinario deve essere sempre adottato(a norma dell'art.72 Cost. IV comma): - per i disegni di legge i materia costituzionale ed elettorale; -per quelli di delegazione legislativa; -di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; -di approvazione di bilanci e consuntivi; -per i disegni di legge di conversione di decreti-legge; -per i disegni di legge rinviati alle Camere per una nuova deliberazione dal Presidente della Repubblica. Si tratta delle **riserve di legge di assemblea.** Per quanto riguarda le ragioni che hanno indotto il Costituente a riservare all'intera Assemblea l'esame e l'approvazione di determinati progetti di legge, si deve anzitutto ricordare che l'art.75 comma II Cost. esclude dall'abrogazione mediante referendum,fra le

altre,le leggi di bilancio e le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Esiste pertanto una materia,appunto quella relativa al bilancio e ai trattati internazionali,che possiamo definire "*legislativamente privilegiata*",in quanto i disegni di legge che la riguardano non possono essere esaminati e approvati con un procedimento diverso da quello ordinario, e le seconde non possono essere abrogate mediante referendum. La ratio che accomuna questi due divieti risiede nel fatto che,trattandosi di materia attinente all'indirizzo politico sia nell'uno che nell'altro caso,si è voluto che l'esame e l'approvazione delle leggi relative avvenisse ad opera dell'intera Assemblea,il più possibile coralmente,mediante il procedimento ordinario che oltre ad offrire le più ampie garanzie alle minoranze,è la sola che consente la partecipazione di tutti i parlamentari al procedimento legislativo; e ciò in ragione dell'incidenza di queste materie sull'indirizzo politico. Il concetto di "materia costituzionale" cui si riferisce l'art.72 comma IV è tutt'oggi di difficile determinazione. In una prima approssimazione si potrebbe ritenere che materia costituzionale sia quella relativa all'attuazione della Costituzione, oppure, più in particolare,quella che riguarda ad esempio l'indirizzo politico generale o gli elementi costitutivi dello Stato. L'unico criterio certo fino ad ora è quello che è stato adottato dalla Corte che nella sent.168 del 1963 ha statuito che le leggi in materia costituzionale non differiscono dalle leggi di revisione costituzionale o dalle altre leggi costituzionali menzionate nell'art.138 Cost.;ne deriva che le Camere possono approvare in commissione tutte le leggi che non rientrino fra quelle espressamente elencate nell'art.72 comma IV. In tal modo però viene fatta anche cadere la riserva di legge dell'Assemblea per quei progetti di legge che,anche se non espressamente modificativi della Costituzione,certamente vertono in materia costituzionale. Leggi in materia costituzionale sono anche infatti quelle che disciplinano ad esempio la costituzione e il funzionamento del CSM o della Corte costituzionale. L'art.72 comma IV Cost. dispone che i regolamenti camerali possono stabilire procedimenti **abbreviati** per i loro progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. In realtà non si tratta di un procedimento distinto da quello ordinario,ma soltanto di una riduzione dei suoi termini interni. Sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza(sollevata alla Camera: da parte del Governo, di un presidente di un gruppo o di 10 deputati; al Senato: da parte del proponente, del presidente della commissione competente o di 8 senatori), l'Assemblea delibera per alzata di mano. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta al Senato la riduzione dei termini alla metà; mentre il regolamento della Camera dispone la riduzione volta per volta(ad esempio l'art.81 riduce alla metà il termine per la presentazione delle relazioni all'Assemblea).

29. b) il procedimento decentrato- La peculiarità di questo procedimento consiste in ciò che le commissioni legislative non si limitano(come nel procedimento ordinario)ad esaminare il progetto di legge ma lo **approvano** anche. Per questo esso viene definito **decentrato**, perché appunto non si svolge innanzi all'intera Assemblea(o "in aula",come si dice in gergo),bensì in sede decentrata,vale a dire innanzi alla commissione legislativa competente per materia:in questo caso si dice che la commissione svolge i suoi lavori **in sede deliberante**. L'assegnazione del

This document is available free of charge on StuDocu.com

progetto alla commissione in sede deliberante viene proposta alla Camera(qualora ricorrano determinate condizioni)dal suo Presidente e dev'essere approvata dall'Assemblea,mentre al Senato è decisa dal Presidente che ne da comunicazione all'Assemblea. Il procedimento decentrato(o come è stato pure definito, "*per commissioni*"),è proprio soltanto del nostro ordinamento e di quello spagnolo,ed è stato introdotto storicamente per la prima volta in Italia dalla legge del 1939 che sopprimeva la Camera dei deputati e istituiva in sua vece la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Un procedimento che affida a commissioni ristrette l'approvazione dei progetti di legge vale a sveltire e di molto l'iter legislativo(ma non sembra sia stata questa la ragione della sua prima istituzione,quanto piuttosto quella di depotenziare la funzione legislativa delle due Camere,che erano chiamate soltanto a "collaborare"con il Governo per la formazione delle leggi). Il sistema però non ha dato buon esito,perché si è spesso e volentieri prestato ad abusi:risulta infatti che la maggior parte delle leggi approvate in commissioni siano settoriali o singolari(c.d."Leggine")e non di interesse generale; e ciò si spiega facilmente,laddove si considera che queste leggi hanno maggiori probabilità di essere approvate in commissione,dove (per il ridotto numero dei componenti) è più facile raggiungere il compromesso fra maggioranza e opposizione,anziché in Assemblea. In tempi recenti tuttavia,la prassi della delega legislativa concessa su sempre più vasti settori ha determinato un minor ricorso al procedimento decentrato. Solo nel 1971 la Camera dei deputati(e non anche il Senato)ha adottato un criterio direttivo di massima per tale assegnazione,disponendo all'art.92 del suo regolamento che il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea che un progetto di legge venga deferito alla commissione in sede deliberante quando riguarda "…questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale". La formula adottata si presta ad un'interpretazione restrittiva:la concreta applicazione della norma avrebbe potuto porre un freno all'approvazione in commissione delle "leggine"(nelle quali non si riscontra alcuna "rilevanza di ordine generale"),ma la norma è rimasta in buona parte inapplicata. L'altra garanzia,consistente nel potere attribuito al Governo; ad 1/10 dei componenti la Camera o ad 1/5 della commissione di richiedere che il progetto di legge venga rimesso alla Camera non ha evidentemente dato buon esito allo stesso modo,dal momento che il Governo e le minoranze hanno rare volte richiesto la rimessione alla Camera,preferendo che il procedimento si svolgesse e si esaurisse in commissione per le ragioni sopra dette.
E' da ricordare che a norma dell'art.72 comma IV Cost. il procedimento decentrato non può essere adottato per i: -progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale; -per quelli di delegazione legislativa; -di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; -di approvazioni di bilanci e consuntivi. (Alcuni hanno aggiunto a questi progetti di legge anche i regolamenti parlamentari).

30. Il procedimento misto- Oltre che in sede referente(ordinario) e in sede deliberante(decentrato),le commissioni possono svolgere i loro lavori anche **in sede redigente**(misto).Il procedimento consiste in una ripartizione del lavoro legislativo fra la commissione e l'Assemblea. Secondo l'art. 96 R.C.D., l'Assemblea può,prima

di passare all'esame degli articoli,decidere di deferire alla commissione competente (permanente o temporanea) la formulazione,entro un termine determinato,degli articoli di un progetto di legge e riservare per sé medesima l'approvazione dei medesimi articoli nonché l'approvazione finale del progetto di legge. Più spedita la disciplina prevista per il Senato,laddove il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alla commissioni (permanenti o temporanee), progetti di legge per la deliberazione dei singoli articoli,riservando all'Assemblea la votazione finale. Tale procedimento risulta sempre meno utilizzato.

31. Alcune considerazioni sulla fase costitutiva- Le Camere devono approvare il testo di legge in unico documento: ciò significa che se una Camera approva il testo e l'altra lo emenda, il testo dovrà tornare all'altra Camera che lo riesaminerà e se la stessa apporterà modifiche ulteriori dovrà ancora una volta ripassare all'altra Camera, e così di seguito il progetto passerà da un'Assemblea all'altra (la c.d. "navetta")fino a quando sarà raggiunto l'accordo. I Presidenti delle Camere possono disporre che su un progetto di legge assegnato ad una commissione si pronunci un'altra commissione. In particolare,alla Camera è obbligatorio il parere della commissione bilancio, tesoro e programmazione se un progetto di legge implica nuove entrate o spese, mentre la commissione affari costituzionali, su richiesta del Presidente, esprime pareri sulla legittimità costituzionale (c.d. "commissioni filtro"). I pareri delle commissioni sono vincolanti se si è in sede deliberante. Al Senato è obbligatorio il parere della Commissioni Politiche dell'Unione Europea, per i progetti di leggi concernenti l'applicazione del Trattato sull'Unione Europea o relativi all'attuazione di norme comunitarie, e della commissione affari costituzionali per i progetti di legge di rilevanza costituzionale. Altri pareri obbligatori sono quelli della commissione programmazione economica e bilancio per i progetti di legge in materia finanziaria e della commissione giustizia per i progetti di legge che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative. E' tacito che il procedimento di formazione adottato da una Camera non vincola anche l'altra (cosicchè,ad esempio,una Camera può approvare un progetto di legge secondo il procedimento ordinario e l'altra secondo il procedimento decentrato).

32. c)la promulgazione- La legge approvata dalle due Camere viene trasmessa dal Presidente della Camera che l'ha approvata per ultima al Presidente della Repubblica per la promulgazione. La promulgazione costituisce assieme alla pubblicazione l'ultima fase del procedimento di formazione della legge, quella integrativa dell'efficacia. (La promulgazione si distingue dalla *sanzione regia* attribuita al re dallo Statuto albertino, che si concreta in una vera e propria approvazione regia della proposta di legge,di modo che la legge non era perfetta se non riceveva l'approvazione,oltre che delle due Camere,anche del re,che costituiva quindi un terzo organo legislativo. La promulgazione invece non attiene alla fase dell'approvazione ma appunto all'integrazione dell'efficacia.) La promulgazione delle leggi deve avvenire entro un mese dall'approvazione(salvo che in caso di urgenza le Camere non dispongano un termine inferiore) e consiste in un decreto del Presidente della

This document is available free of charge on StuDocu.com

Repubblica,con il quale egli: 1) attesta che la legge è stata approvata dalle due Camere; 2) dichiara la sua volontà di promulgare la legge; 3) ordina la pubblicazione della legge e vi appone la clausola esecutiva (E' fatto obbligo a chiunque di osservarla). Il Presidente della Repubblica non è tenuto a promulgare la legge se vi trova elementi di incostituzionalità formali o sostanziali (art. 74 cost.). Avvalendosi del potere conferitogli dalla Costituzione all'art.74,egli può infatti rinviare la legge alle Camere entro lo stesso termine previsto per la promulgazione,accompagnandola con un messaggio nel quale esporrà i motivi per cui ha ritenuto di non dover pubblicare(**decreto motivato**),e chiedere una nuova deliberazione. Il Presidente può addurre a base del rinvio della legge alle Camere motivi relativi sia alla legittimità formale della legge(quando cioè il suo procedimento di formazione non sia stato quello previsto nella Costituzione) sia alla legittimità sostanziale(quando la norma contenuta nella legge sia in contrasto con una norma contenuta nella Costituzione),o ancora motivi relativi al merito costituzionale(che non dovrebbero peraltro implicare una valutazione strettamente politica della legge da parte del Presidente della Repubblica,che non è organo di indirizzo politico bensì di garanzia,e quindi presuppone una valutazione obiettiva del contenuto della stessa:come quando ad esempio la legge non risulti più adeguata alla situazione cui intendeva provvedere per il suo lungo procedimento di formazione,o quando,pur non violando direttamente ed espressamente la Costituzione,è palesemente contraria allo spirito di essa). Con il rinvio della legge alle Camere,il Presidente esercita di fatto sulla stessa un controllo che è di **legittimità costituzionale** formale o sostanziale(è da notare che la maggior parte dei rinvii hanno fino ad ora avuto per oggetto leggi che in violazione dell'art.81 IV comma,pur importando nuove o maggiori spese non avevano indicato i mezzi per farvi fronte. Ad ogni modo,il controllo svolto mediante il rinvio si risolve in un atto che non ha valore definitivo e decisivo(cioè non serve ad impedire l'entrata in vigore della legge),giacchè le Camere sono assolutamente libere di accogliere o meno i rilievi presidenziali. Pertanto,se le Camere dovessero riapprovare la legge nel medesimo testo,senza cioè modificarla o eliminando i vizi denunciati nel messaggio presidenziali,il Presidente dovrà promulgarla(art.74 Cost.,cosiddetto "*veto sospensivo*"),di modo che fra la valutazione del Presidente e quella delle Camere finisce col prevalere quest'ultima. Può però accadere che la legge integri gli estremi di attentato alla Costituzione,per cui il Presidente della Repubblica (e questa è ipotesi di scuola) può rifiutarsi una seconda volta di promulgare la legge. Un caso importante di rinvio presidenziale è quello effettuato dal Presidente Ciampi nel 2003 della legge sul riordino del sistema radiotelevisivo e della RAI (legge Gasparri). Il Presidente Napolitano ha fatto ricorso al rinvio una sola volta nel suo prima mandato, nel 2010.

33. La pubblicazione della legge-La pubblicazione della legge avviene ad opera e sotto la responsabilità del Ministero di grazia(guardasigilli),o meglio del ministro della giustizia,e consiste tecnicamente nella inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale; queste operazioni sono precedute dall'apposizione, da parte del ministro, del visto, che attesta la regolarità formale dell'atto, e del "gran

sigillo di Stato", che vale come autenticazione. L'inserzione nella Raccolta è disposta in funzione della certezza del diritto,giacchè il testo che entra in vigore è quello in essa inserito, mentre la pubblicazione nella Gazzetta vale solo ai fini della conoscenza e realizza dunque una forma di pubblicità-notizia. In caso di difformità fra il testo inserito nella Raccolta e quello pubblicato sulla Gazzetta si fa fede al documento originale che risulta dall'atto autentico rilasciato dal ministro guardasigilli. Alla pubblicazione si deve provvedere subito dopo la promulgazione(art.73 Cost.) o comunque non oltre 30 giorni da essa:la legge entra in vigore(e diviene quindi obbligatoria per tutti i soggetti ai quali è indirizzata) nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale(VACATIO LEGIS),a meno che la legge stessa non indichi un termine minore o maggiore. Pubblicata la legge nella Gazzetta Ufficiale e decorso il termine di vacatio,sorge la presunzione assoluta che tutti i suoi destinatati la conoscano,per cui essi sono tenuti ad osservarla e non possono invocare a loro scusante il fatto di non aver preso visione del testo ("IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT"). Il rigore di tale principio è stato tuttavia notevolmente attenuato dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 364/88, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 cod. pen. "…nella parte in cui non esclude l'ignoranza inevitabile".La Corte nella sua complessa decisione,partendo dall'esame del combinato disposto del I e del III comma dell'art.27 della Costituzionale (e facendo riferimento anche agli art. 2,3,73, comma 3, e 25,comma2), ha osservato che l'art. 5 cod. pen. viola lo spirito stessa della carta costituzionale e dei suoi principi fondamentali sottoponendo il soggetto alla sanzione più grave senza alcuna prova della sua consapevole ribellione o indifferenza all'ordinamento tutto,il che equivale a scardinare le garanzie fondamentali che lo Stato democratico offre al cittadino. Se la pubblicazione della legge costituisce un atto diretto a dare "comunicazione" della stessa ai cittadini per renderne possibile la conoscenza e quindi consentirne la generale osservanza, la promulgazione attribuisce immediata efficacia,o **esecutorietà** all'atto normativo(che si differenzia dall'*obbligatorietà erga omnes* conseguente invece alla pubblicazione). La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della Raccolta ufficiale.

34. Il procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali- In virtù della rigidità della nostra Costituzione, le disposizioni della stessa non possono essere integrate,modificate o abrogate se non in virtù di una procedura particolare,che si dice per l'appunto aggravata rispetto al procedimento previsto per le leggi ordinarie. Tale procedura ha in comune con quella diretta alla formazione delle leggi ordinarie la fase dell'iniziativa e,con alcune modifiche nella formulazione,la fase della promulgazione e della pubblicazione,e ne differisce invece sostanzialmente per quanto attiene alla fase dell'approvazione. A norma dell'art.138 infatti,che disciplina la procedura,"le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione". Rispetto alla

This document is available free of charge on StuDocu.com

procedura ordinaria,si possono notare le seguenti differenze: i progetti di legge costituzionale devono essere deliberati due volte da parte di ciascuna Camera e fra la prima e la seconda deliberazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre mesi. Si è voluto,in tal modo,far si che le Camere esaminino le leggi costituzionali(data la loro maggiore rilevanza rispetto alle leggi ordinarie)con una più compiuta attenzione; il progetto di legge costituzionale deve essere approvato,nella seconda votazione,dalla maggioranza assoluta(o qualificata) dei componenti di ciascuna Camera(=la metà dei componenti di ciascuna camera + 1)e non dalla maggioranza semplice(=la metà dei presenti+1) sufficiente invece per l'approvazione delle leggi ordinarie. Ci si è chiesti in passato,in mancanza di una precisa indicazione costituzionale,se la doppia deliberazione dovesse avvenire in forma consecutiva(due volte in una Camera e due volte nell'altra)o alternativa(una prima volta nell'una e nell'altra e successivamente,trascorsi tre mesi,una seconda volta,sempre nell'una e nell'altra Camera).I regolamenti della Camera(1957)e del Senato(1958)avevano accolto la procedura alternativa,confermata poi nei regolamenti del '71,a norma dei quali,dopo la prima deliberazione,il progetto di legge viene trasmesso all'altra Camera. I regolamenti aggiungono che ai fini della seconda deliberazione,la commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e dopo la discussione sulle linee generali,si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. In questa seconda fase quindi,non sono ammessi emendamenti al testo di legge. L'aggravamento della procedura non si esaurisce nella doppia deliberazione del progetto di legge costituzionale da parte delle Camere e nella maggioranza assoluta per la seconda approvazione. Il progetto di legge costituzionale infatti non si trasforma in legge ma resta allo stato di progetto; come tale,viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale al solo fine di far conoscere il suo contenuto e di iniziare a far decorrere il termine(3 mesi)entro il quale -500.000 elettori, -1/5 dei membri di ciascuna Camera o 5 Consigli regionali potranno richiedere che il progetto di revisione costituzionale o di legge costituzionale sia sottoposto a referendum popolare(come previsto dal II comma dell'art.138). Il referendum viene indetto con decreto del Presidente della Repubblica ed il progetto sul quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi si intende approvato se ottiene la maggioranza dei voti validi,esclusi cioè i voti nulli e le schede bianche. Se questa maggioranza non viene raggiunta,il progetto è respinto. Bisogna tuttavia precisare che il referendum rappresenta una fase soltanto eventuale del procedimento aggravato,e non obbligatorio. Pertanto,i tre mesi potranno decorrere senza che esso venga richiesto. In tal caso,il progetto si intende ***tacitamente approvato*** dal corpo elettorale,che pur avendone il potere legittimo non ha richiesto il referendum. Il progetto di revisione o di altra legge costituzionale ***espressamente*** (mediante il referendum) o ***tacitamente approvato*** diventa automaticamente legge che viene quindi promulgata dal Presidente della Repubblica nelle forme dovute. Di contro,qualora il referendum abbia esito negativo,esso assume il valore di un'opposizione popolare al progetto di legge,impedendo così l'entrata in vigore della stessa. (Il 25 e il 26 giugno 2006 si è svolto un referendum costituzionale ai sensi dell'art.138,comma II Cost.,avente per oggetto la riforma della seconda parte della

Costituzione approvata dal Parlamento nella XIV legislatura. Ha preso parte al voto il 53,6% degli aventi diritto e si è espresso per il NO il 61,7% dei votanti. Il progetto di legge di revisione costituzionale è stato in tal modo respinto dal corpo elettorale). Qualora nella seconda deliberazione, il progetto venga approvato da ciascuna Camera a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti,esso si trasforma automaticamente in legge,che verrà promulgata e pubblicata. In tale ipotesi quindi non è prevista la possibilità di sottoporre a referendum il progetto,e ciò partendo dall'assunto che anche il corpo elettorale,i cui rappresentanti hanno dato con una percentuale molto alta voto favorevole al progetto,approvi la legge costituzionale. Il quorum strumentale (il numero di votanti) non è pregiudiziale alla validità del referendum, poiché questo tipo di procedimento, a differenza del referendum abrogativo(art.75 Cost.), non è finalizzato al perfezionamento ed al bilanciamento delle scelte del legislatore, ma si presenta piuttosto come uno strumento di garanzia delle minoranze e come tale ne verrebbe inficiato il valore qualora venisse richiesto un numero minimo di votanti(ma le leggi costituzionali 1 del '93 e 1 del '97 avevano stabilito,in deroga all'art.138,l'obbligatorietà del referendum popolare).La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale è disciplinata dal titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352. Fino al 1970, infatti, non era richiedibile il referendum costituzionale, essendo assente qualunque legge disciplinante tale istituto, e quindi fino ad allora per ogni revisione e legge costituzionale si è raggiunta in seconda delibera la maggioranza qualificata.
Il primo referendum costituzionale nella storia della Repubblica, che ha anche avuto esito positivo, è quello che ha portato all' approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha sancito una vasta ed organica riforma del titolo V parte seconda della Costituzione riguardante le autonomie locali. Il procedimento si dice quindi "aggravato" rispetto alla procedura prevista per le leggi ordinarie perché: richiede più tempo, vengono richieste maggioranze più elevate, prevede un'eventuale consultazione popolare tramite referendum(Il popolo viene tenuto ai margini del procedimento di revisione perché,così come stabilito dalla sentenza 740 del 2000 dalla Corte,si tratta di una procedura razionale: ossia volta alla depurazione dalle soggettività,dalle particolarità,dagli umori contingenti. Si tratta infatti di una scelta così importante da non poter essere affidata alle esigenze del momento). L'intero procedimento si svolge nelle due Camere,ed è quindi pubblico(si dice che le leggi di revisione costituzionale hanno *RISERVA DI ASSEMBLEA*,in quanto non possono essere votate dalle commissioni parlamentari in sede di prima lettura,ma unicamente dall'Assemblea);non così l'attività delle commissioni,di cui si redige un resoconto sommario e non stenografico(come per le riunioni dell'assemblea per la revisione).
L'art.138 entra in vigore,come la restante parte del testo della Costituzione,nel '48,quando valeva il sistema elettorale proporzionale:salvo che nelle elezioni del 18 aprile 1848,in cui la DC ottenne il 48,8% dei voti(la maggioranza assoluta)non è mai accaduto che un partito abbia raggiunto,da solo,la maggioranza qualificata. La maggioranza assoluta,che serve a ciò che i progetti di revisione costituzionale passino, coincide però con la maggioranza di governo: ogni governo può quindi,in realtà,revisionare la Costituzione con una certa facilità. Il problema si è posto ed è

This document is available free of charge on StuDocu.com

stato discusso solo a partire dal ’93(seconda repubblica) perché,in precedenza,era opinione condivisa che le leggi di revisione costituzionale venissero approvate dalla maggioranza e dall’opposizione insieme. Ciò significa che ogni governo può apportare modifiche anche piuttosto sostanziali alla Costituzione tramite revisioni,secondo quelle che sono le proprie linee e i propri fini politici. Tuttavia,appare chiara ed evidente la necessità di non poter lasciare la Costituzione in balia forze di governo contingenti: la Costituzione deve essere al di sopra delle esigenze politiche particolari del momento,in quanto fonte che si colloca sopra ogni altra e che si pone al vertice dell’intero ordinamento statale. Solo la Costituzione è espressione diretta ed immediata dell’atto costituente; non si tratta di un ordine cristallizzato,perfetto e immutabile(come si professava lo Statuto),ma si affida allo strumento della REVISIONE per aderire ai cambiamenti sociali e politici che intervengono in progressione di tempo; Il soggetto titolare della revisione costituzionale è il Parlamento;le due Camere non possono sostituire la Costituzione nella sua interezza né tantomeno determinarne l’eliminazione,devono anzi conservarne la struttura nonostante le modifiche che possono intervenire progressivamente tramite l’approvazione di leggi di revisione(la costituzione spagnola e svizzera prevedono invece la revisione totale della Costituzione); il soggetto titolare del potere costituente è invece l’Assemblea costituente. Sebbene l’art.72,comma IV,Cost.,parli comunemente di “leggi in materia costituzionale” bisogna anzitutto definire e chiarire cosa si intenda per *leggi di revisione cost. e le altre leggi costituzionali*. Adottando il criterio formale,leggi di revisione e altre leggi sono semplicemente quelle approvate con la procedura aggravata ex art.138 Cost. (come stabilito dalla sentenza 168 del ’63 della Corte costituzionale),e,come tali,sembrerebbero apparentemente la medesima cosa. Ma questo criterio non può soddisfare,proprio perché si tratta anzitutto di stabilire quando debba essere adottata la procedura aggravata;occorre dunque ricorrere al criterio sostanziale. Sotto quest’ottica, “leggi di revisione costituzionale” sono quelle che disciplinano la materia che ne forma oggetto in modo difforme da quello in cui la stessa trova disciplina nella Costituzione, o in altre leggi costituzionali. In questo caso quindi la modifica della Costituzione è palese:come tali,le leggi di revisioni,cambiano sia in senso formale che materiale il testo della Costituzione,apportandovi una revisione appunto,e vengono quindi ad essere incorporate al testo costituzionale stesso,sostituendo il vecchio testo. “Altre leggi costituzionali” sono innanzitutto quelle che la stessa Costituzione qualifica in tal senso(legge che conferisce il potere d’iniziativa legislativa ad altri organi o entri oltre a quelli menzionati dall’art.71; leggi con le quali sono stati adottati gli Statuti regionali speciali(art.116);legge che stabilisce le condizioni,le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte(art.137,comma I).Si tratta,in tutti questi casi,di leggi integrative del testo costituzionale,valgono cioè ad aggiungervi qualcosa. Ora,la scelta fra il procedimento ordinario richiesto per le leggi in materia costituzionale e il procedimento aggravato richiesto invece per le altre leggi costituzionali è solitamente demandata al Parlamento. (Ad ogni modo,generalmente,una legge che aggiunge competenze a quelle degli organi

costituzionali,deve essere adottata con la procedura aggravata.) La scelta dell'uno o dell'altro procedimento può anche dipendere da criteri politici più che giuridici,oltre che di opportunità(basti pensare che il procedimento ordinario è più spedito di quello aggravato e che invece,fino all'entrata in vigore della legge attuativa del referendum,per poter approvare una legge costituzionale era necessaria,in seconda deliberazione,la maggioranza dei due terzi).
Diversa dalla revisione costituzionale in senso stretto è la cosiddetta **rottura della Cost.**,che si ha quando una norma contenuta nel testo costituzionale si pone in contrasto con un'altra norma o con un principio contenuti nel medesimo testo. Nel nostro ordinamento,le rotture della Costituzione si trovano nelle disposizioni transitorie e finali (ad es.la XII disposizione,che in deroga all'art.49,che sancisce il diritto di tutti i cittadini ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale,vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista e in deroga all'art.48 demanda alla legge di stabilire,per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione,limitazioni temporanee al diritto di voto e all'eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista).
Una rottura(intesa come deroga)della Costituzione può rinvenirsi anche nell'art.68 che,in deroga al principio di eguaglianza formale(sancito dal I comma dell'art.3)prevede speciali garazie a favore dei cittadini eletti deputati o senatori.

35. I limiti alla revisione costituzionale- La legge di revisione può modificare la Costituzione,ma incontra precisi limiti, espressi o impliciti.
Non tutte le disposizioni costituzionali possono essere modificate,sia pure ricorrendo alla procedura aggravata(Half Ross:la norma che dispone la rigidità costituzionale è più rigida delle altre norme). Occorre in via preliminare osservare che la **rigidità** di una costituzione non si risolve affatto nella sua *immodificabilità*, giacchè l'assetto della società statale può subire nel corso del tempo(e di fatto subisce)delle evoluzioni che devono trovare rispondenza in omologhi mutamenti delle disposizioni costituzionali,se si suole che esse siano effettivamente vigenti. Pur essendo per sua stessa natura destinata a durare nel tempo quindi,la costituzione di uno Stato può subire delle modifiche espresse o tacite. Quanto alle prime,esse possono avvenire o per opera di un'assemblea appositamente eletta,o dalle due Camere riunite o con l'intervento del corpo elettorale(referendum)oppure ancora da parte degli stessi organi legislativi ordinari ma con procedure aggravate(come in Italia). Le seconde dipendono invece dal modo in cui alla costituzione viene data attuazione ad opera delle leggi ordinarie,delle consuetudini e delle convenzioni costituzionali,delle sentenze dei magistrati e della prassi costituzionale. Queste modifiche sono sempre legittime se contenute entro i limiti che le rendono compatibili con la rigidità della Costituzione;limiti che derivano da quella che è stata definita come **elasticità** o **duttilità** della costituzione, il cui testo si presta,per la generalità di alcune formule,per l'indeterminatezza e la plurivalenza di alcuni concetti,i cosiddetti "*concetti valvola*" e per gli stessi spazi vuoti in esso rinvenibili, ad essere interpretato ed attuato in modo non del tutto univoco da parte delle varie forze politiche che,di volta in volta,assumono il governo. La questione quindi non consiste tanto

This document is available free of charge on StuDocu.com

nell'ammettere la revisione come strumento attraverso cui viene meno,almeno in parte,la rigidità della Costituzione,quanto piuttosto nello stabilire il grado e la misura della revisione.
Esistono quindi limiti **assoluti** alla revisione costituzionale,sia espressi che impliciti. I limiti cosiddetti **impliciti**,immanenti all'interno del testo costituzionale, sono rappresentati da quelle norme-principio sulle quali si fonda e si identifica l'intero sistema costituzionale. Così costituisce un limite il principio democratico(contenuto nell'art.1)che contraddistingue l'intera nostra organizzazione costituzionale e statale;il principio secondo il quale il lavoro è posto a fondamento dello Stato;il principio dell'inviolabilità della persona umana,sancito dall'art.2;il principio di eguaglianza(art.3)sia formale che sostanziale;il principio di unicità e indivisibilità della Repubblica(art.5);il principio di libertà,che si riflette nei vari diritti della tutela e del rispetto delle minoranze,siano esse religiose,culturali,linguistiche,politiche,economiche etc. La norma-principio che racchiude tutti i principi elencati è contenuta nell'art.2,per il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità:in tal modo,viene asserito che il potere pubblico,nel momento stesso in cui sorge,trova già sul terreno questi diritti(esistenti in una sorta di "sfera meta-positiva")per cui si limita a riconoscerli sul piano delle garanzie costituzionali. La costituzione è quindi servente dei diritti dell'individuo,non se ne serve. Questi diritti,nel loro contenuto essenziale,non possono essere modificati o alterati tramite revisione(così come sancito dalla sentenza 1146 del 1988 della Corte: "La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale. […] Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale,quale la forma repubblicana(art.139),quanto i principi che,pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale,appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.") Il vero limite implicito che pertanto la revisione incontra consiste nel principio generale dell'INVIOLABILITA' DEI DIRITTI,che si concretizza in quei diritti particolari che vengono espressamente definiti "inviolabili"dalla Costituzione(art.13,diritto alla libertà personale;art.14,diritto al domicilio;art.15,diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza;art.24,diritto alla difesa personale) e anche in quei diritti che sono inviolabili,seppure non espressamente definiti tali nel testo costituzionale(diritto alla salute,al lavoro,libertà di coscienza,di religione,libertà personale,non solo come libertà fisica ma anche come libertà di pensiero,ai sensi dell'art.21,quindi come HABEAS MENTES). Per tutti questi principi vale il criterio della NON REGRESSIONE,per il quale queste forme di tutela non possono in alcun modo essere ridotte o abrogate. Se ciò avvenisse infatti verrebbe meno quella parte dell'ordinamento che su di esso si fonda. Non solo,ma il mutamento sarebbe da considerare come la conseguenza di un nuovo modo di intendere i rapporti sociali,di una nuova organizzazione,e dell'affermarsi di nuovi fini politici in seno alla società statale. Di modo che non avremmo una Costituzione

modificata,ma una nuova Costituzione.
Il limite **espresso** contenuto nell'art.139 ("La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale")è un limite assoluto(così come ha riconosciuto la Corte nella sentenza 1146) nel senso che la forma repubblicana dello Stato deve considerarsi intimamente connessa alla struttura della nostra società,ed al sistema costituzionale in cui essa ha trovato espressione. Un'eventuale restaurazione della monarchia potrà quindi avvenire non secondo un procedimento giuridico(attraverso quindi revisione)bensì soltanto attraverso un procedimento di fatto extragiuridico,rivoluzionario,extralegale. L'intangibilità delle norme-principio dipende dal radicamento delle stesse nel sistema e,in particolare,dalla persistenza nel tempo di questi valori,e dalla capacità delle forze politiche e sociali che le hanno poste in essere di salvaguardare questo nucleo essenziale di fini e interessi pur continuamente adeguandolo alle mutevoli esigenze della comunità sociale. In una comunità politicamente non omogenea,ciò costituisce chiaramente lo strumento principale che vale a garantire l'equilibrio fra le diverse e contrastanti istanze politiche,faticosamente raggiunto attraverso il compromesso. Limiti alla revisione si rinvengono anche nelle costituzioni flessibili e sarebbero dati dal nucleo di principi fondamentali cui si ispira il singolo Stato. Così,nello Statuto albertino,si riteneva che fossero immodificabili la forma di governo monarchica-rappresentativa parlamentare,la posizione e la funzione della Corona,e la forma unitaria dello Stato.

Sezione V-L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO POLITICO DELLE CAMERE
Lo Stato italiano è retto da una forma di governo parlamentare:ciò significa che il Governo,per iniziare a svolgere la sua attività di indirizzo politico e per poter attuare tale indirizzo ha bisogno di godere della fiducia di ambedue le Camere o che,in altri termini,fra il Governo e le Camere deve intercorrere un **rapporto fiduciario**. Venuta meno la fiducia di una sola delle due Camere, il Governo ha conseguentemente l'obbligo giuridico di dimettersi. Ora,le Camere,nel nostro sistema costituzionale,non hanno soltanto la funzione di porre le norme costitutive dell'ordinamento giuridico(funzione legislativa,alla quale esse adempiono con l'emanazione delle leggi formali),ma anche quella di collaborare con il Governo,proprio in virtù del rapporto fiduciario che le lega ad esso nello svolgimento della attività di INDIRIZZO POLITICO.

36. L'indirizzo politico- E' anzitutto da escludere che tale indirizzo politico costituisca l'oggetto di una quarta funzione dello Stato(come pure è stato ritenuto),osservando invece che si ci trova di fronte ad una *attività* di fatto,e che deriva dall'esigenza di far precedere alla ripartizione dei vari compiti fra i vari organi un momento di impulso unitario e di coordinazione,affinchè tali stessi organi svolgano in modo armonico le funzioni alle quali sono preposte. Per cui l'indirizzo politico appare strettamente collegato con l'azione di governo stessa. L'attività di indirizzo politico può essere distinta in 3 fasi: una prima fase, che può definirsi *teleologica*, relativa alla definizione dei fini da perseguire; una seconda *strumentale* per la predisposizione dell'apparato organizzativo e dei mezzi necessari per tradurre

This document is available free of charge on StuDocu.com

in risultati giuridici la volontà programmata e conseguire i fini; una terza *effettuale* con la creazione di atti mirati a dare concreta attuazione ai fini programmati. Per quanto riguarda la fase teleologica, c'è da osservare che in regime di Costituzione rigida,la scelta e la determinazione dei fini è già contenuta nelle norme costituzionali. Non per questo l'attività che ad essi si riconnette può dirsi estranea all'indirizzo politico:infatti il fine costituzionalizzato deve essere meglio individuato e reso concreto in relazione al momento in cui lo stesso viene assunto come proprio dall'azione di governo. Oltretutto,la nozione di indirizzo politico viene in considerazione come nozione unitaria,nel senso che non è possibile distinguere un indirizzo politico generale(o costituzionale)da un indirizzo politico contingente(o della maggioranza),laddove l'indirizzo politico generale tenderebbe alla sola attuazione della costituzione mentre l'indirizzo politico della maggioranza tenderebbe ad attuare la costituzione solo parzialmente,in riferimento alle parti che risulterebbero ad essa congeniali. Tant'è che la maggioranza non ha,né potrebbe avere nel corretto funzionamento del sistema,un indirizzo politico che si discosti da quello costituzionale o con questo in contrasto,mentre l'attuazione dell'indirizzo politico avviene sempre ad opera dell'intero apparato amministrativo dello Stato tenuto al rispetto del principio di imparzialità(art.97). Nella forma di governo parlamentare,gli organi preposti all'indirizzo politico sono il Parlamento ed il Governo,i quali agiscono in stretta e intima connessione fra loro,attraverso un coordinamento che viene ad istaurarsi al momento in cui il Governo ottiene la fiducia da parte della maggioranza delle due Camere. Infatti le Camere partecipano alla determinazione dell'indirizzo politico sia approvando il programma presentato dal Governo mediante il loro voto favorevole sulla mozione di fiducia,sia attraverso una serie di atti di direzione politica(ordine del giorno,mozioni,risoluzioni)diretti a modificare o integrare il programma originariamente concordato,impegnando così il Governo a dare attuazione al programma stesso. La fase strumentale vede impegnati Governo e Parlamento soprattutto nella predisposizione,discussione e approvazione della legge **di bilancio**,la legge con la quale i mezzi finanziari reperiti attraverso il gettito delle imposte(così come determinate dalle leggi tributarie)vengono normativamente ripartiti fra i vari settori dell'attività statale in vista dei fini da raggiungere. All'attività di indirizzo politico vanno ricondotte anche quelle procedure di controllo e di informazione con le quali le assemblee legislative mirano ad accertare che l'indirizzo effettivamente svolto dal Governo sia conforme a quello enunciato e in base al quale esse hanno votato la fiducia;se dovesse risultare da questo controllo che il Governo si è arbitrariamente discostato dalla programmazione originariamente fissata,le Camere possono e devono far valere la sua **responsabilità politica** colpendolo con una **mozione di sfiducia** e costringendolo quindi alle dimissioni. (Risulta da queste osservazioni che almeno nella nostra forma di governo Presidente della Repubblica e Corte costituzionale non svolgono l'attività di indirizzo politico,anche se al Presidente della Repubblica ed alla Corte è da riconoscere una *forza politica* in grado di condizionare in vario modo,con i loro atti,l'indirizzo politico così come determinato da Camere e Governo.) Nè è da tacere l'influenza ab externo esercitata sugli organi di indirizzo politico dai partiti politici,basti pensare

che il programma di governo è la risultante degli accordi sorti fra i partiti che costituiscono la maggioranza;dai sindacati,oggi chiamati ad una più concreta partecipazione alle scelte concernenti in genere la politica sociale;dall'opinione pubblica ecc.). In merito alla natura dell'attività di indirizzo politico sono state avanzate due diverse tesi contrapposte: l'una che vedrebbe nell'indirizzo politico la natura di fonte normativa e quindi di fonte del diritto,in base all'enunciazione di scopi da perseguire, che vincolano l'esercizio dei poteri discrezionali conferiti ai vari organi; l'altra che vede invece nell'indirizzo politico una natura esistenziale,puramente ricognitiva. E' indubbio che l'attività di indirizzo politico si traduca in determinati atti giuridici,fatto questo che avalla la tesi della natura normativa dell'indirizzo politico,o meglio,che consente di sostenere che quest'attività ha natura normativa nella misura in cui trovi corrispondenza nella costituzione materiale e che tale attività venga assistita dalla previsione dei mezzi finanziari,oltre che da un sistema di garanzie e sanzioni che ne assicuri lo svolgimento nella direzione voluta.Gli atti mediante i quali le Camere svolgono l'indirizzo politico sono: A) la mozione di fiducia; B) le leggi di indirizzo politico; C) la deliberazione dello stato di guerra; D) le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione; E) la mozione di sfiducia.

37. La mozione di fiducia- Attiene alla fase di determinazione(teleologica)dell'indirizzo politico. Ai sensi dell'art. 94 comma 3 Cost. "Il governo entro 10 giorni dalla sua formazione si deve presentare alle camere per ottenerne la fiducia". I dieci giorni decorrono dal giuramento prestato dal Governo nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Governo, a mezzo del suo Presidente del Consiglio, espone alle Camere il programma che intende svolgere (cosiddetta "DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA"). Si procede poi alla discussione sulle dichiarazioni che si chiude con la presentazione, da parte dei gruppi parlamentari di maggioranza, di una mozione di fiducia che deve essere: **motivata** perché con essa le Camere devono esprimere le ragioni del loro consenso al programma politico presentato dal Governo, ed impegnano allo stesso tempo il Governo allo svolgimento di quel programma; **votata per appello nominale** perché ciascuno dei parlamentari assuma nei confronti del Paese e dell'elettorato(nonché verso il partito di appartenenza)le sue responsabilità. Nella prassi,la mozione di fiducia non è motivata,o meglio viene motivata *per relationem* con un generico riferimento al programma di governo(la formula comunemente adottata è: "La Camera,udite le dichiarazioni del Governo,le approva e passa all'ordine del giorno").Tale prassi non sembra tuttavia corretta perché la mancata o implicita motivazione impedisce il realizzarsi di un vero e proprio incontro paritario delle volontà di Camere e Governo,mentre si limita ad una sorta di assenso delle Camere quanto piuttosto ad una vera adesione delle stesse al programma presentato dal Governo,con la conseguenza che il ruolo del Parlamento risulta almeno formalmente sminuito. Oltretutto,per l'approvazione della mozione di fiducia non è richiesta una maggioranza qualificata,ma soltanto la maggioranza dei presenti:ciò vale a spiegare come sia possibile la costituzione di Governi minoritari o senza maggioranza

This document is available free of charge on StuDocu.com

precostituita(fondati sull'appoggio esterno,mediante l'astensione o anche il voto favorevole,di alcuni gruppi parlamentari non direttamente impegnati nell'attività di governo).Tali Governi si costituiscono generalmente per garantire comunque una direzione politica al Paese in assenza di un accordo programmatico fra i partiti,e sono perciò anche detti governi "*di affari o amministrativi*" per sottolineare la loro provvisorietà ed eccezionalità,e sono di regola monocolori. L'esperienza repubblicana è in effetti ricca di questi governi(III governo Andreotti,1976,che si è retto inizialmente non sulla base del consenso ma sulle astensioni della maggioranza dei parlamentari),situazione comunque sia singolare,la cui correttezza costituzionale è quanto meno dubbia e che può trovare legittimazione soltanto nello stato di necessità che l'ha originata. Ad ogni modo,nel momento in cui questi governi si svolgono,si torna alla formula tradizionale del Governo con maggioranza precostituita e alla tradizionale dialettica maggioranza-opposizione.(Un altro caso di governo minoritario si ha anche quando viene a formarsi un Governo senza maggioranza precostituita,al solo scopo di gestire le elezioni una volta sciolte le Camere;anche sulla legittimità costituzionale di questi Governi sono stati avanzati seri dubbi,in riferimento all'art.94 della nostra Costituzione,che richiede tassativamente che i Governi ottengano la fiducia delle Camere.)Appare quindi chiaro che nel nostro sistema,tali governi minoritari dovrebbero cedere al più presto possibile il posto a Governi sostenuti da una maggioranza,e che se mai non si dovesse raggiungere un accordo tra le forze politiche,l'unico rimedio sarebbe quello dello scioglimento delle Camere da parte del Pres.della Repubblica,in modo da consentire al corpo elettorale di trovare nuovi equilibri.

38. Le leggi di indirizzo politico: la legge di bilancio e la legge di stabilità- Si definiscono **leggi di indirizzo politico** quelle leggi medianti le quali il Parlamento partecipa direttamente alla direzione politica dello Stato(in realtà buona parte delle leggi del Parlamento sono espressione di indirizzo politico,basti pensare alle leggi che dettano norme in materia di ordine pubblico,a quelle che disciplinano le modalità di sciopero o i rapporti fra lo Stato e le Regioni ecc.,per cui bisogna meglio specificare la nozione di legge di indirizzo politico, attribuendo questa qualifica a quelle leggi mediante le quali il Parlamento partecipa,in via Diretta ed Immediata,alla determinazione dei fini o alla predisposizione dei mezzi). Secondo questo criterio,leggi di indirizzo politico sono: -la legge di approvazione del bilancio preventivo; -la legge finanziaria **oggi legge di stabilità;** -la legge di approvazione dei programmi economici; -le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; le leggi di amnistia e indulto. Infatti,la legge di bilancio e la legge di stabilità valgono a predisporre normativamente la ripartizione dei mezzi finanziari fra i vari rami dell'amministrazione la prima,e ad operare modifiche e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle aziende del c.d. "Settore pubblico allargato" la seconda. Le leggi di programma valgono invece ad identificare e a rendere espliciti,traendoli dall'astrattezza e dalla generalità del programma di governo,i "fini sociali" ai quali deve essere indirizzata l'attività economica pubblica e privata. Le leggi di autorizzazione alla ratifica

valgono invece ad esprimere il consenso del Parlamento su un atto estraneo all'ordinamento ma pur sempre espressione di indirizzo politico(il trattato internazionale),la cui efficacia viene tuttavia sospesa quando,in ragione della sua particolare natura,la ratifica del trattato deve essere autorizzata dalle assemblee rappresentative(art.80 Cost.).Infine,le leggi di amnistia e di indulto indicano la discrezionalità politica del Parlamento in ordine alla concessione di questi particolari provvedimenti di clemenza. La legge di bilancio, trova la sua regolamentazione nell'art. 81 Cost., che ha subito una riscrittura ad opera della legge cost. n. 1 del 2012. Con l'approvazione del *Fiscal Compact,* gli Stati dell'UE si sono impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti la regola aurea del principio del pareggio del bilancio. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per garantire l'equilibrio tra entrate e uscite sono stabiliti ora con legge ordinaria, approvata a maggioranza assoluta. I principi del pareggio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico sono imposti a tutte le PP.AA. L'Ufficio parlamentare di bilancio, presso le Camere, valuta l'osservanza delle regole sul bilancio e gli andamenti di finanza pubblica (organismo indipendente istituito nel 2012). Fra le novità di rilievo è la previsione (con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016) di una legge che accorperà in un unico provvedimento la legge di bilancio e quella di stabilità. A norma dell'art.81 comma IV Cost.,"Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo".Ai sensi degli art.7 e 10 della legge 31 dicembre 2009,in vigore dal 1 gennaio 2010,entro il 20 settembre di ogni anno il Governo deve presentare alle Camere lo schema di "Decisione della finanza pubblica"(che sostituisce il documento di programmazione economico-finanziaria,quale previsto dalle legge 5 agosto '78 n.468,abrogata dalla nuova legge n.196).La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo,e definisce gli obiettivi relativi alle amministrazioni centrali,alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Sempre secondo la nuova legge(n.196/2009)entro il 15 ottobre di ogni anno deve essere presentato dal Governo alle Camere il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato,e sempre entro tale data deve essere presentato il disegno di **legge di stabilità**(che sostituisce la legge finanziaria).
La legge di stabilità e la legge di bilancio contengono quindi la manovra triennale di finanza pubblica che mira appunto a realizzare gli obiettivi prefissati dalla Decisione di finanza pubblica. La manovra è preceduta dalla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile,e che contiene: - l'analisi dell'andamento dell'economia,del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella precedente Decisione di finanza pubblica; - l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e,in caso di scostamento dagli obiettivi,le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare; - le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura. Il bilancio annuale oltre ad indicare l'ammontare delle entrare che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare (**bilancio di**

This document is available free of charge on StuDocu.com

competenza) indica anche l'ammontare delle entrare che si prevede di incassare o delle spese che si prevede si pagare (**bilancio di cassa**): l'art.42 della 296 ha conferito delega al Governo per il passaggio al solo bilancio di cassa. La stessa legge prevede che,a partire dal 2010,il Governo debba inviare entro il 15 luglio alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica(che ha sostituito la Conferenza unficiata Stato-Regioni) le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici per il preventivo parere della Conferenza,da esprimersi entro il 10 settembre. In tal modo le Regioni sono chiamate a partecipare(sia pure in forma consultiva)alla programmazione economico-finanziaria e all'elaborazione dei bilanci. Sempre a norma della legge citata,entro il mese di giugno di ogni anno il ministro dell'economia e della finanza deve presentare al Parlamento un disegno di legge contenente il rendiconto generale dell'anno precedente,scaduto il 31 dicembre. Tale rendiconto,prima della presentazione al Parlamento,deve essere trasmesso alla Corte dei Conti per la *parificazione*. L'esame in commissione e in assemblea(n.b.:la legge di bilancio rientra fra le leggi che devono essere tassativamente esaminate e approvate con procedura ordinaria)del disegno di legge sul bilancio e di quello di legge finanziaria(oggi legge di stabilità),si svolge secondo le disposizioni particolari dettate nei regolamenti parlamentari(art.119 R.C.D. e 125 R.S.),integrate con quelle che disciplinano in via generale l'esame dei progetti di legge in assemblea. La natura di indirizzo politico della legge di bilancio discende dal fatto che con essa le entrate vengono suddivise fra i vari settori dell'attività statale in funzione dei fini che si intendono raggiungere(così ad es. si potrebbero aumentare le spese sociali a scapito di quelle di organizzazione ecc.),di modo che la legge di bilancio non si limita ad essere soltanto un documento contabile:il Parlamento conserva sempre infatti un certo margine di discrezionalità,entro in quale può compiere scelte di anno in anno quali espressione del suo potere di indirizzo politico;allo stesso modo per la legge di stabilità. L'approvazione della legge di bilancio da parte della Camere autorizza il Governo a riscuotere le imposte e ad utilizzare i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento della sua attività. Tale autorizzazione ha effetto per l'**esercizio finanziario** (che ha durata annua e vale dal 1 gennaio al 31 dicembre,c.d."Anno finanziario"). Qualora le Camere non facciano in tempo ad approvare il bilancio di previsione prima della data di inizio dell'anno finanziario,esse approvano una legge per concedere al Governo l'esercizio provvisorio del bilancio, per una durata complessiva non superiore ai 4 mesi(art.81 II comma Cost.) Questa legge autorizza il Governo a riscuotere le entrare e ad effettuare le spese per tanti 12esimi delle relative previsione contenute nel disegno di legge di bilancio quanti sono i mesi per i quali è concesso l'esercizio provvisorio.
Sempre a norma dell'art.81 comma II Cost.,"Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese",e ciò al fine di evitare che vengano istituiti nuovi oneri tributari senza una legge convenientemente discussa e meditata dal Parlamento. Considerato il fatto che essa manca di ogni carattere innovativo,la legge di bilancio è stata ritenuta da molti soltanto una legge in senso formale e non anche materiale. C'è invece chi sostiene il carattere normativo della legge,giacchè è proprio mediante questa che Parlamento e Governo procedono

annualmente alla ripartizione delle spese fra i vari settori dell'amministrazione statale,con ciò innovando quindi profondamente rispetto alla situazione e all'anno precedente. A norma infine dell'ultimo comma dell'art.81,ogni altra legge diversa da quella di bilancio che indichi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte,al fine di evitare stanziamenti da parte delle Camere senza che vi sia la necessaria copertura finanziaria. La legge di bilancio vincola il Governo a riscuotere le entrare e ad effettuare le spese entro i limiti in essa fissati:il Governo non può trasferire i fondi da un capitolo all'altro;eventuali spostamenti sono consentiti solo all'interno dello stesso capitolo.
Il controllo sull'osservanza della legge di bilancio da parte delle amministrazioni statali è affidato in Italia al Parlamento,che lo esercita avvalendosi della Corte dei Conti(art.100 comma II Cost.).
A questo riguardo,si può notare che le origini storiche dei Parlamenti si ricollegano al periodo feudale,quando il re interpellava gli appartenenti alla nobiltà laica e gli alti dignitari ecclesiastici,cui si aggiunsero in un secondo momento i rappresentanti della borghesia,riuniti in consiglio tutte le volte che aveva bisogno del loro consenso per imporre una nuova prestazione tributaria,dichiarare una guerra o concludere una pace. Spetta poi alla Corte(sempre a norma dell'art.100 Cost.) il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato,e in generale sul rendiconto generale dello Stato(vale a dire sul c.d. **bilancio consuntivo**,che deve essere approvato con legge)al fine di confrontarne i risultati,tanto per le entrare quanto per le spese,con la legge di bilancio(c.d. **parificazione**). Inoltre la Corte accetta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge,valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa(c.d. **controllo di gestione**).

39. Le leggi di approvazione dei programmi economici- Anche queste leggi sono leggi di indirizzo politico,laddove si considera che esse valgono a fornire una serie di direttive allo sviluppo economico del Paese attraverso la formulazione di previsioni tecniche concernenti questo stesso sviluppo. Il programma economico è inteso infatti come quadro della politica del Governo e di tutti gli investimenti pubblici non soltanto nel campo economico-finanziario,ma anche in quello sociale(fino a comprendere i settori dell'urbanistica, dell'istruzione, dell'assistenza e ad occuparsi dell'intera area dell'azione statale).
Risulta perciò evidente la stretta connessione di queste leggi con la legge di bilancio:un razionale programma di sviluppo economico-sociale infatti non può prescindere da un supporto finanziario adeguato,per cui il bilancio si pone come lo strumento necessario per il conseguimento dei fini programmati. (C'è da dire che in Italia manca un'organica legge di programmazione generale:in questi ultimi anni si è infatti accolta la tendenza a dar vita a tutta una serie di programmi settoriali e intersettoriali,come il piano sanitario nazionale,il piano energetico nazionale,il piano agricolo nazionale ecc. In queste condizioni,non può affermarsi che ad oggi in Italia esista un razionale e concreto processo di programmazione,mentre poteri sempre più effettivi in tal senso vengono assunti dalla Banca d'Italia,attraverso la manovra e il

This document is available free of charge on StuDocu.com

controllo dei flussi monetari,posta in grado di partecipare attivamente e soprattutto nei periodi di crisi alla gestione dell'economia in virtù della sua autonomia. Dopo il trattato di Maastricht e l'ingresso dell'Italia nel sistema della moneta unica europea,l'Euro,il controllo della politica economica è passato in gran parte alla BCE).

40. Le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali- I trattati internazionali costituiscono una delle fonti del diritto internazionale,in particolare essi costituiscono il c.d. "Diritto internazionale pattizio",che va distinto da quello costituito dalle norme di diritto internazionale consuetudinarie. Come atto esterno all'ordinamento giuridico italiano,il trattato acquista efficacia nell'ordinamento interno in seguito ad un apposito **ordine di esecuzione,** che viene generalmente adottato con decreto presidenziale oppure inserito nella *legge di autorizzazione alla ratifica.* Il procedimento di formazione dei trattati inizia con la **negoziazione** ad opera dei plenipotenziari(= l'organo che, essendo munito dei cosiddetti *pieni poteri*, è autorizzato a negoziare e firmare un trattato internazionale per conto del proprio Stato),continua con la **conclusione** (sempre ad opera dei plenipotenziari) che non fa però sorgere alcun obbligo,fino alla **ratifica**,vale a dire l'approvazione dell'organo competente,in Italia il Capo dello Stato(ai sensi dell'art.87 Cost.)per terminare con lo scambio delle ratifiche o con il loro deposito presso uno Stato incaricato di raccoglierle:è solo a questo punto che i trattati diventano obbligatori per gli Stati contraenti. A norma dell'art.80 Cost.,la ratifica deve essere autorizzata con legge dalle Camere nel caso in cui il trattato abbia: natura politica, preveda arbitrati o regolamenti giudiziari o variazioni del territorio di uno Stato, oneri alle finanze o proponga modificazioni di leggi. L'intervento del Parlamento è giustificato dal rilievo di questi trattati per quanto attiene l'indirizzo politico nel campo delle relazioni internazionali;per cui si rende necessario che le Camere collaborino con il Governo nella determinazione di tale indirizzo,pronunciandosi sull'entrata in vigore del trattato. Secondo una prassi ormai consolidata, le Camere esprimono nella stessa legge di autorizzazione alla ratifica(con la formula "*piena ed intera esecuzione sia data al trattato…"*)la volontà di dare esecuzione al trattato nell'ordinamento interno.

41. Le leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto- A norma dell'art. 79 cost. comma 1 Cost., come modificato dalla legge cost. 1/92, "L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale."
Tale legge è di indirizzo politico in quanto espressione della discrezionalità politica del Parlamento,sia in ordine al momento in cui adottarla sia in relazione alla categorie di reati da porre ad oggetto di questi provvedimenti di clemenza. La sua natura di indirizzo politico è confermata dalla maggioranza qualificata richiesta per approvare i singoli artt. e per la votazione finale. L'amnistia estingue il reato e se questo ha fatto scattare una condanna , anche l'esecuzione della stessa e della pena accessoria. L'indulto invece condona in tutto o in parte la pena senza cancellare il reato, o lo commuta in pena minore. In ogni caso entrambi non si applicano ai casi sorti dopo la presentazione del disegno di legge.

42. La deliberazione dello Stato di guerra- A norma dell'art. 78 Cost. "Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari". Spetta al Presidente della Repubblica dichiarare poi lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87 Cost.). Si è voluto in tal modo affidare alle Camere la decisione sullo stato di guerra perché rappresentative della volontà popolare. Bisogna però considerare non di meno, che l'Italia ripudiando la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (art. 11 Cost.) consente solo una guerra puramente difensiva,e la scelta dovrebbe pertanto essere obbligata.
L'art.78 Cost. non richiede espressamente che la deliberazione dello stato di guerra avvenga con legge;per cui è stato ritenuto che la deliberazione possa assumere anche forma non legislativa:in tal caso si ci troverebbe dinanzi ad un *atto bicamerale non legislativo di indirizzo politico*. A tal proposito si sono confrontate due tesi opposte: quella dell'Elia, che sostiene che non occorre una legge a proclamare lo stato di guerra ma semplicemente una deliberazione delle camere, e quella di altri come Biscaretti, Lavagna, che ritengono invece che la deliberazione debba avvenire con una legge: se si tiene presente infatti che,una volta dichiarato lo stato di guerra,il Parlamento conferisce al Governo i poteri necessari e che tale conferimento non può non avvenire che con legge(trattandosi infatti di poteri EXTRA ORDINEM che potrebbero giungere,data l'eccezionalità della situazione,fino a limitare l'esercizio di alcuni diritti fondamentali,come la libertà di circolazione e di soggiorno,oppure ancora la libertà e la segretezza della corrispondenza)si ha ragione di ritenere che lo stato di guerra debba essere contestualmente deliberato con legge .

43. Le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione: le procedure di indirizzo- Accanto alle leggi di indirizzo politico esistono atti unicamerali mediante i quali le Camere esercitano la loro attività di direzione politica. Questi atti sono la **mozione e la risoluzione.** La ***mozione***, diversa da quella di fiducia e di sfiducia, consiste nel promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento. Può essere presentata alla Camera da un presidente di gruppo o da 10 deputati e al Senato da almeno 8 senatori. La ***risoluzione*** è (alla Camera) diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Essa può essere votata in commissione,su proposta di un suo componente,negli affari per i quali la commissione non debba riferire all'Assemblea. Alla discussione deve essere invitato a partecipare il rappresentante del Governo che può, a norma del regolamento camerale, chiedere di fermare la votazione e di investire l'Assemblea per la decisione. Al Senato la risoluzione è più cauta:si prevede infatti che,a conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al resto dell'Assemblea,le commissioni possano votare risoluzioni intese ad esprimere il loro "pensiero". Quando ne facciano richiesta il Governo o 1/3 dei componenti della commissione,le risoluzioni vengono comunicate al Presidente del Senato affinchè le sottoponga all'Assemblea. Quanto all'efficacia delle mozioni e risoluzioni(che sono state accomunate nell'unica definizione di *direttive parlamentari*)va detto che l'efficacia di queste direttive va ricondotta nell'ambito del rapporto di fiduciario,per

This document is available free of charge on StuDocu.com

cui laddove il Governo non ne desse esecuzione, verrebbe meno all'obbligo costituzionale di svolgere e contenere la sua attività entro l'ambito di detto rapporto; le Camere dovrebbero pertanto valutare la responsabilità politica del Governo,giungendo in ipotesi(nei casi più gravi) a richiederne le dimissioni.

44. Le procedure di controllo e di informazione- Nelle forme di governo parlamentari, il Governo è sottoposto a controllo da parte delle Camere per quanto concerne lo svolgimento della sua attività politico-amministrativa: le Camere devono quindi essere poste in grado di conoscere anche nei particolari l'attività svolta dal Governo e dagli organi dipendenti per poter accertare se essa corrisponda all'indirizzo politico concordato. Così,strettamente connesse all'attività di indirizzo politico,ma non rientranti propriamente in essa,sono le **procedure di controllo e di informazione**, sensibilmente arricchite nei nuovi regolamenti parlamentari. Gli strumenti predisposti affinchè le Camere operino un diretto controllo sull'attività di Governo sono le: **interrogazioni, interpellanze, inchieste, indagini e attività conoscitive** in genere svolte dalle commissioni. L'*interrogazione* consiste nella semplice domanda,rivolta da un parlamentare per iscritto al Governo(o ad un singolo ministro)per sapere se un fatto sia vero,se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta,se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie,o abbia preso o stia ancora per prendere dei provvedimenti. La risposta all'interrogazione può essere data anche in commissione e può essere orale o,su richiesta dell'interrogante,scritta. In ogni caso,il Governo può dichiarare di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad un altro giorno determinato. (Gli artt.135 bis R.C.e 151 bis hanno introdotto un tipo di interrogazione a risposta immediata(c.d. "**question time**"),consistente in una sola domanda,formulata in modo chiaro e conciso in un minuto di tempo su un argomento di rilevanza generale,connotato da urgenza o da particolare attualità politica. Il presentatore ha la facoltà di illustrare la domanda per non più di un minuto,mentre il rappresentante del Governo può rispondere per non più di tre minuti .L'interrogante o altro deputato del medesimo gruppo può replicare per non più di due minuti(tre al Senato).Al question time è riservata una seduta alla settimana(o al mese al Senato). L'*interpellanza* consiste nella domanda,rivolta per iscritto al Governo(o a un singolo ministro) circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica. Esse hanno quindi un carattere più penetrante delle interrogazioni,sia perché hanno un più diretto riferimento all'attività di indirizzo politico, sia perché qualora l'interpellante dovesse dichiararsi insoddisfatto della risposta ottenuta,può trasformare l'interpellanza in mozione e investire così l'intera Assemblea della discussione e del voto sulla condotta del Governo(a differenza che nell'interrogazione,laddove l'interrogante può soltanto dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta ottenuta). E'da rilevare tuttavia che la facoltà di trasformare l'interpellanza in mozione non è prevista nel regolamento del Senato;anche la facoltà del Governo di dichiarare di non poter rispondere o di voler differire la risposta è espressamente prevista solo nel regolamento della Camera. Le *inchieste* possono essere disposte(a norma dell'art.82 Cost.)da ciascuna Camera su

materie di pubblico interesse. Ciò non toglie che le Camere possano anche deliberare congiuntamente,con una legge o con un atto bicamerale non legislativo,di condurre un'inchiesta nei casi in cui la materia su cui indagare sia particolarmente complessa o,per la connotazione politica,venga ritenuto opportuno impegnare il Parlamento nel suo complesso, cd *commissioni bicamerali.*. E' la maggioranza(di cui il Governo è espressione)a decidere di condurre o no le inchieste,con ciò sminuendo il valore di strumento di controllo dell'inchiesta sulla condotta politica del Governo. Sarebbe pertanto auspicabile che l'avvio dell'inchiesta fosse deciso anche dalla minoranza. L'inchiesta come strumento di controllo è quella c.d. **politica**,diretta ad accertare la situazione dell'ordine pubblico in una determinata parte del Paese(ad esempio l'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali),la responsabilità di funzionari e di uomini politici in relazione ad una certa situazione di pubblico interesse. Vi è poi l'inchiesta c.d. **legislativa**,che mira ad acquisire dati e informazioni per un migliore svolgimento dell'azione legislativa(anche se ha valore puramente conoscitivo). Nella XVI legislatura sono in corso le inchieste bicamerali sul fenomeno della mafia e sul ciclo dei rifiuti,nonché le inchieste monocamerali della Camera sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali,e del Senato sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Le inchieste sono condotte da apposite commissioni in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria(art.82 comma II Cost.),cosicchè la commissione è legittimata a convocare e interrogare testimoni,ordinare perizie,richiedere documenti ecc. Essa incontrerà allo stesso tempo i limiti derivanti dal diritto di alcune persone(ministri di culto,avvocati,medici ecc.)di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale,e di altre(pubblici impiegati,pubblici ufficiali ecc.)di astenersi dal testimoniare su fatti conosciuti per ragioni di ufficio su fatti che debbano rimanere segreti o addirittura coperti dal segreto di Stato. Segreto di Stato e segreto d'ufficio possono tuttavia non essere opponibili alle commissioni d'inchiesta qualora disponga in tal senso la legge istitutiva della commissione medesima(come per la commissione che negli anni '70 fu chiamata a indagare sull'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia). Dalle commissioni di inchiesta vanno distinte le commissioni di vigilanza,organo risalente addirittura al periodo statutario,come ad es. la commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La natura giuridica di queste commissioni è controversa,non solo perché alcune di queste comprendono membri estranei al Parlamento,ma anche perché la loro attività non sempre è raccordata a quella delle Camere. Le **indagini ed attività conoscitive** svolte dalle commissioni parlamentari(che siedono in tal caso "*in sede politica*")sono state introdotte dai regolamenti parlamentari del '71. Le commissioni possono infatti disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie,informazioni e documenti utili alle attività delle Camere. Nelle sedute dedicate a queste indagini possono essere chiamati a intervenire i ministri competenti,funzionari ministeriale,amministratori di enti pubblici,rappresentanti di enti territoriali,di organismi privati,di associazioni di categoria e altre persone esperte nella materia in esame,ossia qualunque persona in

This document is available free of charge on StuDocu.com

grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine. Un particolare tipo di indagine conoscitiva è rappresentato dalle *udienze legislative*, indagini svolte in occasioni dell'esame di un progetto di legge da parte di una commissione camerale: non sono previste nei regolamenti parlamentari,ma per la loro innegabile utilità si sono sinora svolte in via di prassi. Al fine di sottolineare che l'attività delle commissioni è meramente conoscitiva,l'art.48 R.S. precisa che nello svolgimento delle indagini le commissioni non hanno i poteri dell'autorità giudiziaria né hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico,di emanare direttive,procedere a imputazioni di responsabilità,ecc.

45. La mozione di sfiducia- Le Camere possono porre termine al rapporto che le lega al Governo con l'approvazione di una mozione di sfiducia. In seguito all'approvazione della mozione(che può venire anche da una sola delle due Camere),il Governo ha l'obbligo giuridico di presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica,anticipando la fine della legislatura e si apre così la "**crisi di governo**". Se il Governo non si dimettesse,spetterebbe al Presidente della Repubblica revocarlo dalla carica(ed è questo l'unico caso in cui,nella nostra forma di governo,il Presidente della Repubblica può revocare il Governo per ripristinare la legalità costituzionale,così come asserito dal Lavagna). Il venir meno del rapporto fiduciario che aveva per l'innanzi legato le Camere e il Governo è determinato da un mutamento della maggioranza parlamentare che aveva espresso il Governo,o da un insanabile dissenso sorto tra maggioranza e Governo,per cui la prima fa valere la responsabilità politica del secondo.

La Costituzione(art.94)contiene una precisa regolamentazione della mozione di sfiducia:essa deve essere motivata e votata per appello uninominale (per le stesse ragioni per cui deve essere motivata e votata per appello nominale la mozione di fiducia). Deve essere inoltre firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla presentazioni,al fine di evitare votazioni di sorpresa(c.d. assalti alla diligenza)e di consentire che il voto sia "l'espressione meditata e sicura della volontà della maggioranza parlamentare"(Virga).E poiché la sfiducia deve investire l'intera azione politica del Governo e può essere votata soltanto mediante una mozione motivata,lo stesso art.94 ha disposto che "il voto contrario di una o entrambe le Camere su una singola proposta del Governo non comporta l'obbligo di dimissioni". Bisogna distinguere opportunamente tra **mancata fiducia iniziale e voto di sfiducia**; si ha la prima allorquando il Governo,presentatosi dinanzi alle Camere ed esposto il proprio programma dopo la sua formazione,non ne ottiene la fiducia;si ha invece il voto di sfiducia allorquando al Governo viene revocata la fiducia già concessa a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia da parte delle Camere. Il voto di sfiducia può, secondo un'interpretazione controversa dell'art. 95 Cost. comma II, anche un singolo ministro.

Dalla mozione di sfiducia/fiducia va poi distinta la **questione di fiducia**: mentre le prime infatti sono presentate dai parlamentari,la seconda è proposta dal Governo tutte le volte che,temendo colpi di mano da parte di una maggioranza divenuta incerta e malsicura,soprattutto in sede di votazioni a scrutinio segreto(fenomeno dei

“FRANCHI TIRATORI”,parlamentari che, approfittando del voto a scrutinio segreto, non seguono le indicazioni del proprio partito o gruppo parlamentare),voglia assicurarsene l’appoggio relativamente alla votazione su un atto che ritiene essenziale ai fini del proseguimento della sua azione politica. Ponendo la questione di fiducia insomma,il Governo avverte implicitamente le Camere che,in caso di esisto contrario a quello da esso voluto,si dimetterà ed aprirà la crisi. La questione di fiducia rappresenta dunque uno strumento per superare l’ostruzionismo di minoranze parlamentari e per ottenere decisioni più tempestive;a questo scopo è stata più volte posta negli ultimi anni. In tal caso si parla di “FIDUCIA TECNICA”,per significare che la questione non coinvolge direttamente l’azione globale del Governo ma soltanto aspetti procedurali. In via generale,la questione di fiducia NON può essere posta su quanto attiene al funzionamento interno della Camera(per esempio proposte di modifica dei regolamenti)e su tutti quegli argomenti per i quali il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o a scrutinio segreto. Pur essendo uno strumento di cui il Governo si serve per perseguire e attuare l’indirizzo politico originariamente concordato con le Camere,va osservato che la questione di fiducia è,o almeno dovrebbe essere,uno strumento eccezionale:il ricorso ad essa è infatti chiaro ed evidente indice di un sovvertimento dei naturali rapporti fra maggioranza e Governo.

SEZIONE VI- FUNZIONI ELETTORALI, GIURISDIZIONALI, CONSULTIVE

-FUNZIONE ELETTORALE: Alle Camere compete a) l’elezione del Presidente della Repubblica; b) quella di 5 giudici ordinari della Corte costituzionale; c) di 1/3 dei membri del CSM; d) dei 45 cittadini fra i quali vengono eletti a sorte i 16 giudici aggregati della Corte costituzionale nel caso di giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica.

-FUNZIONE MATERIALMENTE GIURISDIZIONALE: Svolgono tale funzione allorquando procedono alla verifica delle elezioni contestate dai propri membri e quando sono chiamate a svolgere funzioni istruttorie nel procedimento per la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica(art.90 Cost.)Esse sono inoltre destinatarie,separatamente,dei messaggi del Presidente,e collegialmente del giuramento del Presidente neo-eletto.

Sembra infine(non esistendo alcuna disciplina della materia)che le due Camere debbano anche partecipare all’accertamento dell’impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica al fine di dar luogo alla supplenza da parte del Presidente del Senato(art.86 comma I Cost.).

CAPITOLO SECONDO-IL POTERE LEGISLATIVO DEL POPOLO

1. L’iniziativa legislativa del popolo ed il referendum costituzionale (rinvio)- Il popolo può esercitare la funzione legislativa oltre che attraverso i suoi rappresentanti anche in modo diretto mediante i referendum, abrogativo e costituzionale , e l’iniziativa legislativa; cioè interviene sia nella fase introduttiva del procedimento di

This document is available free of charge on StuDocu.com

formazione della legge (con iniziativa), sia in quella costitutiva (referendum costituzionale) e sia infine, in via diretta ed esclusiva, con l'abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge. In tal modo la sovranità popolare si rende operante e concreta.

2. Il referendum abrogativo: la disciplina- Il referendum abrogativo è disciplinato dall'art. 75 Cost. , nonché dagli artt. 25-40 legge 352/70. L'art.75 dispone che il referendum venga indetto (dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.87 Cost.) per deliberare l'abrogazione,totale o parziale,di una legge o di un atto avente forza di legge,quando lo richiedano 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali. Sempre a norma dell'art.75 Cost.,il referendum NON E' AMMESSO per le leggi tributarie e di bilancio,di amnistia e indulto e di autorizzazione alla ratifica di trattato internazionali,in quanto in merito a queste leggi si oppongono al referendum ragioni di opportunità politica riconducibili alla volontà del Costituente di riservare al Parlamento la tutela di alcuni interessi fondamentali dello Stato. Al referendum ha inoltre diritto a partecipare l'intero corpo elettorale. Ci si è chiesti se la partecipazione degli elettori al referendum costituisca un dovere,oltre che un diritto. Le opinioni al riguardo sono opposte:autori come Fois,Barile hanno sostenuto che il dovere di voto previsto dall'art.48 Cost. sia configurabile come tale solo e unicamente nelle competizioni elettorali in senso proprio,dirette ad eleggere i membri degli organi rappresentativi,e non anche nel referendum,nel quale il voto non ha una simile funzione. Bassanini invece ha sostenuto che il voto è in ogni caso espressione della volontà popolare,e come tale è un dovere costituzionale,anche se l'adempimento di tale dovere viene rimesso in ultima analisi alla sensibilità democratica dei cittadini. La proposta soggetta a referendum viene approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Tale disposizione,già presente nella Costituzione di Weimar del 1919,potrebbe neutralizzare la funzionalità stessa del referendum,giacchè le forze che avversano il suo successo potrebbero provocarne il fallimento sollecitando l'astensione dal voto(come già accaduto in Italia più di una volta). Sull'ammissibilità del referendum abrogativo è chiamata a giudicare la Corte(art.2 legge cost.22 marzo 1953 n.1),cui spetta pertanto di accertare se la legge(o l'atto avente forza di legge)rispetto al quale sia stato richiesto il referendum rientri o meno fra quelle per le quali questo strumento è escluso ai sensi dell'art.75 Cost. Nelle consultazioni referendarie svoltesi il 12 e il 13 giugno 2011 è stato raggiunto, dopo 16 anni, il quorum per la validità delle stesse e i voti favorevoli all'abrogazione delle leggi in oggetto sono stati di gran lunga superiori ai contrari. Sono state abrogate norme relative alle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, alla determinazione della tariffa del servizio idrico, alla produzione di energia nucleare nello stato e al legittimo impedimento del Presidente del Consiglio a comparire in udienza penale. Successivamente, il Governo ha adottato un D.L. in cui dettava la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell'abrogazione. Alcune regioni lo hanno impugnato per violazione e la Corte Cost. con sentenza 199 del 2012, ha riconosciuto che la norma impugnata aveva violato il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, accogliendo la tesi delle ricorrenti.

3. I limiti e le sentenze della Corte Cost. sull'ammissibilità - Un'interpretazione restrittiva del II comma dell'art.75 Cost. porterebbe ad ammettere l'abrogazione per referendum di tutte le leggi che non vengano indicate in esso. Questa interpretazione non sembra tuttavia da condividere:esistono infatti limiti ulteriori e cosiddetti IMPLICITI all'abrogazione,rappresentati in primis dalle leggi di revisione costituzionale e dalle altre leggi costituzionali per il semplice motivo che il procedimento di revisione o di integrazione della Costituzione è riservato al Parlamento(ai sensi dell'art.138 Cost.).Sembra poi che data la brevità e la perentorietà del termine previsto per la conversione in legge(60 giorni)sia da escludere un referendum abrogativo di un decreto legge. Alcuni autori escludono anche l'abrogazione per referendum delle leggi di delegazione, assumendo che esse immettono nell'ordinamento norme incapaci di operare all'esterno prima che siano emanate le norme delegate,ma potrebbe affermarsi a tal riguardo che l'abrogazione refendaria di una legge di delega avrebbe proprio l'effetto di impedire che le norme in essa contenute divengano operanti.
Altri limiti all'abrogazione sono impliciti al sistema,come nel caso delle leggi attuative della Costituzione e di alcuni diritti fondamentali di libertà,che,se abrogati,determinerebbero una rottura del sistema costituzionale. L'esistenza di questi limiti è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale nella sent. n.6 del 1978:con questa sentenza,la Corte ha ritenuto inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza della legge ordinaria ma che tendano ad abrogare o in tutto o in parte la Costituzione,le leggi di revisione costituzionale,le altre leggi costituzionali considerate dall'art.138 Cost.,confermando al tempo stesso l'inammissibilità del referendum su materie che l'art.75 comma II Cost. esclude esplicitamente dalla votazione popolare. Nella stessa sentenza la Corte ha individuato un'ulteriore serie di ragioni di inammissibilità della richiesta di referendum;in particolare ha ritenuto inammissibile la richiesta:a)quando la richiesta concerne un'eterogenea pluralità di disposizioni legislative,carenti di una matrice unitaria;b)quando la richiesta concerne materie di "rilevanza" o "copertura" costituzionale; c)quando la richiesta concerne disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato,in quanto strettamente connesse a disposizioni costituzionali di cui riproducono i contenuti o alle quali danno attuazione.
In particolare la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta quando i quesiti sono privi di CHIAREZZA,SEMPLICITA' e COERENZA. Con la sentenza n. 13 del 2012 la Corte ha dichiarato inammissibili 2 richieste di referendum popolare per l'abrogazione della legge n. 270 del 2005, in materia di leggi elettorali di Camera e Senato.

4. Le modalità di attuazione- Le modalità di attuazione del referendum sono disciplinate dagli art.27-40 della legge 352/70: la richiesta di referendum deve essere approvata dai Consigli regionali con maggioranza assoluta; non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei 6 mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle due Camere medesime; le richieste di referendum devono essere depositate

This document is available free of charge on StuDocu.com

in ciascun anno dal 1 gennaio al 30 settembre presso la Corte di Cassazione,unitamente alle firme e ai certificati elettorali dei sottoscrittori(entro 3 mesi dalla data del timbro apposto sui documenti medesimi a cura delle segreterie comunali e delle cancellerie degli uffici giudiziari);la loro legittimità,per quanto riguarda i requisiti previsti nell'art.75 comma I Cost. è controllata dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione,eventualmente in contraddittorio con i delegati dei Consigli regionali ed i presentatori della richiesta,oltre che con i rappresentanti di partiti e di gruppi politici. Spetta inoltre all'Ufficio centrale di accertare se,prima della data di svolgimento del referendum,la legge o l'atto che si intende abrogare con il referendum siano già stati abrogati. In tal caso,l'Ufficio dichiara che il referendum non avrà più corso. Qualora però il Parlamento approvasse una nuova legge contenente modifiche di pura forma della legge o dell'atto abrogati, rispetto alla o al quale era stato richiesto il referendum,il referendum verrà effettuato sulle nuove disposizioni legislative. Lo stesso Ufficio centrale per il referendum stabilisce,sentiti i promotori,la denominazione della richiesta del referendum,da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione al fine di identificare l'oggetto del referendum stesso. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri,che fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse,il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso; l'abrogazione(totale o parziale)di una legge mediante referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica;il decreto viene poi immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana(elemento questo che conferma la natura di fonte normativa del referendum); l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale;ma il Presidente della Repubblica può ritardare l'entrata in vigore per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione; nel caso di risultato contrario all'abrogazione,ne è data notizia; in tal caso la richiesta di referendum in merito all'abrogazione della stessa legge/atto non può essere riproposta prima che siano trascorsi 5 anni. Se prima della data di svolgimento, la legge o l'atto avente forza di legge sono abrogati, le operazioni non avranno più corso. Tale disposizione è stata giudicata incostituzionale dalla Corte. La consultazione referendaria non avrà più corso se la disposizione in oggetto sarà dichiarata illegittima dalla Corte, ma la valutazione sugli effetti di tale pronuncia spetta sempre all'Ufficio centrale.

5. Riflessioni conclusive- C'è da osservare che soltanto in pochi casi la volontà del cittadino-elettore riesce a determinarsi autonomamente in merito alla questione che forma l'oggetto del referendum mentre subisce molto più spesso l'influenza delle valutazioni espresse al riguardo dalle varie forze politiche o dalle direttive dei partiti;cosicchè si è giunti a sottolineare la sostanziale subordinazione del referendum alla democrazia rappresentativa.

6. Referendum d'indirizzo- La legge cost. 2/89 ha introdotto una nuova figura di referendum: quello di indirizzo. In esso si sottoponeva agli elettori la questione relativa alla trasformazione della Comunità Europea in Unione Europea,dotata di un Governo responsabile di fronte ad un Parlamento europeo,incaricato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica da parte degli organi competenti dei singoli Stati membri della. Per questo tipo di referendum si rese necessario il ricorso alla legge cost., perché la nostra Costituzione non lo prevedeva. La legge costituzionale non ha però introdotto nel nostro ordinamento il referendum di indirizzo,si è limitata all'indizione di un singolo referendum,cosicchè una volta svoltasi la consultazione,il referendum di indirizzo è uscito dallo scenario costituzionale e la temporanea "rottura della Costituzione" si è sanata.

This document is available free of charge on StuDocu.com

Capitolo terzo-IL POTERE ESECUTIVO

Con la funzione amministrativa lo Stato apparato svolge un'attività effettiva e concreta diretta a raggiungere i suoi fini immediati(ad esempio,la cura dei rapporti internazionali,la difesa del territorio,la tutela dell'ordine pubblico e della salute,lo sviluppo economico ecc.). Questa complessa attività viene svolta dal Governo e dagli organi da esso dipendenti, oltre che dagli uffici dei minori enti pubblici territoriali. Essa può essere definita "attività amministrativa"e deve svolgersi secondo le direttive ed entro i limiti predisposti dalla Costituzione e dalla legge(principio di legalità). Assieme all'attività amministrativa in senso proprio,gli organi e gli enti di governo svolgono anche una diversa attività diretta alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

1. Gli organi del potere esecutivo- Il potere esecutivo è costituito da un complesso di organi(centrali e periferici)al vertice dei quali è posto il Governo come organo costituzionale. In specie,il Governo nel nostro ordinamento è un "governo a ministeri",l'apparato dello Stato è stato infatti diviso in apparati centrali di settore detti **ministeri** perché facenti capo ad un organo costituzionale,il **ministro**. Possono esservi tuttavia dei settori dell'amministrazione centrale che non vengono organizzati in ministero(ad es. Politiche europee,Protezione civile,Rapporti con il Parlamento,Rapporti con le Regioni) e che fanno capo,di regola,a dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio;gli organi direttivi posti a capo di tali settori assumono il nome di "**ministri senza portafoglio**", se entrano a comporre il Consiglio dei Ministri e partecipato all'attività di direzione politica del Governo,o di "**commissari straordinari del governo**" qualora si limitino a svolgere attività amministrativa e non entrino a far parte del Consiglio dei ministri. Del Governo possono entrare a far parte uno o più vice- presidenti del Consiglio. A norma dell'art.92 Cost. "Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri,che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri".Come chiaramente risulta da tale disposizione,il Governo è composto dunque da più organi **individuali**(Presidente del Consiglio ed i singoli ministri)e da un organo **collegiale**(il Consiglio dei Ministri),di modo che esso costituisce un organo **complesso**(formato da più organi). La disposizione dell'art.92 non si presterebbe a consentire la nomina di uno o più vicepresidenti del Consiglio,cui invece la prassi ha dato luogo nel passato(anche se non con continuità)e che è adesso prevista dall'art.8 della legge 23 agosto 1988 n.400 sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art.92 sembrerebbe richiedere infatti che i ministri siano in numero pari a quello dei ministeri,di modo che non sarebbero ammissibili componenti del Governo che svolgano compiti interamente politici e che,di conseguenza,non siano preposti ad un ramo della pubblica amministrazione. Allo stesso modo,anche la nomina di ministri senza portafoglio non rientrerebbe nella previsione dell'art.92,pur se è da riconoscere che la complessità dei compiti affidati al Governo può far si che si creino degli "spazi vuoti" che è opportuno affidare ad un ministro. In ogni caso i ministri senza portafoglio svolgono,a norma dell'art.9 comma I della legge 400 soltanto le funzioni loro delegate da Presidente del Consiglio sentito

il parere del Consiglio dei ministri. Ha fatto sorgere alcune perplessità l'istituzione di un **"Consiglio di Gabinetto"** avvenuta,per la prima volta,con deliberazione formale del Consiglio dei ministri nell'agosto 1983 ed ora prevista dall'art.6 della legge 400/1988 a norma del quale il Presidente del Consiglio,nello svolgimento delle funzioni di cui all'art.95 comma I Cost.,può essere coadiuvato da un Comitato che prende il nome di Consiglio di Gabinetto composto da ministri da lui designati,sentito il Consiglio dei ministri. Non è da escludere infatti che il concreto funzionamento del Consiglio di Gabinetto finisca col creare una distinzione di ruoli fra i ministri che verrebbero a ordinarsi(come è stato da più parti rilevato)in ministri di serie A (o "SUPERMINISTRI") e ministri di serie B. Sta di fatto che i ministri che compongono il Consiglio di Gabinetto svolgono,rispetto a quelli che ne sono esclusi,un'attività in più in ordine alla determinazione della politica generale del Governo e potrebbero,per ciò solo,acquisire una sorta di "PLUSVALORE POLITICO"rispetto agli altri. E non è da escludere nemmeno l'ipotesi che si manifesti la tendenza a trasformare il Consiglio di Gabinetto da organo interno di ausilio in un "SUPERGABINETTO",vale a dire nella sede effettiva in cui i partiti politici assumono le decisioni fondamentali che poi l'intero Consiglio dei ministri si limiterebbe a ratificare:rischio,questo,che potrebbe essere evitato,o comunque attenuato,facendo del Consiglio di Gabinetto una struttura "APERTA" agli interventi di quei ministri che possono essere interessati agli argomenti in discussione,secondo quanto è disposto dall'art.6 comma 2 della legge 400. E' da notare che negli ultimi anni il Consiglio di Gabinetto non è stato formato per scelta politica degli ultimi Presidenti de Consiglio,per evitare squilibri interni alla compagine governativa. Accanto a questi organi,vanno ad aggiungersi i **sottosegretari di Stato** e i **Viceministri**, che non entrano a far parte del Governo in senso stretto ed esercitano delle funzioni ora di rilevanza costituzionale,ora meramente amministrative. All'ordinamento della Presidenza del Consiglio provvede invece la citata legge 400,che nelle sue linee essenziali disciplina: le attribuzioni del Consiglio dei Ministri,del Presidente del Consiglio,dei Sottosegretari di Stato; i rapporti fra Stato,Regioni e Province autonome; la potestà normativa del Governo e l'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio. L'art.95 comma III della Costituzione,attuato con D.Lgs 30 luglio 1999 n.300 sull'organizzazione del Governo,stabilisce che il numero dei Ministri è fissato a 13,e precisamente: 1)Affari esteri;2)Interno;3)Giustizia;4)Difesa;5)Economia e finanze;6)Sviluppo economico;7)Politiche agricole,alimentari e forestali;8)Ambiente e tutela del territorio e del mare;9)Infrastrutture e Trasporti;10)Lavoro e politiche sociali;11)Istruzione,Università e Ricerca;12)Beni e Attività culturali;13)Salute. Per snellire il funzionamento dei pubblici apparati, sono state previste le **Agenzie** che svolgono attività tecnico-operative a carattere nazionale ed operano al servizio delle PP.AA. Per **pubblica amministrazione,** in una prima approssimazione, si intendono i pubblici uffici che entrano a comporre l'apparato amministrativo dello stato e degli altri enti pubblici. Tali uffici svolgono attività amministrativa **attiva, consultiva e di controllo**: mediante lo svolgimento del primo tipo di attività,la pubblica amministrazione mira a realizzare i fini che essa è chiamata a perseguire;con l'attività

This document is available free of charge on StuDocu.com

consultiva,gli organi ad essa preposti forniscono pareri agli organi dell'amministrazione attiva che devono provvedere in ordine ad un determinato oggetto(i pareri si distinguono in *facoltativi*, quando sono chiesti di iniziativa dell'organo attivo, *obbligatori*, quando l'organo attivo deve per legge richiederli, *vincolanti* quando l'organo attivo deve uniformarvisi).L'attività amministrativa di controllo infine è diretta a sindacare gli atti o l'operato degli organi di amministrazione attiva adottando come parametro sia regole giuridiche(controllo di legittimità)sia regole di buona amministrazione(controllo di merito).
Gli uffici della pubblica amministrazione possono essere distinti a seconda del settore in cui operano,settore che corrisponde,a livello di amministrazione statale,ad un ministero. Oltre agli uffici,centrali e periferici,dello Stato,entrano a far parte della pubblica amministrazione anche gli uffici di altri enti pubblici sia territoriali(Regioni,Province e Comuni),sia non territoriali(enti pubblici parastatali,consorzi amministrativi,camere di commercio ecc.).Gli atti posti in essere da questi uffici hanno la stessa forza e la stessa efficacia nei confronti dei cittadini rispetto agli atti amministrativi statali(caratteristica precipua dell'**autarchia** propria di questi enti).
Volendo dare uno sguardo d'insieme alla pubblica amministrazione, quindi,avremo che essa è composta dall'apparato dello Stato(centrale e periferico)e da quello delle Regioni,delle Province,dei Comuni e degli enti pubblici non territoriali. Più in generale,la pubblica amministrazione comprende tutti quegli uffici pubblici che svolgono funzioni sostanzialmente amministrative anche non facendo parte dell'amministrazione diretta o indiretta dello Stato. Quest'interpretazione estensiva della nozione,oltre a consentire una visione unitaria dell'attività amministrativa e dei principi che la regolano,vale anche a rafforzare la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione;infatti tale tutela è riconosciuta (a norma degli art.103 e 113 Cost.)quale che sia l'organo o l'ente che ha emanato l'atto lesivo della situazione giuridica soggettiva, purchè l'atto stesso costituisca esercizio di una funzione sostanzialmente amministrativa.

2. I principi costituzionali della P.A. - Un primo principio attiene all'organizzazione dei pubblici uffici(art.97 comma I),in base al quale questa deve essere determinata dalla legge formale; -ugualmente con legge si deve provvedere all'ordinamento della Presidenza del Consiglio ed alla determinazione dell'organizzazione,del numero e delle attribuzioni dei ministeri(art.95 comma III); -le disposizioni di legge che organizzano i pubblici uffici devono mirare ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. In particolare,**l'imparzialità della pubblica amministrazione è ribadita nell'art.98** comma I in base al quale "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"(e non già quindi di un partito o di una fazione). Altro principio ricavabile dalla Costituzione e relativo alla pubblica amministrazione è quello della **legalità**, sia in senso *formale*(l'amministrazione deve agire nei limiti della legge,ma è libera di compiere le sue scelte)che *sostanziale* (l'amministrazione deve agire conformemente alla legge). Secondo poi il principio della **democraticità**, l'attività amministrativa deve ispirarsi

alle effettive esigenze della collettività ed essere sottoposta a controllo da parte dei rappresentanti del popolo(attraverso il rapporto fiduciario che lega il Governo al Parlamento).E poiché l'amministrazione tanto più sarà democratica quanto più si permetterà ai cittadini di parteciparvi nelle sedi in cui gli interessi si concretizzano,l'art.5 dispone che "La Repubblica,una e indivisibile,riconosce e promuove le autonomie locali;(…)attua il più ampio decentramento amministrativo(…);adegua i principi e i metodi della sua legislazione all'esigenze dell'autonomia e del decentramento".Una forma di attuazione di tale principio è data dal riconoscimento del diritto generalizzato di accesso ai documenti amministrativi,al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa. Altro principio posto a garanzia della democraticità è quello sancito dall'art.97 comma III,in base al quale "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,salvo nei casi stabiliti dalla legge", giacchè il concorso è in linea teorica lo strumento più valido per garantire la selezione dei più capaci e meritevoli;tale principio va integrato con l'art.51 comma 1,in base al quale "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza,secondo i requisiti stabiliti dalla legge". A tal proposito,sono state recentemente costituzionalizzate(con la legge cost.n.1 del 2003)le c.d."AZIONI POSITIVE"in favore delle donne,allo scopo di rendere effettiva l'uguaglianza tra i sessi proclamata in via formale:con tale legge cost.è stato infatti aggiunto all'art.51 l'inciso che "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Sempre per garantire la selezione tecnica e neutrale dei migliori,si è imposto che la presenza di tecnici o esperti nelle commissioni dei concorsi debba essere se non esclusiva quanto meno prevalente,tale da garantire scelte fondate sull'applicazione di parametri neutrali e oggettivi,determinati soltanto dall'attitudine e dalla preparazione dei candidati(sent.Corte cost.n.453 del 1990 e n.333 del 1993).La Corte ha inoltre posto limiti molto rigorosi alla pratica del c.d.SPOIL SYSTEM,di origine americana,in base al quale i dirigenti della pubblica amministrazione cambiano al cambiare dei Governi e delle maggioranze politiche. La Corte ha precisato(con la sent.103 e 104 del 2007)che questa possibilità deve ritenersi limitata esclusivamente agli organi politici e non può estendersi a tutti gli altri. La Costituzione infine prevede un'ampia tutela dei cittadini nei confronti degli atti della pubblica amministrazione,stabilendo sia che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,secondo le leggi penali,civili e amministrative,degli atti compiuti in violazione di diritti. Secondo quest'ottica vanno quindi letti gli art.111("Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa")e l'art.113("Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti"). Una conclusione sui rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione,quindi fra il momento della libertà e quello dell'autorità,porta ad osservare in breve che la nostra Costituzione ha mantenuto fermo il principio della supremazia delle pubbliche autorità nei confronti dei privati,a differenza di altri sistemi normativi(come ad es.quello inglese)che pongono le une e

This document is available free of charge on StuDocu.com

gli altri sullo stesso piano nello svolgimento dei rapporti di diritto amministrativo. Questo principio mal si concilierebbe con altri principi costituzionali,quali quelli dell'eguaglianza e della democraticità,se non fosse stato temperato da alcune norme costituzionali poste a tutela del momento della libertà.

3. La formazione del governo- La formazione del Governo costituisce un *procedimento,* che come tale si sostanzia in una serie di atti successivi coordinati e diretti alla formazione di un atto finale(quale è appunto la nomina del Governo).Ora,questo procedimento ha inizio ogni qualvolta un Governo presenti le dimissioni e queste vengano accolte dal Presidente della Repubblica,per cui si rende necessario nominarne uno nuovo.
La nostra Costituzione è estremamente lacunosa al riguardo: essa infatti si limita a disporre (all'art.92 comma II) che "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,su proposta di questo,i ministri". Da questa norma si può ricavare quindi unicamente che titolare del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è il Presidente della Repubblica,e che la nomina dei ministri deve avvenire su proposta del Presidente del Consiglio.
Le norme che presiedono al procedimento di formazione del Governo sono pertanto in gran parte *non scritte* e costituiscono altrettante *convenzioni costituzionali*: come tali,queste norme possono subire delle modifiche nel tempo,sempre però nei limiti entro cui sono consentite dai principi derivanti dalla forma di governo parlamentare vigente in Italia. In base a questi principi,il Presidente della Repubblica dovrà procedere alla nomina di un Governo che abbia le maggiori probabilità di ottenere e mantenere la fiducia delle Camere,di modo che esso si connoti sin dall'inizio per una certa stabilità,al fine di evitare crisi governative. Ora,secondo il modello costituzionale e nel fisiologico funzionamento del sistema politico,il Presidente della Repubblica ha un ristretto margine di discrezionalità nella scelta del Presidente del Consiglio(mentre non ha nessun potere nella scelta dei ministri,formalmente demandata al Presidente del Consiglio),proprio perché egli dovrà tenere in debito conto le indicazioni che gli verranno date in Parlamento. Il passaggio dalla legge elettorale proporzionale a quella maggioritaria e da ultimo il ritorno ad un sistema proporzionale con premio di maggioranza(=la coalizione che ha ottenuto la maggioranza relativa e che non ha raggiunto il 55%dei voti ottiene un *premio di maggioranza*,acquisendo ugualmente 340 seggi) con la legge 207 del 2005,hanno introdotto de facto(per convenzione)un vincolo per il Presidente della Repubblica,nel senso che la nomina del Presidente del Consiglio dovrebbe cadere naturalmente sul leader dello schieramento politico-elettorale risultato vincitore nelle elezioni. (Ciò non toglie che,fermo restando questi principi,il Presidente della Repubblica possa alle volte esercitare un'effettiva influenza nella determinazione di una nuova maggioranza,per esempio dopo una crisi di Governo dovuta ad una frantumazione della maggioranza uscita dalle urne;nello svolgimento della sua azione di moderatore fra i diversi partiti che possono concorrere a formare il Governo,resta sottinteso che il Presidente della Repubblica dovrà sempre mantenersi al di fuori degli interessi strettamente partitici). In particolare,un ruolo attivo e propositivo può essere

assunto,anche se con somma cautela,dal Presidente della Repubblica in caso di "crisi del sistema" :per esempio,in questo quadro,alcuni Presidenti della Repubblica hanno seguito la prassi di conferire l'incarico delimitando contestualmente la formula politica del nuovo Governo,oppure fissando alcune linee del programma,oppure ancora dando indicazioni sui nomi dei ministri o sulle qualità che i futuri ministri dovessero possedere,e ancora ponendo all'incaricato limiti temporali per l'adempimento del suo compito ecc. Il procedimento di nomina del Governo inizia quindi con le **consultazioni**, che vengono svolte dal Capo dello Stato. Di fatti,dopo l'apertura della crisi di Governo(o dopo le elezioni)il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni(non previste dal testo costituzionale),con cui si apre il procedimento di formazione del Governo stesso. Il Capo dello Stato incontra quindi i presidenti dei gruppi parlamentari,accompagnati dagli esponenti più significativi dei rispettivi partiti,vale a dire i segretari dei partiti politici;egli consulta anche(più per una ragione di rispetto formale che per ottenere indicazioni rilevanti)i Presidenti delle due Camere e gli ex-Presidenti della Repubblica,nonché tutte le altre personalità che ritenga utile sentire per venire a conoscenza delle posizioni dei partiti in ordine alla formazione del nuovo Governo. Le personalità consultate esprimono quindi al Capo dello Stato il proprio parere in ordine alla situazione politica generale con riferimento specifico alla formazione del nuovo Governo, cosicchè,alla chiusura delle consultazioni,il Presidente della Repubblica avrà degli elementi di valutazione in base ai quali procederà al conferimento(verbalmente,e non più mediante un apposito decreto,come è avvenuto sino al 1958)dell'incarico a quella personalità politica che egli ritenga abbia le maggiori probabilità di formare il Governo. Tuttavia,può avvenire che,in condizioni particolarmente difficili(quando cioè i partiti non riescono a raggiungere un accordo per la formazione della maggioranza)il Capo dello Stato affidi ad una personalità(spesso il Presidente del Senato o della Camera)il c.d. "MANDATO ESPLORATIVO",vale a dire il compito di svolgere delle consultazioni,in modo da avere una visione più completa degli orientamenti delle forze politiche. Dal mandato esplorativo si distingue invece il c.d. "PREINCARICO",che si avrebbe quando il Presidente della Repubblica affida alla personalità politica,alla quale con ogni probabilità affiderà l'incarico,il compito di svolgere ulteriori consultazioni onde assumere(in questa posizione non ufficiale ma già di candidato in pectore all'ufficio di Presidente del Consiglio)elementi di chiarificazione per la formazione de nuovo Governo.
L'incaricato di regola non accetta semplicemente la nomina,ma si riserva di accettare,o meglio,accetta l'incarico CON RISERVA,ed inizia a sua volta una serie di consultazioni in un certo senso "minori"(che non assumono di fatti il carattere di ufficialità proprio di quelle svolte dal Presidente della Repubblica)dirette in primo luogo ad accertare in concreto quali possibilità vi siano di formare una maggioranza che faccia proprio un programma concordato fra i partiti che andranno a comporla,e in secondo luogo,qualora questa prima parte delle consultazioni sia andata a buon fine,a formare la lista dei futuri ministri. Nel caso in cui l'incaricato non riesca nel suo intento,tornerà dal Presidente della Repubblica e,sciogliendo la riserva,dichiarerà di rinunciare all'incarico. Qualora poi la rinuncia all'incarico sia dovuta

This document is available free of charge on StuDocu.com

all'impossibilità obiettiva di formare una maggioranza,il Presidente della Repubblica può o rinviare il Governo dimissionario(non,però in seguito ad una crisi parlamentare)alle Camere affinchè partiti e singoli parlamentari chiariscano ufficialmente e pubblicamente la loro posizione(nel dibattito e nell'eventuale susseguente votazione),oppure sciogliere le Camere,demandando così al corpo elettorale la decisione. Se invece l'incaricato avrà concluso positivamente i suoi colloqui,sottoporrà al Presidente della Repubblica la lista dei ministri e si dichiarerà pronto a presiedere il nuovo Governo. L'introduzione del sistema maggioritario ha prodotto i suoi effetti anche nel procedimento di formazione del Governo:i problemi di formazione della compagine ministeriale spesso infatti sono stati risolti dal leader della coalizione vincente prima dell'inizio delle consultazioni e pertanto il Presidente incaricato ha potuto in brevissimo tempo proporre al Capo dello Stato la lista dei ministri(così è avvenuto,ad esempio,per la formazione del governo Prodi nella XIII legislatura e del governo Berlusconi nella XIV).Nonostante la reintroduzione del sistema proporzionale(con la legge n.270 del 2005),continua a sussistere,per il meccanismo stesso del nuovo sistema elettorale,la proiezione bipolare della rappresentanza,che produce quindi i suoi effetti anche nel procedimento di formazione del Governo (infatti,in occasione del conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio all'on.Prodi,all'inizio della XV legislatura,e all'on.Berlusconi all'inizio della XVI,il nome del Presidente del Consiglio era già stato di fatto indicato dagli elettori,e al Capo dello Stato non è rimasto che prenderne atto). Si passa così alla fase conclusiva del procedimento,che vede la nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri con decreto del Presidente della Repubblica. Nominati il Presidente del Consiglio ed i ministri,il Governo è formato ma,prima di assumere le funzioni,i membri dell'esecutivo sono tenuti a prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica(art.93 Cost.).Infine,entro 10 giorni dal giuramento,il Governo dovrà presentarsi alle Camere per ottenerne la FIDUCIA,esponendo,a mezzo del Presidente del Consiglio,il suo programma. In realtà,nessuna disposizione costituzionale prevede espressamente la presentazione alle Camere del programma di governo,ma essa è chiaramente implicita nel sistema(oltre che consacrata dalla consuetudine);le Camere infatti non potrebbero votare la fiducia se non sulla base degli obiettivi che il Governo si propone di realizzare,obiettivi che di conseguenza il Governo dovrà necessariamente rendere noti non soltanto all'assemblea parlamentare,ma anche,più in generale,al Paese. La funzione del programma di governo è quindi di fondamentale importanza;esso infatti dopo il voto di fiducia diventa vero e proprio INDIRIZZO POLITICO dello Stato,e come tale,vincola Governo e Parlamento a darvi attuazione. Il ruolo effettivamente svolto dal programma è invece meno rilevante allorquando,a causa della disomogeneità della maggioranza,si rendono necessarie frequenti modifiche o aggiustamenti del programma originariamente concordato,o quando(come nel caso di Governi monocolori)si ritiene opportuno non assumere impegni nei confronti di schieramenti parlamentari non definiti o insicuri. In tali condizioni infatti i programmi risultano essere vaghi e generici,e per di più senza scadenze specifiche per la loro attuazione. In genere,modifiche o aggiustamenti del programma elettorale

sono possibili anche dopo le elezioni,a seguito di accordi nuovi intervenuti tra le componenti della coalizione o per necessità nascenti dai rapporti con l'opposizione. Nel periodo che intercorre tra il giuramento e il voto di fiducia,secondo quanto si deduce chiaramente dall'art.93 Cost.,il Governo è immesso nelle sue funzioni(è quindi Governo a tutti gli effetti):la sua attività incontra però dei limiti in attesa che si instauri il rapporto fiduciario con il Parlamento. Tali limiti consistono nell'attività stessa di indirizzo politico,che il Governo non può svolgere prima che le Camere ne approvino il programma concordato concedendogli la fiducia. Questo limite in effetti trova una giustificazione logica nel sistema:i 10 giorni di tempo dalla sua formazione vengono infatti concessi al Governo proprio per consentirgli di disporre e perfezionare il programma politico che intende sottoporre alle Camere. Uno dei primi atti del Consiglio dei ministri è la designazione dei SOTTOSEGRETARI DI STATO,che vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. I sottosegretari(che la Costituzione non menziona)non fanno parte del Governo e non sono pertanto organi costituzionali;non hanno quindi attribuzioni proprie,ma soltanto quelle delegategli dal singolo ministro,e in genere coadiuvano il ministro stesso nello svolgimento delle sue funzioni. Possono tuttavia intervenire alle sedute delle Camere e delle commissioni parlamentari,sostenere la discussione in conformità alle direttive del Governo,rispondere a interrogazioni e interpellanze. Fra i vari sottosegretari,una posizione di rilievo è venuto ad assumere il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che svolge le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri,con una serie di attribuzioni rilevanti:questo segretario può infatti assistere alle sedute del Consiglio dei ministri(SENZA DIRITTO DI VOTO). Con la legge n.81 del 2001 è stata inoltre introdotta la figura del vice ministro,anch'essa non contemplata dal testo costituzionale;possono essere nominati viceministri al massimo 10 sottosegretari,se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali o di più direzioni generali. In questo caso la delega,conferita dal ministro competente,viene approvata dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio. L'introduzione di questa nuova figura istituzionale non modifica però in modo sostanziale la struttura del Governo:infatti i viceministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio,d'intesa con il ministro competente,a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri SENZA DIRITTO DI VOTO per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

4. I comitati interministeriali ed i comitati di ministri- I comitati interministeriali sono costituiti da più ministri e alcuni di essi anche da funzionari ed esperti. Loro compito è quello di preparare e coordinare l'attività del Consiglio dei ministri in determinati settori(in ciò aderendo ad un preciso dettato costituzionale secondo il quale l'attività della pubblica amministrazione deve rispondere al CRITERIO DELL'EFFICIENZA). Dubbi di costituzionalità sorgono invece quando si attribuiscono ad alcuni di questi comitati poteri decisionali in materie che dovrebbero essere invece riservate alle competenze del Consiglio,perché in tal modo la politica del Governo non viene più ad essere determinata collegialmente ma soltanto da un ristretto numero di ministri. Esempi di comitati interministeriali sono il

This document is available free of charge on StuDocu.com

CIPE(Comitato interministeriale programmazione economica),il Consiglio supremo di difesa(presieduto dal Presidente della Repubblica) e il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica(CISR). A norma dell'art.5 comma 2 della legge 400 del 1988 inoltre il Presidente del Consiglio può disporre,con proprio decreto,l'istituzione di particolari comitati di ministri,con il compito di esaminare,in via preliminare,questioni di comune competenza,eventualmente anche avvalendosi di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione.

5. La funzione amministrativa- Per bene intendere le funzioni svolte dal Governo,bisogna anzitutto tenere presente che i ministri e lo stesso Presidente del Consiglio assumono una duplice veste:di ORGANI BUROCRATICI,in quanto posti gerarchicamente al vertice del rispettivo dicastero(nel caso dei ministri senza portafoglio,del settore dell'amministrazione ad essi affidato),e di ORGANI DI GOVERNO,in quanto determinano collegialmente l'indirizzo amministrativo. E' evidente che queste due funzioni non sono tra di loro autonome ma al contrario strettamente interdipendenti,poiché l'indirizzo amministrativo di ogni ministero deve svolgersi in armonia con la politica generale predisposta collegialmente dal Consiglio. Accanto a quest'attività,si pone quella c.d. di "ALTA AMMINISTRAZIONE",che si pone in effetti al confine,al varco fra l'attività di indirizzo politico e quella propriamente amministrativa. Fra gli atti di alta amministrazione sono infatti compresi: il conferimento degli uffici più alti nella gerarchia statale,degli enti pubblici e delle amministrazioni speciali;la dichiarazione di pericolo pubblico;gli atti di preparazione dei trattati e degli accordi internazionali di natura politica e militare;gli atti concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e le confessioni diverse da quella cattolica ecc. Tali atti vengono di regola deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica(secondo quanto sancito dall'art.2 comma III della legge 400 del 1988).

6. L'attività di direzione politica- Nonostante la politica del Governo venga determinata collegialmente dal Consiglio dei Ministri,la nostra Costituzione ha tuttavia riservato una particolare posizione di preminenza al Presidente del Consiglio("PRIMUS INTER PARES"). Secondo quanto sancito dall'art.95 Cost. infatti "Il Presidente del Consiglio dei ministri DIRIGE la politica generale del Governo e NE E' RESPONSABILE. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,promuovendo e coordinando l'attività dei ministri". Bisogna quindi anzitutto sottolineare che LA DIREZIONE POLITICA GENERALE del Governo non implica anche IL POTERE DI DETERMINAZIONE della stessa,che invece è attribuito appunto al Consiglio dei ministri considerato come organo collegiale. Tuttavia,questa direzione politica generale implica una serie di poteri specificati dall'art.5 della legge 400/'88,che fanno del Presidente del Consiglio l'organo che presiede allo svolgimento stesso dell'indirizzo politico:egli è quindi l'organo cui spetta di assicurare che il programma enunciato dal Governo davanti alle Camere venga effettivamente realizzato. Spetta quindi al Presidente del Consiglio(sempre a norma dell'art.5)il potere di indirizzare ai ministri le direttive politiche e

amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri,coordinare e promuovere l'attività dei ministri stessi ecc. A questa sorta di posizione di "preminenza" del Presidente(che prende corpo in un triplice potere di DIREZIONE,di IMPULSO e di COORDINAMENTO),corrisponde una parallela responsabilità politica,nel caso in cui le Camere ritengano che il Governo non rispetti gli impegni presi al momento della sua formazione. Accanto alla maggiore responsabilità del Presidente del Consiglio si pone però anche la responsabilità dei singoli ministri,sia come organi di governo che come organo burocratici ("I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri,e individualmente degli atti dei loro dicasteri",art.95 comma II Cost.).

7. Separazione tra politica ed amministrazione- Il D.Lgs n.80 del 1998(le cui norme sono ora confluite nel D.Lgs.n.165 del 2001,che ha abrogato gran parte della disposizioni contenute nel D.Lgs.n.80 del 1998)ha precisato e definito il principio della SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO POLITICO E GESTIONE AMMINISTRATIVA:a partire da tale data pertanto si è scissa la responsabilità politica da quella amministrativa,la funzione programmatoria e di controllo spettante agli organi legittimati(direttamente o indirettamente)dalla volontà popolare,da quella degli organi tecnico-amministrativi aventi il compito di attuare i programmi e le direttive.

8. Le funzioni normative. Leggi in senso formale e l. in senso materiale- Il potere esecutivo non si limita a svolgere funzioni amministrative ed attività di direzione politica,ma in deroga al principio della divisione dei poteri(secondo il qual la funzione normativa dovrebbe essere riservata in via esclusiva alle Camere)pone anche in essere norme costitutive dell'ordinamento giuridico dello Stato. Tale funzione viene detta MATERIALMENTE LEGISLATIVA per porre in evidenza come gli atti normativi predisposti da organi esecutivi abbiano,di regola,CONTENUTO TIPICO della legge ma non la FORMA,che è data alla legge dal suo particolare procedimento di formazione da parte delle Camere. Per LEGGI IN SENSO FORMALE si intendono quindi tutti gli atti deliberati dalle due Camere o comunque da un organo cui è attribuita la funzione legislativa dalla Costituzione(Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano)secondo il procedimento disciplinato dagli art.70 Cost.e seguenti,negli Statuti regionali e nei regolamenti delle Camere e dei Consigli regionali. Non vanno pertanto incluse tra le leggi formali(proprio perché posti in essere tramite un procedimento diverso da quello legislativo)i c.d. ATTI BICAMERALI NON LEGISLATIVI,quali quelli diretti a costituire commissioni bicamerali di inchiesta,a deliberare lo stato di guerra,a deliberare sullo scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana (art.8 Statuto Sicilia)o a ricorrere alla Corte costituzionale in caso di conflitto o attribuzioni fra il Parlamento ed un altro potere dello Stato. LEGGI IN SENSO MATERIALE sono invece tutti gli atti (quale che siano gli organi che li pongono in essere e quale che sia il loro procedimento di formazione) che contengono norme giuridiche. Ne consegue che gli atti del potere esecutivo che

This document is available free of charge on StuDocu.com

contengono norme giuridiche sono leggi in senso soltanto materiale. Il criterio che consente di distinguere la legge dagli atti aventi forza o valore di legge va pertanto rinvenuto sul piano formale(vale a dire nel diverso procedimento di formazione)e non su quello contenutistico. I due atti hanno infatti la medesima forza attiva e passiva e,quanto al contenuto,non è possibile operare alcuna distinzione netta e precisa fra di loro. In generale,gli atti normativi del potere esecutivo si distinguono a seconda che abbiano o non abbiano la stessa efficacia formale della legge.Così sono equiparati alla legge(cioè hanno la stessa efficacia)i decreti legge e i decreti legislativi,mentre hanno efficacia inferiore a quella della legge i regolamenti.

9. I decreti legge- A norma dell'art.77 Cost. il Governo può,in casi straordinari di necessità e di urgenza,adottare,sotto la sua responsabilità,provvedimenti provvisori con forza di legge,ma deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere,che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Già da questa prima affermazione possiamo notare che il potere del Governo di adottare decreti-legge assume un carattere di eccezionalità, essendo la regola che le fonti di primo grado o vengono emanate direttamente dalle Camere(nel caso della legge formale)o dal Governo su delegazione delle Camere(nel caso dei DECRETI LEGISLATIVI). L'eccezionalità del decreto legge è già resa evidente dall'espressione "PROVVEDIMENTI PROVVISORI",con i cui i decreti-legge vengono appunto designati nell'art.77,per la loro efficacia limitata nel tempo e per le conseguenze giuridiche della loro mancata conversione da parte delle Camere. Presupposto essenziale perché il Governo possa adottare un decreto-legge è la sussistenza di un caso straordinario di necessità e di urgenza. In altri termini,il Governo può sostituirsi alle Camere e approvare un atto avente la stessa efficacia della legge soltanto quando la STRAORDINARIETÀ del caso e la necessità ed urgenza di provvedere impediscano alle Camere di intervenire tempestivamente(al fine di evitare il lungo procedimento di formazione della legge).La straordinarietà del caso può essere associata ad esempio ad una grave calamità naturale(un'alluvione,un terremoto)ma non può essere ricondotta unicamente a quest'interpretazione(naturalistica,per così dire):si sarebbe di fatti limitata la straordinarietà a casi del tutto sporadici .Questo requisito è perciò stato inteso riferendolo alla STRAORDINARIA NECESSITA' E URGENZA DI PROVVEDERE,dandone quindi un significato e un'interpretazione di natura POLITICA,e quindi non esclusivamente limitata al caso fenomenologico,oggettivo:ad esempio,straordinaria necessità e urgenza a provvedere si ha anche nel caso di una sentenza della Corte costituzionale che crei un vuoto nel sistema normativo e tale vuoto richieda di essere immediatamente colmato,oppure ancora il caso dei c.d. DECRETI CATENACCIO,impiegati per apportare con effetto immediato variazioni a prezzi o a tariffe di dazi doganali(in genere decreti finanziari per evitare l'evasione fiscale),ad es. l'aumento del prezzo della benzina o del prezzo dei tabacchi.
In realtà,l'uso che del decreto-legge è stato fatto dai vari Governi repubblicani che si

sono succeduti fino ad ora non è sempre stato aderente alla ratio della disposizione,basti osservare l'alto numero di decreti adottati fino ad oggi,non certamente giustificato dall'esistenza di altrettanti casi straordinari di necessità e urgenza. Per cui è stato rilevato che il ricorso al decreto-legge è diventato "un modo frequente di accelerare o in un certo senso eludere il procedimento canonico di formazione della legge" e che come tale,il decreto legge finisce con l'essere "una sorta di disegno di legge a urgenza garantita"(Predieri). Inoltre,il presupposto dell'URGENZA è stato alle volte clamorosamente smentito quando il Governo ha dato attuazione solo in parte o tardivamente alle norme contenute nel decreto,o ancora quando l'esecuzione di un decreto-legge è stata sospesa dal Governo stesso. La Corte costituzionale ha affermato la propria competenza a verificare il "rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla pre-esistenza dei presupposti di necessità e urgenza",precisando che il proprio controllo di legittimità differisce da quello operato dal Parlamento in sede di conversione,avente un carattere squisitamente politico(sent.n.29 del 1995). In virtù di quest'orientamento,è stata ad es.dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma contenuta in un decreto-legge a causa dell'EVIDENTE CARENZA DEI PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI dell'esercizio del potere di decretazione d'urgenza da parte del Governo (con le due sentenze 171 del 2007 e n.128 del 2008).
Sempre con la stessa sentenza n.29 del '95,la Corte ha inoltre statuito che il vizio dei presupposti del decreto si trasmette in automatico alla legge di conversione dello stesso,per cui la Corte è legittimata a giudicare sulla stessa legge:si tratta di un vero e proprio espediente procedurale,in quanto la Corte,visti i tempi troppo brevi entro i quali avrebbe dovuto emettere la sentenza(prima dello scadere dei 60 giorni a seguito del quale il decreto scade o viene convertito in legge),non era mai riuscita,fino a quel momento,ad emettere una sentenza sul decreto. La brevità del termine di decadenza dei decreti-legge rendeva infatti estremamente difficile il ricorso alla Corte costituzionale,se non fosse stato affermato dalla stessa Corte questo principio per cui il controllo di legittimità sul decreto in un certo senso si "trasferisce" sulla legge di conversione. Assolutamente incostituzionale appare poi la prassi,largamente seguita in passato,di adottare un nuovo decreto-legge,in caso di mancata conversione del precedente,ripetitivo di quello decaduto. La Corte costituzionale ha di fatto posto fine alla prassi della REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI dichiarandola illegittima perché alterativa della natura provvisoria della decretazione d'urgenza:il decreto legge non convertito e tuttavia reiterato,in tutto o in parte,dal Governo,è quindi stato dichiarato incostituzionale in violazione dell'art.77 Cost.con la sent.n.360 del 1996.Tant'è che con la sent.84 del 1996 la Corte aveva già stabilito che,in caso di reiterazioni senza sostanziali variazioni dei decreti non convertiti,il controllo di legittimità operato dalla Corte si trasferisce sui nuovi decreti,riproduttivi di quelli precedenti. Ora,la responsabilità di questo stato di cose va in effetti fatta risalire non solo al Governo,ma anche e soprattutto al Parlamento,che ha spesso e volentieri convertito in legge i decreti anche quando non ricorrevano i presupposti dei casi straordinari di necessità ed urgenza. Il giudizio del Parlamento si muove infatti,come è ovvio,nella sfera della discrezionalità politica:per questo motivo si ci è

This document is available free of charge on StuDocu.com

posti anche dinanzi all'interrogativo se non sia effettivamente auspicabile un più vigile controllo da parte del Presidente della Repubblica sull'intero procedimento emanativo del decreto legge e sulla sua conversione. A sostegno di questa tesi,si è sostenuto che sebbene il Presidente non abbia un potere d'arresto nei confronti dei provvedimenti deliberati dal Governo,i suoi rilievi sulla mancanza dei presupposti voluti dalla Costituzione per l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza potrebbero comunque sia costituire un deterrente affinchè del decreto legge non si faccia un uso sconsiderato e contrario alla Costituzione. Per agire nell'ambito ed entro i limiti delle sue attribuzioni costituzionali,il Presidente della Repubblica dovrebbe tuttavia limitare il proprio intervento ai casi di EVIDENTE,MACROSCOPICA carenza di tali presupposti,laddove non si riscontrano palesemente e oggettivamente questi presupposti. In questa direzione sembra ad esempio essersi mosso il Presidente Napolitano quando nel febbraio del 2009 si è opposto all'emanazione di un decreto legge che il Governo si accingeva ad approvare per vietare l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale nei confronti di soggetti non in grado di provvedere a se stessi. La legge 400 del 1988 ha posto una serie di limitazioni in merito all'adozione dei decreti-legge .In particolare,i decreti devono indicare,nel preambolo,le circostanze straordinarie di necessità e urgenza che ne giustifichino l'adozione. Inoltre,il Governo non può,mediante decreto legge: conferire deleghe legislative; provvedere nelle materie indicate dall'art.72 IV comma(RISERVA DI ASSEMBLEA); rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge anche da una sola delle due Camere; regolare rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti; ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento(vizi non formali,sostanziali). Infine, i decreti devono contenere misure di immediata applicazione,e il loro contenuto deve essere SPECIFICO, OMOGENEO(qualora non lo fosse,fosse anzi eterogeneo,ciò sarebbe chiaramente significativo di un venir meno del requisito della straordinarietà e dell'urgenza) e CORRISPONDENTE AL TITOLO. A norma dell'art.77 comma II,il Governo adotta i decreti-legge sotto la sua responsabilità. Il che significa che esso dovrebbe rispondere dinanzi alle Camere tutte le volte in cui le stesse,negando la conversione del decreto,giudichino che abbia usato del suo potere in maniera illegittima,senza cioè che ricorressero i presupposti. Le Camere quindi esercitano un controllo sull'esistenza dei presupposti richiesti dal comma II dell'art.77 per l'adozione dei decreti legge. A norma, infatti, dell'art.96 bis del R.C.D. il Governo,nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione,deve dare conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto,e deve inoltre descrivere gli effetti previsti dalla sua attuazione. Al senato,a norma dell'art.78 del regolamento,qualora la Commissione permanente esprima un parere contrario in merito all'esistenza dei presupposti richiesti dall'art.77,questo parere viene trasmesso al Presidente del Senato che lo sottopone al voto dell'Assemblea:se l'Assemblea si pronuncia per la non sussistenza,il disegno di legge di conversione si intende respinto. Si tratta tuttavia,come già detto,di un controllo eminentemente politico,soggetto alle diverse valutazioni politiche del momento,che

pertanto rare volte si è effettivamente concluso con una pronuncia negativa. I decreti legge hanno un'efficacia temporalmente limitata a 60 giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:il giorno stesso della loro emanazione(e per tale giorni si intende quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta,e non quello dell'adozione da parte del Governo)devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge. Più esattamente,il Governo presenta alle Camere per la conversione in legge la stessa legge di conversione in legge del decreto legge. Entro i 60 giorni,le Camere potranno: non prendere in esame il disegno di legge di conversione o prenderlo in esame ma non esaurire il procedimento di formazione della legge; prenderlo in esame e non approvarlo; prenderlo in esame e approvarlo convertendo in legge formale il decreto-legge(e apportandovi eventualmente tutte le modifiche ritenute opportune). Nelle prime due ipotesi,il decreto legge non convertito in legge perde efficacia SIN DALL'INIZIO(vale a dire RETROATTIVAMENTE,dal momento della sua entrata in vigore,ed è da considerare come mai esistito quale fonte a livello legislativo (sent. Corte cost. n.307 del 1983). Ora,tuttavia,la disposizione costituzionale contenuta nell'art.77 comma III a norma della quale i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione,resta di fatto del tutto inattuata qualora il decreto abbia comunque sia prodotto EFFETTI IRREVERSIBILI(basti pensare ad un decreto legge non convertito che abbia inciso sulla libertà personale).Si tratta di effetti per così dire "naturali":gli effetti GIURIDICI (sorti sulla base dei decreti non convertiti)vengono invece ad essere sanati dalla cosiddetta "LEGGE RISANATORIA",di competenza esclusiva del Parlamento(RISERVA). L'art.35 del regolamento del Senato prescrive che per i disegni di legge di conversione è necessaria e obbligatoria la discussione e la votazione da parte dell'assemblea,individuando in tal modo una RISERVA DI LEGGE DI ASSEMBLEA oltre a quelle previste dall'art 72 comma IV Cost. E' evidente che il procedimento di conversione di un decreto legge dovrebbe coerentemente arrestarsi qualora venissero meno quelle situazioni di necessità ed urgenza che ne avevano legittimato l'adozione da parte dell'esecutivo;in tal caso spetterebbe al Governo adottare un nuovo decreto,contrario al precedente,che lo annulli. Altra questione è quella che attiene alla possibilità di apportare emendamenti al decreto-legge. La tesi secondo la quale le Camere,in sede di conversione,non potrebbero modificare il decreto-legge(secondo la logica del "PRENDERE O LASCIARE")ha dato luogo a diverse perplessità ed è stata comunque sia generalmente superata dalla prassi parlamentare. Il punto controverso è invece quello relativo all'efficacia ex tunc o ex nunc degli emendamenti,anche se l'opinione ormai prevalente sembra essersi orientata nel senso che gli emendamenti acquistano efficacia ex nunc(in particolare quando si tratti di EMENDAMENTI AGGIUNTIVI o MODIFICATIVI):vale a dire dall'entrata in vigore della legge di conversione,e più precisamente,dalla pubblicazione della stessa(salvo diversa disposizione della legge),come peraltro dispone l'art.15 comma 5 della legge 400/1988. *LIMITI ALLA DECRETAZIONE D'URGENZA: L'art.15 della legge 400 stabilisce(o meglio elenca)espressamente i limiti alla decretazione d'urgenza,che rinviano a precise disposizioni costituzionali: deleghe legislative(art.76),materie riservate all'assemblea secondo il IV comma*

This document is available free of charge on StuDocu.com

dell'art.72 Cost.,ratifica dei trattati internazionali(art.80), delle leggi di bilancio e dei consuntivi (art.81),materie coperte da riserva costituzionale,non può ripristinare disposizioni annullate dalla Corte per vizi di contenuto(per violazione dell'art.137 e del giudicato della Corte);non può reiterare decreti bocciati da una delle due Camere e quindi non convertiti.

10. I decreti legislativi- Il Governo può adottare decreti aventi forza di legge anche senza che ricorrano casi straordinari di necessità e di urgenza. In situazioni di normalità,però,perché il Governo possa emanare tali atti è necessario che l'esercizio della funzione legislativa gli venga espressamente delegato dalle Camere a mezzo di una legge che assume il nome di LEGGE DELEGA(o DI DELEGAZIONE).Bisogna però sottolineare il fatto che le Camere delegano al Governo non già la TITOLARITA' della funzione legislativa(che rimane esclusiva del Parlamento)bensì solo e unicamente l'ESERCIZIO di questa funzione. Di regola le Camere ricorrono alla delega nei casi in cui la materia da disciplinare sia molto complessa,richieda competenze eccessivamente tecniche o un lungo procedimento di formazione della legge,per cui il Governo appare come l'organo più qualificato a predisporre i provvedimenti legislativi(basti fare l'esempio dei codici,che sia per i loro numerosi articoli sia per la specialità della materia mal si presterebbero ad essere approvati dalle assemblee legislative e sono stati infatti emanati in Italia ricorrendo a decreti legislativi. Allo stesso modo i testi unici,raccolte di norme legislative emanate successivamente nel tempo e coordinate fra loro mediante modifiche e comportamenti in modo da assicurare la loro organicità). Innanzitutto,la delega(quale istituto di applicazione generale del diritto che presuppone un conferimento di poteri dal delegante nei confronti del delegato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla stessa)che conferisce il Parlamento non può essere implicita(e quindi tacita),deve anzi essere chiara,visibile(tant'è che dopo la legge 400/1988 la stessa deve auto identificarsi come tale). Deve,oltretutto,essere esaminata e/o approvata unicamente in aula(RISERVA DI ASSEMBLEA)e non già nelle singole commissioni. Qualora il decreto valichi le condizioni poste dalla legge di delega risulta costituzionalmente illegittimo:la legge delega diviene pertanto vero e proprio parametro interposto,misura,criterio della costituzionalità del decreto. A norma dell'art.76 Cost.,la legge con la quale le Camere delegano al Governo l'esercizio della funzione legislativa deve quindi contenere: la determinazione dei PRINCIPI e dei CRITERI DIRETTIVI ai quali il Governo dovrà attenersi nel predisporre i decreti legislativi; l'indicazione del LIMITE DI TEMPO entro il quale il Governo dovrà emanare il decreto; l'OGGETTO DEFINITO sul quale il Governo potrà legiferare. 1) LIMITI TEMPORALI: Il limite temporale è rappresentato dalla DATA DI SCADENZA della delega(esplicita o implicita che sia:non è ancora stato raggiunto un accordo in dottrina).Il termine temporale della delega decorre a partire dall'entrata in vigore della stessa legge delega e si considera rispettato allorquando è intervenuta l'emanazione presidenziale(perciò il decreto viene in genere inviato 20 giorni prima all'Ufficio di Presidenza della Repubblica).Il Governo inoltre è tenuto,a norma dell'art.14 comma IV della legge n.400 del 1988 a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti legislativi qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i 2 anni(quando cioè la delega è ULTRABIENNALE). L'ipotesi dell'inadempienza dovuta alla mancata conclusione

del procedimento di formazione del decreto legislativo entro il termine prefissato fa sorgere la responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere(sent. n.8 del 1977 della Corte).
2)OGGETTO DELLA DELEGA: Il principio basilare in merito all'oggetto della delega è che non si può conferire una delega su un'intera materia,sulla quale vale il monopolio della funzione legislativa da parte delle Camere. L'unico caso riconosciuto di c.d."DELEGA IN BIANCO"è quella relativa allo stato di guerra:al di fuori di questo caso,la delega avviene sempre e unicamente per oggetti ben determinati e specificati appunto dalla legge di delega. Al fine di evitare un'errata interpretazione dell'oggetto,per rintracciare il significato stesso dell'oggetto delegato si fa sempre valere IL CRITERIO RESTRITTIVO e si cerca sostanzialmente di risalire al significato generalmente ricondotto a determinate espressioni(costitutive dell'oggetto)dal legislatore storico,attraverso una sorta di processo di "RICOGNIZIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI"(ammesso solo in questo caso specifico),al fine di arrivare a comprendere come effettivamente queste espressioni debbano essere intese,secondo quanto stabilito dalla Corte con la sent.292 del 2000. Non possono essere oggetto di delega(c.d."OGGETTI NON DELEGABILI"): - leggi di ratifica dei trattati internazionali; -leggi di allocazione delle risorse(legge di stabilità; -legge di bilancio(art.81)in quanto su di essa grava una riserva di legge formale del Parlamento in attuazione della funzione di controllo; -materie disciplinate da leggi rinforzate.3) PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: Principi e criteri direttivi costituiscono il LIMITE CONTENUTISTICO del decreto. Per PRINCIPI si intende una prima disciplina generale degli oggetti trattati;costituisce quindi una prima specificazione qualitativa,che è pertanto rivolta all'OGGETTO del decreto legislativo. Con i CRITERI DIRETTIVI invece si individuano i mezzi,le azioni,gli strumenti cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega,così come sostenuto dallo stesso Angelo Antonio Cervati. Sono quindi rivolti al Governo. E' sicuramente in questo modo che viene limitata maggiormente la discrezionalità del Governo.E' ad ogni modo facile e palese verificare l'attinenza della delega ai limiti temporali e all'oggetto:molti sono invece i casi in cui il Governo ha male interpretato o non ha applicato i principi e i criteri direttivi. Secondo la Corte(sent.n.3 del 1957)bisogna far riferimento alla norma interposta,vale a dire alla legge di delega. Bisogna tuttavia notare che con la legge delega il Parlamento può porre al Governo altri limiti oltre quelli(inderogabili)previsti nell'art.76 Cost.Così ad esempio può(secondo una prassi ormai corrente)imporre l'obbligo sentire il parere(talvolta anche vincolante)di determinate commissioni parlamentari o di riprodurre nel decreto legislativo alcune disposizioni contenute nella stessa legge di delega;ancora,se il Parlamento decide di legiferare su parte dell'oggetto della delega è assolutamente legittimato a farlo. Tali limiti devono tuttavia essere già esplicitati nel Preambolo della legge delega. La Corte cost. ha cercato di contenere l'eccessivo ricorso alle deleghe legislative con una serie di pronunzie che individuano limiti sempre più rigorosi. La determinazione dei criteri e dei principi direttivi(ed eventualmente del testo di alcuni disposizioni da inserire nel decreto legislativo)porta ad una interdipendenza fra legge delegante e decreto legislativo,che configura pertanto una

This document is available free of charge on StuDocu.com

compartecipazione del Parlamento all'esercizio del potere legislativo da parte del Governo.
C'è da dire che nel tempo è occorsa una vera e propria evoluzione in merito alla possibilità di applicare la delega: la tesi più risalente,appoggiata da parte della dottrina,sostiene che la delega sia esercitabile (UNA ACTUM";la prassi è andata invece orientandosi in direzione contraria. In particolare,l'art.15 della legge 400/1988 ha riconosciuto un esercizio per così dire FRAZIONATO DELLA DELEGA(purchè il termine venga effettivamente rispettato).Tale prassi è stata diffusa soprattutto per i decreti cosiddetti INTEGRATIVI e CORRETTIVI,per cui il legislatore stabilisce contestualmente che il Governo potrà tornare su questi decreti a integrarli e/o correggerli(nel rispetto però sempre dei principi e dei limiti posti,ai quali la delega correttiva non può comunque sia disattendere e deve anzi porsi sempre in conformità rispetto alla delega originaria,può tutt'al più introdurre un qualcosa di aggiuntivo). Alla legge delega inoltre va riconosciuta,secondo parte della dottrina,un'efficacia formale consistente nel legittimare il Governo all'esercizio della funzione legislativa,di modo che essa è da ritenere per quest'aspetto una LEGGE MERAMENTE FORMALE,e quindi una FONTE SULLA PRODUZIONE(la Corte l'ha definita "fonte di un potere governativo"nelle sent.111 del 1972 e 91 del 1974).Ma la sent.n.224 del 1990 definisce invece la legge delega "un vero e proprio atto normativo",quindi con efficacia erga omnes. Ovviamente,se alla legge delegante(legge delega)non segue la legge delegata(decreto legislativo),la prima resta un atto meramente formale;ne consegue che la legge delega acquista efficacia sostanziale se e in quanto il Governo emani il decreto legislativo. Per cui mentre la legge delega condiziona la validità del decreto legislativo,questo condiziona l'efficacia sostanziale della legge delega. Secondo invece una tesi diversa(convalidata dalla sent.224 del 1990 della Corte)alla legge delega bisogna riconoscere la natura di fonte direttamente produttiva di norme giuridiche:l'accoglimento di questa tesi comporta l'impugnabilità delle disposizioni di legge dinanzi alla Corte,qualora queste disposizioni si pongano in contrasto con norme costituzionali o siano idonee a ledere la sfera di competenza di una Regione.
Ad ogni modo,il procedimento di formazione della legge delega deve essere quello ordinario,e la stessa è gerarchicamente superiore al decreto. Il decreto legislativo viene deliberato dal Consiglio dei ministri(e cioè dal Governo nella sua collegialità)e emanato formalmente con decreto del Presidente della Repubblica.

11. I regolamenti - *Con il termine "REGOLAMENTO"si designano atti normativi difficilmente riconducibili a tipologie unitarie. Abbiamo già visto infatti che esistono regolamenti che si pongono quale espressione dell'autonomia organizzativa delle Camere e degli altri organi costituzionali,che hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti,garantita dalla stessa Costituzione;esistono poi regolamenti emanati dagli organi delle Regioni e degli enti locali ed anche,importantissimi,i regolamenti dell'Unione europea. Regolamenti sono poi emanati da un'infinità di organismi pubblici e privati(si pensi ai regolamenti condominiali). Il termine insomma è impiegato per indicare le più svariate tipologie di atto normativo. In alcuni casi però il termine regolamento designa atti tipici,fonti dell'ordinamento giuridico generale:è questo il caso dei REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI,categoria in cui rientrano i REGOLAMENTI*

DELL'ESECUTIVO(a loro volta divisi in REGOLAMENTI GOVERNATIVI e REGOLAMENTI MINISTERIALI o INTERMINISTERIALI),i REGOLAMENTI REGIONALI e i REGOLAMENTI DEGLI ENTI LOCALI. La tradizionale definizione dei regolamenti come atti "SOSTANZIALMENTE LEGISLATIVI" ma "FORMALMENTE AMMINISTRATIVI"rispecchia ancora bene l'attuale realtà soprattutto dei regolamenti dell'esecutivo:i regolamenti infatti non si distinguono dalle leggi ordinarie per contenuto o per importanza(vi sono leggi di scarsa importanza,le c.d."LEGGINE",e vi sono regolamenti che,al contrario,dettano la disciplina normativa di settori di rilevante interesse). I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO sono atti normativi spesso complessi,ma emanati dagli organi dell'esecutivo(infatti hanno sempre la forma del decreto)attraverso una procedura che non ha le garanzie di controllo parlamentare che caratterizzano le leggi e gli atti con forza di legge. Quale spazio normativo possa occupare il regolamento dell'esecutivo dipende dalla legge:questo perché il regolamento dell'esecutivo è una FONTE SECONDARIA,sottoposta nella gerarchi delle fonti alle FONTI PRIMARIE,cioè alla legge e agli atti con forza di legge. Appartiene alla logica della gerarchia delle fonti che ogni fonte trovi il proprio fondamento nelle fonti immediatamente superiori.Quindi è nella legge ordinaria che va ricercato il fondamento dei regolamenti,vale a dire le condizioni per la loro validità;da qui derivano due importanti conseguenze: a)mentre per le fonti primarie il sistema è chiuso,in quanto la tipologia degli atti è compiutamente e tassativamente elencata dalla Costituzione,lo stesso non vale per le fonti secondarie,che sono modellabili dalla legislazione ordinaria; b)mentre esiste uno spazio costituzionalmente garantito per le leggi e gli atti equiparati o concorrenti,non vi è invece uno spazio garantito per i regolamenti dell'esecutivo,anzi le numero riserve di legge contenute nella Costituzione servono principalmente a limitare lo spazio che la legge può concedere ai regolamenti amministrativi,imponendo il ricorso alla fonte primaria per la disciplina(esclusiva o parziale)della materia.

La potestà del Governo di emanare regolamenti è prevista dalla legge 400 dell'88,che ha sostituito la precedente disciplina,risalente alla legge 100/1926:la Costituzione infatti non contiene alcuna norma su tale potestà,limitandosi ad affermare(art.87)che i regolamenti(al pari dei decreti aventi forza di legge)vengono formalmente emanati dal Presidente della Repubblica. I regolamenti vengono infatti deliberati dal Consiglio dei ministri udito il parere del Consiglio di Stato(entro 90 giorni) ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica. I regolamenti sono poi inseriti nella Raccolta ufficiale degli atti amministrativi della Repubblica italiana e pubblicati in Gazzetta,ed entrano in vigore dopo la vacatio legis, 15 giorni(salvo indicazioni di un termine più breve). Sono soggetti anch'essi al controllo della Corte dei conti e sono pubblicati da ultimo nella Gazzetta Ufficiale. Ai sensi dell'art.17 I comma della legge 400,i regolamenti governativi si distinguono in: -REGOLAMENTI DI ESECUZIONE emanati per rendere più concreto il contenuto di una legge o di un decreto legislativo tutte le volte che questi,per il loro carattere di generalità e astrattezza,o per la loro particolare formulazione tecnica,necessitano di norme di dettaglio,integrative o esplicative,per una migliore applicazione al caso concreto. Il termine stesso "esecuzione" è indicativo di un livello minimo di scelta politica:eseguire significa infatti semplicemente definire i mezzi,le procedure per dare attuazione a provvedimenti legislativi generali e astratti; -REGOLAMENTI DI ATTUAZIONI E DI INTEGRAZIONE DELLE LEGGI DEI DECRETI LEGISLATIVI RECANTI NORME DI PRINCIPIO: si nota come qui si richieda all'esecutivo qualcosa in più della semplice esecuzione. Nell'attuazione e

This document is available free of charge on StuDocu.com

nell'integrazione è infatti implicito uno spazio di discrezionalità riservato al Governo:pertanto questo tipo di regolamento è escluso da materie coperta da riserva ASSOLUTA di legge,come ad esempio la libertà personale,di domicilio ecc. Per questo tipo di regolamenti,la legge inoltre dovrà dettare almeno i principi della materia,lasciando al regolamenti la disciplina di dettaglio:di conseguenza il potere regolamentare si fonderà su un'esplicita previsione della legge da attuare; -REGOLAMENTI AUTONOMI O INDIPENDENTI,emanati in materie non disciplinate da leggi o da atti aventi forza di legge(e non riservate alla legge),vale a dire in materie NON LEGIFICATE,sempre che non siano materie comunque riservate alla legge(indipendentemente dal fatto che venga posta una riserva ASSOLUTA o RELATIVA)nel presupposto che,laddove la Costituzione non richieda espressamente l'intervento del legislatore,la materia può essere disciplinata anche mediante regolamento. La legittimità costituzionale di questi regolamenti è stata fortemente messa in discussione da coloro che invece ritengono,al contrario,che valga la generale presunzione di competenza normativa del Parlamento e che non esistono quindi settori normativi che non siano coperti da riserva di legge. -REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, in materia di organizzazione in senso lato,con riferimento cioè alla struttura,alla ripartizione delle competenze ecc.,ammissibili entro i limiti posti dagli art.95 comma III e 97 Cost.,che riservano alla legge,rispettivamente,l'ordinamento della Presidenza del Consiglio,la determinazione del numero,delle attribuzioni e dell'organizzazione dei ministeri,nonché l'organizzazione dei pubblici uffici. Si tratta,in generale,di regolamenti di attuazione e integrazione riferiti a una specifica materia,vale a dire il FUNZIONAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Il II comma dell'art.17 della legge 400 prevede inoltre i c.d.- "REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE,che mirano essenzialmente a coprire,a disciplinare una materia precedentemente disciplinata dalla legge. Il problema che si pone è come può il regolamento,fonte secondaria,derogare o addirittura abrogare la legge,fonte primaria: è stato ritenuto che tali regolamenti vengono autorizzati a fare ciò(perciò detti anche REGOLAMENTI AUTORIZZATI),contravvenendo quindi al principio di gerarchia. Nelle materie in cui sono permessi,le leggi della Repubblica,autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo,determinano le norme regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari:l'effetto abrogativo quindi scatta solo all'intervento del regolamento,e ciò per impedire un eventuale vuoto normativo.
La legge di delegificazione quindi differisce l'effetto abrogativo al momento in cui interverrà il regolamento:la precedente normativa continua quindi di fatto a valere(e ad essere attuata),fintanto che non venga disposto il regolamento. Nel caso in cui il regolamento non intervenga,la normativa precedente continua ad essere attuata. N.B.: Il legislatore deve dettare le linee direttive generali della materia:conferisce quindi un potere e al tempo stesso lo circoscrive:rinveniamo pertanto lo schema tipico della LEGALITA' SOSTANZIALE. Tale categoria di regolamenti è stata utilizzata per mettere in atto un progressivo processo di DELEGIFICAZIONE,fermo restando che spetta alla legge di dettare le norme generali(di principio)che disciplinano la materia.

Dubbia è invece la legittimità costituzionale dei c.d. "REGOLAMENTI DELEGATI" (definizione già di per sé impropria,giacchè la delega è consentita dalla Costituzione solo e unicamente per l'emanazione dei decreti aventi forza di legge),che si hanno quando una legge autorizza il regolamento a derogare ad alcune sue norme o a norme contenute in altre leggi o ancora a disciplinare ex novo materie già disciplinate da una legge o coperte da riserva di legge. E di fatti appare evidente la difficoltà a conciliare questo tipo di regolamento con le norme costituzionali,a meno che non si ritenga che il legislatore,demandando al Governo la disciplina ulteriore di una materia anche in deroga a quella legislativamente vigente,abbai inteso autolimitarsi per meglio rispondere alle esigenze del decentramento legislativo. Secondo tale chiave di lettura quindi i regolamenti delegati potrebbero essere ricomprese nella categoria dei regolamenti autorizzati. Restano tuttavia forti dubbi sulla compatibilità di questa forma di regolamento. E' stata poi introdotta una vera e propria "RISERVA DI REGOLAMENTO"mediante il comma 4bis aggiunto all'art.17 della legge 400/88 dalla legge n.59 del 1997:tale riserva riguarda l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri. Il regolamento viene di fatti approvato dal Consiglio dei ministri,su proposta del ministro competente,d'intesa con il Presidente del Consiglio e con il Ministro del tesoro,nel rispetto di alcuni criteri di razionalità,efficienza e garanzia indicati nel medesimo comma 4bis. Tale principio è stato esteso a tutte le amministrazioni dello Stato,anche ad ordinamento autonomo,fatte salve le disposizioni di settore riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri,il Ministero degli affari esteri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato,di polizia e giustizia. Di particolare importanza risulta poi l'art.20 della legge n.59 del '97,che fissa l'obbligo per il Governo di presentare al Parlamento entro il 31 maggio di ogni anno un disegno di legge per la SEMPLIFICAZIONE E IL RIASSETTO NORMATIVO. Questo disegno di legge prevede l'emanazione di decreti legislativi nonché di regolamenti ai sensi dell'art.17,comma 1 e 2 della legge 400,per le norme regolamentari di competenza dello Stato. **Regolamenti di riordino e ricognizione delle disosizioni regolamentari vigenti-** la legge 69 del 2009 ha novellato l'art. 17 della legge 400 del 1988, prevedendo che il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 400, provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti. Ciò per dare fondamento ad un autonomo potere regolamentare del Governo. Inoltre l'art.11 della legge n.11 del 2005 prevede che,nelle materie indicate dall'art.117 comma II Cost.,le direttive comunitarie possano essere attuate con regolamenti governati o ministeriali o interministeriali. Oltre al Governo, anche altre autorità dell'esecutivo possono emanare regolamenti: i ministri, i comitati interministeriali, i comandanti di porto, ecc.

12. I limiti alla potestà regolamentare. La riserva di legge- Oltre al limite di carattere generale derivante dalla loro collocazione nel sistema delle fonti secondo il criterio della gerarchia(per cui un regolamento non può modificare o abrogare una legge formale o un atto ad essa equiparato),i regolamenti incontrano quindi limiti specifici contenuti in altrettante RISERVE DI LEGGE espressamente previste nella

This document is available free of charge on StuDocu.com

Costituzione. Si ha una riserva di legge quando una norma costituzionale riserva appunto alla legge la disciplina di una determinata materia,escludendo pertanto (o ammettendo solo in parte)che essa possa essere fatta oggetto del potere regolamentare del Governo. L'origine storica(e la ratio)della riserva di legge vanno ricoleggate al sorgere dei primi Parlamenti medievali,allorquando cioè il potere del monarca venne limitato attribuendo alle assemblee elettive ogni decisione sui diritti patrimoniali e personali dei sudditi. Tale carattere garantista della riserva di legge fu proprio,successivamente,dello Stato di diritto,che vide l'affermazione del principio della separazione dei poteri e la contrapposizione,in un sistema di poteri dualista,del Parlamento quale organo rappresentativo della volontà popolare al monarca,il riconoscimento e la tutela di alcuni fondamentali diritti di libertà. La legge,in quanto votata dai rappresentanti del popolo e atto posto in posizione di supremazia,sembrò allora essere l'unico strumento atto a garantire i diritti dei cittadini contro l'arbitrio del potere esecutivo. Oggi sappiamo invece che questa funzione garantista venne svolta dalla legge solo in parte:innanzitutto,le Carte ottocentesche prevedevano soltanto un ristretto numero di libertà,per cui,se pure delle libertà potevano essere riconosciute,la legge poteva comunque sia legittimare il Governo a disporre circa le loro limitazioni. In secondo luogo,le Costituzioni erano in buona parte flessibili:pertanto il legislatore godeva di un'ampia discrezionalità nell'interpretare la natura e l'intensità della riserva,comprimendo l'esercizio della libertà fino al punto da annullare la funzione garantista della riserva stessa,senza che alcun organo potesse intervenire(come avviene invece nelle costituzioni rigide)per sindacare la legittimità costituzionale della legge. Nelle costituzioni contemporanee la funzione garantista della riserva di legge risulta rafforzata dalla loro rigidità(che comporta l'obbligo del legislatore di attenersi non soltanto alle norme in cui la riserva è espressamente contenuta ma anche ai principi generali che presiedono all'ordinamento). Alla riserva di legge tuttavia non va assegnata unicamente una funzione garantista. In uno Stato interventista e in un tipo di economia c.d."mista", si è voluto infatti riservare al legislatore le scelte politiche di fondo,assegnandogli il compito di determinare i programmi e i controlli opportuni affinchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali(art.41 comma III Cost.).Inoltre la riserva di legge è stata prevista anche per l'adozione di provvedimenti concreti,adottati mediante atti amministrativi,al fine di farli assumere,data la loro rilevanza,alle Camere,sia per sottrarli ai rimedi giurisdizionali esperibili contro questi atti e di sottoporli soltanto al controllo di legittimità costituzionale(art.43 Cost.). Permangono tuttavia non poche incertezze sull'estensione da assegnare alle riserve di legge,soprattutto laddove si considera che la Costituzione adotta il termine "legge" non sempre in senso univoco. Un primo quesito potrebbe essere ad esempio se la riserva di legge debba intendersi sempre come riserva di legge STATALE o possa anche riferirsi alle leggi regionali e provinciali:a tal proposito,sembra che la riserva di legge possa essere intesa anche come riserva di legge regionale e provinciale,oltre che statale(fatto questo che trova peraltro conferma nella giurisprudenza della Corte,in specie nella sentenza n.64 del '65),se si considera che se si accogliesse diversamente la tesi(in un primo tempo

formulata dalla stessa Corte)che,quando la Costituzione rinvia puramente e semplicemente alla "legge"si riferisce soltanto alla legge dello Stato,la potestà legislativa regionale verrebbe ad essere gravemente limitata:così ad esempio se l'art.23 Cost. si interpretasse nel senso che solo la legge dello Stato può imporre tributi,verrebbe ad essere totalmente esclusa la potestà normativa tributaria della Regione,in contrasto con il principio dell'autonomia finanziaria previsto dall'art.119 Cost. Altra ragione di dubbio attiene ai rapporti fra le varie fonti del diritto nelle materie riservate alla legge. Ci si è chiesto infatti se nelle materie riservate,il termine "legge"debba intendersi soltanto ed esclusivamente come legge formale o anche come comprensivo degli atti aventi forza di legge. La dottrina e la giurisprudenza hanno al riguardo fissato alcuni criteri(con riferimento alla ratio della riserva e alla materia che ne forma oggetto)ed identificato,di conseguenza,due tipi essenziali di riserva: ASSOLUTA,che si ha quando la disciplina della materia è riservata alla legge del Parlamento,con esclusione quindi di tutte le altre fonti;tale tipo di riserva vale ad esempio nel campo penale(art.25 Cost.)e in quello dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini(art.13,14,15,16,21,25 comma I).Tuttavia gli atti governativi aventi forza di legge sono stati parificati alla legge formale,anche ai fini di eventuali riserve di legge,e ciò nel presupposto che il Parlamento eserciti su questi atti un controllo o SUCCESSIVO(nel caso dei decreti legge)o PRECEDENTE(nel caso dei decreti legislativi), nelle materie coperte da riserva assoluta, resta escluso l'esercizio del potere regolamentare, a meno che si tratti di regolamenti di esecuzione dati i ristretti limiti entro cui possono essere emanati; RELATIVA,che si ha quando la materia può essere disciplinata oltre che da leggi formali(e dagli atti ad essa euiparati)anche da altre fonti. Non alternativamente,ma soltanto dopo che la legge abbia determinato le linee essenziali della disciplina. Tale tipo di riserva ammette dunque l'intervento del potere normativo del Governo attraverso i regolamenti autorizzati,di organizzazione e i c.d.regolamenti di attuazione. Una riserva relativa è ad esempio quella contenuta nell'art.97 Cost.,nella considerazione che il Parlamento non potrebbe disciplinare minutamente e nel dettaglio l'organizzazione dei pubblici uffici senza interferire nel campo della discrezionalità amministrativa;analoghe ragioni valgono per la riserva contenuta nell'art.23 Cost.,laddove la fissazione di elementi e presupposti della prestazione siano espressione di discrezionalità tecnica, purchè risultino assicurate le garanzie atte ad escludere che la discrezionalità si trasformi in arbitrio. Sia la riserva di legge assoluta che quella relativa possono poi essere RAFFORZATE qualora la Costituzione non si limiti a rinviare puramente e semplicemente alla legge(nel qual caso si parla di RISERVA DI LEGGE SEMPLICE),ma disciplina essa stessa parte della materia ponendo,in tal modo,altrettanti limiti alla discrezionalità del legislatore. Riserve rafforzate sono ad esempio quelle contenute nell'art.16,a norma del quale la legge può stabilire limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno in via generale,per motivi di sanità o di sicurezza;nell'art.97,a norma del quale la legge deve disciplinare l'organizzazione dei pubblici uffici in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione,e nell'art.10,a norma del quale la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati

This document is available free of charge on StuDocu.com

internazionali,e la legge che disciplina l'estradizione dello straniero non può ammetterla per reati politici. Una riserva di legge c.d."IMPLICITA" è contenuta nell'art.72 comma IV Cost., il quale,escludendo che per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,di approvazione di bilanci e consuntivi possa essere adottato un procedimento di formazione diverso da quello ordinario,allo stesso tempo esclude che tali materie possano essere disciplinate da un atto avente forza di legge o da un regolamento(e ha in tal senso inteso riservare al solo Parlamento l'attività di indirizzo politico attinente a questi settori). Infine, si ha riserva di legge COSTITUZIONALE quando la Costituzione espressamente dispone che determinate materie debbano essere regolate con legge costituzionale: ad esempio l'art.116 per l'adozione degli Statuti regionali speciali;l'art.132 per la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni;art.137 per stabilire le condizioni,le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.

13. Le cause di cessazione del Governo- Il Governo rimane in carica fino a quando le Camere non gli revochino la fiducia o non decida di dimettersi. Quale che sia la causa per la quale il Governo scelga di presentare le dimissioni,queste saranno provocate,di regola,dal venir meno della maggioranza e quindi, della piattaforma politica sulla quale il Governo stesso si reggeva. La cessazione del Governo in seguito al venir meno della maggioranza (c.d."CRISI DI GOVERNO")può essere determinata:

- da un voto di sfiducia delle Camere,che è l'atto formale che segna l'inizio della crisi,ponendo il Governo in minoranza. Il governo battuto da un voto di sfiducia ha l'obbligo giuridico di dimettersi,obbligo che non è espressamente previsto dalla nostra Costituzione,ma che si deduce dal sistema e in specie dalla norma contenuta nell'art.94,in base al quale "Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere",il che implicitamente significa che non può esserci Governo che non abbia la fiducia di ambedue le Camere;
- dal ritiro dell'appoggio al Governo da parte di uno o più gruppi parlamentari,qualora ciò comporti che il Governo non possa più contare su una maggioranza;
- dalla decisione del Governo di dimettersi quando,dall'andamento di una discussione o dai risultati di una votazione(ad esempio,quando abbia posto la questione di fiducia),riporti il convincimento di non godere più della fiducia della maggioranza.

A norma dell'art.94, comma IV Cost.,il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo NON COMPORTA L'OBBLIGO DI DIMISSIONI. E' tuttavia evidente che qualora la proposta governativa non approvata dalle Camere sia di particolare rilievo ai fini dello svolgimento dell'attività di indirizzo politico del Governo o qualora tutta una serie di proposte dovessero non ricevere in blocco l'approvazione delle Camere,questi sarebbero chiari segni del fatto che la

maggioranza non condivide più la linea politica del Governo,per cui allo stesso non resterebbe che prenderne atto. Il Governo, infine, è tenuto a dimettersi quando,presentatosi alle Camere dopo la sua formazione,non ne ottiene la fiducia(anche in questo caso il Governo è DIMISSIONARIO:viene a formarsi,ma è tenuto a dimettersi immediatamente dopo la sua formazione se non ottiene l'iniziale voto di fiducia da parte delle Camere):in tal caso,le dimissioni dono dovute alla mancata costituzione iniziale del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento. Solo 5 Governi(De Gasperi nel '53,Fanfani nel '58,Andreotti nel '72 e nel '79,Fanfani nell'87)dall'entrata in vigore della Costituzione fino ad oggi sino sono dimessi per non aver ottenuto la fiducia iniziale. Pertanto la maggioranza delle crisi ha avuto natura e origine EXTRAPARLAMENTARE.
La frequenza con la quale si verificano le crisi(e la conseguente instabilità governativa)sottolineano la peculiarità del caso italiano,dovuta essenzialmente al sistema in cui sono venuti ordinandosi i partiti. Tale sistema infatti appare incora irrigidito,nonostante le notevoli trasformazioni subite in questi ultimi anni dalla "forma" partito,e mostra evidenti sintomi di crisi. La necessità di dare comunque una direzione politica al Paese ha portato,d'altra parte,anche alla formazione di Governi monocolore(=governo formato dai rappresentanti di un solo partito politico)o senza maggioranza precostituita,che si sono retti sulle astensioni o hanno trovato a loro volta appoggio in varie parti dello schieramento parlamentare(c.d."GOVERNI PENDOLARI").Gli stessi Governi a maggioranza precostituita infine sono stati in alcune circostanze condizionati dalla mancanza di una sufficiente omogeneità fra i partiti che li formavano, che ha portato alla formulazione di programmi troppo vaghi e generici e in ogni caso rimasti in buona parte inattuati;dai patteggiamenti con l'opposizione,dall'ostruzionismo spesso vincente di alcune minoranze,dal fenomeno dei franchi tiratori e in buona sostanza dalla loro stessa vulnerabilità politica. Non può dirsi che tutto questo sia voluto dalla Costituzione,che mirava unicamente,con la razionalizzazione del voto di fiducia e di sfiducia,a dare stabilità ai Governi,né sembra che l'adozione del sistema elettorale maggioritario prima,e il ritorno al proporzionale con premio di maggioranza dopo,abbiano finora portato a quei risultati che i loro fautori si attendevano. Le crisi che si verificano in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia sono comunemente dette PARLAMENTARI,per distinguerle dalle crisi provocate da secondo e terzo caso(vedi sopra)o dal mutato orientamento dei partiti di maggioranza,che sono dette EXTRAPARLAMENTARI perché non trovano la loro espressione formale nel Parlamento(attraverso la via del voto di sfiducia). Questo tipo di crisi si svolge spesso "al buio",di modo che le loro vere cause non sempre sono portate a conoscenza dell'opinione pubblica,e ciò,oltre a renderne difficile la risoluzione,contrasta nettamente con quell'esigenza di chiarezza e di pubblicità dell'attività dei governanti che dovrebbe essere una regola inderogabile dei regimi democratici. Il Governo può poi dimettersi anche per cause diverse,e più precisamente: per la morte del Presidente del Consiglio o per la cessazione o la sospensione della carica per motivi inerenti la sua persona,per cui non è pensabile che egli possa essere sostituito lasciando intatta la compagine governativa; per l'elezione di un nuovo Presidente della Repubblica(quale

This document is available free of charge on StuDocu.com

“ESPRESSIONE PERSONALE DI DOVEROSO OSSEQUIO”);secondo una norma di correttezza costituzionale tuttavia il Presidente della Repubblica entrante respingerà le dimissioni. Dalla crisi di governo va distinto poi il RIMPASTO,che si ha quando,fermo restando il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento,il Presidente del Consiglio procede alla sostituzione di qualcuno dei ministri(che,ad esempio,non intende più condividere la linea politica del Governo),al fine di poter continuare a mantenere l’unità della compagine governativa. Il Governo dimissionario resta in carica fino alla nomina dei nuovi ministri per il disbrigo degli affari correnti,ma esso non potrà compiere(essendo venuto meno il rapporto che lo legava alle Camere),atti che impegnino l’indirizzo politico e la sua responsabilità nei confronti del Parlamento. *Formalmente, governo dimissionario e governo in attesa della fiducia sostanziale sono nella stessa posizione, essendo ambedue privi della fiducia delle camere. Ma sostanzialmente, il governo in attesa della fiducia è già sostenuto da un accordo politico.*

14. La responsabilità dei ministri- Secondo l’art.95 “I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri,e individualmente degli atti dei loro dicasteri”; a norma poi dell’art.89 comma I Cost.,”Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,che ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri”. Particolare rilievo assume,al fine della configurazione della responsabilità ministeriale,l’ISTITUTO DELLA CONTROFIRMA:la maggior parte degli atti del Presidente della Repubblica sono infatti imputabili al Capo dello Stato solo formalmente,mentre sostanzialmente vengono posti in essere dal Governo. Rispetto a tali atti,il Presidente della Repubblica può sempre esercitare un controllo di legittimità(o anche limitatamente di merito),ma deve emanarli qualora il Governo non accolga i rilievi,o comunque insista nel richiederne l’emanazione. Ne consegue che la responsabilità (POLITICA e GIURIDICA)assunta dai ministri e dal Presidente del Consiglio con la CONTROFIRMA MINISTERIALE di questi atti si configura come una responsabilità per atti propri.
La RESPONSABILITA’ GIURIDICA dei ministri e del Presidente del Consiglio può essere distinta in CIVILE,PENALE ed AMMINISTRATIVA.
Civilmente,essi,al pari degli altri funzionari dello Stato,sono direttamente per i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle loro funzioni(art.28 Cost.)
Penalmente sono responsabili per i c.d.”REATI MINISTERIALI”,vale a dire per quei reati comuni(ad esempio i reati contro la pubblica amministrazione:malversazione,concussione,corruzione ecc.)commessi dai ministri in occasione e a causa dell’esercizio delle loro funzioni e abusando del potere loro conferito. A norma dell’art.96 Cost.,il Presidente del Consiglio ed i ministri,anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni,alla giurisdizione ordinaria(e in particolare al giudizio di un apposito collegio istituito presso il tribunale del capoluogo di distretto della Corte d’appello,il c.d.”TRIBUNALE DEI MINISTRI”),previa autorizzazione della Camera d’appartenenza o del Senato qualora il soggetto non sia parlamentare. Le Camere

possono,a maggioranza assoluta,negare l'autorizzazione laddove reputino,con valutazione insindacabile,che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Amministrativamente i titolari degli organi del Governo sono responsabili,come tutti i funzionari,dinanzi alla Corte dei conti per danni arrecati alla pubblica amministrazione. La REPONSABILITA' POLITICA dei ministri e del Presidente del Consiglio discende dall'art.95 Cost. Essa può essere collegiale o individuale,a seconda che a rispondere innanzi alle Camere degli atti o dei comportamenti posti in essere sia l'intero Governo o il singolo ministro. La responsabilità politica si fonda sul rapporto fiduciario che lega il Governo alle Camere,di modo che,qualora queste ultime ritengano che il Governo o un ministro abbiano posto in essere atti o comportamenti contrari all'indirizzo politico e amministrativo concordato,possono colpirli con un voto di sfiducia,facendo così sorgere l'obbligo giuridico delle dimissioni.A differenza della responsabilità giuridica,quella politica appare molto sfumata nei suoi contorni. Infatti,se è vero che il voto di sfiducia fa sorgere l'obbligo delle dimissioni,è vero anche che il Capo dello Stato può non accogliere le dimissioni e procedere invece allo scioglimento delle Camere,sottraendo in tal modo il Governo alla misura sanzionatoria. Oltretutto i mutamenti intervenuti nella maggioranza potrebbero portare ad un voto di sfiducia nei contri di un Governo che ha sino ad allora puntualmente attuato l'indirizzo politico. Ad ogni modo,il fatto che i ministri siano politicamente responsabili sta a significare che essi devono rispondere del loro operato alle Camere e che devono di conseguenza soggiacere a tutte le misure di controllo(vedi dietro)che le Camere stesse pongono in atto al fine di verificare se gli atti e l'attività di governo siano politicamente opportuni e conformi all'indirizzo politico.

15. Gli organi ausiliari- Sono previsti dalla Costituzione sotto la sezione III del titolo III relativo al Governo. Si dicono "AUSILIARI"perché non svolgono una funzione di amministrazione attiva,bensì una funzione di iniziativa,di controllo,o consultiva,e perché coadiuvano in modo diverso e con diversa efficacia l'opera degli organi deliberanti. Il CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO,previsto dall'art.99 Cost.,è stato istituito con la legge 5 gennaio 1957 n.33.Quest'organo,votato dall'Assemblea Costituente per immettere nell'apparato dello Stato i rappresentanti delle varie categorie produttive del Paese al fine di creare un significativo raccordo fra le forze economico-sociali e le istituzioni(da attivare soprattutto sul piano consultivo e dell'iniziativa legislativa),è stato riformato con la legge 30 dicembre 1986 n.936:tale legge,oltre ad elevare il numero dei componenti,ha apportato notevoli modifiche alle attribuzioni del Consiglio,che,adesso,non riguardano più prevalentemente l'attività consultiva e l'iniziativa legislativa. L'art.10 della legge prevede infatti che il Consiglio possa intervenire per iniziativa propria o su richiesta del Governo in diversi campi,relativi alla politica economica e alla programmazione economica e sociale,al mercato del lavoro e alla contrattazione collettiva. Il CONSIGLIO DI STATO,quale organo

This document is available free of charge on StuDocu.com

ausiliario,è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. La legge 15 maggio n.127 ha fissato in modo tassativo i casi in cui il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio: a)per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri,ai sensi dell'art.17 della legge n.400 del 1988 nonché per l'emanazione dei testi unici; b)per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c)sugli schemi generali di contratti-tipo,accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri. Il parere deve essere reso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta;decorso il termine,l'amministrazione può procedere indipendentemente da esso. La CORTE DEI CONTI esercita il controllo preventivo di legittimità elusivamente sugli atti indicati nell'art.3 della legge 14 gennaio 1994,ed il suo visto è requisito di efficacia per l'esecutività dell'atto sottoposto al suo esame. Tale controllo è stato abolito sui decreti legge e decreti legislativi dall'art.16 della legge 400 dell'88. Come organo ausiliario delle Camere,essa esercita il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato e sul patrimonio delle amministrazioni pubbliche,e riferisce,almeno annualmente,al Parlamento sull'esito del controllo eseguito. Oltre alle funzioni ausiliarie,la Corte esercita anche funzioni giurisdizionali in materia contabile e finanziaria ed in materia di pensioni(civili e militari).E' da osservare infine che alla Corte dei Conti è stata riconosciuta,quando opera nell'esercizio di tali funzioni,la qualità di potere dello Stato,in considerazione della sua posizione di organo terzo,estraneo all'apparato amministrativo dello Stato e che svolge la sua funzione in modo autonomo e in posizione di indipendenza e,dunque,in veste obiettiva e neutrale. L'ambito del controllo della Corte dei conti si è allargato,in seguito al progredire del processo di decentramento,estendendosi anche alle Regioni:le sue funzioni vanno quindi interpretate in senso espansivo come organo imparziale,garante dell'equilibrio economico-finanziario de settore pubblico e,in particolare,della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità(sent.Corte cost.n.29 del 1995). L'AVVOCATURA DELLO STATO svolge il compito primario di assistere e difendere lo Stato e,più in generale,le pubbliche amministrazioni nei giudizi in cui sono parte. Uno dei compiti più rilevanti è quello di assistere e difendere lo Stato(e,per esso,la Presidenza del Consiglio)nei giudizi innanzi la Corte costituzionale,giudizi che non mirano alla tutela di interessi specifici o di parte,bensì,più in generale,a quella del diritto obiettivo.

CAPITOLO QUARTO- IL POTERE GIUDIZIARIO

Con la funzione giurisdizionale lo Stato accerta la volontà normativa da far valere in un caso concreto,allo scopo di eliminare lo stato di dubbio che si sia determinato in ordine alla qualificazione da dare al caso stesso,oppure mettere in atto le sanzioni previste nell'ipotesi che la volontà della legge non sia stata osservata,assicurando così la certezza del diritto e la reintegrazione dell'ordine giuridico violato. Così come, dunque, con la funzione legislativa lo Stato pone le norme costitutive del suo ordinamento giuridico,con la funzione giurisdizionale garantisce l'osservanza e la

conservazione delle norme ritenute essenziali ai fini dell'ordinato svolgimento della vita sociale. Inoltre,dal momento che non sempre il significato delle norme è univoco e,di conseguenza,possono sorgere delle controversie in ordine alla interpretazione da dare alle norme stesse,è necessario che lo Stato predisponga gli strumenti per accertare(con efficacia vincolante fra le parti in lite)quale sia la volontà normativa da far valere nel caso concreto. Si hanno tre tipi di giurisdizione: *penale, civile ed amministrativa.* Con l'entrata in vigore della Cost., se n'è aggiunto un quarto: la *giurisdizione costituzionale.* La giurisdizione civile regola le controversie sorte fra privati o fra i privati e la pubblica amministrazione,ed aventi per oggetto un diritto soggettivo. La giurisdizione penale mira a realizzare l'interesse della collettività organizzata a Stato a ciò che determinati valori o istituti(la vita e l'incolumità dell'individuo,la libertà personale e morale,la proprietà,la moralità pubblica ed il buon costume,la famiglia ecc.)vengano salvaguardati e ad irrogare una PENA a coloro i quali abbiano commesso un reato in violazione di tali valori e istituti. La giurisdizione amministrativa tutela gli interessi legittimi(ed eccezionalmente i diritti soggettivi)dei cittadini che siano stati lesi da un atto della pubblica amministrazione,ed assicura,in tal modo,la GIUSTIZIA DELL'AMMINISTRAZIONE. A norma dell'art.1 dell'ordinamento giudiziario,"La giustizia,nelle materie civili e penali,è amministrata: dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dalla Corte d'Appello, dalla Corte di Cassazione, dal tribunale per i minorenni, dal magistrato di sorveglianza, dal Tribunale di sorveglianza. Sono questi i magistrati ORDINARI(civili e penali)che esercitano la funzione giurisdizionale(vale a dire quegli organi giusdicenti istituzionalmente collegati al CSM).Tale assetto deriva dalla soppressione dell'Ufficio del Pretore operata dal D.Lgs.19 febbraio 1998 n.51,istitutivo del GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO; tutti gli altri organi che esercitano tale funzione rientrano nelle GIURISDIZIONI SPECIALI: -tribunali militari in materia penale; -tribunali amministrativi regionali,Consiglio di Stato e Corte dei Conti in materia amministrativa; -Corte costituzionale in materia costituzionale.

1. Il principio dell'unicità della giurisdizione- Non tutta la funzione giurisdizionale è quindi esercitata da magistrati ordinari. Tuttavia,la Costituzione contiene al riguardo un preciso principio(art.102)secondo il quale "La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario" e organizza la magistratura ordinaria in un ordine AUTONOMO e INDIPENDENTE da ogni altro potere(art.104 Cost.).E' questo il PRINCIPIO DELL'UNICITA' DELLA GIURISDIZIONE,la cui applicazione integrale dovrebbe quindi portare ad attribuire l'esercizio della funzione giurisdizionale esclusivamente ai magistrati ordinari. Tuttavia la stessa Costituzione dispone delle deroghe a questo principio,prevedendo(art.103)che la funzione giurisdizionale possa anche essere esercitata: -dal Consiglio di Stato e dagli altri organi di giustizia amministrativa,per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi; -dalla Corte dei Conti,nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge; -dai tribunali militari che,in tempo di guerra,hanno la giurisdizione stabilita

This document is available free of charge on StuDocu.com

dalla legge e in tempo di pace soltanto quella per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate; -dalla Corte costituzionale; -da ciascuna Camera,in sede di giudizio sulle elezioni contestate,e dalle Camere in seduta comune quando devono valutare le accuse mosse nei confronti del Presidente della Repubblica. Tutte le altre giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione avrebbero dovuto essere sottoposte a revisione da parte del legislatore ordinario(che non è detto dovesse necessariamente provvedere alla loro soppressione),entro un termine(non perentorio)di 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione (art. VI delle disposizioni transitorie e finali). Qualora il legislatore non provveda alla revisione,ne consegue che o la funzione dell'organo non è più da considerare giurisdizionale o le disposizioni sulla composizione dell'organo sono da ritenere costituzionalmente illegittime. L'art.102 Cost. prevede inoltre l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di SEZIONI SPECIALIZZATE per determinate materie,anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura,mentre fa divieto assoluto di istituire GIUDICI STRAORDINARI e nuovi GIUDICI SPECIALI.

***2. Giudici straordinari; giudici speciali; sezioni specializzate.* -** Lo stesso disegno costituzionale che ha posto il divieto di istituire giudici straordinari o speciali ha espressamente mantenuto in vita alcune giurisdizioni speciali.
Il divieto di istituire giudici straordinari è uno dei più notevoli portati della civiltà giuridica,e discende direttamente dal principio secondo il quale ciascun individuo deve preventivamente poter conoscere quale sarà il suo GIUDICE NATURALE,vale a dire il GIUDICE PRECOSTITUITO PER LEGGE,dal quale sarà giudicato se commetterà un determinato reato e dal quale(a norma dell'art.25 Cost.)non può essere distolto. Ciò implica che non si possono creare giudici "AD HOC",ossia il giudice nominato appositamente per giudicare di fatti già previsti come reati o per giudicare unicamente determinate persone,ma implica anche che l'istruzione ed il giudizio non possono essere sottratti al giudice competente per territorio.
Suscita qualche perplessità la legge 248/2002,che ha introdotto la possibilità di derogare alla competenza territoriale,oltre che per i gravi motivi indicati dall'art.45 del codice di procedura penale (sicurezza e incolumità pubblica,libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo) anche per "LEGITTIMO SOSPETTO". La genericità di questa formula normativa potrebbe infatti autorizzare l'uso di una larga discrezionalità nelle deroghe alla competenza territoriale,difficilmente compatibile con il principio del giudice naturale contenuto nell'art.25 I comma Cost. Il divieto di istituire giudici speciali trova la sua prima giustificazione nel principio secondo il quale tutta la funzione giurisdizionale(tranne le eccezioni espressamente previste)deve essere esercitata dai magistrati ordinari. D'altra parte in alcuni casi la natura particolarmente tecnica di alcune controversie,la particolare qualità dei soggetti attivi del reato ecc. richiedono che la funzione giurisdizionale sia svolta da organi dotati di una speciale competenza o inseriti nello stesso ordinamento particolare nel cui ambito il reato è stato compiuto,per cui la Costituzione ha mantenuto,rispettivamente,il Consiglio di Stato,la Corte dei Conti e i tribunali militari. Il **Consiglio di Stato**(costituito da 7 sezioni,quattro delle quali

svolgono funzioni consultive e tre funzioni giurisdizionali)ha giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e,in particolari materie indicate dalla legge,anche dei diritti soggettivi (c.d. "GIURISDIZIONE ESCLUSIVA"). Con l'entrata in vigore della legge 1034/71,istitutiva dei TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI,il Consiglio di Stato è diventato organo di appello contro le sentenze dei TAR:si è instaurato in tal modo,anche nel campo della giustizia amministrativa,il DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE. La **Corte dei Conti**,suddivisa in 10 sezioni,di cui una di controllo e nove giurisdizionali,più una sezione giurisdizionale in ogni Regione e due nel Trentino-Alto Adige,ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. In particolare essa giudica sui conti che devono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge(esclusi i tesorieri degli organi costituzionali)e sulla responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionai(con esclusione dei dipendenti di enti pubblici economici). Giudica inoltre sui ricorsi in materia di pensioni ordinarie(civili o militari)e di pensioni di guerra. Spetta poi alla Corte dei Conti parificare il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato ed i rendiconti delle aziende autonome soggette al suo riscontro,prima che siano presentati al Parlamento. I TRIBUNALI MILITARI: Hanno giurisdizione soltanto per i reati commessi da appartenenti alle forze armate. Contro le sentenze dei tribunali militari è ammesso ricorso davanti alla Corte militare d'appello formata da un magistrato militare di cassazione,che la presiede,e da magistrati di cassazione e di appello. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI: Istituiti nel 1971,ma entrati in funzione soltanto nel 1974,hanno assorbito le funzioni giurisdizionali già attribuite alle soppresse Giunte provinciali amministrative,ma funzionano anche come organi di primo grado nelle controversie prima di competenza del Consiglio di Stato. In particolare,ai TAR è attribuita la competenza a giudicare gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,degli enti pubblici territoriali e non territoriali,lesivi di interessi legittimi e viziati di incompetenza,eccesso di potere o di violazione di legge. Essi sono poi competenti a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per l'elezioni dei Consigli comunali,provinciali e regionali. I TAR(bene inteso,sono organi giurisdizionali STATALI E NON REGIONALI),sono composti da un presidente e da non meno di 5 magistrati(distinti in consiglieri,primi referendari e referendari).
Un particolare regime di giustizia amministrativa vige invece nella Regione siciliana,dove sin dal 1948 è stato creato il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA(secondo quanto previsto dallo Statuto),considerato da alcuni una sezione del Consiglio di Stato e sulla cui legittimità costituzionale sono stati avanzati seri dubbi. Oltre che la funzione giurisdizionale,quest'organo svolge anche quella consultiva:in sede giurisdizionale quest'organo decide,di unico grado,sui ricorsi contro gli atti dell'amministrazione regionale e di ogni altra autorità amministrativa avente sede in Sicilia,ed è inoltre giudice d'appello contro le sentenze del TAR siciliano. Inoltre lo Statuto del Trentino-Alto Adige ha previsto l'istituzione di un tribunale regionale di giustizia

This document is available free of charge on StuDocu.com

amministrativa con un'autonoma sezione per la Provincia di Bolzano. Altra giurisdizione speciale è il **tribunale superiore delle acque pubbliche** (composto da magistrati ordinari, consiglieri di Stato e tecnici), che giudica in unico grado, su controversie in materia di lesioni di interessi legittimi e in appello sui ricorsi avverso le sentenze dei tribunali regionali delle acque pubbliche (la competenza di questi organi è ristretta al regime delle acque pubbliche). Alle **commissioni tributarie** (provinciali e regionali) è attribuita la competenza di risolvere le controversie fra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria. Fra i giudici speciali devono farsi rientrare anche le Camere,il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale nell'esercizio della c.d. "**giurisdizione domestica**"(o anche detta "**AUTODICHIA**"),consistente nella potestà riconosciuta a questi organi in via assoluta(sostituendosi cioè agli organi di giurisdizione amministrativa)di giudicare sui ricorsi relativi al rapporto d'impiego del personale da essi dipendente. Questa potestà (un tempo riconosciuta anche alla Corte dei Conti)è stata ritenuta in contrasto con gli art.102 comma II (DIVIETO DI ISTITUIRE GIUDICI SPECIALI),108 comma II (INDIPENDENZA DEI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI),113 I e II comma(tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa)oltre che con il principio dell'imparzialità o terzietà del giudice. Di parere contrario, invece, è stata la Corte costituzionale,secondo la quale deroghe alla giurisdizione sono ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato,e perciò situati ai vertici dell'ordinamento. SEZIONI SPECIALIZZATE: Sono istituite presso gli organi di giurisdizione ordinaria e legittimati dal fatto che in determinate materie si rende necessaria l'integrazione del collegio giudicante con degli esperti(cittadini idonei anche estranei alla magistratura),come nel caso dei tribunali per i minorenni,le sezioni specializzate in materia agraria,ecc. Le **Corti d'Assise** rientrano invece in quei casi in cui la Costituzione ammette la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Esse sono composte da due magistrati ordinari e da sei giudici popolari:il numero pari dei componenti fa si che,a parità di voto,prevalga la decisione più favorevole all'imputato. Un caso di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia si può rinvenire anche nella composizione allargata della Corte costituzionale in sede di giudizi sulle accuse.

3. Il problema dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali. - Mentre l'indipendenza dei giudici ordinari è garantita direttamente dalla Costituzione,quella dei giudici delle giurisdizioni speciali,pur essendo prevista dalla Costituzione(e in specie all'art.108 II comma) è affidata alla legge,che dovrebbe provvedere ad assicurarla. La legge dovrebbe assicurare inoltre l'indipendenza del pubblico ministero presso le giurisdizioni speciali e dei cittadini estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. A tal scopo è stato istituito (dalle leggi 186/1982 e 205/2000) un CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA,composto da: Presidente del Consiglio di Stato che lo presiede, -4 magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, -6 magistrati in servizio presso i

TAR, -4 cittadini eletti(due dalla Camera e due dal Senato) tra i professori ordinari universitari in materie giuridiche o tra gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio professionale. A tale consiglio spetta di deliberare sullo stato giuridico dei magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR e,in particolare,delle assunzioni,delle assegnazioni di sedi e di funzioni,di trasferimenti,promozioni,conferimenti di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico di questi giudici,oltre che sugli eventuali provvedimenti disciplinari riguardanti tali magistrati. Un organo analogo è stato istituito per la Corte dei Conti con il CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI,di cui fanno parte,oltre che i magistrati della Corte stessa,quattro cittadini fra i professori universitari ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale.
Al di là di questo,l'art.100 comma III Cost. espressamente prevede che la legge debba assicurare l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e dei loro componenti di fronte al Governo. Tuttavia,la particolare composizione del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti,secondo la quale solo una parte dei posti dei consiglieri è riservata ai magistrati dei due organi(che vi accedono per promozione),mentre per i posti restanti si procede mediante nomina del Governo (normalmente scelti fra gli alti funzionari di Stato)ha fatto ritenere non del tutto operante sul piano concreto tale garanzia d'indipendenza. Si è temuto in particolare che i componenti di questi organi nominati dal Governo,nonostante le garanzie di INAMOVIBILITA' di cui godono,possano subire influenze da parte del potere politico. Portata la questione dinanzi la Corte costituzionale,questa (con sent.1 del 1967)ha assunto che,una volta intervenuta la nomina da parte del Governo,cessa ogni vincolo che eventualmente sussiste tra il Governo che nomina e la persona che viene nominata,a null'altro tenuta se non all'obbedienza alla legge.

4. La ripartizione tra i vari organi della funzione giurisdizionale.- Possiamo così suddividere la funzione giurisdizionale: la **giurisdizione civile** è esercitata dai giudici di pace,dal tribunale,dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione(tutti organi della magistratura ordinaria); la **giurisdizione penale** è esercitata dai giudici di pace,dal tribunale,dalla Corte di assise e di appello,dalla Corte di Cassazione e inoltre dai tribunali militari,dalle Camere in seduta comune per le accuse nei confronti del Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale nei giudizi sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; la **giurisdizione amministrativa** è esercitata dal Consiglio di Stato,dalla Corte dei Conti,dai TAR,dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione Trentino-Alto Adige; la giurisdizione costituzionale è invece esercitata dalla Corte costituzionale,in sede di giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge,sui conflitti di attribuzione e sull'ammissibilità del referendum abrogativo. In merito alla *ripartizione della competenza* fra la giurisdizione ordinaria(civile) e quella amministrativa,qualora siano chiamate a giudicare sulla lesione di situazioni giuridiche soggettive dei cittadini da parte della pubblica amministrazione,il criterio fondamentale è quello che vede attribuita al giudice ordinario le controversie nelle

This document is available free of charge on StuDocu.com

quali si discute della lesione di un diritto soggettivo,leso da atto amministrativo(che si assume quindi come ILLEGITTIMO)e alla competenza del giudice amministrativo la lesione di un interesse legittimo. Tuttavia chi agisce in giudizio dinanzi al giudice ordinario(per la lesione di un diritto soggettivo)non può richiedere la revoca,la modifica o l'annullamento dell'atto amministrativo,perché ciò costituirebbe un'indebita ingerenza dell'autorità giudiziaria nel campo dell'attività amministrativa(ed una violazione,pertanto,del principio della separazione dei poteri),ma soltanto una sentenza dichiarativa della illegittimità dell'atto e degli effetti che ne derivano. Spetta infatti solo all'autorità amministrativa il compito di procedere alla revoca,alla modifica o all'annullamento eventuale dell'atto.
La Corte però ha specificato (con sent.275 del 2001)ha precisato che il tradizionale divieto per il giudice ordinario di annullare atti della pubblica amministrazione non ha rango costituzionale. Pertanto,resta affidata alla discrezionalità del legislatore l'attribuzione del potere di annullamento al giudice amministrativo o a quello ordinario. Tale sistema tuttavia è causa di non pochi inconvenienti,dovuti alla difficoltà di distinguere nella società attuale,i diritti dagli interessi;per cui la controversia giudiziaria si trascina molto spesso per anni prima che la Corte di cassazione decida quale sia il giudice competente. La distinzione insomma è ormai superata. La **giurisdizione esclusiva dei TAR e del Consiglio di Stato** fa sì che questi organi siano competenti a decidere anche in merito alla lesione di diritti soggettivi. Le materie di giurisdizione esclusiva sono indicate nell'art. 133 del Codice del processo amministrativo. Di contro,il giudice ordinario è competente a conoscere di tutte le controversie inerenti al rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Si vede dunque come i criteri di riparto delle controversie tra giurisprudenza ordinaria e amministrativa tendano ad uscire sempre di più dai canoni tradizionali,per avvicinarsi ad una distinzione per materia,allontanandosi progressivamente dal criterio,ormai superato,della distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Ai TAR e al Consiglio di Stato è poi attribuita la c.d. "**GIURISDIZIONE DI MERITO**",vale a dire la competenza a giudicare (nelle materie tassativamente indicate dalla legge),oltre che sulla legittimità degli atti amministrativi,anche sulla loro OPPORTUNITA',CONVENIENZA,UTILITA' ed EQUITA'. In alternativa al ricorso giurisdizionale è proponibile il **ricorso al Presidente della Repubblica**(in Sicilia al Presidente della Regione)contro atti amministrativi che si presumono lesivi non solo di interessi legittimi ma anche di diritti soggettivi. La decisione del ricorso(che può portare finanche all'annullamento dell'atto stesso)avviene con decreto presidenziale.
Secondo una tendenza giurisprudenziale che va notevolmente affermandosi,è stata riconosciuta la possibilità di tutela in giudizio i c.d."INTERESSI DIFFUSI".In particolare la Corte di cassazione che la nozione di "interesse diffuso" evidenzia una pluralità di interessi individuati dallo stesso contenuto, e dunque non esclude le posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo dei singoli. Così argomentando,la Corte ha ammesso che,qualora l'interesse al godimento di un bene pubblico(nella specie,la sanità e l'ambiente)assuma la dignità di diritto

soggettivo,esso può trovare tutela dinanzi al giudice ordinario,ma anche sa parte della giurisdizione amministrativa(in specie,interessi diffusi di associazioni o comitati).

5. I ricorsi amministrativi - La tutela del cittadino nei confronti degli atti della pubblica amministrazione è assicurata,nel nostro ordinamento,oltre che dal ricorso agli organi giurisdizionali(ordinari e speciali)anche dai c.d."RICORSI AMMINISTRATIVI". Pur rientrando,in senso lato,nel concetto di "giustizia amministrativa",questi ricorsi non hanno natura giurisdizionale,poiché essi sono rivolti alla stessa autorità che ha emanato l'atto;per cui manca,in chi è chiamato a deciderli,l'essenziale carattere dell'IMPARZIALITA'. I ricorsi amministrativi sono nella specie: l'OPPOSIZIONE(ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge),che consiste in un'istanza rivolta dall'interessato alla stessa autorità che ha emanato l'atto al fine di richiederne il riesame e l'eventuale rimozione. L'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul ricorso; il RICORSO GERARCHICO,che consiste nell'istanza presentata dall'interessato(entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento impugnato)all'autorità gerarchicamente sovraordinata a quella che ha emanato l'atto al fine di richiedere il riesame dell'atto stesso,che si assume invalido(per vizi di legittimità o di merito)e lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. E' evidente che questo tipo di ricorso è proponibile solo quando l'autorità che ha emanato l'atto abbia superiori gerarchici,e che dunque va escluso(di regola)quando l'autorità che ha emanato l'atto sia posta al vertice della gerarchia statale,sia un organo collegiale,sia un organo collegiale(giacchè questi organi non sono inseriti in un rapporto gerarchico),o sia un ente pubblico,giacchè questi enti si caratterizzano per la loro posizione di autonomia e dunque la loro attività viene svolta senza vincoli di subordinazione gerarchica. Tuttavia,in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge è possibile ricorrere contro gli atti amministrativi di organi posti al vertici della gerarchia statale(ministri,Presidente del Consiglio,Presidente della Repubblica),di enti pubblici o di organi collegiali(RICORSO GERARCHICO IMPROPRIO). La proponibilità del ricorso gerarchico è esclusa oltre che nei confronti degli atti che sono DEFINITIVI per la posizione o la natura dell'autorità che li ha emanati,anche per gli atti dichiarati tali dalla legge e per quelli ritenuti tali in seguito ad una costante interpretazione giurisprudenziale(c.d."DEFINITIVITA' IMPLICITA"). L'atto amministrativo è inoltre definitivo quando contro di esso sia stato esperito un ricorso gerarchico e questo sia stato respinto. Una forma indiretta di tutela del cittadino nei confronti della P.A. è data da quei controlli previsti sugli atti amministrativi dello Stato e di altri enti pubblici da parte di organi a ciò deputati, come la Corte dei Conti, ma anche dalle forme di auto-controllo da parte della stessa P.A. Un potere di annullamento generale era conferito infine dall'art.6 della legge comunale e provinciale del 1934 al Governo nei confronti di tutti gli atti amministrativi sia dello Stato che di qualsiasi altra persona giuridica pubblica,viziati da incompetenza,eccesso di potere o violazione di legge:tale potere è stato confermato dall'art.2 della legge n.400 del 1988 anche nei confronti degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province,ma la

This document is available free of charge on StuDocu.com

Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'articolo,incompatibile con l'art.125 Cost.che impone che il controllo sugli atti della Regione avvenga da parte di un organo statale "in forma decentrata".

6. Le giurisdizioni non statali - A norma del codice di procedura civile,le parti possono far decidere da ARBITRI le controversie tra di loro insorte,mediante una sentenza "LODO ARBITRALE",che deve essere però dichiarata esecutiva dal tribunale. Gli arbitri sono dei privati(di cittadinanza italiana)nominati di regola dalle stesse parti:ad oggi si segnala la tendenza a ricorrere frequentemente(soprattutto per controversie di notevole portata patrimoniale)al giudizio arbitrale invece che alla giurisdizione ordinaria,dovuta ad una maggiore speditezza del primo. Altre giurisdizioni non statali sono i **tribunali ecclesiastici, la giustizia sportiva** e soprattutto le **giurisdizioni internazionali** :ad esse può ricorrere lo Stato quale membro della Comunità internazionale e ad una di esse,la CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO,possono ricorrere i singoli cittadini. La CORTE INTERNAZIONE DI GIUSTIZIA,organo dell'ONU con sede all'Aja,giudica invece,su ricorso dei singoli Stati,su ogni controversia di natura giuridica avente ad oggetto: l'interpretazione di un trattato;la violazione di un obbligo internazionale;qualsiasi questione di diritto internazionale. La CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA,con sede a Lussemburgo invece è stata creata dai trattati istitutivi della Comunità e giudica sulla violazione del trattato da parte di uno stato membro e sulle c.d."questioni pregiudiziali".Infine,la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha istituito la COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO e la CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

7. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria - La Costituzione ha voluto assicurare ai magistrati ordinari una posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti degli altri poteri dello Stato(e in particolare del potere esecutivo),sottraendo pertanto i giudici ad ogni forma di dipendenza,in specie dal ministro della giustizia. L'autonomia e l'indipendenza dei magistrati costituiscono fra l'altro un'importante garanzia per i cittadini,le cui libertà fondamentali non possono incontrare limiti se non nei casi espressamente previsti dalla legge o per l'intervento dell'autorità giudiziaria. Sono diversi gli istituti mediante i quali questa autonomia e indipendenza si realizza: innanzitutto deve essere preso in esame il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA(CSM),cui spetta in via esclusiva di deliberare tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico dei magistrati. Spettano infatti al CSM,secondo le norme dell'ordinamento giudiziario,le assunzioni,le assegnazioni,i trasferimenti,le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati(art.105 Cost.).Nel passato ordinamento,questi provvedimenti erano assunti con decreto reale su proposta del ministro della giustizia,e dunque dal potere esecutivo,mentre questa disposizione costituzionale,assegna noli alla competenza del CSM,ha assicurato quello che si definisce come l'AUTOGOVERNO DEI GIUDICI. Altre attribuzioni del CSM sono: - la nomina e la revoca dei giudici di pace,nonché dei componenti estranei alla magistratura delle sezioni specializzate; -la nomina a

magistrato della Corte di cassazione,per meriti insigni,di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati che abbiano 15 anni di esercizio; -la nomina delle commissioni per le assunzioni in magistratura. Il CSM inoltre può fare proposte su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e può dare pareri propri al ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia. Prima della Costituzione del 1958,il ministro di "grazie e giustizia" aveva rilevanti poteri in materia di ordinamento giudiziario,di status e carriera dei magistrati,e ciò pregiudicava l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. La Costituzione italiana del '48 ha segnato una svolta fondamentale perché,come si è visto,ha spostato in capo al CSM la gran parte di questi poteri. Ormai quindi **il ministro della giustizia** si limita a: curare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia(art.110 Cost.); promuovere l'azione disciplinare davanti all'apposita sezione disciplinare del CSM; partecipare al procedimento di conferimento degli uffici direttivi(cioè degli incarichi di maggior rilievo,come quelli di presidente di Tribunale e di Corte d'Appello).In particolare la legge prevede che tali incarichi vengano attribuiti con deliberazione del CSM,sulla base di una proposta formulata di concerto fra un'apposita Commissione del CSM ed il ministro. Nella specie,la Corte costituzionale,in occasione di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato,ha affermato che i rapporti tra il CSM ed il ministro devono ispirarsi al principio di LEALE COLLABORAZIONE e che il ministro deve comunque dare corso alla deliberazione consiliare(sent.379/1992); esercitare poteri di sorveglianza ed eventuali attività ispettive nei confronti degli uffici giudiziari. LA COMPOSIZIONE DEL CSM: A norma dell'art.104 Cost.,il Consiglio superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica e ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari fra le carie categorie,e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune fra professori ordinari di università e avvocati dopo 15 anni di servizio. La legge 44/2002 ha fissato a 24 il numero dei componenti elettivi del Consiglio(16 eletti dai magistrati ordinari e 8 eletti dal Parlamento in seduta comune). Vengono eletti,in ciascun collegio,i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti;in caso di parità prevale il candidato più anziano nel ruolo e,in caso di ulteriore parità,prevale il candidato più anziano d'età. L'elezione dei componenti da parte del Parlamento in seduta comune avviene invece a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 3/5 dell'assemblea;per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente invece la maggioranza dei 3/5 dei votanti. In merito alla composizione del Consiglio,bisogna osservare che la Costituzione ha voluto che in esso fossero presenti,accanto alla maggioranza dei magistrati ordinari,anche dei "MEMBRI LAICI"scelti fra teorici e pratici del diritto particolarmente qualificati,eletti dal Parlamento. Un Consiglio composto interamente da magistrati ordinari infatti,mentre da un lato avrebbe assicurato interamente l'autogoverno della maggioranza,avrebbe rischiato,dall'altro di isolare la magistratura stessa dagli altri poteri dello Stato. Per temperare d'altra parte la prevalenza dei magistrati ordinari,l'art.104 Cost. ha disposto che il vicepresidente del Consiglio venga eletto dai consiglieri fra i membri designati dal

This document is available free of charge on StuDocu.com

Parlamento. Nell'assegnare la presidenza dell'organo al Presidente della Repubblica,la Costituzione ha voluto originariamente affidargli il compito di moderatore dell'attività del Consiglio,ritenendo che il Capo dello Stato potesse esercitarlo meglio di altri sia per il prestigio del suo ufficio e sia per la sua posizione di organo posto al di sopra delle parti. E tuttavia,data la irresponsabilità del Presidente della Repubblica e la sua stessa posizione di organo imparziale,la sua partecipazione alle sedute del Consiglio fa sorgere delicati problemi circa il ruolo che la Costituzione ha voluto attribuirgli nell'affidargli la presidenza dell'organo. I membri elettivi del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili:essi non possono far parte del Parlamento,dei Consigli regionali,provinciali e comunali,e della Corte costituzionale,né assumere la carica di ministro o di sottosegretario di Stato;se eletti dal Parlamento non possono,finchè sono in carica,essere iscritti agli albi professionali. I componenti del Consiglio inoltre non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni(la Corte costituzionale ha ritenuto che tale insindacabilità valga a garantire ai componenti del Consiglio una qualificata e rafforzata libertà di manifestazione del pensiero);con una limitazione però rispetto all'insindacabilità dei parlamentari e dei giudici costituzionali:deve infatti trattarsi di opinioni concernenti l'oggetto della discussione. Si è lungamente discusso sulla natura del CSM,e cioè se esso debba considerarsi organo costituzionale,a rilevanza costituzionale o di "alta amministrazione",particolarmente dopo l'emanazione della legge istitutiva,che ha stabilito che è ammesso ricorso al TAR del Lazio contro i provvedimenti deliberati dal CSM (e adottati con decreto del Presidente della Repubblica,controfirmato dal ministro della giustizia)per motivi di legittimità,e che contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Questa disposizione non consentirebbe,secondo alcuni autori,di assegnare al Consiglio la posizione di organo costituzionale;è da dire tuttavia che la natura costituzionale di un organo non impedisce che gli atti da esso deliberati (e recepiti nella specie con decreto del Presidente della Repubblica)possano essere sottoposti ad un controllo giurisdizionale. La natura di organo costituzionale del Consiglio sembra peraltro possa essere dedotto dalle attribuzioni ad esso conferite dall'art.105 Cost.,che valgono ad integrare il precetto costituzionale a norma del quale la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Di modo che il Consiglio rappresenterebbe,per quest'aspetto,un organo indefettibile del nostro sistema,nel senso che,se esso non ci fosse,verrebbero meno le garanzie di indipendenza e di autonomia che la Costituzione ha voluto assicurare al potere giudiziario nel suo complesso e ai singoli magistrati nei confronti degli altri poteri dello Stato. Il Consiglio non di rado ha preso posizione su questioni che pur riguardando la magistratura nel suo complesso,implicano più in generale valutazioni non strettamente inerenti alle sue attribuzioni(come quando,ad esempio,attraverso il giudizio disciplinare,ha finito col sindacare non il comportamento del magistrato ai fini dell'accertamento delle sue responsabilità ma il contenuto degli atti da lui compiuti).In altre occasioni ancora il Consiglio è entrato in conflitto con lo stesso Presidente della Repubblica nella sua qualità di presidente dell'organo,e con il

ministro della giustizia a causa di pretesi straripamenti delle sue attribuzioni(dovuti,secondo alcune tesi,ad una sua eccessiva "politicizzazione"). Questi conflitti(risolti dalla Corte costituzionale e spintesi spesso fino al limite di una crisi istituzionale)sono sicuramente sintomatici dell'indeterminatezza della posizione del Presidente della Repubblica quale presidente del Consiglio.
In conclusione,se da un lato la tesi secondo la quale il Consiglio è chiamato a svolgere soltanto compiti di "alta amministrazione"appare limitativa,dall'altro non si può dire che sia organo di indirizzo politico. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono assicurate,oltre che dal CSM anche da alcune norme costituzionali:così l'art.101 Cost. dispone che "I giudici sono soggetti soltanto alla legge",nel senso che essi devono godere di un'assoluta autonomia di giudizio,oltre che dall'art.107 comma III,secondo cui "I magistrati si distinguono fra loro soltanto per la diversità di funzioni",il cui fine è quello di sottrarre i giudici da rapporti di tipo gerarchico,che ne intaccherebbe l'autonomia. Una disciplina particolare vige poi per il **pubblico ministero** che,a norma dell'art.107 IV comma Cost. "gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario".In attuazione di questa disposizione il pm esercita le sue funzioni non più sotto la direzione del ministro della giustizia(come in origine),bensì unicamente sotto la sua VIGILANZA. Permane ancora una certa organizzazione gerarchica all'interno degli uffici del pm:il titolare dell'ufficio dirige lo stesso,ne organizza l'attività ed esercita personalmente le funzioni attribuite dal pm dal codice di rito penale. Nel corso delle udienze penali il magistrato designato svolge le funzioni di pm con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Un'altra garanzia dell'indipendenza dei magistrati(già prevista dall'ordinamento statutario)è stata ulteriormente prevista dalla Costituzione,secondo cui "I magistrati sono INAMOVIBILI."I magistrati non possono cioè essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non col loro consenso(sempre su deliberazione del CSM);il consenso non è richiesto quando i magistrati si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario o quando,per qualsiasi causa,anche indipendente da loro colpa,non possono svolgere le proprie funzioni con piena INDIPENDENZA ed IMPARZIALITA'. Possono tuttavia essere trasferiti di sede o destinate ad altre funzioni su loro domanda. A norma dell'art.106 Cost.,le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso:in tal modo si assicura la selezione dei migliori e si sottraggono i magistrati da influenze che potrebbero derivare da altri sistemi di designazione all'ufficio(ad esempio l'elezione).

8. Altre disposizioni costituzionali relative alla funzione giurisdizionale **-**Fra le disposizioni costituzionali relative alla funzione giurisdizionale bisogna ricordare: l'art. 111 "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata." . questo art. prevede inoltre l'obbligo di motivazione per tutti o provvedimenti giurisdizionali e stabilisce il fondamentale principio del contraddittorio; ancora l'art. 113, che aasicura la tutela giurisdizionale avverso gli atti della P. A.; l'art. 101, I

This document is available free of charge on StuDocu.com

comma, “La giustizia è amministrata in nome del popolo”. -quella relativa al ricorso in Cassazione contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà persona,quale garanzia riconosciuta all’imputato nei confronti di provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale; -l’ESTRADIZIONE(art.26): L’estradizione consiste nella consegna da parte di uno Stato ad un altro Stato di chi è accusato o condannato affinchè possa essere giudicato o sottoposto alla pena nello Stato richiedente,e nel nostro ordinamento non è ammessa per reati politici. Essa è regolata da apposite Convenzioni internazionali(ed ha dunque carattere di reciprocità),in specie dalla Convenzione europea di estradizione stipulata a Parigi nel 1957 ed entrata in vigore in Italia nel 1963,che conferma che l’estradizione del cittadino non può in alcun caso essere ammessa per reati politici;allo stesso modo,l’art.10 comma IV Cost.non ammette l’estradizione,sempre per reati politici,dello straniero. Scopo di queste norme sembra essere quello di sottrarre il cittadino a persecuzioni determinate da ragioni politiche e di parte;tuttavia gli ultimi commi dell’art.10 e del 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio. In nessun caso comunque è ammessa l’estradizione per reati sanzionati con la pena di morte nell’ordinamento dello Stato richiedente; - la disposizione relativa al carattere PERSONALE della responsabilità penale(art.27),in base al quale nessuno può essere ritenuto responsabile penalmente se non per un fatto commissivo o omissivo a lui direttamente imputabile. Non sarebbe pertanto ammessa la c.d.”RESPONSABILITA’ OGGETTIVA”, situazione in cui il soggetto può essere responsabile di un illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è riconducibile a dolo o colpa del soggetto stesso; - la PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA(art.27 II comma),secondo la quale l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva:tale presunzione si applica a maggior ragione all’indiziato di reato. La relativa norma costituzionale(art.27 II comma)posta a tutela della persona umana presenta anche aspetti pratici di rilievo laddove si fa riferimento alla CUSTODIA CAUTELARE,rispetto alla quale sono stati fissati dei limiti massimi(dando così attuazione all’art.13 comma IV Cost.)e la cui durata è stata commisurata alla natura del delitto; - la funzione delle PENE,che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità(art.27,III comma)e devono tendere alla rieducazione del condannato(no funzione punitiva).Anche in questo caso la Costituzione si è chiaramente ispirata al principio della tutela della persona umana.

9. La responsabilità dei giudici **–** Problemi delicati si pongono in relazione alla responsabilità dei giudici. Quanto alla *responsabilità penale*,vengono previste delle sanzioni per i magistrati nei casi di CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI,specialmente quando la corruzione sia commessa al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile,penale o amministrativo. Oltretutto viene sanzionato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio che,per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica,o ancora di ordine pubblico o di igiene e sanità,deve essere compiuto senza ritardo. Per quel che riguarda la *responsabilità civile*,il soggetto che ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento,di un atto o di un provvedimento

giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa o per diniego di giustizia può agire contro lo Stato al fine di ottenere il risarcimento per i danni materiali e non che derivano da privazione della libertà personale. Lo Stato esercita poi l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati può essere promossa o dal ministro della giustizia, o dal procuratore della Corte di cassazione ed è fatta valere dall'apposita sezione del CSM quando,nell'esercizio delle loro funzioni,manchino ai doveri di imparzialità,correttezza,diligenza,laboriosità,riserbo,equilibrio e rispetto della dignità della persona. Problemi più complessi presenta l'individuazione di una responsabilità politica dei magistrati: infatti,se è vero che l'attività del giudice può essere sindacabile quando è svolta in contrasto coi fini e i valori fondamentali cui è rivolto il suo ufficio,è anche vero che il nostro sistema non prevede la possibilità di far valere una responsabilità politica del giudice in sede istituzionale. Può quindi essere fatta valere tutt'al più una responsabilità diffusa,una forma di responsabilità cioè che i giudici assumono nei confronti dell'opinione pubblica e dell'intera collettività.

10. Il problema della politicità del giudice - Non esiste quindi un indirizzo politico dei giudici o della magistratura,ma esistono i giudici quali "operatori politici",in quanto istituzionalmente chiamati a incidere sulla realtà sociale. Con una sostanziale differenza però tra il giudice e gli altri operatori politici che si riconoscono nel nostro ordinamento:mentre infatti questi agiscono sempre come "parti",il giudice invece non è portatore di un particolare interesse,ma valuta interesse altrui e tutela quello fra essi che riconosce conforme alla Costituzione e al diritto obiettivo. Per cui il giudice deve essere libero da ogni influenza e suggestione che possono pervenirgli da altri organi o poteri,in specie dal potere esecutivo.
E' tuttavia proprio nell'interpretazione della legge che egli esprima giudizi di valore,che altro non sono se non la manifestazione della sua cultura,delle sue convinzioni,della sua ideologia o della sua condizione umana. Si tratta comunque sia di aspetti che evidenziano una contrapposizione dialettica che da un lato vale a rendere il magistrato partecipe della società in cui vive ed opera,dall'altro deve essere ricomposta nel momento in cui egli si pone "super partes" ed amministra la giustizia.

Capitolo quinto IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1. L'elezione e la durata del mandato- A norma dell'art.83 Cost.,il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune,integrato da 3 delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze(la Valle d'Aosta ha un solo delegato). L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza di 2/3 dell'assemblea;solo se al terzo scrutinio non si sia raggiunta tale maggioranza è sufficiente ai fini dell'elezione la maggioranza assoluta.(La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica viene fatta dal Presidente della Camera 30 giorni prima che scada il termine di 7 anni del mandato presidenziale;se le Camere sono sciolte,o manca meno

This document is available free of charge on StuDocu.com

di 3 mesi alla loro cessazione,l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere.Nel frattempo,vengono prorogati i poteri del Presidente in carica,ai sensi dell'art.83 Cost.)
La nostra Costituzione ha quindi adottato la soluzione di far eleggere il Capo dello Stato dai deputati e dai senatori riuniti in seduta comune e non già direttamente dal corpo elettorale (o dal corpo elettorale con procedimento di II grado,come avviene negli Stati Uniti,dove gli elettori di ogni Stato-membro designano gli elettori presidenziali che,a loro volta,eleggono successivamente il Presidente).Il metodo previsto per l'elezione del Presidente nella nostra Costituzione è senza dubbio più consono alla forma di governo parlamentare,mentre l'elezione da parte del corpo elettorale più si addice alla forma di governo presidenziale,che vede incentrata la funzione di indirizzo politico proprio nel Presidente della Repubblica. Se il Presidente fosse direttamente investito nel suo ufficio dal popolo infatti,questi potrebbe essere indotto a intervenire nella direzione politica dello Stato(proprio in quanto espressione diretta della volontà popolare)mentre,come sappiamo,nei regimi parlamentari tale direzione è riservata al raccordo tra gruppi parlamentari di maggioranza e Governo. La proposta,pure avanzata da alcune parti politiche,di far eleggere direttamente dal popolo il Presidente della Repubblica suscita a tal proposito notevoli perplessità. L'elezione diretta infatti non concorrerebbe a risolvere il problema della governabilità del Paese,ma rappresenterebbe anzi,con ogni probabilità,semplicemente la prima fase della trasformazione della forma di governo da parlamentare in presidenziale,dato che un Presidente della Repubblica eletto dal popolo sarebbe contrario alla logica costituzionale e finirebbe unicamente col provocare ulteriori squilibri istituzionali. C'è pure chi ha sostenuto in merito che la forma di governo presidenziale valga a meglio assicurare la stabilità politica,ma appare evidente che tale forma di governo mal si concilierebbe con la realtà politica italiana,nella quale la crisi di governabilità,più che alla mancanza di una centralizzazione del potere,sembra da imputarsi alla frantumazione dei partiti,anche dopo la trasformazione del sistema elettorale da proporzionale in parzialmente maggioritario,problemi questi per i quali la terapia di un'eventuale "personalizzazione" del potere potrebbe risultare del tutto inefficace(o addirittura controproducente). D'altra parte,prescrivendo per l'elezione l'intervento dei delegati regionali si nota come si sia inteso volutamente di allargare il più possibile la base elettorale,in modo che il Capo dello Stato,al quale sono attribuite,fra le altre,delicate funzioni di moderatore tra le varie forze politiche,non risulti elettoralmente collegato ad alcun partito. Opportunamente inoltre,è stata prevista la segretezza del voto per dar modo agli elettori presidenziali di votare in piena libertà e secondo il loro intimo convincimento. Per essere eletto Presidente della Repubblica,è sufficiente che il candidato sia cittadino italiano,abbia compiuto 50 anni di età e che doga dei diritti civili e politici. Il Presidente della Repubblica rimane in carica per 7 anni,che iniziano a decorrere dal giorno in cui il Presidente(a norma dell'art.91 Cost.)presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione innanzi al Parlamento in seduta comune,in quanto è da quel momento che il Presidente entra nel pieno esercizio delle sue funzioni. Il lungo periodo del mandato affidato al Presidente della

Repubblica trova una sua giustificazione laddove si osserva che,nel nostro regime parlamentare,il Capo dello Stato quale organo costituzionale non è organo di indirizzo politico,per cui non si rende necessario un rinnovamento a scadenze ravvicinate (come avviene invece nei regimi presidenziali). Inoltre,la Costituzione non pone alcun divieto alla rieleggibilità del Presidente alla scadenza della carica.

2. Le incompatibilità; la cessazione d'ufficio; la supplenza **-** A norma dell'art.84 comma II Cost.,"L'Ufficio di Presidenza della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica"(quindi anche con quella di deputato o senatore). La cessazione dell'ufficio può avvenire,oltre che,in via normale,per la scadenza del settennio,anche per: impedimento PERMANENTE(nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni); morte o dimissioni; decadenza dalla carica(in seguito,ad esempio,alla perdita della cittadinanza o dei diritti civili o politici). In caso di cessazione anticipata dall'ufficio,il Presidente della Camera indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni,salvo maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. Qualora il Presidente sia PERMANENTEMENTE o TEMPORANEAMENTE impedito ad adempiere le sue funzioni,queste vengono esercitare dal Presidente del Senato(c.d."SUPPLENZA",non esistendo nel nostro ordinamento,l'istituto della vicepresidenza). C'è da dire che non sempre si è fatto luogo alla supplenza tutte le volte in cui il Presidente della Repubblica si sia assentato dal territorio nazionale recandosi all'estero in veste ufficiale. Questa prassi trova una sua giustificazione nel fatto che il Presidente si reca all'estero in ragione del suo ufficio,e che,anche fuori dal territorio italiano,egli può continuare a svolgere le sue funzioni(firmando gli atti trasmessigli con apposito corriere nella sede dell'ambasciata italiana,o a bordo di una nave o di un aeromobile militari),prassi in merito alla quale sono tuttavia state sollevate non poche obiezioni e critiche in dottrina,mettendo soprattutto in rilievo che una prolungata assenza dall'Italia e la distanza dal territorio nazionale potrebbero impedire al Presidente di esercitare le sue funzioni con quella continuità e quella pienezza di informazioni che possono essere assicurate soltanto dalla presenza del Capo dello Stato in territorio nazionale.
Quanto all'impedimento permanente,l'art.86 Cost. non dispone nulla al riguardo,né circa la sua natura né circa i metodi del suo accertamento:l'articolo si limita di fatti a disporre che "Le funzioni del Presidente della Repubblica,in ogni caso in cui egli non possa adempierle,sono esercitate dal Presidente del Senato",e da riferimento all'impedimento permanente solo come stato di fatto al cui verificarsi il Presidente della Camera è legittimato ad indire le elezioni del nuovo Presidente. La natura e il modo di accertamento dello stesso,pertanto,vanno determinati in via interpretativa: la natura deve essere tale da provocare l'impossibilità (fisica o psichica) del Presidente ad esercitare le sue funzioni per un periodo di tempo indeterminato,indeterminabile o particolarmente lungo. Bisogna tuttavia chiarire che "permanente" non equivale a "definitivo",e sta ad indicare che l'impedimento deve avere tali caratteristiche da permanere nel tempo,senza escludere però che esso possa cessare. La permanenza dell'impedimento insomma vale ad indicare uno stato di fatto tale da lasciar

This document is available free of charge on StuDocu.com

prevedere,sulla base dei dovuti accertamenti compiuti,che non cesserà,almeno per la residua durata del mandato presidenziale.
Si pone pertanto la questione su chi debba effettivamente accertare e dichiarare lo stato di impedimento permanente;nell'incertezza che a tal proposito domina ancora in dottrina(c'è chi ritiene sia competente il Governo,chi il Presidente del Senato,chi il Presidente della Camera,altri ancora la Corte costituzionale o il Parlamento in seduta comune),non resta che riferirsi all'unico caso di impedimento fino ad ora verificatosi(malattia del Presidente Segni nel 1964):in quell'occasione,il Segretario generale della Presidenza della Repubblica comunicò al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle due Camere un bollettino medico attestante la malattia;il Consiglio dei Ministri diede atto dell'impedimento e ne trasmise notizia al Presidente del Senato,che convocò il Presidente della Camera e il Presidente del Consiglio;questi organi decisero che si era dunque venuto a verificare lo stato di fatto previsto dall'art.86 Cost.,per cui si diede luogo alla supplenza. Dal momento che l'impedimento si protrasse per oltre 4 mesi,furono assunte alcune iniziative in sede parlamentare perché venisse dichiarato l'impedimento permanente,ma a ciò non si giunse perché lo stesso Presidente Segni si dimise dall'ufficio. Il supplente del Presidente della Repubblica acquista la carica automaticamente,senza bisogno cioè di alcun atto di investitura e senza dover prestare giuramento. I poteri del supplente sono quelli propri del Capo di Stato;si ritiene tuttavia che egli(proprio perché occupa l'ufficio in via temporanea)debba,per correttezza costituzionale,e a meno che non ricorrano cause di assoluta necessità,astenersi dal compiere atti che incidano sull'equilibrio dei rapporti fra gli organi costituzionali(come ad es. lo scioglimento delle Camere o le consultazioni per la formazione del Governo).

3.Irresponsabilità del PDR e suoi limiti. In particolare: la controfirma ministeriale

- L'IRRESPONSABILITA' POLITICA: Il Presidente della Repubblica è politicamente irresponsabile in via istituzionale, giacchè la responsabilità politica degli atti presidenziale viene ad essere assunta dai ministri proponenti(o dai ministri competenti,nel caso in cui l'atto manchi di una proposta)che li controfirmano.
A ciò risaliva il divieto di far risalire al Capo dello Stato il biasimo e la responsabilità per gli atti di governo cui egli partecipa(art.279 codice penale,abrogato dalla legge 25 febbraio 2006 n.85). Ad ogni modo,l'art.89 richiede la controfirma ministeriale di tutti gli atti presidenziali non soltanto come strumento idoneo a fare assumere la responsabilità di tali atti al ministro,ma anche come requisito fondamentale di validità degli atti stessi("Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti"). E se mai si potrebbe parlare di una responsabilità politica diffusa del Presidente della Repubblica,soggetto,come tutti gli altri operatori politici,al potere di critica politica. Si è però sottolineato che tale tipo di responsabilità non avrebbe modo di esplicarsi pienamente,giacchè esisterebbe una regola convenzionale in virtù della quale le forze politiche dominanti tendono a sottrarre alle critiche il Capo dello Stato,non per avvantaggiarlo,bensì per,al contrario,per esigere,in contropartita,che egli non intervenga in tutte le vicende legate alle lotte fra i partiti e alla funzione di governo. L'IRRESPONSABILITA'

GIURIDICA: Diversamente si considera l'irresponsabilità giuridica del Presidente:mentre infatti il Presidente non è responsabile,sia penalmente che civilmente,per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,tranne che per ALTO TRADIMENTO o per ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE(art.90 Cost.),come privato cittadino egli è pienamente responsabile,ma,in materia penale,soltanto alla scadenza dell'ufficio(restando affidata alla responsabilità del Presidente la possibilità di presentare le dimissioni,qualora il reato commesso sia particolarmente grave) sempre che non siano decorsi i termini di prescrizione. La legge n.140 del 2003 prima e la 124 del 2008 come sappiamo avevano previsto la sospensione dei processi penali a carico,tra gli altri,anche del Presidente della Repubblica:in entrambi i casi tuttavia le norme sono state ritenute incostituzionali dalle Corte costituzionale. I REATI PRESIDENZIALI: Di difficile configurazione appaiono invece i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione,dal momento che tali stessi reati presidenziali non trovano previsione e disciplina nel codice penale. Sembra,comunque,che per ALTO TRADIMENTO debba intendersi ogni comportamento doloso che si concretizza in una violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica(as es.,l'attentato all'integrità e all'indipendenza dello Stato)e per ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE ogni comportamento,ugualmente doloso,atto a sovvertire le istituzioni costituzionali(ad esempio un compo il Stato)o a violare deliberatamente la Costituzione. Spetta al Parlamento porre in stato d'accusa il Presidente,a maggioranza assoluta dei suoi membri:il Presidente è poi sottoposto al giudizio della Corte costituzionale(secondo l'art.134 Cost.)

5. Le attribuzioni- Il Presidente della Repubblica è posto,nella nostra Costituzione,al di fuori dei tre poteri fondamentali dello Stato. Egli esercita quindi le sue attribuzioni non già come organo di questi poteri,bensì come Capo dello Stato,per cui in dottrina si è identificato un autonomo potere presidenziale,le cui funzioni non implicano mai una partecipazione diretta del Presidente all'attività di indirizzo politico(potere NEUTRO).In relazione alla funzione legislativa,il Presidente della Repubblica: indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione,e può convocare ciascuna Camera in via straordinaria; -può inviare messaggi alle Camere; - autorizza con suo decreto la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa; può,prima di promulgare una legge,chiedere una nuova deliberazione alle Camere con messaggio motivato; -può nominare cinque senatori a vita; -può sciogliere le Camere,sentiti i loro Presidenti,o una sola di esse; -promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; -indice il referendum abrogativo e costituzionale. In relazione al potere esecutivo il Presidente della Repubblica: nomina il Presidente del Consiglio e,su proposta di questi,i ministri; -nomina,nei casi previsti dalla legge,i funzionari dello Stato(di regola,di grado più elevato); -accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; -ratifica i trattati internazionali,previa,quando occorre,autorizzazione delle Camere; -ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa; -dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; conferisce le onorificenze della Repubblica; -ha una serie di competenze in ordine

This document is available free of charge on StuDocu.com

alle funzioni amministrative svolte dal potere esecutivo;così ad esempio decide i ricorsi straordinari a lui rivolti contro gli atti amministrativi illegittimi,conferisce la cittadinanza italiana,rimuove i sindaci dalla carica,scioglie i Consigli regionali,provinciali,comunali ecc. In relazione al potere giudiziario,il Presidente della Repubblica: -preside il CSM; -concede la grazia e commutata le pene; -nomina 5 giudici della Corte costituzionale(art.135 Cost.); può nominare 5 senatori a vita.

6. I messaggi ed il potere di esternazione- L'art.87 II comma Cost.si limita a disporre che il Presidente della Repubblica può inviare messaggi alle Camere. La sua dizione letterale(oltre che ragioni di opportunità politica,data la sua posizione super partes)porta quindi ad escludere che il Presidente possa leggerli o pronunciarli personalmente davanti alle Camere(come avveniva invece per il discorso alla Corona,pronunciato direttamente dal Stato),anche se sembra eccessiva la preoccupazione di chi(secondo una tesi sostenuta dal Rescigno),ritiene che la presenza fisica del Presidente della Repubblica entro le Camere suonerebbe come un'alterazione degli equilibri costituzionali. Mediante tale tipo di messaggio,il Presidente può segnalare agli ordinari legislativi(e attraverso essi,al Paese)gravi necessità comuni o l'esigenza di provvedere a determinate situazioni senza,in ogni caso,prendere posizione a favore dell'una o dell'altra parte politica. I messaggi(al pari di ogni atto compiuto nell'esercizio delle funzioni presidenziali)devono essere controfirmati,sia perché con la controfirma la responsabilità politica dell'atto viene assunta dal ministro o dal Preisdente del Consiglio(più in generale dal Governo)e sia perché tali atti possano essere validi. Nella prassi però si è affermato un altro tipo di messaggio,quello che il Presidente neo-eletto pronuncia davanti alle Camere in seduta comune subito dopo il giuramento:questo messaggio si distingue dagli latri perché non è INVIATO dal Presidente alle Camere e non è CONTROFIRMATO. Come tale,esso non dovrebbe rientrare,a stretto rigore,nel potere di messaggio del Presidente,bensì in un più generico "POTERE DI ESTERNAZIONE",che può manifestarsi in varie forme. Di tale potere i Presidenti della Repubblica hanno usato,con maggiore o minore intensità,a seconda del modo in cui hanno inteso l'esercizio delle loro funzioni. Suo presupposto è che il Presidente non può limitarsi a manifestarsi ufficialmente il suo pensiero soltanto mediante i messaggi,anche se la sua libertà di manifestazione del pensiero,per l'ufficio che ricopre,incontra sicuramente dei limiti. Innanzitutto egli deve evitare di ricorrere a forme di esternazione diverse dal messaggio quando potrebbe,invece,fare uso proprio di tale strumento. Ogni manifestazione del pensiero presidenziale che possa essere espressa con i messaggi di rinvio o con i messaggi alle Camere dovrebbe,insomma,esservi correttamente ricondotta. In secondo luogo,il potere di esternazione del Presidente è strettamente connesso all'esercizio delle sue funzioni e alla sua posizione di rappresentante dell'unità nazionale:ciò significa che egli può esercitarlo in occasione,durante l'esercizio delle sue funzioni,ed usando le forme proprie di tale stesso esercizio. Per cui ogni manifestazione del pensiero presidenziale,scritta o orale che sia,deve ottenere di regola,a meno che non si tratti,ovviamente,di manifestazioni di pura cortesia voluta dal protocollo,la controfirma e l'assenso preventivo del

Governo. Il Presidente della Repubblica,infatti,non è nel nostro ordinamento un organo di indirizzo politico e,pertanto,lettere alle Camere,discorsi pronunciati in Patria o all'estero,indirizzi alle forze armate o al CSM,interviste o dichiarazioni alla stampa,interventi alla televisione(a meno che non siano di pura circostanza,come i messaggi augurali)e ogni altra forma atipica di manifestazione del pensiero che abbia o possa avere riflessi politici dovrebbero trovare un limitato impiego.
Si ci è posti,pertanto,il problema relativo alle forme e ai limiti di questo potere presidenziale. C'è da dire che il Presidente della Repubblica si è sempre visto attribuiti ampi poteri nell'esercizio delle sue funzioni,che non ne fanno certamente uno spettatore passivo del gioco politico,un Presidente silenzioso,ma al contrario pongono in risalto la sua "forza politica". L'unico limite effettivo è che il Presidente deve e può manifestare il suo pensiero nelle forme e nei limiti voluti dalla Costituzione,via questa,che è di sicuro la meno agevole(soprattutto in presenza di vuoti politici e di crisi delle istituzioni)ma l'unica costituzionalmente ortodossa da seguire.

7. Lo scioglimento delle Camere- Lo scioglimento delle Camere può essere determinato da una situazione di contrasto fra Parlamento e Governo a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia da parte delle Camere(SCIOGLIMENTO SUCCESSIVO); dalla constatazione che le Camere,per chiari e inequivocabili segni(per esempio i risultati delle elezioni regionali),non rispecchino più la volontà del corpo elettorale;dall'incapacità delle Camere di esprimere una maggioranza stabile o ancora da una crisi di governo che la maggior parte dei partiti politici ritiene di poter risolvere soltanto ricorrendo ad una nuova consultazione elettorale(SCIOGLIMENTO ANTICIPATO o PREVENTIVO).
Nel caso in cui il Governo venga battuto da un voto di sfiducia,il Presidente della Repubblica può,valutate le circostanze che hanno determinato il voto e la situazione politica generale,usare del suo potere di scioglimento e rimettere quindi la decisione alla volontà popolare(scioglimento successivo).
Lo scioglimento anticipato invece deve essere giustificato da ragioni obiettive,e deve tendere a ristabilire il corretto funzionamento del meccanismo costituzionale.
Prima di sciogliere le Camere,il Presidente della Repubblica deve sentire il parere dei loro Presidenti. Tale parere è obbligatorio(ai sensi dell'art.88 Cost.)ma non vincolante ed è diretto a fare acquisire al Capo dello Stato le valutazioni politiche che,per la loro posizione,i Presidenti sono in grado di conoscere e riferire obiettivamente. Inoltre,egli non può sciogliere le Camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato,salvo che essi coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura(art.88 comma II così come modificato da legge cost.4 novembre 1991 n.1),il c.d."SEMESTRE BIANCO".Si è ritenuto che il divieto sia stato posto per impedire che il Presidente(il quale aspiri ad essere rieletto)sciolga le Camere,i cui membri egli stimi non essere favorevoli alla rielezione,facendo invece assegnamento sulle nuove Camere per la rielezione. Secondo un'altra ipotesi invece,sostenuta da Mortati e da Reposo,e che sembra preferibile,il divieto troverebbe il suo fondamento nella considerazione che il Presidente,ormai giunto alla fine del settennio,subisca una sorta

This document is available free of charge on StuDocu.com

di “depotenziamento di rappresentatività”,così da apparire meno idoneo a compiere quelle valutazioni di opportunità politica che lo scioglimento delle Camere senza dubbio comporta. (A norma dell’art.88 il Presidente potrebbe decidere di sciogliere anche una sola delle due camere: ora,se questa norma aveva una sua giustificazione quando la durata in carica delle due Camere era differenziata,adesso che,dopo la riforma del 1963,ambedue sono elette per 5 anni,lo scioglimento di una sola Camera provocherebbe,più che nel passato,gravi ripercussioni sullo svolgimento dei lavori parlamentari. Sembra quindi che ad oggi siano venuti meno i presupposti stessi dello scioglimento di una sola Camera.)

8. Classificazione degli atti presidenziali - Gli atti presidenziali possono classificarsi in tre grandi categorie: ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI (il cui contenuto è cioè predisposto e voluto dai membri del Governo); ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI; ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE COMPLESSI(il cui contenuto è predisposto e voluto sia dal Presidente della Repubblica sia dal Governo). Appartengono alla prima categoria i decreti presidenziali contenenti atti aventi forza di legge (decreti-legge e decreti legislativi),sia aventi efficacia subordinata a quella della legge formale(i regolamenti)e gli atti che siano espressione della funzione amministrativa(ad es.la nomina degli alti funzionari)e dell’attività di indirizzo politico(ad es.,la nomina dei ministri,l’autorizzazione alla presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa). Rispetto a tali atti,il Presidente della Repubblica può esercitare soltanto un controllo di legittimità (o,anche se limitatamente,di merito)e richiederne il riesame,senza poter tuttavia incidere sulla determinazione di volontà del Governo,che di fatti,se insiste nel volere il provvedimento,obbliga il Presidente,che non potrà più rifiutarsi,a sottoscriverli. Appartengono alla seconda categoria la nomina di cinque senatori a vita,la nomina di cinque giudici costituzionali,la nomina di otto esperti quali componenti del CNEL,il rinvio al Parlamento di una legge,la promulgazione delle leggi,i messaggi. Rispetto a tali atti,il Presidente gode(pur nei limiti della Costituzione) di un’ampia sfera di discrezionalità,perché il loro contenuto viene determinato esclusivamente dalla sua volontà. A questi atti va ad aggiungersi la concessione della grazia:infatti la Corte costituzionale,con la sent.n.200 del 2006 ha stabilito che il potere di grazia risponde ad esigenze essenzialmente umanitarie,e pertanto la sua titolarità spetta al Presidente della Repubblica,quale organo super partes e rappresentante dell’unità nazionale(anche per evitare che un provvedimento destinato a rimuovere un giudicato possa essere assunto in obbedienza a ragioni politiche di parte). Appartengono infine alla terza categoria la nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento delle Camere:per quel che riguarda l’atto di nomina del Presidente del Consiglio,questo è da considerarsi quale atto formalmente presidenziale e sostanzialmente complesso perché mentre spetta al Presidente di scegliere (entro i margini di discrezionalità di cui gode)la personalità che egli ritenga meglio in grado di costituire un Governo che possa ottenere la fiducia,l’incaricato,a sua volta,accettando la nomina e

controfirmando il relativo decreto,mostra essenzialmente di accettare la valutazione compiuta dal presidente. Per quel che riguarda invece lo scioglimento delle Camere,si tratta di un atto sostanzialmente complesso perché nel caso di scioglimento anticipato il Presidente non potrebbe,di sua esclusiva volontà,rompere il rapporto Parlamento-Governo senza il pericolo di provocare delle gravi ripercussioni politiche(ad esempio il rifiuto della controfirma da parte del Presidente del Consiglio):la sua decisione pertanto,non può non essere affidata,oltre che al presidente,anche al Governo dimissionario,che dovrà valutare l'opportunità politica dello scioglimento e assumerne,con la controfirma del relativo decreto,la responsabilità.

9. La posizione giuridica - In merito alla posizione che il Presidente della Repubblica assume nel sistema costituzionale,va anzitutto tenuta ferma la qualificazione dell'organo come "POTERE NEUTRO",come potere cioè che non rientra nel gioco politico,che è posto al di sopra delle parti e che non svolge alcuna funzione attiva nella determinazione e nell'attuazione dell'indirizzo politico. Proprio in tal senso,il Presidente è rappresentante dell'unità nazionale(art.87 Cost.)e ne è il simbolo:nella sua persona si assomma e si armonizza quindi l'unità dello Stato(e in questa limitata accezione deve intendersi la dizione di "Capo dello Stato"enunciata nell'art.87 Cost.). Le stesse attribuzioni del Presidente confermano sostanzialmente il carattere imparziale e neutrale che i Costituenti vollero assegnare al suo ufficio,ma egli non è tuttavia un "personaggio evanescente,un motivo di pura decorazione" citando le parole di Ruini,ma anzi esercita una concreta influenza sul corretto svolgimento delle attribuzioni costituzionali,attraverso: il potere di controllo della costituzionalità dei provvedimenti imputati al Governo; il potere di iniziativa,di impulso e di persuasione(*); il potere di decisione(entro i limiti visti)sul modo di risoluzione dei conflitti fra Governo e Parlamento; il potere di nomina del Presidente del Consiglio,nel caso in cui sia politicamente possibile la formazione di più coalizioni governative. Il Presidente della Repubblica insomma,nell'esercizio delle sue funzioni,vigila sul funzionamento del meccanismo costituzionale ed interviene nel momento in cui le regole che lo disciplinano non vengono osservate,al fine di assicurare il rispetto,formale e sostanziale,della Costituzione e il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi cui spetta la direzione politica del Paese. E' bene tuttavia,come ha osservato Esposito,non mitizzare eccessivamente il ruolo del Capo dello Stato in regime parlamentare,quale potere neutro,dal momento che l'interpretazione dei poteri che ad esso vengono attribuiti è pur sempre condizionata da chi impersona l'ufficio,come la stessa esperienza italiana insegna. Potrebbe tuttavia accedere che,in caso di crisi,il Presidente tenda ad ampliare le sue funzioni,a divenire cioè Capo dello Stato non soltanto formalmente,ma anche sostanzialmente(secondo appunto la tesi sostenuta da Esposito).Anche a volere ammettere in tal caso l'estensione dei poteri presidenziali,occorre però che l'attività del Presidente sia sempre contenuto e circoscritto entro ben precisi limiti,posti dalla Costituzione,e che egli si attenga alle regole del gioco,in modo da partecipare,assieme agli altri organi costituzionali,alla corretta soluzione della crisi. Il Presidente deve esercitare la sua *forza politica* senza diventare uomo di parte-egli

This document is available free of charge on StuDocu.com

dev’essere sempre dalla parte della COSTITUZIONE e rappresentare l’unità nazionale, anche se i suoi atti incidono inevitabilmente sullo schieramento delle forze politiche. Una certa attenzione merita la figura dell’ex Presidente, definito Presidente emerito, al quale spetta un seggio di diritto e a vita al Senato.

CAPITOLO SESTO-LA CORTE COSTITUZIONALE

Il carattere rigido di una costituzione richiede che le sue norme vengano garantite contro possibili violazioni operate dal legislatore ordinario. In regime di costituzione rigida infatti il legislatore incontra precisa limiti(formali e materiali)nell'emanazione delle leggi,che non possono di fatti porsi in contrasto con la costituzione. Sappiamo invece come le costituzioni flessibili possano essere modificate da legge ordinaria. Ne consegue che le costituzioni rigide prevedono,di regola,alcuni strumenti mediante i quali è possibile controllare la LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE delle leggi,al fine di togliere ogni efficacia a quelle che risultino essere in contrasto con una disposizione costituzionale. La nostra Costituzione,a tal proposito,ha creato un organo ad hoc,appunto la Corte costituzionale(art.134 e seguenti)alla quale è stato affidato,oltre che il giudizio sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge,dello Stato e delle Regioni,anche il giudizio sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato,fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni,il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e infine(art.2 legge cost.1/1953)il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo. I giudizi sulle accuse(che non rientrerebbero nella normale competenza della Corte),sono stati affidati alla Corte medesima,ma integrandola con alcuni membri aggiuntivi,per contemperare il loro indubbio carattere politico con quelle esigenze di imparzialità e di tecnica giuridica che sono proprie dello svolgimento dell'attività giudiziaria. E' da rilevare che nel nostro ordinamento non è ammesso il ricorso individuale alla Corte, per cui il soggetto che ritenga di aver avuto lesa da un altro privato o da un pubblico potere una sua situazione giuridica soggettiva costituzionalmente rilevante dovrà pur sempre,per ottenere giustizia,rivolgersi ad un giudice(ordinario o speciale a seconda dei casi),e dipenderà dal giudice se la legge che una delle parti presume lesiva di una norma costituzionale che tutela la situazione giuridica soggettiva oggetto del giudizio verrà sottoposta al controllo della Corte.

1. La composizione e il funzionamento- La Corte costituzionale è composta in modo diverso,a seconda che giudichi sulle controversie di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge,sui conflitti di attribuzione e sull'ammissibilità del referendum abrogativo o sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica. Nei primi tre casi(che sono quelli più frequenti,rimanendo eccezionale il quarto),la Corte è composta da 15 giudici nominati per 1/3 dal Presidente della Repubblica,per 1/3 dal Parlamento in seduta comune,e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa(art.135 Cost.). I giudici la cui nomina spetta alle supreme magistrature sono eletti:tre da un collegio composto da magistrati della Corte di cassazione,uno da un collegio composto da magistrati del Consiglio di Stato e uno da un collegio composto da magistrati della Corte dei Conti; i giudici la cui nomina spetta al Parlamento in seduta comune sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei componenti nel primo,secondo e terzo scrutinio,mentre negli scrutini successivi al terzo sono sufficienti i 3/5 dei componenti; infine i giudici la cui

This document is available free of charge on StuDocu.com

nomina spetta al Presidente della Repubblica sono nominati con suo decreto,controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri(atto formalmente e sostanzialmente presidenziale). Questo perché la maggioranza parlamentare contribuisce ad eleggere già 1/3 dei membri della Corte,se poi la stessa maggioranza,attraverso il Governo che ne è l'espressione,potesse proporre al Capo dello Stato anche i nomi di altri 5 giudici,la scelta di ben 10 dei 15 membri sarebbe da collegare direttamente o indirettamente alla maggioranza,che in tal modo riuscirebbe a far sentire il suo peso nella Corte,il che avrebbe ripercussioni di rilievo circa l'imparzialità dell'organo.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti: fra i magistrati,anche a riposo,delle giurisdizioni superiori,ordinarie e amministrative;fra i professori ordinari di università in materie giuridiche;fra gli avvocati dopo 20 anni di esercizio professionale. Nei giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica,la composizione ordinaria della Corte viene integrata con l'aggiunta di altri 16 membri(GIUDICI AGGREGATI).Tali giudici,a norma dell'art.135 comma VII Cost.,vengono eletti a sorte da un elenco di persone compilato mediante elezione,ogni 9 anni,dal Parlamento in seduta comune fra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
I giudici ordinari della Corte sono nominati per 9 anni,decorrenti dal giorno del giuramento di osservare la Costituzione e le leggi nelle mani del Presidente della Repubblica,alla presenza dei Presidenti delle due Camere,e non possono essere nuovamente nominati:alla scadenza del termine,il giudice cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Un'ipotesi di PROROGATIO,definita "speciale",è però disciplinata dalla legge n.20/1962(contenente norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa),che dispone che "I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte fino all'esaurimento del giudizio,anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico":è stato questo ad esempio il caso che si è venuto a determinare con l'inizio del processo penale nei confronti degli ex ministri Gui e Tanassi,essendo nel frattempo scaduto il mandato di due giudici della Corte,che venne quindi ad essere istituita da 17 giudici. Per quel che riguarda il funzionamento,va detto che le udienze della Corte sono pubbliche,ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse qualora la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico,o ancora quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni che possano turbare la serenità,ai sensi della legge 87/1953. La Corte funziona con l'intervento di almeno 11 giudici. Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio,e vengono prese con l maggioranza assoluta dei votanti;nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente(legge n.87 del '53). Nei giudizi sulle accuse,il Collegio giudicante deve in ogni caso essere costituito da almeno 21 giudici(il doppio),dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza. In caso di parità di voti prevale sempre l'opinione più favorevole all'accusato(ai sensi della legge n.20 del 1962).Infine,la Corte può disporre anche l'audizione di testimoni e,in deroga a divieti stabiliti da altre leggi,il richiamo di atti e documenti.

2. Lo status di giudice costituzionale- I giudici costituzionali non possono anzitutto assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati,né esercitare attività professionali che abbiano fini di lucro. Durante il periodo di appartenenza alla Corte i giudici che siano magistrati in servizio o professori universitari non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni;i giudici inoltre non posso essere candidati in elezioni amministrative o politiche(legge 87/1953). La stessa legge ha posto ai giudici costituzionali il divieto di svolgere attività inerenti ad un'associazione o partito politico(la formula lascia intendere che il giudice che all'atto della nomina sia iscritto ad un partito possa continuare a farne parte,senza però svolgervi alcuna attività,mentre una norma di correttezza costituzionale dovrebbe consigliare i giudici costituzionali in carica a non chiedere l'iscrizione ad alcun partito).
I giudici costituzionali sono ad ogni modo assistiti da una serie di garanzie d'indipendenza,in particolare:

- non possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni(art.3 legge cost.1 del 1948); la deliberazione della Corte deve essere assunta a maggioranza di 2/3 dei componenti che partecipano all'udienza(art.7 legge cost.n.1 del 1953);
- finchè durano in carica godono delle stesse garanzie previste in Costituzione dall'art.68 II comma per i parlamentari,ivi compresa quella per la sottoposizione a giudizio penale,ormai abolita per i parlamentari;le relative autorizzazioni a procedere sono date dalla Corte stessa(ai sensi dell'art.3 legge cost.n.1 del 1948);
- non sono sindacabili né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni(art.5 legge cost.n.1 del 1953);
- spetta alla Corte accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'art.135 ultimo comma,deliberando a maggioranza assoluta dei componenti. I giudici ordinari hanno una retribuzione mensile non inferiore a quella del più alto magistrato della g. ordinaria ed è determinata con legge.

3. Il Presidente della Corte c. **-**Una particolare posizione assume,in seno alla Corte,il Presidente della Corte medesima:egli è eletto dalla Corte a maggioranza assoluta;nel caso in cui nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione,e dopo di questa,eventualmente,alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parità,è proclamato eletto il più anziano in carica e,in mancanza,il più anziano di età(art.6 legge n.87/1953). Il Presidente resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile:egli rappresenta la Corte,la convoca,la revoca,sovraintende all'attività delle commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti per legge e dai regolamenti della Corte. In particolare il Presidente:

This document is available free of charge on StuDocu.com

- nomina nei giudizi di legittimità costituzionale un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca entro i successivi 20 giorni la Corte per la discussione;
- quando lo ritenga necessario può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti;
- fissa con decreto il giorno dell'udienza pubblica e convoca la Corte;se nessuna delle parti si è costituita in giudizio può convocare la Corte in Camera di consiglio;
- regola la discussione e può indicare i punti e determinare i tempi nei quali essa deve contenersi;
- nella deliberazione delle ordinanze e delle sentenze vota per ultimo,e in caso di parità,prevale il suo voto(tranne che nei giudizi di accusa,nei quali,come detto,prevale il giudizio più favorevole all'imputato).

Da queste attribuzioni del Presidente,sembra che la sua posizione,se da un punto di vista puramente formale possa considerarsi quella di un "primus inter pares",sotto il profilo sostanziale invece si configura come una posizione di reale preminenza,non assoluta ma comunque sia tale da consentirgli di svolgere un ruolo di impulso e di coordinamento nello svolgimento e nella decisione dei giudizi,pur nella piena applicazione del principio di collegialità che regola lo svolgimento dell'attività della Corte. Questa influenza ha modo di esprimersi soprattutto con la determinazione del calendario dei giudizi,mediante la quale il Presidente può scegliere il momento favorevole alla discussione delle varie questioni, e la designazione del giudice istruttore e relatore che può sicuramente incidere sull'impostazione stessa della trattazione. Anche le disposizioni a norma delle quali il Presidente vota per ultimo e in caso di parità il suo voto prevale possono sicuramente in determinate circostanze concorrere a porre il Presidente in una posizione di preminenza sostanziale all'interno della Corte.

Sezione I- I GIUDIZI SULLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

4. I vizi di legittimità costituzionali delle leggi- Si distinguono in VIZI FORMALI e VIZI MATERIALI. Si ha VIZIO FORMALE quando la legge viene approvata dal Parlamento violando una delle norme sul procedimento di formazione della legge o secondo un procedimento diverso da quello prescritto in Costituzione. Così ad esempio accadrebbe qualora una Camere approvasse una proposta di legge senza che sia stata preventivamente sottoposta all'esame della commissione legislativa competente per materia o votasse una proposta di legge senza che questa sia stata prima approvata articolo per articolo(la legge sarebbe formalmente viziata per violazione dell'art.72 comma I Cost.,in base al quale ogni disegno di legge deve essere esaminato da una commissione competente per materia e poi dalla Camera stessa,che l'approva articolo per articolo con votazione finale).
Con le sent.n.9 del 1959,78 del 1984 e 154 del 1985,la Corte ha affermato la sua competenza a controllare la legittimità formale della legge che risulti viziata per violazione delle norme costituzionali sul procedimento,escludendo invece che il

controllo possa estendersi anche sulle norme sul procedimento contenute nei regolamenti parlamentari. Si ha invece VIZIO MATERIALE quando la norma contenuta in una legge ordinaria o in un atto ad essa equiparato è in contrasto con una norma costituzionale o con un principio costituzionale(anche implicito nell'ordinamento)o quando l'organo che ha emanato la legge non era competente secondo il riparto delle competenze legislative previsto in Costituzione.Come esempio del primo tipo di vizio materiale si può considerare il caso di una legge che autorizzi la limitazione della libertà di corrispondenza anche senza previa deliberazione dell'autorità giudiziaria(laddove l'art.15 Cost. dispone invece che la limitazione di tali libertà può venire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria).Si ha invece il secondo tipo di vizio materiale (detto anche "PER INCOMPETENZA")quando una legge dello Stato invade per esempio la sfera di competenza riservata ad una Regione(dalla Costituzione o dallo Statuto regionale)e viceversa quando una legge regionale invade la sfera di competenza legislativa dello Stato. I vizi materiali delle leggi si estendono anche agli atti aventi forza di legge(che sono pertanto sindacabili dalla Corte costituzionale tutte le volte che si pongano in contrasto con la Costituzione). Concludendo,si può dire quindi che i vizi formali attengono all'atto e,più precisamente,al procedimento con il quale l'atto è stato posto in essere;i vizi materiali invece o al contenuto dell'atto,vale a dire alla norma in quanto contrastante con un precetto costituzionale(si avrà allora la violazione di una legge costituzionale)o al soggetto che ha emanato l'atto legislativo al di fuori della sfera di competenza ad essa riservata dalla Costituzione(ed avremo allora l'incompetenza) o ancora l'esercizio del potere legislativo per un fine diverso da quello assegnato dalla Costituzione o in modo non conducente ai fini o ancora non rispondente al criterio della ragionevolezza(e avremo allora l'eccesso di potere). Tracciare una linea di confine fra il giudizio sulla legittimità delle leggi e il giudizio sul merito delle stesse è comunque un'operazione non facile. La Corte è chiamata infatti a giudicare la legittimità di una legge assumendo come canoni di valutazione criteri elastici quali la ragionevolezza,il senso comune,la coscienza sociale,i valori culturali ecc.,e tenendo anche conto che alcune disposizioni costituzionali contengono concetti indeterminati,sono formulate genericamente o indicano i fini generalissimi che il legislatore dovrebbe perseguire. Racchiudere il giudizio nell'ambito della legittimità senza invadere quello della discrezionalità proprio del legislatore,evitare che il giudizio sulla conformità delle leggi alla Costituzione si trasformi in un giudizio sulla loro opportunità richiede pertanto da parte della Corte una rigorosa autolimitazione dei suoi poteri (SELF-RESTRAINT),nel senso che la stessa dovrà porre a fondamento delle sue valutazioni criteri e canoni (ancorchè metagiuridici) obiettivamente ricavabili dalle norme costituzionali,senza interferire nelle scelte operate dal legislatore. Anche le leggi costituzionali possono essere sottoposte al controllo della Corte sia sotto il profilo dell'illegittimità formale(quando cioè non sia stato osservato il procedimento di formazione previsto nell'art.138 Cost.)sia sotto il profilo dell'illegittimità materiale,se si ammette l'esistenza di alcuni limiti posti al potere di revisione costituzionale. L'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti equiparati può farsi valere secondo due distinti procedimenti:un

This document is available free of charge on StuDocu.com

primo procedimento in via D'ECCEZIONE(o INCIDENTALE) ed un secondo in via D'AZIONE(o PER IMPUGNATIVA DIRETTA).Questo secondo procedimento può essere adottato soltanto dallo Stato per impugnare una legge regionale o provinciale o dalla Regione per impugnare una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o una legge di altra Regione. Resta pertanto esclusa nel nostro sistema l'impugnativa diretta delle leggi e degli atti equiparati che si ritengano in contrasto con la Costituzione da parte di chi lamenti che una legge o un atto equiparato abbia leso una situazione giuridica soggettiva. Alla Corte è precluso ogni giudizio sul merito delle leggi.

5. Gli atti soggetti al sindacato di legittimità costituzionale- Dispone a questo riguardo l'art.134 Cost. che "La Corte giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni". Secondo un'interpretazione restrittiva della disposizione,sono quindi soggetti a sindacato: le leggi, gli atti aventi forza di legge (restandone in tal modo esclusi gli atti materialmente amministrativi e le sentenze,insieme anche ai regolamenti). Si tratta di una scelta operata dall'Assemblea costituente giacchè in linea di principio anche i regolamenti,gli atti amministrativi e le sentenze potrebbero essere soggetti al sindacato di costituzionalità. Tale interpretazione restrittiva è prevalsa(anche nella stessa giurisprudenza della Corte)rispetto a quella estensiva(Mortati)che vorrebbe assoggettati al sindacato di legittimità costituzionale anche i regolamenti qualora,derogando alla legge,ne acquistino la stessa efficacia sostanziale. Nell'individuare gli atti aventi forza di legge si è cioè preferito il criterio formale a quello sostanziale,forse anche per un'esigenza di certezza derivante dalle difficoltà interpretative che possono sorgere nell'accertare l'efficacia sostanziale in un regolamento. D'altra parte,l'illegittimità costituzionale di un regolamento può sempre essere accertata in sede giurisdizionale(ordinaria o amministrativa)facendo valere il vizio di violazione di legge.
La Corte ha anche escluso(sent.183 del 1973 e n.170 del 1984)che oggetto del suo sindacato possono essere gli atti normativi dell'UE perché,sebbene siano da considerare come atti aventi forza e valore di legge in ogni Stato membro dell'Unione,essi non sono di per sé atti aventi forza di legge dello Stato.Quindi in definitiva,atti soggetti al sindacato di costituzionalità della Corte sono:

-leggi ordinarie dello Stato e delle Regioni(alle quali bisogna aggiungere le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano);

-le leggi costituzionali,sicuramente sotto il profilo dell'illegittimità formale ma anche sotto quello dell'illegittimità sostanziale se si accoglie la tesi che accerta l'esistenza di alcuni limiti assoluti alla revisione costituzionale;

-gli atti aventi forza di legge dello Stato,vale a dire i decreti-legge e i le leggi delegate. Dubbi possono sorgere sull'impugnabilità di un decreto-legge,giacchè nel breve periodo della sua vigenza come tale(al massimo 60 giorni,alla scadenza dei quali il decreto legge o viene convertito in legge o decade,perdendo efficace ex tunc),appare problematico che possa instaurarsi ed esaurirsi il giudizio innanzi alla

Corte.N.B.:Ma in questo caso la Corte ha disposto che il controllo di costituzionalità si sposta sulla legge di conversione (sent.n.84 del 1996)in specie nei casi di reiterazione.In particolare,con la sentenza n.29 del 1995 la Corte aveva stabilito che il vizio dei presupposti del decreto si trasmette in automatico alla legge di conversione,che quindi può essere sottoposta a legittimo sindacato di costituzionalità da parte della Corte. D'altra parte la prassi della reiterazione dei decreti legge non convertiti è di per sé stessa da ritenersi in contrasto con l'art.77 della Costituzione(come specificato nella sent.n.360 del 1996)e quindi,già di per sé incostituzionale. La Corte costituzionale ha dichiarato inoltre inammissibile la questione di illegittimità costituzionale su un decreto-legge non convertito. Il decreto potrà invece essere impugnato in via d'azione da una Regione che lamenti la lesione della sua sfera di competenza ad opera del decreto,purchè tale lesioni si determini immediatamente in seguito alla sua entrata in vigore. Altri atti cui l'ordinamento attribuisce la stessa efficacia formale della legge e per i quali è quindi da ammettere la sindacabilità sono i decreti di attuazione degli Statuti speciali,mentre il sindacato della Corte è da escludere per il risultato di un referendum abrogativo,non solo perché il referendum non è atto dello Stato ma diretta espressione della volontà popolare,quanto perché la relativa richiesta è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Corte,in ordine al suo oggetto;per cui un successivo sindacato a referendum avvenuto sarebbe ripetitivo e al massimo si potrebbe ipotizzare un sindacato sulle condizioni di validità del referendum,inerenti alle maggioranze richieste dal penultimo comma dell'art.75 Cost.(già soggette al controllo dell'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione). Anche i regolamenti parlamentari sarebbero, secondo alcuni autori, sottoponibili al giudizio di legittimità, ma la Corte si è espressa in senso contrario.

6. Il procedimento in via incidentale: la proposizione della questione- L'art.1 della legge cost.n.1 del 1948 dispone che la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge,rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio,è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione;precisando ulteriormente,l'art.23 della legge n.87 del 1953 ha statuito che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata,mediante apposita istanza,nel corso di un giudizio innanzi ad un'autorità giurisdizionale: a) da una delle parti(ivi compreso il pubblico ministero); b)d'ufficio,dall'autorità giurisdizionale in causa. Il sistema adottato è quindi il ricorso alla Corte tramite un'autorità giurisdizionale e in occasione e nel corso di un giudizio. Il ricorso diretto all'organo di giustizia costituzionale nel caso in cui i pubblici poteri violino un diritto fondamentale infatti non è previsto nel nostro ordinamento(mentre è previsto nella Germania federale,in Austria,in Spagna e in alcuni Paesi latino-americani). L'idoneità a sollevare la questione di legittimità costituzionale è stata riconosciuta anche alla Corte dei Conti,al CSM,alle commissioni tributarie,al giudice di sorveglianza per l'esecuzione della pena,al giudice istruttore in sede civile e agli arbitri in sede d'arbitrato;infine la Corte ha riservato a se stessa la questione in sede di conflitto di attribuzione,sia in sede di giudizi su controversie di legittimità

This document is available free of charge on StuDocu.com

costituzionale sia nel caso di giudizio sulle accuse. La questione di legittimità costituzionale viene sollevata mediante apposita istanza indicando:

- le disposizioni della legge o dell'atto equiparato che si assumono viziate;
- le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si presumono violate.

Può però accedere che il vizio di legittimità costituzionale sia determinato non dalla violazione diretta di una disposizione costituzionale,bensì dalla violazione di una c.d."**norma interposta**".Gli esempi più semplici sono dati dal decreto legislativo emanato in contrasto con il contenuto della legge di delega(in ipotesi,su un oggetto diverso da quello in essa definito):la difformità immediatamente rilevabile è infatti quella fra decreto legislativo e legge di delega(che è quindi la norma interposta) ma,al tempo stesso,il primo ha violato l'art.76 Cost.,a norma del quale il Governo è tenuto ad osservare i limiti posti alle Camere nella legge di delega all'esercizio del potere legislativo delegato. Altro esempio è quello delle leggi dello Stato,che definiscono i principi fondamentali cui devono attenersi le leggi regionali nelle materie di competenza concorrente con lo Stato(indicate dal III comma dell'art.117 Cost.),perché anche in questo caso la difformità immediatamente rilevabile è fra legge regionale e le disposizioni della legge statale,ma al tempo stesso la legge regionale viola,seppur indirettamente,i precetti costituzionali contenuti nel III comma dell'art.117. Con le sent. n.348 e n.349 del 2007,da ultimo la Corte costituzionale ha chiarito che la natura di fonti interposte deve inoltre essere riconosciuta non solo alle consuetudini internazionali,ma anche alle norme contenute nei trattati internazionali,in virtù della formula contenuta nel nuovo comma I dell'art.117 Cost.che fa riferimento genericamente agli "OBBLIGHI COMUNITARI". L'istanza respinta può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo(art.24 legge n.87 del 1953).

7. I poteri del giudice a quo- Il giudice innanzi al quale è sollevata la questione(GIUDICE A QUO)deve pronunciarsi su di essa. Dispone al riguardo l'art.1 della legge cost.n.1 del 1948 che il giudice deve accertare che la questione NON SIA MANIFESTAMENTE INFONDATA. Preliminarmente alla decisione sulla questione,il giudice deve quindi accertare:

- che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione(la c.d."RILEVANZA DELLA QUESTIONE"):in altri termini,il giudice dovrà esaminare se la questione sia stata sollevata nei confronti di una legge o atto equiparato fondamentale ai fini della definizione del giudizio. E' infatti questo il punto di diritto che interessa al giudice a quo,e non l'astratta possibilità che una legge sia incostituzionale. Ed infatti,se la questione riguardasse una legge che il giudice non ritiene di dover applicare per la definizione della controversia sottoposta al suo esame,la questione stessa sarebbe del tutto irrilevante per quel giudizio.Pertanto(e secondo la consolidata giurisprudenza della Corte)perché la questione sia rilevante

deve esistere un rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione stessa e la decisione del giudizio principale;

- ritenuta rilevante la questione,il giudice dovrà accertare che essa non sia manifestamente infondata,il che vuol dire che il giudice dovrà respingere la questione quando PALESEMENTE gli appaia priva di ogni fondamento giudiziario,e dovrà accoglierla quando,al contrario,l'infondatezza non gli appaia manifesta,palese,quando cioè egli sia sfiorato dal dubbio della legittimità costituzionale della legge,ritenga cioè che possa esistere un "FUMUS BONI IURIS"sulla fondatezza della questione. Bisogna tuttavia aggiungere che l'orientamento ormai prevalso della giurisprudenza della Corte è che il giudice a quo debba sollevare la questione solo se sia risultato impossibile dar luogo ad un'interpretazione conforme a Costituzione(c.d."ADEGUATRICE")della disposizione da applicare nel giudizio. I poteri conferiti al giudice a quo sono quindi notevoli,giacchè la proposizione del giudizio innanzi alla Corte costituzionale dipende esclusivamente da questi. Come è stato acutamente osservato dal Calamandrei,"il giudice funziona dunque da "portiere",da INTRODUTTORE NECESSARIO del giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale." E' sufficiente infatti che egli ritenga la questione irrilevante o manifestamente infondata perché la stessa non trovi ingresso alla Corte costituzionale. Qualora poi il giudice ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata,emette un'ordinanza (ORDINANZA DI REMISSIONE)con la quale,riferiti i termini e i motivi dell'istanza con cui fu sollevata la questione stessa,dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale(divenendo,in tal modo,l'introduttore del giudizio,c.d."GIUDICE A QUO")e sospende il giudizio in corso(ai sensi dell'art.23 comma II legge n.87/1953). Nell'ordinanza devono essere indicate le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge di cui si denuncia l'incostituzionalità e le disposizioni costituzionali che si assumono violate. L'ordinanza dovrà poi essere notificata alle parti in causa e al pubblico ministero(qualora il suo intervento sia obbligatorio),nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale(qualora la questione riguardi una legge regionale)e comunicata ai Presidenti delle Camere o al Presidente del Consiglio regionale interessato. Scopo della notifica e della comunicazione ai Presidenti del Consiglio dei ministri e della Giunta regionale,nonché ai Presidenti delle Camere e del Consiglio regionale è quello di consentire che vengano eventualmente adottate le opportune iniziative legislative atte a modificare l'atto,eliminando i vizi denunciati prima che la Corte intervenga pronunciando la sua sentenza,abrogandolo. L'ordinanza stessa viene inoltre pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quando occorra nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate,e ciò al fine di portare a conoscenza di tutti che si è instaurato un giudizio di legittimità costituzionale. Se invece il giudice respinge la questione,la relativa ordinanza deve essere "adeguatamente motivata":il giudice dovrà cioè dar conto adeguatamente dei motivi che lo hanno indotto a respingere la questione perché irrilevante o manifestamente infondata. Il modo di instaurazione del giudizio incidentale presenta dunque l'evidente inconveniente di essere strettamente subordinato al sorgere di un

This document is available free of charge on StuDocu.com

giudizio innanzi ad un'autorità giurisdizionale;per cui,fino a quando tale giudizio non venga ad instaurarsi,non è comunque possibile far valere l'incostituzionalità della legge.

8. Il giudizio innanzi alla Corte costituzionale- Entro 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza emessa dal giudice a quo,le parti in giudizio potranno esaminare gli atti depositati nella cancelleria ed eventualmente presentare le loro deduzioni. Allo stesso modo,entro lo stesso termine di 20 giorni,il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale interessata potranno intervenire in giudizio(il Presidente del Consiglio rappresentato dall'Avvocatura di Stato,il Presidente di Giunta da un avvocato libero professionista)e presentare le loro deduzioni(l'intervento del Presidente del Consiglio,così come quello del Presidente della Giunta non ha alcun valore tecnico;come tale non è necessario o obbligatorio,ma facoltativo;allo stesso modo le parti nel giudizio a quo non sono tenute a costituirsi come parte innanzi alla Corte,in quanto oggetto del giudizio è la legittimità costituzionale della legge,e non l'esistenza o meno di una determinata situazione giuridica soggettiva).
Trascorso il termine di 20 giorni entro il quale le parti e il Presidente del Consiglio o della Giunta regionale possono intervenire,il Presidente della Corte nomina un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca entro i successivi 20 giorni la Corte per la discussione. Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza,la Corte può decidere in Camera di consiglio. L'art.9 comma 2 delle NORME INTEGRATIVE del 2008 prevede inoltre che il Presidente possa convocare la Corte in Camera anche qualora ravvisi che ricorra il caso di manifesta inammissibilità,di estinzione o di restituzione degli atti al giudice rimettente. La Corte funziona con l'intervento di almeno 11 giudici,e le decisioni vengono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio,e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità,si fa valere il voto del Presidente. La Corte giudica in via definitiva con sentenza.

9. Il procedimento in via d'azione o principale - A norma dell'art.127 comma I,nel nuovo testo introdotto dalla legge cost. n.3 del 2001,il Governo della Repubblica,qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione,può promuovere la questione di legittimità costituzionale finanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge stessa. La questione viene sollevata dal Presidente del Consiglio,previa deliberazione del Consiglio dei ministri. A norma poi del secondo comma dello stesso articolo(come modificato dalla legge cost.n.3 del 2001),la Regione,qualora ritenga che una legge statale o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza,può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. Con la nuova normativa costituzionale,Stato e Regione vengono posti sullo stesso piano per quanto riguarda il carattere del sindacato di legittimità costituzionale in via d'azione(o principale)delle rispettive leggi:sia che il ricorso provenga dallo Stato,sia

che provenga da una Regione,il sindacato è SUCCESSIVO alla pubblicazione della legge impugnata. Per quanto riguarda i VIZI DENUCIABILI davanti alla Corte,il nuovo spirito "federalistico"della riforma costituzionale portava a pensare che sia lo Stato che le Regioni potessero proporre ricorso in via d'azione solo per invasione delle rispettive sfere di competenza costituzionalmente tutelate. La Corte costituzionale ha invece rimesso in piedi l'originaria disparità di posizione,attribuendo allo Stato la possibilità di impugnare le leggi regionali con la stessa ampiezza del recedente regime,a causa della "POSIZIONE PECULIARE"riservata allo Stato dall'ordinamento costituzionale a garanzia dell'unità della Repubblica(sent.n.274 del 2003). Questa disparità di trattamento nel giudizio principale appare quindi come una sorta di "residuo"della mentalità centralistica dura a morire(nonostante i dettami dell'art.5 Cost.) L'efficacia della legge impugnata può essere sospesa dalla Corte costituzionale nelle more del giudizio,qualora ritenga che possa da essa derivare "il rischio di un'irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica,ovvero il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini"(art.9 comma 4 legge n.131 del 2003).Finora, la Corte non ha mai usato tale potere. A norma del II comma dell'art.123 Cost. inoltre,il Governo può impugnare gli Statuti regionali davanti alla Corte entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

10. Le decisioni della Corte cost.- A norma dell'art.18 della legge 87 del 1953,la Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e devono contenere,oltre alle indicazioni dei motivi di fatto e di diritto,il dispositivo,la data della decisione e la sottoscrizione del Presidente e del giudice che le ha redatte. La Corte inoltre non può ampliare l'ambito del suo giudizio,ma deve attenersi,nel pronunciare la sentenza,a ciò che le è stato chiesto e non allargare il thema decidendum oltre i limiti in cui è stato formulato dalle parti e dal giudice,secondo il principio della CORRISPONDENZA FRA CHIESTO E PRONUNCIATO. Nel caso dunque in cui la Corte accerti il contrasto con la Costituzione della disposizione legislativa,la dichiarerà illegittima(ai sensi dell'art.136 Cost. e della legge 87 del 1953).
Tuttavia c'è da precisa re che la Corte,che aveva precedentemente dichiarato la questione infondata,potrebbe successivamente ritenere illegittima una disposizione legislativa per vizi diversi da quelli un tempo denunciati;non solo,ma può anche accadere(ed è di fatto accaduto)che la Corte,che aveva dichiarato l'infondatezza della questione,muti giurisprudenza e dichiari l'illegittimità della disposizione legislativa ancorchè la questione che le è stata posta sia identica a quella prima respinta,nel senso che denunci i medesimi vizi di incostituzionalità(il mutamento della giurisprudenza della Corte è sempre possibile,laddove si considera il rinnovarsi della composizione della Corte stessa,i cui membri non sono nominati a vita ma anzi restano in carica nove anni e non possono,alla scadenza,essere nuovamente nominati). Quel che deve sempre prevalere è,comunque sia,il FAVOR CONSTITUTIONIS,per cui se la legge o l'atto avente forza di legge vengano

This document is available free of charge on StuDocu.com

riconosciuti costituzionalmente illegittimi,la Corte ne dichiarerà una volta per tutte l'ILLEGITTIMITA',con la conseguenza di togliere loro efficacia ed applicabilità. Altro tipo di pronuncia si ha quando la Corte dichiara la MANIFESTA INFONDATEZZA della questione:ciò può avvenire nel caso in cui la Corte prenda in esame questioni formulate negli stessi termini,motivi o profili già dichiarati infondati(e non ritenga di dover cambiare giurisprudenza) o ancora quando la questione sia palesemente inconsistente. Quando invece si tratta di questioni relative a norme già dichiarate incostituzionali,la Corte preferisce ricorrere ad una DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA'. Infine, in via generale va detto che a norma dell'art.137 comma III Cost., "Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione":esse sono cioè DEFINITIVE e, come ribadito dalla Corte stessa, inoppugnabili e insindacabili. La corte provvederà solo alla correzione di errori materiali.

11. I tipi di sentenze: le sentenze di accoglimento- Giudicando con sentenza definitiva,la Corte può:a)dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa;b)dichiarare l'infondatezza della questione(ai sensi dell'art.18 legge.87 del 1953).Nel primo caso si ha una SENTENZA DI ACCOGLIMENTO,nel secondo una SENTENZA DI RIGETTO. A tal proposito,l'art.136 Cost.dispone che "Quando la Corte dichiara l'illegittimià costituzionale di una norma di una legge o di un atto avente forza di legge,la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza". L'EFFICACIA DELLE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO: Sembrerebbe quindi che l'EFFICACIA di queste sentenze abbia valore per l'avvenire (EX NUNC) e non riguardi,pertanto,i rapporti e le situazioni giuridiche già pendenti,che dovrebbero continuare ad essere disciplinati(in obbedienza al principio TEMPUS REGIT ACTUM) della legge dichiarata costituzionalmente illegittima. Conseguenza,questa,palesemente assurda. L'art.1 della legge cost.n.1 del 1948 dispone allora che la questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata in sede di applicazione giudiziale della legge(ossia nel corso di un giudizio),per cui la "perdita d'efficacia" della norma va intesa nel senso che,dal giorno successivo della pubblicazione della sentenza,la legge non può più trovare applicazione,diventa una sorta di "guscio vuoto" che non può più spiegare i suoi effetti:le norme incostituzionale vengono,per così dire,"espunte" dall'ordinamento giuridico. In un ordinamento a costituzione rigida come il nostro,nel quale esiste un apposito organo deputato a sindacare in merito alla legittimità costituzionale delle leggi,sarebbe infatti contraddittorio che leggi dichiarate costituzionalmente illegittime continuino a spiegare i loro effetti. Se la perdita di efficacia valesse inoltre per l'avvenire(ex nunc)e non anche per il passato(ex tunc)nessuna parte in giudizio solleverebbe la questione di legittimità costituzionale,per il semplice motivo che non ne avrebbe più interesse:infatti,la sentenza di accoglimento della Corte non spiegherebbe i suoi effetti nel giudizio in cui la questione è stata appunto sollevata. E' quindi intuitivo che la parte in tanto solleverà la questione in quanto abbia interesse a ciò che la norma supposta illegittima venga dichiarata tale dalla Corte e quindi non le venga applicata,e perdano

dunque di efficacia;perdita di efficacia dunque intesa come DISAPPLICAZIONE della norma stessa,e disapplicazione non soltanto da parte del giudice a quo ma anche da parte di ogni altro giudice(per cui,per evidenti ragioni di economia,quando viene sollevata una questione di incostituzionalità,i giudici che hanno in corso un processo nel quale la stessa norma denunciata di incostituzionalità dovrebbe trovare applicazione,di regola lo sospendono anch'essi,in attesa del giudizio della Corte),e non solo da parte dei giudici,ma anche da parte di qualsiasi altro soggetto(pubblico o privato)che avrebbe potuto o dovuto applicare la norma. Da ciò deriva che le sentenze di accoglimento della Corte hanno efficacia ERGA OMNES,con l'effetto di produrre l'ANNULLAMENTO delle norme dichiarate illegittime. Ma le sentenze di accoglimento hanno anche per destinatario,in senso più ampio,il legislatore,al quale l'art.136 comma I Cost.impone di accettare l'immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima,anziché prolungarne la vita fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore,e al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia,bensì il perseguire e raggiungere,anche se indirettamente,esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione(sent.88 del 1966).
Occorre a questo punto chiedersi fino a che punto si estenda l'efficacia retroattiva della sentenza,e quindi la disapplicazione della legge costituzionalmente illegittima. Sembra che il punto di arresto sia dato dai rapporti già regolati in via definitiva dalla legge incostituzionale,quindi dalle sentenze passate in giudicato e dagli atti amministrativi che sono divenuti definitivi,o ancora dai rapporti per i quali siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza,con una sola eccezione,che è quella prevista dall'art.30 comma IV legge 87 del 1953,a norma del quale "Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna,ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali". Si tratta,nella specie,di un'applicazione del principio contenuto nell'art.2 comma II del codice penale,giustificata dalla particolare tutela della libertà personale voluta dalla nostra Costituzione. La sentenza della Corte si applica invece a tutti i rapporti in qualunque modo ancora pendenti,e cioè non ancora esauriti. L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE: Nella stessa sentenza di accoglimento,la Corte può dichiarare(art.27 legge 87)quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata(la c.d.ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE).Si può pensare ad esempio alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma contenuta in un decreto legislativo,dalla quale derivi l'illegittimità della norma delegante affetta dallo stesso vizio(sent.390 del 1991). La giurisprudenza della Corte tuttavia non è univoca in merito al c.d."NESSO CONSEGUENZIALE",anche se sembra affermarsi la tendenza a rinvenire tale nesso tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di disposizioni CONFERMATIVE,APPLICATIVE o RIPETITIVE di quelle dichiarate illegittime o di disposizioni a queste strettamente collegate. In ogni caso,la dichiarazione di illegittimità consequenziale rappresenta una chiara deroga al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Un ulteriore effetto delle sentenze di accoglimento è dato poi dalla RIVIVISCENZA

This document is available free of charge on StuDocu.com

delle norme abrogate dalle norme dichiarate costituzionalmente illegittime,ma spetta in tal caso alla Corte controllare se le norme ridivenute operanti non presentino a loro volta aspetti di parziale illegittimità(sent.n.107 del 1974).

Il dispositivo delle sentenze di accoglimento è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana(proprio perché la decisione della Corte incide sul preesistente ordine normativo);le sentenze e le ordinanze vengono pubblicate nel testo integrale nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e,se riguardano leggi regionali,nel Bollettino Ufficiale della Regione interessata;le sentenze sono comunicate entro due giorni dalla data del deposito alle Camere ed ai Consigli regionali interessati affinchè,laddove lo ritengano necessario,adottino i provvedimenti di loro competenza. Scopo della comunicazione è infatti quello di consentire a questi organi di colmare,dove lo ritengano opportuno o si renda necessario,con l'approvazione di una nuova legge,il vuoto legislativo determinatosi in seguito alla sentenza della Corte,ma non è da escludere che,qualora vi sia urgenza di provvedere,possa,e anzi debba,intervenire il Governo con un decreto-legge. Sia il regolamento della Camera che quello del Senato prevedono poi adeguate procedere dirette a disciplinare l'intervento delle Camere nel caso in cui,a seguito della sentenza della Corte,si renda necessario o si ritenga opportuno assumere un'iniziativa per colmare il vuoto provocato dalla decisione. In particolare,alla Camera la commissione competente per materia esprime in un documento il proprio parere sulla necessità dell'iniziativa legislativa,mentre al Senato la commissione competente,allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge,adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.

12. Le sentenze di rigetto- Sono le sentenze con le quali la Corte dichiara infondata la questione. Si è già detto che la sentenza di rigetto vale ad escludere la sussistenza dei vizi di legittimità così come formulati nella questione,ma non ad escludere che possano essere denunciati dalle stesse parti gli stessi o altri vizi(pertanto tale sentenza non ha l'efficacia del giudicato). Se mai dubbi permangono sulla possibilità che la questione di legittimità possa essere riproposta in un'ulteriore fase dello stesso giudizio nel corso del quale venne sollevata la prima volta(per essere poi respinta dalla Corte):sembra di si,a patto però che si facciano valere vizi di legittimità diversi da quelli già ritenuti insussistenti dalla Corte.
Può accadere(come già detto) sia che la Corte dichiari in un nuovo giudizio l'illegittimità costituzionale di norme rispetto alle quali si era già pronunciata con una sentenza di rigetto,qualora siano denunciati nuovi o diversi vizi;sia(ma più raramente)che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale di norme denunciate di illegittimità per quegli stessi vizi di incostituzionalità dei quali precedentemente aveva escluso la sussistenza con una sentenza di rigetto. Va tuttavia detto che la Corte dichiara di regola "MANIFESTAMENTE INFONDATE"le questioni di legittimità costituzionale riproposte negli stessi termini di altre sulle quali si era già pronunciata con sentenza di rigetto. L'EFFICACIA DELLE SENTENZE DI RIGETTO: Le

sentenze di rigetto non hanno dunque efficacia ERGA OMNES:la loro efficacia vale soltanto(nel procedimento in via incidentale)nei confronti del giudice a quo,nel senso che il giudice sarà tenuto ad applicare la legge rispetto alla quale era stata formulata la questione.

13. Le sentenze interpretative- Secondo quanto dispone l'art.23 della legge 87/1953,"i TERMINI E I MOTIVI DELL'ISTANZA con cui fu sollevata la questione"vengono formulati dalle parti e riferiti dal giudice nell'ordinanza di rimessione. Essi costituiscono quindi il THEMA DECIDENDUM del giudizio innanzi alla Corte:per cui la parte in giudizio(o il giudice),avendo ritenuto che da un certo testo legislativo è da trarre una norma costituzionalmente illegittima,solleva la questione di legittimità costituzionale;la Corte pertanto è chiamata a giudicare NEI TERMINI E PER I MOTIVI IN CUI FU SOLLEVATA LA QUESTIONE,dovrà pertanto decidere la norma in esame sia o meno in contrasto con la Costituzione. Senonché la Corte ha ritenuto alle volte di dover REINTERPRETARE il testo legislativo:è accaduto così che la Corte ha tratto dal testo legislativo non la stessa norma tratta dalle parti o dal giudice ma una norma diversa(il che è possibile,se si pensa al modo talvolta ambiguo,polivalente in cui vengono formulati i testi legislativi. A conclusione del giudizio pertanto non si avrà una sentenza di accoglimento né una sentenza di rigetto,bensì una sentenza che è stata definita INTERPRETATIVA e che,a sua volta,può essere DI ACCOGLIMENTO o DI RIGETTO. Il potere di reinterpretare il testo si arresta però per riconoscimento della stessa Corte davanti alla costante interpretazione giurisprudenziale che attribuisce al precetto legislativo un determinato significato(DIRITTO VIVENTE).Al riguardo infatti,la Corte ha rilevato che essa,pur nella sua piena autonomia di giudizio,non può non tenere in debito conto una costante interpretazione giurisprudenziale,se è vero che le norme non sono quelle proposte in astratto,ma quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice,intesa a renderle efficaci in concreto(sent.88 del 1977). SENTENZE INTERPRETATIVE DI RIGETTO: Si ha tale tipo di sentenza quando la Corte,avendo tratto dal testo legislativo una norma in tutto o in parte diversa da quella tratta dalle parti e dal giudice,dichiara che, rispetto a questa norma,non sussistono vizi di legittimità costituzionale,facendo in tal modo salvo il testo legislativo. Delle sentenze interpretative di rigetto sono state date diverse giustificazioni:quella del Branca(ex Presidente della Corte)parla,a questo riguardo,di "opportunità,convenienza,riflessi politici"come motivi contingenti di tali decisioni,al fine di evitare "un buco nell'ordinamento,buco che è di per se stesso un male"(l'HORROR VACUI),per sostenere poi che la Corte costituzionale è portata piuttosto a conservare la legge che ad annullarla,non per una sorta di "FAVOR LEGITIMITATIS"bensì perché "eliminare radicalmente un atto legislativo che può essere salvato in tutto o in parte sarebbe come uscire dal campo delle proprie attribuzioni per invadere quello delle abrogazioni,riservato al legislativo".A questa tesi si è opposto che Parlamento e Corte costituzionale non operano in campi totalmente separati e contrapposti,e che quindi l'horror vacui non avrebbe ragion d'essere perché,nel caso in cui la Corte riconosca che la norma deducibile dalla

This document is available free of charge on StuDocu.com

disposizione legislativa non è conforme alla Costituzione e la espunga dall'ordinamento giuridico,il Parlamento dovrebbe,qualora fosse necessario ai fini della completezza e della coerenza dell'sistema normativo,colmare la lacuna e sostituire la disposizione dichiarata illegittima con una conforme alla Costituzione. Nel passato poi le sentenze interpretative di rigetto sono state contestate dalla magistratura ordinaria(in particolare dalla Corte di cassazione)che ha rimproverato alla Corte costituzionale di non attenersi al principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Per cui un certo potere di reinterpretare il testo legislativo va indubbiamente riconosciuto alla Corte,sia pure entro certi limiti,soprattutto quando la questione sia relativa a norme recenti,sulle quali quindi non si sono ancora formati orientamenti giurisprudenziali consolidati. L'EFFICACIA DELLE SENTENZE INTERPRETATIVE DI RIGETTO: In merito all'efficacia delle sentenze interpretative di rigetto,esse non valgono a privare d'efficacia la legge,nel senso che fanno salvo il testo legislativo. Altrettanto chiaramente però esse non hanno efficacia ERGA OMNES,anche perché,se così fosse,la Corte si sostituirebbe indebitamente al legislatore fornendo una specie di interpretazione autentica del testo legislativo. Si tratta allora di esaminare se vincolato all'interpretazione della Corte sia il giudice a quo.La dottrina al riguardo è divisa: alla tesi infatti,secondo la quale il giudice è tenuto ad applicare la norma come individuata dalla Corte nel suo significato proprio,si oppone(ed è prevalente)quella di chi ritiene che il vincolo sia soltanto NEGATIVO,giacchè la sentenza vieterebbe al giudice di interpretare il testo nel senso disatteso dalla Corte,ma lo lascerebbe libero di dargli qualsiasi altra interpretazione. Nella specie,la Corte di cassazione ha stabilito il principio secondo cui le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale determinano solo un VINCOLO NEGATIVO per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione. In tutti gli altri casi,il giudice conserva il potere e anzi il dovere di interpretare le disposizioni di legge in piena autonomia,secondo quanto prescive l'art.101 Cost. Qualora però alla Corte dovessero continuare a pervenire questioni di legittimità costituzionale formulate secondo l'interpretazione del testo legislativo da essa respinta,alla stessa non resterebbe che colpire il testo dichiarandone l'illegittimità costituzionale con una sentenza puramente di accoglimento. LE SENTENZE INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO: Si hanno quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di un testo se e in quanto si ricavi da esso una determinata norma illegittima. In tal mod vengono fatte salve tutte le altre possibili interpretazioni del testo. In altre parole,E' DICHIARATO ILLEGITTIMO SOLO UN CERTO SIGNIFICATO INTERPRETATIVO DEL TESTO,che viene espunto in quanto norma in contrasto con la Costituzione. E' da dire però che decisioni di questo tipo sono andate via via rarefacendosi,ed oggi la Corte preferisce ricorrere piuttosto a sentenze di accoglimento PARZIALE che si hanno quando,pur lasciando immutato il testo,la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di norme o di frammenti di norme da esso desumibili in via interpretativa. Con questo tipo di sentenze,la Corte in realtà interviene sulla portata normativa della disposizione,che viene estesa,ridotta o comunque cambiata,in modo da ricondurre il testo nell'alveo della legittimità costituzionale. In tutti i casi in cui la Corte usa questa tecnica di intervento,si parla di

SENTENZE MANIPOLATIVE,che implicano la nascita di una nuova norma,più ampia,più ristretta o comunque diversa da quella prospettata come illegittima dal giudice a quo. La tipologia delle sentenze manipolative comprende ancora:

- le sentenze ADDITIVE,con le quali la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di un testo nella parte in cui NON contiene una previsione normativa,che deve invece necessariamente esserci (ad esempio la sentenza con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art.5 codice penale nella parti in cui non escludeva dall'INESCUSABILITA' dell'ignoranza della legge penale l'IGNORANZA INEVITABILE);senza che ciò significhi che la norma immessa sia creata dalla Corte,essendo già implicita nel sistema. Le sentenze additive possono inoltre essere DI GARANZIA quando riconoscono un diritto fondamentale negato dalla norma illegittima,o DI PRESTAZIONE quando riconosco una pretesa patrimoniale tutelata dalla Costituzione e negata dalla norma legittima. Può accadere inoltre che la Corte non immetta nell'ordinamento una regola immediatamente applicabile,ma solo un principio derivante dalla Costituzione,cui il legislatore dovrà attenersi nella disciplina futura del medesimo oggetto(SENTENZE ADDITIVE DI PRINCIPIO);
- le sentenze RIDUTTIVE,con le quali la Corte dichiara l'illegittimità di un testo nella parte in cui contiene una previsione normativa,che invece NON deve esserci.

14. Altri tipi di sentenze- Le sentenze SOSTITUTIVE,che si hanno quando la Corte sostituisce ad una parte del testo(che così come formulata,vale a qualificarne l'illegittimità costituzionale)con un'altra;

- sentenze D'INDIRIZZO o sentenze MONITO, con le quali la Corte,rilevata la mancanza in una determinata legge di disposizioni che dovrebbero esserci perché ritenute essenziali al fine di assicurare il rispetto della Costituzione,si indirizza al legislatore e detta essa stessa i criteri ai quali dovrà uniformarsi per adeguare la disciplina della materia ai precetti costituzionali. Si distinguono dalle "ADDITIVE DI PRINCIPIO"perché non immettono un principio nuovo in una disciplina particolare,ma indicano al legislatore la strada da seguire per una futura normativa costituzionalmente legittima. Altre volte invece la Corte si limita a dare dei SUGGERIMENTI sul modo di disciplinare la materia conformemente a Costituzione,con l'auspicio che tali suggerimenti vengano accolti e seguiti,ma raramente il legislatore è sollecito ad accoglierli,costringendo così la Corte a far ricorso alla sentenze di monito o a quelle additive di principio.

Sezione II- I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

15. I conflitti di attribuzione, fra i poteri dello Stato- A norma dell'art.134 comma III Cost.,la Corte costituzionale giudica "sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello

This document is available free of charge on StuDocu.com

Stato,e su quelli tra lo Stato e le Regioni,e tra le Regioni ".Perché sorga conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato sono necessarie le seguenti condizioni:

- che sorga fra organi appartenenti a poteri diversi;
- che sorga fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono;
- che sorga per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

Restano pertanto esclusi dalla competenza della Corte i conflitti fra organi appartenenti a giurisdizioni diversi(c.d."CONFLITTI DI GIURISDIZIONE") ed i conflitti fra organi appartenenti ad uno stesso potere(ad esempio,fra due ministri)(c.d. "CONFLITTI DI COMPETENZA"). Tuttavia,l'indeterminatezza della formula ha fatto sorgere non poche incertezze interpretative:il primo dubbio è sorto,in particolare,in merito alla nozione di "POTERE",che solitamente viene inteso come un organo o insieme di più organi fra loro funzionalmente collegati ed al quale va riferita una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite. In questo senso,fra i poteri dello Stato rientrano oltre che le tre funzioni tradizionali(legislativa,esecutiva,giudiziaria),anche il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Questo modo di intendere i poteri dello Stato che vede gli stessi compresi nell'ambito dello Stato-soggetto va tuttavia aggiornato alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale:di fatti è stata riconosciuta la qualità di potere dello Stato anche alla Corte dei Conti in sede di esercizio sia della funzione giurisdizionale e sia della funzione di controllo,e con la stessa sentenza(n.69 del 1978),la Corte ha riconosciuto tale qualità alla frazione del corpo elettorale,rappresentata dai PROMOTORI,che può richiedere(a norma dell'art.75 Cost.)il referendum abrogativo(e in generale,ai firmatari delle richieste di referendum). La Corte ha ritenuto al riguardo che se "poteri dello Stato"legittimati a proporre conflitto di attribuzione ai sensi dell'art.134 Cost.sono anzitutto e principalmente i poteri dello Stato-apparato,ciò non esclude che possano riconoscersi come poteri dello Stato anche figure soggettive esterne rispetto allo Stato apparato,purchè ad esse l'ordinamento conferisca la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite,concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statuali in senso proprio. Per cui vanno riconosciuti come poteri anche quelli compresi nell'area dello Stato-istituzione. Tuttavia,nel momento in cui ha stabilito che deve trattarsi di figure soggettive cui l'ordinamento conferisce la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite,suscettibili di concorrere con quelle attribuite a organi e poteri statali in senso proprio,la Corte ha chiaramente fissato non solo un criterio di individuazione,ma soprattutto di DELIMITAZIONE di tali poteri. Sono pertanto esclusi dai poteri esterni allo Stato-soggetto i partiti politici,i sindacati e ogni altri figura soggettiva non compresa nell'apparato statale,che non hanno attribuite dall'ordinamento funzioni suscettibili di concorrere con quelle attribuite a organi e poteri dello Stato in senso proprio.
In merito agli "organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere

cui appartengono"si deve anzitutto notare che anche in questo caso permangono diverse incertezze interpretative circa la loro identificazione,dubbi che tuttavia sono stati risolti dalla Corte stessa,che ha stabilito:

- che l'art.37 legge 87/1953 designa gli organi legittimati ad essere parti di conflitti ex art.134 Cost. valendosi di una perifrasi con la quale si allude ad organi i cui atti o comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi;
- che dunque la cerchia degli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono è più larga di quella degli organi comunemente detti "SUPREMI"(vale a dire gli organi costituzionali)in quanto strutturalmente collocati al vertice di un potere,e devono essere individuati caso per caso.Cosicchè,come è stato osservato da Cerri,il requisito della "DEFINITIVITA'"coincide con l'esercizio indipendente di attribuzioni costituzionali.

In conclusione si può dire che nel conflitto di cui si discute possono anche essere parti sia poteri strutturati in un solo organo(c.d. "POTERI ORGANO,ad es.il Presidente della Repubblica,la Corte cost.)sia organi minori di un singolo potere,in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere al quale appartengono(c.d."ORGANI POTERI"). La Corte peraltro ha negato che la legittimazione a sollevare conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato possa spettare a singoli ministri o al solo Presidente del Consiglio,in nome dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo proclamata dall'art.95 comma I Cost.,che altrimenti rischierebbe di venire compromessa,e sia perché,di norma,le specifiche funzioni amministrative dei singoli non assumono rilievo costituzionale,bensì le attribuzioni dell'esecutivo complessivamente intese. La regola ha però le sue eccezioni:la Corte ha infatti ammesso che un ministro,nella specie il ministro della giustizia,può essere parte di un giudizio su conflitto di attribuzione quando è abilitato dalla Costituzione a esercitare attribuzioni a lui proprie(costituzionalmente conferite)in merito all'oggetto o alla materia di cui si tratta;analoghe considerazioni valgono per il Presidente del Consiglio.

Ricapitolando,soggetti del conflitto possono essere:

- i giudici;
- le Camere(singolarmente e nel loro complesso);
- le Commissioni parlamentari d'inchiesta;
- il Governo come organo complesso;
- il Presidente del Consiglio e i ministri(nei limiti sopra detti);
- il Presidente della Repubblica;
- la Corte costituzionale;
- il CSM;
- la Corte dei Conti;
- figure soggettive esterne allo Stato-apparato(ad es.i promotori del referendum abrogativo).

This document is available free of charge on StuDocu.com

Un primo dato che possiamo trarre dalla formulazione dell'art.37 della legge 87 del '53 è che affinchè sorga conflitto di attribuzioni,la sfera di attribuzione stessa degli organi configgenti deve essere delimitata da norme costituzionale;ciò premesso,sorge subito il quesito alla possibilità di far sorgere un conflitto per la delimitazione delle sfere di attribuzioni di ciascun potere se tale stessa sfera è determinata espressamente da norme costituzionali. Deve trattarsi anzitutto di un conflitto tra organi appartenenti a poteri diversi,che ha per oggetto l'attribuzione di una competenza,il che lascia intendere che la determinazione della sfera di attribuzioni ad opera della Costituzione possa anche non essere netta ed inequivocabile. Oltre che in tale ipotesi,il conflitto può sorgere anche quando un organo non rivendichi a sé la competenza a compiere un determinato atto,ma denunci che il comportamento omissivo di un altro soggetto o un atto abbiano menomato la sua competenza o ne abbiano impedito l'esercizio(c.d."CONFLITTO DA MENOMAZIONE").
Un esempio del primo tipo di conflitto si potrebbe avere nel caso il cui il Parlamento si rivolga alla Corte assumendo che il Presidente della Repubblica non potesse ratificare un trattato senza autorizzazione delle Camere,perché rientrante fra quelli previsti dall'art.80 Cost.Esempio di conflitto del secondo tipo invece si potrebbe avere nel caso in cui le Camere lamentino che il Presidente della Repubblica,non promulgando una legge entro un mese dall'approvazione,e senza rinvio,abbia impedito la tempestiva entrata in vigore della legge medesima,rendendo in tal modo vano l'esercizio della sua competenza. Riassuntivamente,possiamo quindi affermare che un conflitto tra poteri può sorgere quando un atto o un comportamento,che si assume illegittimo,provochi un pregiudizio al ricorrente,vuoi perché interviene nella sfera di competenza in tutto o in parte a lui riservata,vuoi perché gli impedisce di esercitare proprie attribuzioni o ostacola l'efficacia dei suoi atti,vuoi perché ne turba in qualche modo l'indipendenza come potere dello Stato. A parametro del giudizio devono essere poste norme costituzionali.

16. Fra Stato e Regioni e fra Regioni- Secondo quanto disposto dall'art.39 legge n.87 del 1953,tale conflitto può sorgere quando una Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato o viceversa quando lo Stato invade con suo atto la sfera di competenza costituzionale di una Regione. Anche in questo caso deve trattarsi di una sfera di competenza delimitata dalla Costituzione;in più,l'art.in esame(a differenza del 37 della stessa legge) dispone che,perché sorga conflitto,si deve avere un' "INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA".Inoltre,sempre a differenza dell'art.37,l'art.39 prescrive che il conflitto può sorgere in seguito all'emanazione di un atto che deve essere specificato nel ricorso. Nella prassi invece la Corte costituzionale ha slargato le ipotesi di conflitto all'emanazione di qualsiasi atto. C'è da dire però che il giudizio della Corte verte non tanto sull'atto quanto,piuttosto,sulla controversia in ordine allo svolgimento di funzioni di livello costituzionale,di cui l'atto è mero,se pur necessario,indizio. Inoltre,il conflitto è stato giudicato ammissibile anche quando,pur non essendo stata contestata l'appartenenza del potere,il "cattivo uso"che se ne è fatto configuri una menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente,o

anche quando ancora attraverso un "comportamento significante"si è avuto l'indebito rifiuto dell'emanazione di un atto. Quel che importa ad ogni modo è che,perché possa sorgere conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni,la lesione della sfera di competenza non deve essere operata da una legge o da un atto avente forza di legge,perché in quel caso rientreremmo nell'ipotesi di controversie di legittimità costituzionale,risolte dalla Corte in via principale. Ne consegue che l'atto che dà luogo a conflitto può essere un qualsiasi atto che non sia una legge formale(dello Stato o della Regione)o un atto avente forza di legge,e potrà essere quindi un atto amministrativo,un regolamento o un atto di un Consiglio regionale che non sia formalmente legislativo(per es.un regolamento interno al Consiglio)o anche un atto giurisdizionale dello Stato(e non della Regione,perché questo ente non ha avuto attribuita la funzione giurisdizionale). Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta stessa. Nella sentenza,la Corte dichiara a quale dei due enti spetti la competenza e,se è stato emanato un atto viziato da incompetenza,lo annulla. Le stesse osservazioni valgono per i conflitti di attribuzione fra Regione e Regione(in più,nella regione Trentino-Alto Adige,anche le province sono legittimate a ricorrere alla Corte contro un atto dello Stato lesivo della loro competenza).

Sezione III – IL GIUDIZIO SULLE ACCUSE

17. I REATI PRESIDENZIALI (RINVIO)- 18. Il procedimento- La Corte è chiamata a decidere in merito ai reati presidenziali(art.90 Cost.).In particolare,l'art.3 della legge cost.n.1 del 1989 dispone che la deliberazione sulla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere. La deliberazione è adottata a scrutinio segreto. A norma dell'art.13 della legge cost.11 marzo 1953 n.1.il Parlamento in seduta comune,nel porre in stato d'accusa il Presidente,elegge anche fra i suoi componenti uno o più commissari per sostenere l'accusa,i quali esercitano dinanzi alla Corte le funzioni di pubblico ministero. Nei giudizi di accusa contro il Presidente intervengono oltre ai giudici ordinari della Corte 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini eleggibili a senatore,che il Parlamento compila in seduta comune ogni 9 anni mediante elezioni(vedi dietro).Il Collegio giudicante deve in ogni caso essere costituito da almeno 21 giudici,dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza. Il Presidente della Corte provvede,direttamente o delegando giudici della Corte,al compimento degli atti di indagine necessari,ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato nonché la successiva relazione. Il Presidente accoglie poi tutti i voti e infine vota per ultimo:in caso di parità,prevale l'opinione più favorevole all'accusato. Ulteriori norme sullo stato d'accusa sono contenute nel regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa:tale regolamento dispone fra l'altro che il Comitato parlamentare per i provvedimenti d'accusa può dichiarare la propria incompetenza

This document is available free of charge on StuDocu.com

perché il reato è diverso da quelli previsti dall'art.90 Cost.o deliberare l'archiviazione degli atti del procedimento. La sentenza è irrevocabile,ma può essere sottoposta a revisione se dopo la condanna sopravvengono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che rendono evidente che il fatto non sia sussistente o che il condannato non lo abbia commesso(ai sensi della legge n.20 del 1962).

Sezione IV CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

19.LA FORZA POLITICA DELLA CORTE COSTITUZIONALE: Nel corso della sua esistenza,in relazione ai poteri attribuitele,la Corte ha scolto una vera e propria "forza politica". La Corte infatti è il supremo giudice:

- della legittimità costituzionale delle leggi statali,regionali e provinciali,oltre che degli atti equiparati alla legge;
- dei conflitti fra poteri dello Stato in ordine alla delimitazione costituzionale delle loro attribuzioni;
- dei conflitti fra Stato e Regioni riguardanti anch'essi la delimitazione costituzionale delle rispettive attribuzioni;
- dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica;
- dell'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo.

Spetta pertanto alla Corte l'interpretazione ultima della Costituzione,quella decisiva,in seguito alla quale una legge posta in essere dai rappresentanti del popolo può essere annullata,un'attribuzione può essere conferita o sottratta ad un potere dello Stato o allo Stato medesimo o ancora ad una Regione,il Presidente della Repubblica può essere condannato e destituito dall'ufficio,un referendum abrogativo può essere ammesso o no. Una somma di funzioni quindi notevolissima,che attribuisce alla Corte una "forza politica"derivantele dal ruolo che essa svolge come organo posto a tutela della Costituzione sia in senso attivo(della corretta attuazione)sia in senso negativo(della mancata attuazione).Tali funzioni possono essere ricondotte unicamente(come ha precisato la stessa Corte con la sent.n.15 del 1969)ad un principio fondamentale unitario,e cioè garantire e rendere concretamente operante nell'ordinamento il PRINCIPIO DI LEGALITA'. Il ruolo della Corte e la sua forza politica sono tuttavia stati accentuati molto spesso in seguito all'inerzia e alle inadempienza costituzionali delle maggioranze che hanno assunto il governo:è spettato infatti alla Corte sostituirsi alle assemblee legislative e al Governo a smantellare almeno in parte, "a colpi di sentenza",il sistema legislativo anteriore alla Costituzione,e con questa in netto ed inequivocabile contrasto. Altre volte poi la Corte è intervenuta per dichiarare l'illegittimità di leggi successive alla Costituzione,lesive di valori fondamentali in essa contenuti,anche in questo caso implicitamente dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'indirizzo politico del quale esse erano espressione. Un campo molto delicato d'intervento è stato infine quello dei giudizi sulle leggi regionali e sui conflitti d'attribuzione fra Stato e Regioni,per l'incidenza che essi possono avere nel delimitare l'ambito delle

autonomie regionali;in questi ultimi anni poi il ruolo di Corte quale arbitro imparziale dei conflitti fra Stato e Regione è venuto via via accrescendosi(in specie per l'aumento dei ricorsi da parte del potere regionale).Possiamo dunque asserire che oggi la Costituzione della Repubblica italiana(laddove si intenda la costituzione effettivamente vigente)risulta essere in buona parte quella che la Corte ha statuto che sia,per cui molti suoi articoli vanno ormai letti,interpretati e attuati alla luce delle sentenze della Corte stessa. Sembra infine che la Corte sia ormai inserita nel circuito d'indirizzo politico,variamente condizionandolo nelle sue fasi(ad esempio con le sentenze additive,con le quali finisce addirittura col sovrapporsi alle Camere vincolando l'esercizio della funzione legislativa).L'incidenza delle sue decisioni,la rilevanza che assumono le sue sentenze,la diffusa(e per certi versi inevitabile)tendenza a sostituirsi al legislatore inadempiente hanno fatto si che la Corte sia venuta ad assumere progressivamente un ruolo che almeno secondo il disegno costituzionale originario non era chiamata a svolgere,per cui ad oggi alla Corte risultano affidati poteri sostanziali,pur nel quadro complessivo delle sue funzioni,diretti ad assicurare il pieno rispetto e la corretta osservanza della Costituzione.

Sezione V- L'ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA

20. L'alta Corte per la Regione siciliana e lo stato attuale del sistema di giustizia Costituzionale in Sicilia- è prevista nell'art. 24 dello Statuto della Sicilia, che dispone che sia composta da 6 membri effettivi e 2 supplenti, oltre il Presidente e il procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione tra persone competenti in materie giuridiche. L'alta Corte giudica sulla costituzionalità delle leggi dell'Assemblea regionale, delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato, rispetto allo Statuto. Ormai da oltre 50 anni, non funziona più. Inoltre contrasta con l'unicità della giurisdizione costituzionale e l'unitarietà dello Stato. La sua esistenza è incompatibile con quella della Corte cost. Ormai l'alta Corte ha funzioni residuali e in particolare, relativamente al sistema di impugnazione delle leggi regionali.

This document is available free of charge on StuDocu.com

PARTE TERZA- LE LIBERTA' E LE AUTONOMIE

Capitolo primo- Le libertà

Il concetto di libertà appare come uno dei più lungamente controversi nel corso della storia,e nella sua pratica attuazione,uno dei più condizionati. Basti pensare ai diversi modi in cui gli uomini sono stati(e si sono sentiti)liberi nei vari periodi storici e sotto i più vari regimi politici:alle libertà degli antichi(e in specie nella polis greca o nell'età romana preclassica) che consistevano nell'esercitare collettivamente ma direttamente la sovranità,mentre l'individuo era totalmente assoggettato alla comunità che ne controllava e guidava tutte le attività private,si contrappongo le libertà modernamente intese, che vedono invece riconosciuta e garantita una sfera di autonomia dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri. Strettamente connesso a quello di libertà è infatti il concetto di **autonomia**:entrambi i concetti infatti esprimono l'idea della capacità,al riparo da interferenze esterne,di esprimere e selezionare i propri interessi e predisporre i modi idonei a comporre e soddisfare gli stessi interessi selezionati. Ma libertà e autonomia,proprio perché essenzialmente concetti di **relazione**(si è liberi/autonomi da o rispetto a qualcuno/qualcosa),fanno si che la misura e i limiti entro i quali si è liberi ed autonomi debbano essere predeterminati dall'ordinamento giuridico,cui spetta di dettare le regole organizzative e di condotta e di comporre gli interessi configgenti. La libertà e l'autonomia di un soggetto non esistono dunque in assoluto,ma anzi trovano limite e misura da un lato nella libertà e nell'autonomia degli altri soggetti,e dall'altro nell'interesse generale,secondo quanto viene disposto dal diritto. E' quindi questo l'aspetto *formale* dei due concetti,quello cioè che vede le sfere di libertà e di autonomia dei singoli e dei gruppi sociali delimitate e garantite da norme giuridiche. Ad esso si contrappone l'aspetto *sostanziale*, secondo il quale libertà e autonomia sono effettivamente vigenti,nella misura ed entro i limiti in cui le condizioni economiche e sociali dei soggetti alle quali vengono attribuite le rendono,di fatto,operanti. A livello storico,il riconoscimento delle libertà e delle autonomie è stato consacrato a partire dallo Stato di diritto ed in contrapposizione allo Stato assoluto,nelle costituzioni e nei documenti costituzionali di fine Settecento- inizi Ottocento. Oltretutto,la misura e i limiti entro i quali avviene tale riconoscimento ad opera delle forze politico-sociali dominanti è sempre espressione diretta del regime politico dello Stato e lo caratterizza. Fondamentale è poi il rapporto fra libertà/autonomia e l'eguaglianza sostanziale,dal momento che non è mai sufficiente riconoscere e garantire le prime se,al tempo stesso,non si rimuovono gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono o ne limitano l'effettivo esercizio.

Sezione I- IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

1. L'eguaglianza formale. -Il principio di eguaglianza formale è espresso dall'art.3 I comma Cost. "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge,senza distinzione di sesso,di razza,di lingua,di religione,di opinioni politiche,di condizioni personali e sociali". Va anzitutto precisato che,sebbene oggetto lessicale della disposizione siano "tutti i cittadini",è opinione ormai comune che vero e proprio destinatario siano anche,per alcune situazioni,gli stranieri e gli apolidi. La "pari dignità sociale"consacrata nella norma sta inoltre a significare che non esistono più distinzioni in base al titolo,al grado o all'appartenenza ad una determinata classe sociale(per cui di conseguenza la XIV disposizione transitoria e finale dispone che "I titoli nobiliari non sono riconosciuti"),ma che l'unico titolo di dignità,in una Repubblica"fondata sul lavoro"(art.1),è ormai da rinvenire unicamente nello svolgimento di attività o funzioni che concorrano al progresso materiale e spirituale/intellettuale della società(art.4 Cost.) Il riconoscimento del principio di eguaglianza davanti alla legge(contenuto già nelle costituzioni liberali dell'800,e in specie nell'art.24 dello Statuto albertino, che recita "Tutti i regnicoli,qualunque sia il loro titolo o grado sono eguali dinanzi alla legge"),è stato arricchito e rafforzato ad oggi dalla previsione costituzionale delle situazioni di fatto alle quali deve essere applicato. Infatti,sia per la trascorsa esperienza autoritaria(basti pensare alla discriminazioni avvenute in regime fasciste,sulla base dell'appartenenza alla razza ebraica o ad una minoranza linguistica,o ancora per razza ebraica o per le opinioni politiche,la fede religiosa ecc.),sia per l'evoluzione della coscienza sociale(che vede ormai le donne poste sullo stesso piano degli uomini),l'Assemblea Costituente ritenne che fosse necessario prestabilire dei limiti ben precisi all'attività dei pubblici poteri,al fine di evitare incertezze interpretative che sarebbero sempre state possibile qualora il principio fosse stato enunciato in termini generali,lasciando così un ampio margine di discrezionalità al legislatore. Fra le leggi che hanno dato attuazione al principio di eguaglianza formale,possono citarsi: la legge n.205 del 1993,che punisce penalmente fra l'altro,chi incita a commettere discriminazioni per motivi razziali,etnici,nazionali o religiosi,e la legge n.903 del 1977 sulla parità uomo/donna in materia di lavoro. E' stata inoltre data attuazione(con decreto legislativo)alla direttiva europea per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Si distingue in particolare tra: DISCRIMINAZIONE DIRETTA,quando,per la razza o l'origine etnica,una persona è trattata o meno favorevolmente di quanto sia,sia stata o sarebbe stata trattata in una situazione analoga; DISCRIMINAZIONE INDIRETTA,quando una disposizione,un criterio,una prassi,un atto,un patto o un comportamento apparentemente neutri possano mettere le persone di una determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. La norma contenuta nell'art.3 comma I Cost. vale quindi a stabilire che il legislatore non può operare discriminazioni fra i cittadini,e più generalmente fra i soggetti dell'ordinamento,a seconda del loro sesso,della loro razza,lingua,religione,delle loro opinioni politiche e delle loro condizioni personali o sociali. Ciò non significa però assoluta parità di trattamento,sia perché possono esistere circostanze obiettive che la impediscono,sia perché la stessa Costituzione ha apportato delle deroghe al principio,ritenendo che esso dovesse cedere di fronte ad un altro valore riconosciuto prevalente. Tali deroghe sono contenute: nell'art.29,per il quale l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi può essere limitata dalla legge a

This document is available free of charge on StuDocu.com

garanzia dell'unità familiare; negli art.68 e 122,che sottraggono i parlamentari ed i consiglieri regionali alla responsabilità civile,penale ed amministrativa per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; ancora nell'art.68,che subordina all'autorizzazione della Camera di appartenenza le limitazioni della libertà personale e domiciliare dei parlamentari; nell'art.90,che sottrae il Presidente della Repubblica che abbia compiuto determinati reati alla giurisdizione ordinaria; nell'art.98,che prevede la possibilità di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune categorie di cittadini. Il principio inoltre non può significare assoluta parità di trattamento anche perché,se così fosse,contraddirebbe se stesso:è evidente infatti che intanto il principio può dirsi integralmente applicato in quanto la legge tratti in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse. Tuttavia,lasciare all'assoluta discrezionalità del legislatore la valutazione della diversità delle situazioni avrebbe potuto trasformare tale discrezionalità in arbitrio. Per cui la Corte costituzionale ha successivamente precisato che l'art.3 mira a impedire che vengano poste a danno dei cittadini discriminazioni arbitrarie,ma al tempo stesso consente al legislatore di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale. Tale principio,sempre secondo la Corte,rientra nel piano di un'esigenza di logica legislativa:un ordinamento che non distingua situazioni da situazioni e le consideri tutte allo stesso modo non è di fatti nemmeno pensabile,in quanto finirebbe col non disporre alcuna regola. Ad ogni modo,secondo la sent. n. 200 del 1972,la discrezionalità legislativa trova sempre limite nella RAGIONEVOLEZZA delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento fra i cittadini. Nella specie,l'uso del canone della ragionevolezza da parte della Corte costituzionali mira a valutare le discipline normative in modo che siano soddisfatte sia la salvaguardia della discrezionalità del legislatore,sia la tutela del principio di pari trattamento in situazioni uguali,sia,infine,il bilanciamento di valori costituzionali diversi e contrastanti,allo scopo di individuare un equilibrio valido per la fattispecie normativa considerata. Quanto poi ai destinatari dell'art.3 comma I,essa si rivolge non soltanto al legislatore,ma anche agli amministratori e ai giudici che sono chiamati ad osservarla nell'esercizio delle loro funzioni. La Costituzione infine contiene numerose applicazioni del principio di eguaglianza formale,quali l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge(art.8),l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,con i soli limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare(art.29),l'eguaglianza dei diritti e,a parità di lavoro,di retribuzione fra lavoratori e lavoratrici e,sempre a parità di lavoro,di retribuzione dei minori(art.37),l'eguaglianza dei cittadini dell'uno o dell'altro sesso nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive(art.51).

2. L'eguaglianza sostanziale- Il passaggio dallo Stato di diritto(che vede affermato il principio dell'uguale soggezione alla legge di tutti i cittadini)allo Stato sociale è segnato nella nostra Costituzione,dal II comma all'art.3,che enuncia uno dei principi fondamentali in essa contenuti. Il principio di uguaglianza formale rischierebbe infatti di rimanere una pura e mera affermazione teorica se non fosse integrato da quello di EGUAGLIANZA SOSTANZIALE. Al II comma,l'art.3 Cost. dispone che "E'

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,che,limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,economica e sociale del Paese". Il Costituente ha cioè riconosciuto che non è sufficiente stabilire il principio dell'eguaglianza giuridica dei cittadini(art.3 comma I),quando esistono ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la loro libertà ed eguaglianza,impedendo che siano effettive;ed ha pertanto coerentemente assegnato alla Repubblica(vale a dire al legislatore ed a tutti i pubblici poteri)il compito di rimuovere questi ostacoli, affinchè tutti i cittadini(e in particolare i lavoratori che si trovino in situazione di inferiorità a causa delle loro condizioni economiche e sociali)siano posti sullo stesso punto di partenza,abbiano le medesime opportunità,possano godere tutti alla pari dei medesimi diritti loro riconosciuti formalmente dalla Costituzione. Non avrebbe infatti significato concreto riconoscere il diritto di lavoro(art.4)quando,di fatto,esistono larghe sacche di disoccupazione,oppure il diritto alla salute(art.32)quando l'organizzazione sanitaria del Paese,le condizioni ambientali e l'assetto del territorio non sono in grado di assicurarlo pienamente;il diritto allo studio(art.34)quando,di fatto,può accadere che le condizioni sociali,economiche ed ambientali non consentano ai capaci e ai meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi. Tale principio mira pertanto a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica,economica e sociale del Paese,in un regime di effettiva libertà ed eguaglianza,di modo che le discriminazioni fra i cittadini si operino non a causa delle loro condizioni economiche e sociali,bensì soltanto per le loro capacità naturali. Il principio di eguaglianza sostanziale si indirizza quindi al legislatore ma anche agli altri pubblici poteri,non soltanto statali,ma anche degli enti(soprattutto per le competenze ad essi attribuite,per es.le Regioni)diversi dallo Stato,e li impegna a porre in essere tutte le misure idonee a conseguire i fini da esso indicati:infatti,se la Costituzione si fosse limitata a statuire il principio dell'eguaglianza formale(proprio,come si è detto,della società liberale ottocentesca)avremmo avuto un diverso tipo di Stato,fondato sì sul diritto,ma non giuridicamente impegnato ad eliminare,mediante la sua azione,le condizioni di privilegio e ad assicurare la piena e libera espressione della persona umana. Il principio di eguaglianza sostanziale viene ad essere precisato inoltre da tutta una serie di norme che valgono sia a meglio specificarlo in relazione a determinate situazioni,sia a imporre a carico dello Stato degli obblighi precisi a favore di categorie di cittadini che si trovino in particolari condizioni di inferiorità economica e sociale: art.4:riconoscimento del diritto al lavoro e promozione delle condizioni che rendano effettivo questo diritto; art.24:riconoscimento del diritto alla difesa personale e assicurazione,per i meno abbienti,dei mezzi per difendersi davanti a ogni giurisdizione; art.34:"I più capaci e meritevoli,anche se privi di mezzi,hanno diritto a raggiungere i gradi più elevati di studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,assegni alle famiglie ed altre provvidenze"; art.36:diritto alla retribuzione,proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente a garantire per il lavoratore e per la sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; art.38:"Ogni cittadino inabile al

This document is available free of charge on StuDocu.com

lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

SEZIONE II- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

3. I diritti pubblici soggettivi e le libertà- Come già detto,il concetto di libertà presuppone una relazione,nel senso che si è liberi nei confronti di(o rispetto a)un'entità distinta. Così inteso,il concetto non assume però valore giuridico,ma rimane confinato sul piano della morale,delle aspirazioni,insomma su un piano che non è ancora quello del diritto. Ciò spiega perché le lotte che i popoli hanno condotto per la libertà siano dirette ad ottenere il riconoscimento formale,vale a dire consacrato in una norma giuridica,di alcune pretese nei confronti dell'apparato autoritario dello Stato e più in generale dei pubblici poteri. Queste pretese hanno ad oggetto un comportamento omissivo da parte dei pubblici poteri(le autorità,i governanti)consistente nel fatto che essi non devono interferire nella sfera privata dei singoli. Il riconoscimento giuridico delle libertà segna il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato di diritto e la conquista della qualità di cittadino da parte di chi era prima considerato soltanto suddito. Senonchè il mero riconoscimento di alcune libertà non è certamente sufficiente tutte le volte che ad esso non si accompagni tutta una serie di garanzie dirette a stabilire dei limiti invalicabili all'attività dello Stato. Una prima forma di garanzia,prevista già nelle Carte ottocentesche,è data dalla riserva di legge,che doveva assicurare i cittadini contro gli arbitri del potere esecutivo. Successivamente però ci si accorse che tale garanzia era solo apparente,perché lasciava il legislatore ordinario arbitro,nella sua piena discrezionalità,di determinare entro quali limiti le libertà erano riconosciute e potevano essere esercitate. Di modo che le libertà finivano con l'essere delle semplici enunciazioni e potevano essere compresse a discrezione del legislatore,cioè delle forze politico-sociali dominanti. Così,nelle costituzioni contemporanee,le norme nelle quali le libertà sono enunciate assumono un contenuto non più generico ma dettano una disciplina puntuale delle materie riservate;e inoltre la riserva di legge viene resa più efficace col conferire carattere rigido alle costituzioni e con la previsione di un sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi. A questo punto,le LIBERTA' DALLO STATO(o LIBERTA' NEGATIVE)divengono l'oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo; cosicchè le libertà costituzionalmente garantite vengono elevate al rango di "DIRITTI INVIOLABILI" o "DIRITTI ASSOLUTI". Le libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione consistono dunque,originariamente,in una pretesa ad un comportamento omissivo dello Stato,e costituiscono pertanto l'oggetto di una situazione giuridica attiva e,più precisamente,di un diritto soggettivo,vale a dire vanno configurate come un interesse protetto in via diretta ed immediata dall'ordinamento giuridico. A questa pretesa(garantita da norme costituzionali),si accompagna poi quella ad un intervento attivo dei pubblici poteri tendente a dare attuazione al principio costituzionale d'eguaglianza sostanziale e,per questa via,ad assicurare il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini al governo dello Stato(LIBERTA' NELLO STATO).Alcuni dei diritti soggettivi pubblici

costituzionalmente garantiti non hanno,tuttavia,ad oggetto una libertà in senso stretto,e in particolare: il DIRITTO ALLA DIFESA,che la Costituzione(art.24 comma II)definisce "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" e che è strettamente connesso al diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa consiste nella possibilità di resistere in un giudizio(civile,penale o amministrativo)sia personalmente(nei rari casi in cui ciò è ammesso)sia per mezzo di un difensore(avvocato o procuratore). La Costituzione (art.24 comma II)si preoccupa anche di rendere effettivo tale diritto disponendo che siano assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giudizio. Inoltre,la legge costituzionale n.2 del 1999 ha introdotto nell'art.111 Cost.una serie di principi molto dettagliati per garantire un "giusto processo"e rendere così effettivo il diritto alla difesa. In particolare è statuito che la persona accusata di reato sia nel più breve tempo possibile informata della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico,disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa,abbia la facoltà,davanti al giudice,di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. La nuova norma costituzionale stabilisce inoltre che deve essere garantito nella sua pienezza il rispetto del principio del contraddittorio nel processo(si può fare a meno del contraddittorio unicamente o per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita).(Il carattere dettagliato di questa disposizione è stato inoltre criticato,ritenendosi i principi enunciati più adatti ad un codice che ad una Costituzione,ed è forse vero); il DIRITTO DI VOTO(art.48),vale a dire il diritto ad essere iscritto nelle liste elettorali ed a partecipare alle elezioni degli organi rappresentativi dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed a votare nei vari referendum previsti nella Costituzione; il DIRITTO DI PETIZIONE(art.50):tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per richiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Si tratta di uno degli istituti di democrazia diretta,la cui incidenza politica è peraltro quasi nulla,anche se le c.d. "PETIZIONI COLLETTIVE"(presentate cioè da gruppi di cittadini o da associazioni)potrebbero svolgere un efficace ruolo di sollecitazione nei confronti dell'attività legislativa e di indirizzo politico delle Camere. I regolamenti delle Camere si limitano a disporre,a loro volta:quello della Camera che le petizioni siano esaminate dalle commissioni competenti e che l'esame in commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione o una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge; e quello del Senato che la petizione debba essere trasmessa alla commissione competente per materia e che le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a commissioni sono inviate alle commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge o,qualora non venga adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'art.80,vengono trasmesse al Governo con l'invito a provvedere. -il DIRITTO ALL'ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI E ALLE CARICHE ELETTIVE(art.51),che si specifica nel diritto a porre la propria candidatura nelle elezioni politiche ed amministrative ed a partecipare ai pubblici concorsi;la legge cost.n.1 del 2003 ha inserito nell'art.51 Cost.il principio delle pari

This document is available free of charge on StuDocu.com

opportunità tra donne e uomini nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive. Infine, il diritto per chi svolge funzioni pubbliche elettive, a disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro (comma III art. 51).

4. I doveri costituzionali- La Costituzione,nel disciplinare i rapporti fra i singoli ed i pubblici poteri,prevede anche una serie di prestazioni puntuali e di comportamenti qualificanti il cui adempimento,per la sua necessarietà e rilevanza sociale,viene considerato un DOVERE. In particolare,la Costituzione impone ai cittadini i seguenti doveri: DOVERE DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA:A norma dell'art.54 "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica",dovere che si sostanzia nella fedeltà ai principi dello Stato repubblicano,così come sono stati costituzionalizzati. DOVERE DI DIFENDERE LA PATRIA:La difesa della Patria è "sacro dovere" del cittadino(art.52):a tale dovere si adempie non solo prestando servizio militare,ma anche in altre forme più dirette quale,ad esempio,la resistenza individuale o collettiva contro forze militari straniere che abbiano occupato il territorio italiano o parte di esso(l'adempimento del servizio militare non deve però pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici). OBIEZIONE DI COSCIENZA: I cittadini che per obbedire alla loro coscienza non accettano l'arruolamento nelle forze armate e nei corpi armati dello Stato hanno il diritto di adempiere gli obblighi di leva prestando un servizio civile,diverso per natura e autonomo dal servizio militare,ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria.Il servizio civile ha la stessa durata del servizio militare ed è a quest'ultimo parificato ad ogni effetto previdenziale,assicurativo e amministrativo. Il servizio militare obbligatorio di leva è stato via via sostituito con il servizio volontario. L'obbligatorietà del servizio militare rimane confinata a due sole ipotesi: 1)qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art.78 Cost.; 2)qualora una grave crisi internazionale,nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o come membro di un'organizzazione internazionale,giustifichi un aumento della consistenza numerica delle forze armate. Il servizio civile ha finalità direttamente collegate ad altrettanti valori costituzionalmente tutelati,e precisamente:concorrere in alternativa al servizio militare obbligatorio alla difesa della Patria con mezzi e attività non militari;favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione,con particolare riguardo al settore ambientale, storico-artistico,culturale e della protezione civile. Inoltre,il servizio civile è volontario dal momento della sospensione del servizio militare obbligatorio di leva. DOVERE DEL LAVORO(art.4 comma II):La rilevanza costituzionale del lavoro si manifesta non soltanto nel diritto di ogni cittadino ad avere un lavoro ma anche nel dovere di "svolgere,secondo le proprie possibilità e la propria scelta,un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. In tal senso,tale dovere può farsi rientrare in quei "doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale"il cui adempimento è previsto dall'art.2 Cost. DOVERE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI: Tutti hanno il dovere di concorrere alle spese pubbliche(mediante il pagamento dei tributi)in ragione della loro capacità contributiva(art.53);le prestazioni patrimoniali non

possono essere imposte se non in base alla legge(art.23 Cost.)e il sistema tributario è informato a CRITERI DI PROGRESSIVITA' (e non di PROPORZIONALITA'):ciò significa che,in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale e del principio di solidarietà sociale,le aliquote delle imposte devono essere tanto più alte quanto più alto è il reddito e di conseguenza,tanto più alta è la capacità contributiva del soggetto. DOVERE DI VOTO,definito come dovere "civico"dall'art.48 comma II;l'adempimento di tale dovere è peraltro affidato più alla coscienza,appunto civica,degli elettori che all'obbligatorietà del relativo comportamento,non essendo assistito da efficaci sanzioni giuridiche. In questo elenco di doveri,particolare attenzione va infine rivolta ai DOVERI SOCIALI che trovano fondamento nell'art.2 Cost.,a norma del quale la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale":tali doveri sono poi specificati in altre disposizioni costituzionali e,nello specifico,nell'art.4 comma II,nel 53 e nel 54.

SEZIONE III- LE LIBERTA' NEGATIVE

Le libertà negative rientrano fra quei diritti inviolabili che l'art.2 Cost. riconosce e garantisce all'uomo "sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".Va sottolineato che la Costituzione ha preso atto che i diritti inviolabili dell'uomo possono avere ad oggetto non soltanto la libertà dallo stato ma anche la pretesa ad un comportamento omissivo da parte di formazioni sociali diverse dallo Stato,nelle quali il singolo svolge la sua personalità. Si tratta di un riconoscimento che acquista un particolare valore laddove si riflette che,nel mondo contemporaneo,gli attentati alle libertà individuali possono essere posti in essere anche dai gruppi sociali in cui il singolo si trova ad operare. Le garanzie che la Costituzione appresta per le libertà negative consistono nel fatto che le loro limitazioni da parte delle pubbliche autorità possono essere adottate non a discrezione o ad arbitrio di chi detiene il potere politico(e in particolare degli organi del potere esecutivo)bensì nei soli casi e modi previsti dalla legge(cioè da un provvedimento generale e astratto)e/o in seguito ad un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria(cioè di un'autorità che la stessa Costituzione ha posto in una posizione di autonomia ed indipendenza da ogni altra). Inoltre la Costituzione indica espressamente i motivi(di sanità,pubblica sicurezza,incolumità pubblica ecc.)per i quali l'esercizio di alcuni diritti di ,libertà può essere limitato. Va precisato inoltre che le limitazioni alle libertà costituzionalmente garantite intanto sono ammesse nel nostro ordinamento in quanto siano dirette ad assicurare il rispetto reciproco delle varie sfere di autonomia privata e la pacifica convivenza dei consociati. L'inviolabilità dei diritti di libertà,pertanto,costituisce un limite sia alla revisione costituzionale(nel senso che non sarà possibile prevedere la soppressione o la riduzione delle garanzie che li assistono)sia al legislatore ordinario che dovrà assicurare la loro massima espansione,compatibilmente con la tutela dell'interesse generale e dei singoli soggetti dell'ordinamento. Le libertà negative riconosciute dalla nostra Costituzione sono quindi: libertà personale(art.13); libertà di domicilio(art.14); libertà e segretezza della corrispondenza(art.15); libertà di circolazione e di soggiorno(art.16);libertà di riunione(art.17); libertà di associazione(art.18); libertà

This document is available free of charge on StuDocu.com

religiosa(art.19); libertà di manifestazione del pensiero(art.21); libertà dell'arte e della scienza e libertà di insegnamento(art.33). Di queste,alcune(libertà personale e di domicilio,libertà e segretezza della corrispondenza,libertà di religione,libertà di manifestazione del pensiero)sono riconosciute sia ai cittadini sia ai non cittadini;altre(liberta di circolazione e di soggiorno,di riunione e associazione)solo ai cittadini.

5. Libertà personale- Consiste nella libertà della persona fisica da ogni coercizione che ne impedisca o limiti(anche per breve tempo)i movimenti e le azioni. Nella libertà personale può farsi rientrare la libertà morale,vale a dire la pretesa dei singoli all'autodeterminazione e all'integrità della propria coscienza,che non deve essere coartata(come spesso è avvenuto nei regimi totalitari)direttamente o indirettamente,con minacce o intimidazioni,al fine di annientare la volontà e renderla acquiescente supinamente ai comandi dei governanti. La libertà personale non può essere limitata se non nei soli casi e modi previsti dalla legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Modi di limitazione della libertà personale sono,fra gli altri: la DETENZIONE, l'ISPEZIONE, la PERQUISIZIONE, la CUSTODIA CAUTELARE, l'ARRESTO DI POLIZIA, il FERMO DI INDIZIATI DI DELITTO(che viene disposto dal pubblico ministero)ecc. Il codice di procedura penale del 1988 ha peraltro maggiormente garantito la libertà personale dell'imputato adottando ad esempio alcuni istituti del sistema accusatorio,per cui il ruolo del p.m. risulta adesso nettamente distinto da quello del giudice,unico organo competente a pronunciarsi non soltanto sulla colpevolezza e sull'innocenza dell'imputato,senza partecipare alla raccolta delle prove,ma anche sulle eventuali misure cautelari coercitive della libertà personale. Pertanto,il p.m. non può emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale(che sono di competenza esclusiva del giudice delle indagini preliminari,c.d."GIP");inoltre non è più previsto il MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO,di modo che,anche nel caso di commissione di reati di particolare gravità,il giudice potrà,in relazione alle circostanze del caso,non disporre la cattura. In casi eccezionali di NECESSITA' e URGENZA(in specie nell'ipotesi di FLAGRANZA DI REATO,nei quali l'imputato è direttamente colto sul fatto dalle autorità di polizia)tassativamente indicati dalla legge,gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono adottare PROVVEDIMENTI PROVVISORI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE (c.d."FERMO DI POLIZIA");tali provvedimenti devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e si intendono revocati e restano pertanto privi di ogni effetto qualora il giudice non ne decida e stabilisca espressamente la convalida nelle 48 ore successive al momento in cui l'arrestato(o il fermato)è posto a sua disposizione. Se queste sono le garanzie poste a presidio della libertà personale,occorre tuttavia osservare che non sempre il legislatore ordinario vi si è attenuto,ponendo in essere(soprattutto in situazioni eccezionali dell'ordine pubblico)una serie di leggi che hanno di fatto limitato la libertà prevista dall'art.13 Cost.,oltre che altri diritti fondamentali(come ad es. quello alla segretezza della corrispondenza),la cui legittimità costituzionale appare,per alcuni versi,discutibile. Tali leggi hanno suscitato severe critiche in dottrina,che

soltanto in parte possono oggi essere attenuate in seguito all'abrogazione o alla mancata proroga della vigenza di alcune disposizioni particolarmente lesive dei precetti costituzionali. ULTERIORI GARANZIE DELLA LIBERTA' PERSONALE: E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà (art.13 comma IV).La Corte costituzionale(sent.n.526 del 2000),pur non ritenendo applicabili ai soggetti detenuti nelle carceri il secondo e terzo comma dell'art.13 Cost.,riservato ai soggetti in stato di libertà,ha tuttavia indicato limiti rigorosi delle perquisizioni personali sui detenuti stessi,in ossequio al quarto comma dello stesso articolo. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che,al fine di rendere possibile il controllo del rispetto dei diritti dei detenuti,è sempre necessaria una forma di documentazione dell'avvenuta perquisizione,allo scopo di verificare la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento penitenziario; La legge stabilisce i limiti massimi alla carcerazione preventiva(art.13 comma IV);tali limiti sono fissati in relazione alla gravità del reato; Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità,e devono tendere alla rieducazione del condannato; Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge(art.25 comma III); L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto laddove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali e non può in alcun caso essere ammessa per reati politici(art.26); Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.Si può derogare a questa norma solo per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra(art.111 comma VII).

6. La libertà di domicilio e il diritto alla riservatezza- Per "domicilio"nel senso dell'art.14 Cost. si intende non solo il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi(art.43 codice civile)ma anche qualunque altro luogo in cui la persona riesca ad isolarsi dal mondo esterno e a mettersi al riparo da ogni invasione della propria sfera privata(ad es.,oltre l'abitazione abituale,anche una dimora precaria,come una camera d'albergo,un camper,una tenda ecc.).Inoltre per domicilio ai sensi dell'art.14 Cost. deve intendersi anche la sede delle persone giuridiche o degli enti di fatto(quali un'impresa,un partito politico,un'associazione culturale ecc.). La Costituzione ha inteso tutelare pertanto,in modo più ampio,il diritto dell'uomo ad avere una propria sfera privata,spazialmente delimitata,entro la quale possa svolgere,in piena riservatezza e senza interferenze esterne,ogni attività individuale o collettiva. Per quest'aspetto,la libertà di domicilio tutela anche la PRIVACY (e quindi il DIRITTO ALLA RISERVATEZZA). Non sempre però tale diritto è effettivo,nel senso che la natura del domicilio non consente l'isolamento dal mondo esterno(si pensi a questo riguardo ad un'abitazione impropria,che potrebbe non consentire a chi vi abita di porsi al riparo dalle interferenze esterne). Per cui sembra che all'art.14 possa farsi risalire il fondamento di quello che è stato definito il "DIRITTO ALLA CASA",vale a dire il diritto ad avere un'abitazione(non necessariamente di proprietà)idonea ad assicurare il libero svolgimento della vita privata. Il diritto alla riservatezza ha ricevuto tutela più specifica con l'entrata in vigore del CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

This document is available free of charge on StuDocu.com

PERSONALI:suddetto codice prevede obblighi in capo a coloro che,per qualsiasi motivo,procedano al trattamento dei dati personali(obblighi inerenti alla modalità di raccolta e requisiti dei dati personali,all'informazione degli interessati al momento della raccolta ecc.)e diritti a favore degli interessati(consenso al trattamento,accesso ai propri dati,aggiornamento e rettifica dei dati o cancellazione degli stessi quando raccolti illegittimamente,opposizione al trattamento in dati casi). Particolare disciplina hanno ricevuto i c.d."DATI SENSIBILI",cioè i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,le convinzioni religiose o di altro genere,le opinioni politiche,l'adesione a partiti,sindacati,associazioni o organizzazioni a carattere religioso,filosofico,politico o sindacale,nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato,e previa autorizzazione del "GARANTE"(=un'autorità che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Si tratta di un organo collegiale costituito da quattro membri,eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica,tra persone che assicurino indipendenza e siano esperti di riconosciuta competenza in materie di diritto o dell'informatica.I membri di tale collegio eleggono inoltre un Presidente,il cui voto prevale in caso di parità). Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del garante non sono richiesti quando il trattamento dei dati personali è effettuato nell'esercizio della professione giornalistica,ed avvenga nel rispetto dei limiti del DIRITTO DI CRONACA,in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Le garanzie che la Costituzione predispone a tutela della libertà di domicilio sono le stesse della libertà personale:l'autorità di pubblica sicurezza non può infatti entrare nel domicilio per eseguirvi perquisizioni o sequestri se non nei soli casi e modi prestabiliti dalla legge e in seguito ad atto motivato dell'autorità giudiziaria,salvo che ricorrano casi eccezionali di necessità e urgenza,indicati tassativamente dalla legge. In tali casi,l'autorità di pubblica sicurezza può limitare la libertà di domicilio ma deve entro 48 ore dare comunicazione dei provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria,cui spetta di convalidarli entro le successive 48 ore;in mancanza di convalida,i provvedimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. L'art.14 comma III Cost. dispone infine che gli accertamenti e le ispezioni per motivi di SANITA' e di INCOLUMITA' PUBBLICA o a FINI ECONOMICI e FISCALI sono regolati da leggi speciali:in deroga alla disciplina generale,queste leggi possono disporre che accertamenti e ispezioni per i motivi sopra citati avvengano senza intervento dell'autorità giudiziaria. Si tratta di deroghe alla garanzia della libertà domiciliare,giustificate dalla necessità di tutelare il prevalente interesse generale(così è ammesso che,senza atto motivato del giudice,la polizia tributaria e gli ispettori del lavoro possano compiere accertamenti o ispezioni nei luoghi di lavoro). L'accesso deve essere invece sempre autorizzato dalla competente autorità giudiziaria quando deve essere eseguito in locali che siano adibiti anche ad abitazione. In ogni caso,l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere sempre eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

7. La libertà e la segretezza della corrispondenza- Per "corrispondenza"deve intendersi quella epistolare(comprese le stampe inviate),telegrafica e telefonica. Dispone l'art.15 Cost. che deve essere assicurata sia la libertà della corrispondenza sia la segretezza del contenuto della stessa(nel senso che i pubblici poteri non possono,se non con le garanzie previste dallo stesso art.15,impedire che persone distanti comunichino fra loro o limitare la libertà di comunicazione e non possono,allo stesso modo,prendere conoscenza dell'oggetto della comunicazione). Bisogna aggiungere che la segretezza della corrispondenza è tutelata anche nei confronti di privati:il codice penale infatti punisce chiunque fraudolentemente prenda cognizione di una comunicazione o di una conversazione,telegrafiche o telefoniche,o le interrompa o ancora le impedisca o ancora ne riveli,in tutto o in parte,il contenuto,e punisce inoltre l'addetto al servizio delle poste,dei telegrafi o dei telefoni che violi,sottragga o sopprima la corrispondenza,o ne riveli,in tutto o in parte,il contenuto. Oltre che la libertà e la segretezza della corrispondenza,l'art.15 tutela anche la libertà e la segretezza di ogni altra forma di comunicazione(si pensi ad esempio alla posta elettronica oggi e alle altre forme di comunicazione tramite internet). Le limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione possono avvenire mediante il sequestro e l'INTERCETTAZIONE telefonica e sono disposti con atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge. Non è quindi ammesso un intervento della polizia giudiziaria senza il preventivo decreto dell'autorità giudiziaria. Il codice di procedura penale ha disciplinato in modo più rigoroso la facoltà di impedire,interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o altre forme di telecomunicazione,disponendo che ciò possa avvenire solo in caso di indagini relative ad alcuni reati e qualora l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Altri casi di limitazioni della libertà e della segretezza della corrispondenza sono previsti in norme speciali e riguardano I DETENUTI,I FALLITI,LE PERSONE IN STATO DI DEMENZA. Non sembrano invece da ammettere(in quanto incostituzionali)limitazioni da parte di soggetti privati,quali i genitori nei confronti dei figli minorenni,i tutori o i coniugi. Più in generale si ritiene che la libertà e la segretezza della corrispondenza possano essere limitate in caso di guerra,valendo al riguardo l'art.78 Cost. che dispone che le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

8. La libertà di circolazione e soggiorno- Consiste nella libertà di ogni cittadino a fissare il proprio domicilio o la propria residenza o soltanto a dimorare e nella libertà di circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale. A norma dell'art.16 Cost.le limitazioni a tale libertà possono essere disposte soltanto con legge,in via generale e PER MOTIVI DI SANITÀ E DI SICUREZZA(RISERVA DI LEGGE RINFORZATA),come ad es. nel caso di un'epidemia che investa parte del territorio nazionale,caso questo in cui le autorità possono per l'appunto limitare la libertà di circolazione,impedire ad altri di entrarvi e a chi vi si trova di uscirne (c.d."CORDONE SANITARIO"),al fine di evitare il propagarsi dell'epidemia stessa.

This document is available free of charge on StuDocu.com

La legge n.1423 del 27 dicembre 1956(art.2),la cui disciplina è stata successivamente estesa anche alla lotta contro la mafia e l'eversione politica,prevede nella specie che qualora gli appartenenti a determinate categorie di persone(ad es. coloro che debbano ritenersi,sulla base di elementi di fatto: sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose;sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni,la sanità,la sicurezza o la tranquillità pubblica)siano pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza,il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio,impedendo loro di tornare,senza preventiva autorizzazione per un periodo non superiore a tre anni nel Comune dal quale sono state allontanante. Allo stesso modo altre limitazioni della libertà di soggiorno(sempre previste dalla legge n.1423 del 1956)si hanno con l'imposizione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale,nel caso in cui le altre misure di sicurezza non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica,sempre a carico dei soggetti sopra detti,o ancora con il divieto di soggiorno in o più Comuni e in una o più Province,misure disposte dal tribunale del capoluogo di distretto ove la persona dimora. Inoltre il giudice può prescrivere all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza previa autorizzazione del giudice. Nessuna restrizione alla libertà di circolazione e soggiorno può essere determinata da ragioni politiche: la XIII disposizione transitoria e finale stabiliva che "Agli ex re di di Casa Savoia,alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale";con legge cost.n.1 del 2002 è stato stabilito che questa norma ha esaurito i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa. Infine,l'art.120 Cost. dispone che la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone(e delle cose)tra le Regioni. Sempre a norma dell'art.16 comma II,"Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,salvo gli obblighi di legge".La libertà di uscire dal territorio della Repubblica è tuttavia subordinata alla concessione del passaporto o di altro documento equipollente(carta d'identità);alla libertà di uscire dal territorio della Repubblica(c.d."LIBERTA' DI ESPATRIO")va ricollegato inoltre l'ultimo comma dell'art.35 Cost.,nel quale viene riconosciuta la libertà di emigrazione salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale. Con il D.Lgs .30/2007 è stata inoltre data attuazione alla direttiva comunitaria relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,fatte salve le limitazioni che possono essere disposte con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato,per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per altri motivi di ordine pubblico(art.20). L'art.6 del decreto 30/2007 riconosce inoltre ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a 3 mesi,senza alcuna condizione di formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio. L'art.7 stabilisce invece che il cittadino dell'Unione ha diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi solo quando: è

lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un'assistenza sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale e dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato e di un assistenza sanitaria o di altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino del UE che ha diritto a soggiornare. Le persone che non possono ottenere il passaporto sono invece(ex legge n.1185/1967): coloro che,essendo sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria,siano privi del consenso della persona che la esercita; i genitori che,avendo prole minore,non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale; coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o ad una misura di prevenzione.

9. La libertà di riunione- L'art.17 Cost. dispone che "I cittadini hanno diritto a riunirsi pacificamente e senza armi".Dunque i cittadini possono far valere il diritto di riunirsi con l'unico limite che le riunioni avvengano pacificamente e senz'armi. Tale diritto,come si legge nella sent.15 della 1973 della Corte costituzionale,ha portata ed efficacia fondamentali;esso tuttavia,al pari di ogni altro diritto di libertà,implica la posizione di limiti e condizioni che lo disciplinino onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso e pericoloso. Per riunione deve intendersi qualunque raggruppamento di più persone non stabile(altrimenti si tratterebbe di un'ASSOCIAZIONE)e tuttavia NON OCCASIONALE(altrimenti si tratterebbe di un semplice assembramento a carattere momentaneo). Si ha dunque riunione quando più persone convergono in un determinano luogo previo accordo fra di loro o su invito dei promotori,al fine di soddisfare un loro interesse individuale(che può essere di varia natura:politico,culturale,religioso,economico,sportivo ecc.) Nel diritto di riunione va fatto rientrare il diritto di riunirsi in assemblea,espressamente riconosciuto a particolari condizioni ai lavoratori dallo Statuto dei lavoratori ed agli studenti nei locali della scuola. L'importanza che assume la libertà si comprende facilmente laddove si riflette che essa è la condizione per l'esercizio di altre libertà(di manifestazione del pensiero,di insegnamento,di culto).Le riunioni possono avvenire o in luogo privato(un'abitazione,un circolo o comunque un luogo in cui possono accedere soltanto coloro che sono stati invitati espressamente e nominatim)in luogo aperto al pubblico(un cinema,un teatro,uno stadio e un luogo nel quale l'accesso può essere consentito a determinate condizioni o sottoposto a particolari limitazioni da parte dei promotori),o in un luogo pubblico(una piazza,una strada e qualunque altro luogo che,per la sua stessa natura,consenta il libero accesso di tutti). A norma dell'art.17 commi II e III,solo quando le riunioni si svolgono in un luogo pubblico i promotori devono darne preavviso almeno tre giorni prima al questore. Nessun preavviso è richiesto quindi per le riunioni che si svolgono in luogo privato o aperto

This document is available free of charge on StuDocu.com

al pubblico. Il preavviso è stato ritenuto dalla Corte costituzionale(sent.90 del 1970)una condizione per lo svolgimento delle riunioni in luogo pubblico,con la conseguenza che l'autorità di pubblica sicurezza può legittimamente impedire che le riunioni non preavvisate abbiano luogo. Una volta dato il preavviso,la riunione in luogo pubblico può tenersi nel giorno e nell'ora indicati,senza attendere alcuna autorizzazione. La ragione del preavviso va dunque rinvenuta in ciò che,svolgendosi la riunione in luogo pubblico,è necessario tutelare la sicurezza e l'incolumità pubbliche. L'autorità di p.s.potrà pertanto predisporre,a tal fine,un servizio d'ordine ed intervenire,sciogliendo la riunione in corso,quando questa non si svolga più pacificamente e senz'armi,condizioni queste alle quali è subordinato l'esercizio del diritto di riunione. Sempre a norma dell'art.17 l'autorità di p.s. può vietare che una riunione in luogo pubblico si svolga quando esistono fondati e comprovati motivi per ritenere che,qualora si svolgesse,ne verrebbe compromessa la sicurezza o l'incolumità pubblica. In particolare,l'art.18 del testo unico delle leggi di pubblico servizio prevede che il questore possa impedire che la riunione abbia luogo per ragioni di ORDINE PUBBLICO, di MORALITA' o di SANITA' PUBBLICA. Nella libertà di riunione va fatta rientrare poi anche la LIBERTA' DI CORTEO,dato che il corteo può considerarsi una "riunione in movimento":vale dunque per essa la disciplina dettata dall'art.17 Cost. Infine,va detto che per le c.d. "RIUNIONI ELETTORALI"(vale a dire per quelle riunioni che si svolgono in occasione e prima delle elezioni e nelle quali rientrano,innanzitutto,i comizi)l'ultimo comma dell'art.18 T.U.delle leggi di p.s.non impone l'obbligo del preavviso e che chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale,sia pubblica che privata,è punito con la reclusione da uno a tre anni e con una sanzione pecuniaria di entità variabile.

10. La libertà di associazione- A norma dell'art.18 Cost.,i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,senza autorizzazione,per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Le associazioni sono formazioni sociali stabilmente organizzate costituite al fine di soddisfare determinati interessi,non contingenti,comuni a tutti coloro che ne fanno parte. La differenza tra associazione e riunione risiede quindi nel fatto che nell'associazione l'interesse che accomuna gli associati può essere perseguito solo in forma collettiva e mediante un'organizzazione avente il carattere della stabilità,nella riunione invece si ha la contemporanea presenza di più persone nello stesso luogo e ciascun partecipante soddisfa il proprio interesse singolarmente e senza che alcun vincolo lo colleghi agli altri convenuti,per il solo fatto di prendere parte alla riunione. La libertà di associazione si specifica: nella libertà di costituire un'associazione, nella libertà di aderire ad un'associazione, nella libertà di recedere da un'associazione e di non associarsi. In particolare,riguardo a quest'ultima ipotesi,secondo la sent.120 del '73 e 239 dell'84 della Corte costituzionale,l'art.18 garantisce la libertà di associazione sotto l'aspetto positivo e sotto l'aspetto negativo,come libertà di non associarsi. La Corte ha riconosciuto però il potere dello Stato di creare enti a struttura associativa(quali ad es. gli ordini professionali)per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici,da cui deriva l'obbligo della iscrizione a

questi enti che si pone come limite alla libertà di non associarsi. Altra questione è se il singolo possa pretendere di entrare a far parte di un'associazione;a tale riguardo bisogna anzitutto distinguere fra associazioni private e pubbliche:nel primo caso infatti non sembra che tale diritto possa esser fatto valere(prevalendo la considerazione che ciascuna associazione privata può autonomamente predisporre criteri e prevedere requisiti per l'ammissione dei soci),nel secondo invece il diritto di associarsi può essere fatto valere qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge. La Costituzione riconosce la più ampia libertà di associazione come presupposto e fondamento di una società e di una democrazia pluralista. L'inciso "senza autorizzazione"contenuto nel I comma dell'art.18 appare in verità superfluo dopo la solenne affermazione della libertà di associarsi,laddove si osservi che la libertà esclude di per se stessa,concettualmente,ogni forma di autorizzazione:le libertà "autorizzate"rappresenterebbero pertanto una contraddizione in termini. I fini per i quali è dato costituire un'associazione possono essere i più vari:politici,culturali,religiosi,economici,ricreativi,sportivi ecc. LE ASSOCIAZIONI VIETATE: Appare invece evidente che questa libertà non può essere riconosciuta a chi si propone di perseguire,in forma associata,fini che sono vietati ai singoli dalle leggi penali(vale a dire di costituire associazioni che abbiano come fine quello di commettere reati). Le associazioni vietate dalla Costituzione sono quelle segrete e che perseguono,anche indirettamente,scopi politici mediante organizzazioni aventi carattere militare. Sono da considerare segrete,a norma della legge n.17 dell'82,quelle associazioni che "anche all'interno di associazioni palesi,occultando la loro esistenza o tenendo segrete congiuntamente finalità e attività o rendendo sconosciuti,in tutto i in parte e anche reciprocamente,i soci,svolgono attività dirette a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali,di amministrazioni pubbliche,di enti pubblici anche economici,nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale". Tali associazioni,qualora ne venga accertata la costituzione con sentenza irrevocabile,vengono sciolte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,previa deliberazione del Consiglio stesso:la stessa legge sopra citata ha infatti disposto lo scioglimento dell'associazione segreta conosciuta come "Loggia P2". Le ragioni di tale divieto vanno anzitutto rinvenute nel fatto che queste associazioni non hanno ragion d'essere in un regime democratico che si caratterizza appunto anche per l'esigenza che le attività che in esso si svolgono siano(o possano essere)rese pubbliche. Tuttavia,il fatto che l'associazione non sia segreta non vale ad escludere che la sua attività si svolga(in tutto o in parte)in segreto e sia organizzata e diretta da capi che non siano quelli conosciuti. Il divieto di costituire associazioni che perseguono,anche indirettamente,scopi politici mediante organizzazioni aventi carattere militare va rinvenuto in ciò che,in regime democratico,i fini politici vanno perseguiti senza ricorrere alle armi,alla violenza,a gerarchie di tipo militare. In particolare,si considerano associazioni aventi carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi,reparti o nuclei,con disciplina e ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari e con organizzazione atta all'impiego collettivo di azioni di violenza o di minaccia. La libertà di associarsi è stata ulteriormente limitata dalla legge n.205 del 1993,che ha modificato la

This document is available free of charge on StuDocu.com

preesistente normativa del ’75,a norma della quale è vietata ogni organizzazione,associazioni,movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali,etnici,nazionali o religiosi. Il fenomeno associativo trova specifica attuazione nella Costituzione, che detta una disciplina particolare per le associazioni a fini politici(i partiti:art.49),sociali(la famiglia,la scuola:art.29 e 33),economico-sociali(istituti di assistenza,sindacati,cooperative:art.38,39,45),religiosi(art.8,20). Una deroga al principio della libertà di associazione (e dunque una “rottura”della Costituzione)è contenuta nella XII disposizione transitoria e finale,a norma della quale è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. I Costituenti hanno cioè ritenuto che il disciolto partito fascista fosse incompatibile con lo Stato democratico per la sua natura stessa di partito(che si poneva appunto come “unico”),per la sua ideologia e per il metodo della sua azione. La legge n.645 del 1952 ha ulteriormente precisato che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista “quando un’associazione,un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista,esaltando,minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione,oppure ancora denigrando la democrazia,le sue istituzioni e i valori della Resistenza,nonché svolgendo propaganda razzista. La Corte costituzionale(sent.1 del 1957)ha ritenuto che si ha APOLOGIA DEL FASCISMO (punita come reato ai sensi della legge sopra citata)quando questa consista non in una difesa elogiativa ma in un’esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito. Ha inoltre precisato che si ha una “manifestazione fascista”(ugualmente punita come reato dalla legge sopra citata)quando questa,in relazione alle circostanze di tempo,di luogo e di ambiente in cui si svolge e per le sue obiettive caratteristiche sia comunque idonea a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito fascista. Inoltre la legge n.152 del 1975 ha aggravato le pene per chiunque,partecipando a pubbliche riunioni,compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista o di organizzazioni naziste. Inoltre la legge n.1546 del 1947 punisce chiunque promuove e costituisce un partito diretto alla restaurazione dell’istituto monarchico o ne agevola la costituzione. Si ci chiede infine se rientrino nella previsione dell’art.18 Cost. i “gruppi”:in realtà non sembra che tali gruppi possano definirsi associazioni,sia per la loro temporaneità sia per la mancanza di un’organizzazione stabile.

11. La libertà di religione- Sotto il profilo soggettivo,la libertà di religione consiste nel diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,individuale o associata,di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. I singoli pertanto possono vantare nei confronti dello Stato la pretesa a professare qualunque fede religiosa(vale a dire a porre in atto manifestazioni esteriori del proprio pensiero sul destino trascendentale dell’uomo o ad aderire ad una confessione religiosa piuttosto che un’altra),di farne propaganda mediante il PROSELITISMO e di esercitarne,sia in privato che in pubblico,il culto. Unico limite posto dall’art.19 è quello che esclude

l'esercizio del culto quando i riti relativi siano contrari al buon costume(sebbene riesca difficile determinare con oggettività quando effettivamente un rito sia contrario o meno al "buon costume",che rappresenta uno di quei concetti valvola,indeterminati,la cui portata varia a seconda del tempo e dello spazio).Nella libertà di religione va fatta rientrare (in negativo)anche quella di non essere costretti a professare una fede religiosa,a farne propaganda,a non esercitare alcun culto(ai sensi della sent.85 del 1963 della Corte) e quindi a non essere credenti,nelle forme esteriori in cui questa libertà può manifestarsi,giacchè la libertà di coscienza in materia religiosa,e quindi la libertà di credere o non credere in un'entità trascendente,attiene all'interiorità di ciascuno e come tale non può essere coartata). Rientra inoltre nella libertà religiosa di non avere imposto il compimento di atti con significato religioso,come ad es.di giurare,nei giudizi civili e penali,davanti a Dio,come la stessa Corte ha affermato in più pronunce. Il nuovo codice di procedura penale ha di fatti adottato una formula che,facendo riferimento all'assunzione di una responsabilità morale e giuridica,ha eliminato,in ossequio alle sentenze della Corte,ogni riferimento alla divinità. Ha suscitato poi non poche controversie l'articolo del codice penale(724)che nel testo originario puniva "chiunque bestemmia,con invettive o parole oltraggiose,contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato".Si sosteneva infatti la difficile compatibilità di questa norma con gli art.8 e 19(libertà ed eguaglianza delle confessioni religiose) e 21 (libertà di manifestazione del pensiero) della Costituzione;la Corte costituzionale,dopo aver in un primo tempo dichiarato infondata la questione,ha pronunciato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo,limitatamente però alle parole "o i simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato"(sent.n.440 del 1995),con l'effetto di estendere la tutela penale a divinità diverse da quelle della religione cattolica. Con una successiva pronuncia(sent.n.508 del 2000)la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.402 del codice penale,inerente al reato di VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO:dopo aver riaffermato il principio di laicità dello Stato,che gode del rango di "PRINCIPIO SUPREMO",la Corte ha sottolineato che tale principio implica la convivenza di diverse fedi,culture e tradizioni. La tutela penale della sola religione cattolica è pertanto,secondo la Corte,"un anacronismo al quale il legislatore non ha posto rimedio in tanti anni":il legislatore resta libero di reintrodurre la tutela penale,nel rispetto però dell'uguaglianza di tutte le confessioni religiose. Da notare che è stato depenalizzato il reato di bestemmia, con la previsione di una pena pecuniaria.

12. La libertà di manifestazione del pensiero: a) la libertà di stampa- L'ampio riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero contenuto nel I comma dell'art.21,che riconosce il diritto di ognuno a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione,lascia bene intendere quale fondamentale rilievo assuma tale libertà in un regime democratico. Appare evidente infatti non solo che un regime in cui non sia possibile manifestare liberamente il proprio pensiero non può certamente dirsi un regime democratico,ma anche che la "democraticità"di un ordinamento è direttamente proporzionale al grado

This document is available free of charge on StuDocu.com

in cui la libera manifestazione del pensiero viene per l'appunto riconosciuta e attuata in concreto. E di fatti a nulla varrebbe assicurare le altre libertà se allo stesso tempo non si desse ai cittadini il diritto di esprimere le loro opinioni,i giudizi,le valutazioni in campo politico,culturale,religioso ecc. I mezzi mediante i quali si può manifestare il proprio pensiero sono la parola(ovviamente il più diffuso),lo scritto(e,in primo luogo,la stampa),la radio,la televisione(e in genere i mezzi di comunicazione di massa),lo spettacolo. Ora,che tutti abbiano il diritto di manifestare il proprio pensiero "con ogni mezzo"non significa naturalmente(come ha osservato la Corte)che tutti debbano avere,di fatto,una materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione,ma vuol dire,più realisticamente,che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi. Si pone in tal modo il problema della disponibilità dei mezzi di diffusione del pensiero,dell'accesso a tali mezzi e dei limiti all'esercizio del diritto. Quanto alla parola,ciascuno di noi è del tutto libero di manifestare il proprio pensiero,salvo poi assumersene le responsabilità qualora commetta un reato(violando ad es. il diritto alla riservatezza di altri soggetti,il diritto alla reputazione o il segreto di Stato,di ufficio,o ancora diffondendo notizie false,esagerate o tendenziose,atte a turbare l'ordine pubblico compiendo il reato di vilipendio delle istituzioni o quello di propaganda sovversiva. Per quanto riguarda i c.d."REATI DI OPINIONE",la Corte costituzionale ha ritenuto che la libertà di manifestazione del pensiero,oltre al limite espresso del buon costume,ne trovi altri impliciti,che risiedono in special modo nella necessità di tutelare beni diversi,parimenti garantiti dalla Costituzione,fra cui il prestigio del Governo,dell'ordine giudiziario e delle forze armate. In regime democratico(sostiene sempre la Corte)sono peraltro ammesse critiche anche severe alle istituzioni vigenti,tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale,per assicurarne l'adeguamento ai mutamenti che intervengono nella coscienza sociale. Il vilipendio è configurabile solo quando la manifestazione in sé è diretta a negare ogni rispetto,prestigio,fiducia all'istituzione considerata,inducendo i destinatari al disprezzo dell'istituzione o addirittura ad ingiustificate disobbedienze. La legge n.85/2006 ha tuttavia apportato significative modifiche alle disposizioni contenute nel codice penale in materia di reati di opinione;in particolare sono stati depenalizzati alcuni reati,fra i quali il vilipendio della Repubblica,delle istituzioni costituzionali e delle forze armate,il vilipendio,il danneggiamento e l'offesa alla bandiera ecc. Il problema si pone pertanto per gli altri mezzi di manifestazione e fra essi,in primo luogo,per la stampa,che costituisce certamente il mezzo più incisivo,almeno ai fini della formazione di una consapevole opinione pubblica e dell'acquisizione di conoscenze,e proprio per questo l'art.21 detta una disciplina specifica sia per la libertà di stampa sia per le limitazioni al suo esercizio. Per "stampa" o "stampato"deve intendersi(secondo la definizione che ne da l'art.1 della legge 47/1948(Disposizioni sulla stampa),ogni riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione;e dunque i libri,la stampa periodica(giornali,quotidiani e riviste),i manifesti,i depliants,i volantini ecc. A norma del II comma dell'art.21,"La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". L'essenza della libertà di

stampa sta dunque in ciò che chiunque voglia pubblicare un libro,un giornale,un opuscolo,un manifesto ecc. non deve chiedere alcuna autorizzazione(vale a dire un consenso preventivo alla pubblicazione),è anzi assolutamente libero di farlo,e una volta stampato il libro,giornale,manifesto ecc.,e prima di procedere alla sua diffusione,non deve sottoporlo ad alcuna censura. Né vale ad incidere sulla libertà di stampa la REGISTRAZIONE presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione deve essere effettuata la pubblicazione,e dalla quale devono risultare i nomi del proprietario e del direttore o del vice direttore responsabile e il domicilio di ciascuno,e della persona che esercita l'impresa giornalistica,qualora sia diversa dal proprietario. Fine della registrazione(che è richiesta solo per la stampa periodica,mentre per la stampa non periodica è sufficiente indicare il luogo o l'anno della pubblicazione,nonché il nome e il domicilio dello stampatore e,se esiste,dell'editore)è quello di consentire l'identificazione dei responsabili nel caso in cui siano commessi reati per mezzo della stampa. IL SEQUESTRO DEGLI STAMPATI:L'unica forma di limitazione espressa della libertà di stampa è il SEQUESTRO,inteso come misura a carattere repressivo che può cioè essere posta in essere soltanto dopo la pubblicazione dello stampato e al fine di impedirne la diffusione(per cui il sequestro non potrebbe essere operato in tipografia). A norma dell'art.21 comma III,si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di letti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. Il sequestro può essere disposto anche dal giudice civile,come misura cautelare qualora si tratti di far cessare l'abuso di immagine altrui;in mancanza di una legge organica sulla stampa,i casi in cui si può procedere al sequestro sono ancora previsti nel R.D.Lgs.del '46(Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni)e per quanto riguarda l'indicazione dei responsabili,nella legge n.47 del '48. Qualora però vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,l'art.21 comma IV dispone che il sequestro della stampa periodica(e non quindi,ad es.,di un libro)può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,che devono immediatamente,e non mai oltre 24 ore,fare denuncia all'autorità giudiziaria;se questa non lo convalida nelle 24 ore successive,il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Ad ogni modo,il sequestro si pone come unico intervento ammesso per reprimere la stampa contraria al buon costume:vengono a porsi pertanto gli stessi problemi relativi alla definizione del "buon costume"visti a proposito della libertà di religione,con in più un'altra considerazione,che discende dalle previsioni legislative che puniscono chiunque metta in circolazione scritti,disegni o immagini osceni,pubblichi notizie false,esagerate o tendenziose,per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico oppure,sempre col mezzo della stampa,attenti alla morale familiare. L'unico punto fermo resta per il momento la definizione di "buon costume"data dalla Corte costituzionale nella sent.n.9 del 1965. La nozione di buon costume che compare nell'art.21 Cost.,come si legge in questa sentenza,non può essere fatta coincidere con la morale o con la coscienza etica(dal momento che la legge morale vive nella coscienza individuale,e come tale non può formare oggetto di previsione

This document is available free of charge on StuDocu.com

legislativa),ma risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione. LA LIBERTA' DI CRONACA: Nel quadro più generale ed ampio della libertà di manifestazione del pensiero si inserisce il problema relativo alla libertà di cronaca(vista come un aspetto particolare della libertà di manifestazione del pensiero),con speciale riguardo alla cronaca giudiziaria. L'art.684 codice penale punisce infatti chiunque pubblichi,in tutto o in parte,anche per riassunto,documenti o atti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione(secondo il c.d."SEGRETO ISTRUTTORIO").La rigidità di tale disciplina non appare del tutto in armonia con l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero(e col connesso diritto di informare)dei giornalisti;si renderebbe pertanto opportuna una revisione della legislazione vigente atta a conciliare il segreto istruttorio col dovere di cronaca del giornalista e col diritto del cittadino ad essere informato(in tal senso si è del resto pronunciata la stessa Corte costituzionale con la sent.n.18 del 1981,dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art.684). Da parte sua,la Corte di Cassazione ha invece determinato le condizioni in presenza delle quali la libertà di cronaca può essere legittimamente esercitata:ad es.,la verità non deve essere "incompleta",la forma della critica deve essere "civile" e improntata a "leale chiarezza" ecc. Può aversi poi una forma di AUTOLIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI CRONACA allorquando gruppi editoriali,singoli direttori di giornali quotidiani o periodici o anche la RAI e le emittenti radiotelevisive private decidano autonomamente di non pubblicare o di non diffondere determinate notizie o determinati documenti riguardanti indagini in corso della polizia giudiziaria,oppure provenienti da soggetti imputati di gravi reati o già condannati per la loro commissione(il c.d."SILENZIO STAMPA" o "BLACKOUT"). Ad ogni modo,il silenzio stampa può essere deciso solo e unicamente dai giornali o dalla RAI o dalle emittenti radiotelevisive private,e una legge che lo imponesse,introducendo surrettiziamente una forma di censura,mal si concilierebbe con l'art.21 Cost. In tutt'altro campo invece va rivenuto un altro limite alla libertà di manifestazione del pensiero,specie in relazione alla posizione che determinati soggetti assumono nel sistema costituzionale:così ad es.il c.d."POTERE DI ESTERNAZIONE"del Presidente della Repubblica deve essere contenuto entro limiti rigorosi,e può essere esercitato solo in stretta connessione con lo svolgimento delle funzioni che gli vengono costituzionalmente attribuite. L'importanza e l'incidenza della stampa ai fini della formazione dell'opinione pubblica ha indotto il Costituente a prevedere(art.21 comma V) che "La legge può stabilire,con norme di carattere generale,che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica",e ciò per consentire una lettura critica e consapevole dei quotidiani e dei periodici in genere,che è resa possibile solo dalla conoscenza dei nomi dei proprietari e dei finanziatori degli stessi(e dunque del loro orientamento). La disposizione risulta sicuramente fondamentale in presenza di una stampa i cui mezzi di finanziamento sono spesso ignoti(o non si conoscono ufficialmente),di una stampa che,per sopravvivere,alle volte risulta costretta a subire condizionamenti da parte di gruppi economici(pubblici e privati)e di un fenomeno,quello della CONCENTRAZIONE DELLE TESTATE(contro cui si

pongono le regole dell'ANTI-TRUST),peraltro espressamente vietata dalla legge n.67 del 1987 qualora valga a far assumere all'avente causa una posizione dominante nel mercato editoriale,e che desta non pochi motivi di preoccupazione,laddove si rifletta che soprattutto nel campo dell'informazione dovrebbe essere assicurato il principio del pluralismo per consentire la libera circolazione di idee e la formazione di un'opinione pubblica non manipolata. Il problema del finanziamento della stampa è quindi,nella specie,direttamente collegato a quello dell'effettivo esercizio della relativa libertà,che è di fatti in buona parte condizionato dalla disponibilità dei mezzi economici necessari in tal senso. Una soluzione(tra l'altro da più parti ipotizzata)sarebbe potuta essere quella di mettere a disposizione di chi voglia liberamente manifestare il proprio pensiero attraverso la stampa tipografie e carta,con un servizio pubblico i cui costi dovrebbero tuttavia essere assunti dalla collettività,soluzione che,seppur realizzerebbe un pieno esercizio del diritto,andrebbe tuttavia incontro a notevoli inconvenienti pratici,dovuti in special modo alla difficoltà di determinare(senza operare discriminazioni)i criteri per l'accesso alle tipografie di Stato.(Essa era stata adottata nella Costituzione sovietica del 1936,che garantiva ai cittadini dell'URSS la libertà di stampa mettendo a disposizione dei lavoratori e delle loro organizzazioni le tipografie,i quantitativi di carta e in generale i mezzi necessari per il suo esercizio,alla condizione,tuttavia,che tale diritto fosse esercitato in conformità con gli interessi dei lavoratori ed allo scopo di consolidare il regime socialista.)Ora,quale che sia il criterio selettivo,esso finirebbe inevitabilmente col condizionare l'effettivo esercizio della libertà di stampa. La legge 7 marzo 2001,n.62 ha ulteriormente modificato la precedente legge sull'editoria del 1981:è stato istituito un Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale,sono stati previsti sgravi fiscali per le imprese editoriali più dinamiche e innovative,è stato istituito un Fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale ed è stata inoltre introdotta una nuova disciplina del prezzo dei libri. Anche la nuova normativa riafferma il principio della necessaria riconducibilità dell'impresa editrice di giornali quotidiani a persone fisiche,per assicurare trasparenza alle fonti di finanziamento di tale branca della stampa periodica,in ossequio all'art.21 comma V. Non è stata tuttavia introdotta l'incompatibilità tra esercizio dell'attività editoriale ed esercizio dell'attività radiotelevisiva,che avrebbe forse garantito meglio il pluralismo dell'informazione e la prevenzione delle formazioni dominanti nel settore.

13. b) Il cinema ed il teatro-Anche lo spettacolo(cinematografico e teatrale)è uno dei mezzi di diffusione del pensiero. La Costituzione vieta quindi gli spettacoli contrari al buon costume,e demanda alla legge di stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le eventuali violazioni. In particolare,la censura sugli spettacoli non è espressamente vietata,e anzi essa è prevista,proprio al fine di "prevenire" le violazioni del buon costume. Infatti la legge n.161 del 1962 dispone che per la proiezione in pubblico dei film è richiesto un nulla-osta rilasciato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,su conforme parere di apposite commissioni di primo e di secondo grado,che possono anche stabilire se alla proiezione del film

This document is available free of charge on StuDocu.com

possono assistere i minori di 14 anni o di 18 in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva. La commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione in pubblico esclusivamente laddove ravvisi nel film,sia nel complesso,sia in singole scene o sequenze,un'offesa al buon costume ai sensi dell'art.21 Cost. Contro il provvedimento del ministro è tuttavia ammesso ricorso al TAR. Originariamente,un meccanismo analogo seppur più attenuato era previsto dalla stessa legge n.161 del 1962 anche per le opere teatrali,per le quali si applicavano le stesse norme previste per le opere cinematografiche,ivi compresa la facoltà di ricorrere alla commissione di secondo grado ed eventualmente al TAR. Oggi invece il meccanismo di revisione preventiva opera esclusivamente per le opere cinematografiche. L'intervento preventivo non esclude,però,quello repressivo qualora siano commessi i reati previsti dall'art.528(Pubblicazioni e spettacoli osceni)e 668 (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)del codice penale;competente in tal caso è il tribunale del luogo dove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima rappresentazione dell'opera teatrale o cinematografica. L'autorità di pubblica sicurezza,quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'art.668 codice penale,sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla legge n.161 del 1962 o al quale sia stato negato il nulla-osta e ne interdice la proiezione in pubblico fino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. Il regolamento di esecuzione della legge del 1962 ha inoltre disposto,travalicando forse quelli che dovrebbero essere i limiti di un regolamento di esecuzione,che devono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche e teatrali che,pur non costituendo offesa al buon costume,contengano battute o gesti volgari,indulgano a comportamenti amorali,contengano scene di violenza verso uomini o animali,o particolarmente impressionanti,fomentino l'odio o la vendetta,presentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione o al suicidio in forma suggestiva.

14. c) la radio e la televisione **-**Radio e televisione occupano fra i mezzi di diffusione del pensiero un posto a sé,laddove si consideri che hanno ormai superato le potenzialità della stampa,soprattutto per quanto attiene alla loro capacità di informare e di incidere sull'opinione pubblica. In Italia,il regime giuridico di radio e televisione è ad oggi dettato(dopo un periodo transitorio durato alcuni anni e nel corso del quale si sono susseguiti leggi,decreti-legge,sentenze della Corte costituzionale oltre che aspre polemiche in sede politica)dalla legge 3 maggio 2004,n.112.Ad ogni modo,la legge 31 luglio 1997 n.249 ha dettato alcune regole essenziali in merito ai sistemi delle telecomunicazioni e al sistema radiotelevisivo,nella specie istituendo l'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,organo composto da un Presidente,nominato dal Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio,previo parere delle commissioni parlamentari competenti e da 8 commissari eletti per metà dal senato e per metà dalla Camera,e che nella specie assorbe le funzioni già attribuite al Garante per la stampa e la radiotelevisione. La stessa legge 249 ha istituito inoltre un Consiglio nazionale degli utenti,con il compito di esprimere pareri e formulare proposte su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini,quali soggetti attivi del

processo comunicativo. Era stato inoltre istituito un Forum permanente per le comunicazioni,composto da rappresentanti del Ministero delle comunicazioni,da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore,con compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie nel settore della comunicazione. Successivamente,la legge n.3 del 2003 ha soppresso il Forum permanente e ne ha trasferito le funzioni al Consiglio superiore delle comunicazioni. L'Autorità detiene importanti poteri di accertamento,regolazione,controllo e sanzione per far rispettare le regole ANTI-TRUST. Quanto a quest'ultime,negli ultimi anni si è sviluppato un travagliato dibattito politico e dottrinale sul pluralismo e sull'imparzialità dell'informazione,seriamente minacciati dalla formazione di vaste concentrazioni di mass media nelle mani di pochi soggetti(in termini specifici,RAI e Mediaset). A tal proposito,nel 2002,il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inviato alle Camere un messaggio ai sensi dell'art.87 comma II Cost.,in cui venivano formulati i principi fondamentali in materia di pluralismo e imparzialità dell'informazione. Dopo aver richiamato le più importanti pronunce della Corte costituzionali in proposito e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE,il Capo dello Stato ha enunciato in quell'occasione alcune linee di indirizzo che sarebbero dovute servire da base per l'intera disciplina delle comunicazioni,delle radio telediffusioni,dell'editoria di giornali e periodici e dei rapporti fra questi mezzi. In particolare,il Capo dello Stato invitava ad un'estensione della vigilanza del Parlamento,in coordinamento con l'Autorità garante,all'intero circuito mediatico,pubblico e privato,allo scopo di rendere uniforme e omogeneo il principio della PAR CONDICIO,in modo da realizzare il bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell'opposizione in un sistema come quello italiano passato,dopo mezzo secolo di rappresentanza proporzionale,al sistema elettorale maggioritario. Dopo un contrastato iter parlamentare,alla fine del 2003 venne approvata una nuova legge sui principi generali in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-radiotelevisione italiana. Il Presidente della Repubblica tuttavia non la promulgava,rinviandola alle Camere con messaggio motivato,ai sensi dell'art.74 comma I della Costituzione. In tale messaggio,il Capo dello Stato muoveva numerosi rilievi di legittimità costituzionale di forte spessore tecnico ed istituzionale. La legge in questione (c.d."LEGGE GASPARRI")non prevede nuove e più rigorose misure anti-trust,ma punta tutto sull'espansione della tecnica digitale terrestre,che avrebbe dovuto produrre l'aumento dei canali fruibili e pertanto assicurare la concorrenza e il pluralismo in un mercato molto vasto in cui le posizioni di RAI e Mediaset sarebbero risultate diluite e depotenziate. Il punto centrale della questione era l'efficacia del meccanismo anticoncentrazione adottato dalla legge citata,giudicato da molti illusorio e fallace,anche per i tempi lunghi e necessari nonostante le procedure accelerate previste,a coprire con la nuova tecnica digitale l'intera popolazione italiana. Secondo alcuni critici questa legge avrebbe di fatto determinato non un contenimento,ma addirittura una ulteriore espansione delle attuali posizioni dominanti:dopo alcune modifiche,la legge è stata però nuovamente approvata dal Parlamento e successivamente promulgata(legge n.112 del 2004). Le norme in materia di radiotelevisione sono state poi raccolte in un Testo unico. Al fine di assicurare

This document is available free of charge on StuDocu.com

l'indipendenza,l'obiettività e l'apertura del servizio pubblico radiotelevisivo alle diverse tendenze politiche,sociali e culturali,la determinazione dell'indirizzo generale del servizio stesso e l'esercizio della relativa vigilanza sono stati affidati ad una COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA:a tale Commissione spetta di stabilire le norme per garantire il diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo,attribuito ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento,alle organizzazioni associative delle autonomie locali,ai sindacati nazionali,alle confessioni religiose,ai movimenti politici,agli enti e alle associazioni politiche e culturali,ai gruppi etnici e linguistici e agli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

15. Internet **–** Un veicolo potente per la manifestazione del pensiero è oggi la rete internet, che consente ad un numero elevato di individui e gruppi di scambiare informazioni, anche se sparsi in diverse parti del mondo. Anche l'uso della rete può ricollegarsi alle previsioni di cui all'art. 21. Bisogna tener conto che si è di fronte ad una massa immensa di informazioni di cui è difficile accertare l'attendibilità. Un aspetto importante riguarda il diritto d'autore, tanto che è stato necessario aggiornare la legge di protezione di questo diritto alla nuova cyber- realtà.

16. Il diritto all'informazione- Secondo la Corte costituzionale,l'art.21 Cost. oltre alla libertà di manifestazione del pensiero tutela,dal punto di vista dei destinatari della manifestazione(sia pure indirettamente)l'interesse generale all'informazione,che in un regime democratico implica la pluralità delle fonti d'informazione,libero accesso alle stesse,libera circolazione di notizie e idee. Questo diritto discende anche dal principio di democraticità dell'ordinamento e da quello di imparzialità della pubblica amministrazione,secondo i quali l'attività della pubblica amministrazione dovrebbe essere esercitata in modo palese;ma in mancanza di disposizioni che lo rendano concretamente e diffusamente operante e in presenza invece di leggi che pongono sensibili limitazioni alla divulgazione di notizie e alla conoscenza di fatti,il diritto all'informazione resta ancora,in buona misura,una pura affermazione di principio. Un vero e proprio diritto all'informazione è invece formalmente riconosciuto ai cittadini dagli Statuti delle Regioni:nell'ordinamento regionale infatti il diritto all'informazione riceve espresso riconoscimento,in modo da rendere il più possibile effettiva la partecipazione all'attività politica,legislativa ed amministrativa della Regione. In tal senso,il diritto all'informazione rientra,più che fra le libertà negative,fra le libertà positive,cioè come diritto a che la Regione predisponga tutte le misure idonee affinchè i cittadini e le organizzazioni sociali possano essere informati e,pertanto,consapevolmente partecipare alla sua attività. LA LIBERTA'DI INFORMAZIONE: Presupposto necessario del diritto all'informazione è la libertà dell'informazione(che prende corpo soprattutto nella libertà di cronaca). Sulla libertà d'informazione può comunque incidere negativamente,limitandola di fatto,il contrasto coesiste fra la norma contenuta nella legge n.69 del 1963(Ordinamento della professione di giornalista)che,dopo aver definito questa libertà come "diritto insopprimibile dei giornalisti",imponendo agli stessi e agli editori di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere

fiduciario delle stesse,e la norma contenuta nell'art.352 del codice di procedura penale previgente che non menzionava i giornalisti fra coloro che non sono obbligati a deporre su ciò che a loro viene confidato o è pervenuto a loro conoscenza in ragione del proprio ministero/ufficio/professione. E'accaduto infatti che giornalisti che si sono rifiutati di rivelare la fonte delle notizie abbiano subito una condanna per aver taciuto,in tutto o in parte,ciò che si sa in merito ai fatti sui quali si è interrogati deponendo come testimoni dinanzi all'autorità giudiziaria(art.372 codice penale). L'art.200 del nuovo codice di procedura penale,pur estendendo ai giornalisti professionisti il segreto professionale relativamente ai nomi delle persone dalle quali gli stessi hanno avuto notizie di carattere fiduciario,dispone tuttavia che se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato e la loro veridicità può essere accertata solo mediante l'identificazione della fonte della notizia,il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte della sua informazione. Il contrasto dunque permane,per cui i giornalisti potrebbero essere indotti o a non acquistare notizie o a non divulgarle per non vedersi costretti,qualora chiamati a testimoniare,a rivelarne la fonte o ad invocare il segreto professionale,contravvenendo nell'uno e nell'altro caso ad una legge dello Stato.

17. La libertà dell'arte e della scienza e del relativo insegnamento- Che l'arte e la scienza siano libere sta a significare non solo che non possono esistere un'arte o una scienza di "Stato",ma anche che all'artista e allo scienziato sono cocesse le massime libertà di espressione,non considerando ad es. oscena un'opera d'arte o l'opera di scienza(sent.9 del 1965)della Corte costituzionale),e ponendo in essere tutte quelle misure idonee a consentire l'effettivo esercizio delle attività artistiche e scientifiche. Quest'ultima notazione vale in particolare per la ricerca scientifica,sebbene,a tutt'oggi,in Italia non esiste una politica della ricerca scientifica,nonostante quanto afferma lo stesso art.9 Cost.,per il quale "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica",che risulta strettamente connesso alla norma contenuta nell'art.33 comma I,per il quale "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento":esse infatti pongono il problema dei rapporti fra scienza(o meglio,libertà della scienza)e politica,il problema cioè di conciliare la libertà della scienza con la necessità di un apparato organizzativo pubblico di supporto e di finanziamento. Sotto questo profilo,sembra che oggi,in Italia,la libertà della scienza non sia pienamente assicurata:basti pensare alle inadeguatezze dell'organizzazione italiana della ricerca scientifica ed alle difficoltà che incontra il suo massimo centro,il CNR (Consiglio nazionale delle ricerche),e ancora allea crisi delle Università come sedi della ricerca. A tali inefficienze si è cercato di porre rimedio con l'istituzione di un ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica(ora confluito nel ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).Tale legge,in attuazione dell'art.22 ultimo comma Cost., disciplina fra l'altro l'autonomia normativa delle Università. In base a tali disposizioni,le Università hanno acquistato un'ampia autonomia didattica,con possibilità di articolare in modo diverso i propri corsi di studio. Strettamente collegata agli art.9 e 33 risultano quindi essere l'art.3 e 4 Cost. Oltretutto,connessa alla libertà dell'arte e della scienza appare essere la LIBERTA'

This document is available free of charge on StuDocu.com

DELL'INSEGNAMENTO,che consiste nel garantire il docente contro ogni costrizione o condizionamento da parte dei pubblici poteri. Deve quindi essere assicurata al docente un'assoluta autonomia circa gli indirizzi e gli orientamenti culturali da elaborare o da seguire,purchè rispetti a sua volta la libertà del discente e ne stimoli il senso critico facendo conoscere,per debito di obiettività,anche le tesi diverse dalle sue.

SEZIONE IV- LE LIBERTA' POSITIVE

Il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale si esplicita anche con il riconoscimento nelle costituzioni del primo e del secondo dopoguerra,di alcuni diritti c.d."SOCIALI"accanto alle tradizionali libertà negative e del principio di eguaglianza sostanziale accanto a quello di eguaglianza formale. Nello Stato sociale che ne è derivato,l'accento viene posto infatti non soltanto sul riconoscimento giuridico-formale di alcune libertà,ma anche sul loro effettivo esercizio. Pertanto,non si fa più valere solo la pretesa a ciò che i pubblici poteri non intervengano nella sfera dell'autonomia privata ma anche quella a che essi si rendano attivi per assicurare il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali ai processi nei quali e mediante i quali si operano le scelte politiche,economiche e sociali. Alla pretesa ad un comportamento omissivo dello Stato si accompagna quindi quella ad un comportamento attivo;accanto alla libertà negative si pongono le libertà positive.

18- Libertà positive e negative- Intese in questo senso,le libertà positive vanno considerate come il risultato ultimo di una serie di interventi dei pubblici poteri diretti a dare attuazione al principio di eguaglianza sostanziale. E in effetti a nulla vale riconoscere ai singoli alcuni diritti fondamentali se poi,al tempo stesso,non si eliminano gli ostacoli,di ordine economico e sociale,che limitano di fatto l'esercizio delle libertà ad essi connesse. Ne consegue che le libertà positive rappresentano,per così dire,un modo di essere delle libertà civili e politiche,l'altra faccia della medaglia. Libertà positiva è ad es. quella contenuta nell'art.49,nella quale si da attuazione alla libertà (negativa) di associazione,riconosciuta dall'art.18,e specificandola come libertà positiva attribuendo a tutti i cittadini il diritto di associarsi in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale.

19. I diritti sociali- Per "diritti sociali" si intendono diritti,riconosciuti a determinate categorie di soggetti,che hanno come fine quello di consentire l'eliminazione delle disparità sociali ed il conseguente esercizio,pieno ed effettivo,delle libertà civili e politiche. Più in particolare,sono da includere nei diritti sociali il diritto al lavoro (art.4);il diritto alla salute,che si specifica nel garantire cure gratuite agli indigenti(art.32)ed implica il diritto alla salubrità dell'ambiente;il diritto allo studio e,per i capaci e i meritevoli,il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi(art.34);il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa(art.36 comma I);il diritto del lavoratore al

riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite(art.36 comma III);la parità dei diritti della donna lavoratrice rispetto al lavoratore e,a parità di lavoro,il diritto alla stessa retribuzione(art.37 comma I);il diritto dei minori,a parità di lavoro,alla parità di retribuzione(art.37 comma III);il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dei cittadini inabili al lavoro,e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere(art.38,comma I);il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,malattia,invalidità,vecchiaia,disoccupazione involontaria(art.38 comma II);il diritto degli inabili e dei minorati all'educazione e all'avviamento professionale(art.38 comma III). Alcune di queste situazioni giuridiche soggettive sono previste e riconosciute in norme programmatiche e le leggi che dovrebbero darvi attuazione non sempre appaiono idonee a renderle concretamente operanti. Se mettiamo ad esempio a confronto la disposizione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività con l'attuale organizzazione sanitaria del Paese e con la mancanza di una razionale e incisiva politica ecologica(anche se un decisivo passo in avanti è stato compiuto con l'istituzione,nel 1978,del servizio sanitario nazionale),le disposizioni sul diritto all'assistenza e alla previdenza sociale con la situazione in cui versano oggi in Italia gli istituti di assistenza e previdenza sociale ecc. La Corte Cost., a proposito della questione "Ilva", ha stabilito un metodo per bilanciare diritto al lavoro e diritto alla salute. Spesso è necessario bilanciare i diritti, per evitare che uno di essi si faccia "tiranno" verso gli altri.

20. Le libertà economiche- In questo quadro assume particolare rilievo la disciplina costituzionale del diritto di proprietà,della libertà di iniziativa economica privata e del diritto al lavoro(c.d."LIBERTA' ECONOMICHE"). Bisogna anzitutto osservare che,in uno Stato interventista,i tradizionali istituti della proprietà privata e dell'iniziativa economica privata non sono più considerati come un mito che ha valore intangibile(e così ad es. la proprietà non è più definita "inviolabile" come nello Statuto albertino).La nostra Costituzione si occupa della proprietà privata negli art.42,43,44 e 47.Nel primo di questi articoli la proprietà viene distinta in pubblica e privata,e si dispone che i beni economici appartengono allo Stato,ad enti o a privati. I beni pubblici possono essere di proprietà dello Stato,delle Regioni,delle Province,dei Comuni o di altri enti pubblici. La loro condizione giuridica è disciplinata dal codice civile,che a sua volta li distingue in BENI DEMANIALI e BENI PATRIMONIALI. I beni demaniali sono quelli destinati a soddisfare in via immediata un interesse o un bisogno pubblico. Essi possono appartenere,per la loro natura,o esclusivamente allo Stato(DEMANIO NECESSARIO),ad es.,il lido del mare,la spiaggia,i porti,i fiumi,le opere destinate alla difesa nazionale ecc.,o anche agli enti territoriali(DEMANIO ACCIDENTALE),ad es. le strade,le autostrade,gli immobili riconosciuti d'interesse storico,archeologico e artistico,le raccolte dei musei e delle pinacoteche ecc. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e possono formare oggetto di diritti a favore di terzi,se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. I beni patrimoniali si distinguono in INDISPONIBILI e DISPONIBILI;fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le miniere,le cose

This document is available free of charge on StuDocu.com

d'interesse storico,archeologico,le cose e i beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica,le caserme,gli armamenti,gli aeromobili militari e le navi da guerra,che non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. I beni patrimoniali disponibili(vale a dire tutti i residui beni di proprietà pubblica che non rientrano nella categoria di quelli indisponibili)possono essere MOBILI(denaro,titoli di credito,ecc.)o IMMOBILI(fondi rustici,boschi di proprietà delle Province o dei Comuni,edifici non destinati ad uso pubblico).Il loro regime giuridico è pari a quello proprio della proprietà privata. I BENI PUBBLICI: A norma dell'art.9 Cost.,la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione,ergo gli immobili di interesse storico,archeologico e artistico,le raccolte dei musei,delle pinacoteche,degli archivi e delle biblioteche. Oggi però in Italia manca un organico indirizzo diretto alla tutela,alla conservazione ed all'incremento di tali beni(che possono tutti riassumersi nella categoria dei "BENI CULTURALI E AMBIENTALI").E solo con la costituzione del ministero per i beni culturali e ambientali(1975)e del ministero dell'ambiente(1986)e con l'avvio di una politica di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali da parte delle Regioni si è cominciato a considerare la disposizione contenuta nell'art.9 Cost. non come mera dichiarazione di principio,priva di valore normativo,bensì come una norma-principio la cui attuazione è condizione per la tutela ed il soddisfacimento di altri valori costituzionali. LA PROPRIETA'-FUNZIONE: L'art.42 dispone che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,che ne determina i modi d'acquisto,di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Ecco quindi che la proprietà privata è riconosciuta e garantita come DIRITTO SOGGETTIVO se ed in quanto adempia ad una funzione sociale,nel senso che il diritto di proprietà si deve intendere "non come mezzo di esclusiva tutela dell'interesse del proprietario"(Pugliatti) in senso egoistico,quanto in senso solidaristico:pertanto,tutte le volte che questa funzione sociale non si ha o viene meno,il diritto di proprietà degrada a interesse legittimo. Inoltre, la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo(art.42 comma III).Più specificamente poi,l'art.44 Cost. dispone,in ordine alla proprietà terriera,che la legge,al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali(e dunque,al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà)può imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,fissare limiti alla sua estensione secondo le Regioni e le zone agrarie,promuovere ed imporre la bonifica delle terre,la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive;la legge ancora aiuta la piccola e media proprietà e dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Quanto all'art.43 Cost.,esso prevede che la proprietà privata di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali,a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed hanno carattere di preminente interesse generale,possa essere trasferita,a fini di utilità generale,con legge e salvo indennizzo allo Stato,ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o utenti. Condizione perché il trasferimento possa essere operato è dunque che si tratti di imprese(o di categorie d'imprese):a)che si riferiscono a servizi pubblici essenziali,a fonti d'energia o a situazioni di

monopolio;b)che hanno carattere di preminente interesse generale;c)che il trasferimento avvenga a fini di utilità generale. La Corte costituzionale,chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legge del 1962 che ha trasferito ad un ente pubblico appositamente creato,l'ENEL,alcune imprese elettriche,ha statuito che,ferma restando la discrezionalità del legislatore circa l'identificazione degli interessi da soddisfare e dei mezzi da imporre,l'utilità generale deve corrispondere al bene della collettività. LA LIBERTA' D'INIZIATIVA ECONOMICA: La libertà d'iniziativa economica(art.41,comma I) si ricollega strettamente al diritto al lavoro,nel senso che l'obiettivo della piena occupazione deve essere perseguito e raggiunto nel rispetto di alcuni valori(la sicurezza,la libertà e la dignità della persona umana)che la Costituzione vuole tutelati anche e soprattutto nei confronti dei lavoratori subordinati;e ancora,solo una seria programmazione economica può valere a rendere effettivo il diritto al lavoro. IL DIRITTO AL LAVORO: Il diritto al lavoro,eminentemente sancito dall'art.4 comma I Cost.,non attribuisce,come del resto chiaramente si ricava dalla sua stessa formulazione,un diritto soggettivo pieno e azionabile ad ottenere(sia dallo Stato che da altro ente pubblico sia dai privati)un posto di lavoro. Spetta infatti alla Repubblica unicamente di PROMUOVERE le condizioni per rendere EFFETTIVO questo diritto,che pertanto,effettivo non è. L'obiettivo da perseguire e raggiungere è quello della PIENA OCCUPAZIONE(vale a dire l'eliminazione della disoccupazione). Obiettivo che a distanza di più di 60 anni dall'entrata in vigore della Costituzione non sembra essere stato conseguito,e ciò a causa di scelte economiche non sempre adeguate,della mancanza di un'organica politica di programmazione e di una non equilibrata utilizzazione delle risorse. Per cui oggi all'art.4 va strettamente collegato l'art.38,a norma del quale i lavoratori disoccupati involontari hanno diritto ad avere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Al diritto al lavoro si ricollega infine la libertà di lavoro,cioè il diritto di scegliere un lavoro secondo le proprie capacità e attitudini(senza dover essere costretti,pur di lavorare,a svolgere un'attività non rispondente ai propri interessi e alle proprie inclinazioni).

21. I nuovi diritti- Con l'espressione *nuovi diritti* ci vogliamo riferire ai diritti relativi a questioni oggi molto dibattute ma che non sono ancora regolamentate da precise norme giuridiche o lo sono solo in parte. Ai *nuovi diritti* appartengono quelli relativi all'ambiente, agli animali (per es. la questione della vivisezione), ecc. Ma rientrano nel tema anche vecchie questioni che solo da poco tempo si sono cominciate a ricondurre al campo dei diritti (per esempio: i diritti dei carcerati, l'aborto, la legalizzazione di certe droghe, ecc.) e nuove questioni che sono state poste dai recentissimi sviluppi della scienza (per esempio gli sviluppi dell'ingegneria genetica, l'eutanasia e tutti gli altri temi che rientrano nella sfera della bioetica).Sono generalmente espressione di interessi diffusi e la loro tutela va affidata al legislatore ordinario. Si parla anche di diritti della terza generazione.

SEZIONE V- LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

A seguito della seconda guerra mondiale,i "diritti dell'uomo"hanno ricevuto una particolare protezione sia in seno alla comunità internazionale(con la "Dichiarazione

This document is available free of charge on StuDocu.com

universale dei diritti dell'uomo"approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948)sia in seno alla Comunità europea(con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,firmata a Roma il 4 novembre del 1950 dagli Stati aderenti al Consiglio d'Europa ed estesa in Italia nel 1955).

22. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO: Il valore programmatico della Dichiarazione è dato innanzitutto dall'essere stata approvata da un organismo di diritto internazionale al quale oggigiorno aderisce la maggior parte degli Stati del mondo. La Dichiarazione costituisce di conseguenza il frutto di un accordo sul riconoscimento e sulla tutela di alcuni diritti fondamentali da parte di tutti gli Stati aderenti all'ONU. Già nel preambolo,però,la Dichiarazione viene definita come "ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni":il suo valore giuridico appare quindi ben limitato;spetterà infatti ai singoli Stati membri di darle attuazione,e se alcuno dei diritti solennemente proclamati non sarà riconosciuto o sarà violato in un singolo Stato,l'ONU non potrà obbligare quest'ultimo a mutare comportamento o non potrà applicargli una sanzione. Ora,la Dichiarazione riconosce non solo il principio di eguaglianza formale ed i tradizionali diritti fondamentali(libertà personale,di domicilio,di corrispondenza ecc.),ma anche ed ampiamente i c.d. "diritti sociali". Così viene riconosciuto il diritto di ognuno alla vita,alla sicurezza sociale,al lavoro e ad una remunerazione equa e sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,il diritto all'istruzione,di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità ecc. Tali diritti sono stati meglio specificati e più concretamente garantiti dall'ONU nei Patti sui "diritti economici,sociali e culturali" e sui "diritti civili e politici"approvati dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1966 e resi esecutivi in Italia nel 1977.

***23.* LA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI E LE ALTRE CARTE DEI DIRITTI FONDAMENTALI**: La Convenzione si propone di prendere le prime misure atta ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Rispetto alla Dichiarazione Universale,la Convenzione appare riduttiva per quanto riguarda i diritti e le libertà in essa compresi ed estensiva per quanto attiene alla loro tutela. Riduttiva,perché essa garantisce le libertà negative(patrimonio comune di tutti gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa)e i diritti sociali .In particolare vengono riconosciuti il diritto alla vita della persona umana,alla libertà e alla sicurezza,ad una sollecita ed imparziale amministrazione della giustizia,al rispetto della vita privata e familiare,alla libertà di domicilio e di corrispondenza,di pensiero,di religione ecc. Estensiva,perché non si limita a proclamare i diritti e le libertà,ma al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati firmatari,ha istituito una COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (CEDU) ed una Corte europea dei diritti dell'uomo;la prima,alla quale possono rivolgersi non soltanto le parti contraenti per denunciare l'inosservanza delle disposizioni della Convenzione imputabili ad un'altra parte contraente,ma anche ogni

persona fisica,ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda di essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione;la seconda,alla quale spetta invece,nel caso di fallimento della composizione amichevole della controversia ad opera della Commissione,di risolvere la questione sottopostale dalla Commissione stessa o da una delle parti contraenti. La decisione della Corte è definitiva e le parti contraenti sono impegnate a darle esecuzione. Tradizionalmente,le norme CEDU erano considerate sullo stesso piano della legge ordinaria,anche se la giurisprudenza della Corte costituzionale aveva precisato che la tutela dei diritti fondamentali derivante dalle norme della Costituzione doveva tener conto,quali canoni interpretativi rilevanti,delle norme della Convenzione e delle pronunce della Corte di Strasburgo. Con le sent.n.348 e 349 del 2007(e da ultimo con le sent.311 e 317 del 2009),la Corte costituzionale ha riconosciuto alle norme CEDU il ruolo di PARAMETRO INTERPOSTO,valido a rendere applicabile il I comma dell'art.117 Cost.,in cui è stabilito che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è esercitata nel rispetto,tra l'altro,degli obblighi internazionali. Questa importante apertura dell'ordinamento italiano alla protezione internazionale dei diritti fondamentali avrà l'effetto pratico che,in tutti i casi di rilevato contrasto tra una legge italiana e una norma della Convenzione,sarà possibile sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art.117 comma I Cost.,reso operativo dalle norme CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo. La Corte costituzionale ha pure precisato che le norme CEDU non hanno la stessa efficacia diretta delle norme comunitarie,che vengono prodotte da un ordinamento sopranazionale,di cui l'Italia fa parte e rispetto al quale,ai sensi dell'art.11 Cost.,ha accettato limitazioni alla propria sovranità. Le norme CEDU,in quanto integratrici del parametro di costituzionalità,devono essere conformi a Costituzione,onde evitare che una legge possa essere dichiarata illegittima sulla base di un'altra norma,a sua volta incostituzionale. Il Consiglio europeo,nella sessione di Nizza del 7-9 dicembre 2000,ha proclamato solennemente la CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA: La Carta era stata inserita come seconda parte della Costituzione Europea,firmata a Roma nel 2004,in modo da farle assumere un valore giuridico formale a seguito della ratifica del Trattato costituzionale. La mancata ratifica di quest'ultimo da parte di alcuni Stati membri dell'Unione ha riaperto il dibattito sull'opportunità di riconoscere alla Carta natura vincolante. La questione è stata risolta inserendo una disposizione nel Trattato di Lisbona che modifica l'art.6 del Trattato sull'Unione europea e stabilisce che "l'Unione riconosce i diritti,le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000,che ha lo stesso valore giuridico dei trattati".Pertanto,alla Carta è stata riconosciuta natura vincolante nei confronti degli Stati membri dell'UE,con l'eccezione del Regno Unito,della Polonia e della Repubblica Ceca,che hanno chiesto ed ottenuto di essere escluse dal campo di applicazione della Carta. Tale documento costituisce un'importante codificazione dei diritti fondamentali a livello europeo,destinata ad incidere in tutti gli ordinamenti degli Stati membri. Il rapporto tra tutela nazionale e tutela europea dovrà sempre essere improntato al principio della massima espansione dei diritti fondamentali,ribadito peraltro dalla Carta stessa,che

This document is available free of charge on StuDocu.com

vieta l'interpretazione lesiva o limitativa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti alla Costituzioni degli Stati membri. La Corte costituzionale ha peraltro statuito(sin dal 1973)che in nessun caso si potrebbe verificare una restrizione dei diritti fondamentali dovuta ad una tutela europea in ipotesi più debole di quella italiana. Disposizioni sulla tutela dei diritti umani sono contenute anche nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internaz. Sui diritti economico, Convenzione sui diritti politici sulla donna, Convenzione sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali del Parlamento europeo (1989).

24. La condizione giuridica dello straniero- Ci si è lungamente interrogati,attraverso un dibattito dottrinale e politico che ancora oggi non può dirsi concluso,in merito alla particolare condizione giuridica dello straniero. Occorre innanzitutto chiedersi infatti se il nostro Stato sia tenuto o meno ad assicurare agli stranieri il godimento di quei diritti e di quelle libertà così solennemente proclamati nei documenti internazionali(ratificati dall'Italia),che contengono appunto un esplicito riconoscimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La risposta che è stata data è generalmente negativa:in particolare,si è ritenuto che al riguardo non possa essere invocato né l'art.10 comma I Cost.,a norma del quale "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute",giacchè esso fa riferimento alle NORME CONSUETUDINARIE,e non al diritto pattizio;né il II comma dello stesso articolo,a norma del quale "La condizione giuridica dello straniero è regolata in conformità alle norme e ai trattati internazionali". Si è rilevato in proposito che,in generale,vige il principio della separazione fra diritto interno e diritto internazionale,e che l'obbligo dello Stato italiano di regolare la condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati internazionali è vincolante nei limiti in cui norme e trattati non siano in contrasto con i principi del sistema costituzionale. Di modo che si rende necessario esaminare quali "diritti dell'uomo" e quali "libertà fondamentali"la nostra Costituzione riconosce ANCHE agli stranieri. Preliminarmente,bisogna dire che la Corte costituzionale ha inteso riaffermare(sent.n.222 e 223 del 2004)anche con riferimento agli extracomunitari,l'eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali(libertà personale,ecc.) Un primo criterio per giungere a questa individuazione è dato da un'interpretazione strettamente letterale degli art.13 e seguenti della Costituzione,secondo la quale agli stranieri sarebbero attribuiti quei diritti(e quei doveri)che la Costituzione espressamente non riserva ai "cittadini":pertanto,applicando tale criterio,i non cittadini non godrebbero delle libertà di circolazione e di soggiorno,di riunione,di associazione,ecc .insomma di tutti quei diritti che la Costituzione espressamente riserva solo ai cittadini italiani. D'altro canto,i non cittadini non sarebbero tenuti ad essere fedeli alla Repubblica e ad osservare la Costituzione e le leggi;inoltre ad essi non sarebbe riconosciuto il diritto al lavoro(né sarebbero soggetti al corrispondente dovere)e ad essi non sarebbe applicabile il principio di eguaglianza. Questo criterio appare però palesemente limitativo,in presenza anche di un principio interpretativo che ad esso si sovrappone e

secondo il quale lo Stato italiano è tenuto a parificare la condizione giuridica dello straniero a quella dei cittadini tutte le volte che ciò non contrasti con i suoi preminenti interessi,principio che è deducibile dall'art.10,comma II,dall'art.2(a norma del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo),dall'art.10 comma III,che attribuisce agli stranieri il diritto di asilo e dall'art.11,con il quale l'Italia si è impegnata a consentire,in condizioni di parità con gli altri Stati,alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Oltre a ciò,a norma dell'art.16 delle Disposizioni sulla legge in generale,"Lo straniero è ammesso al godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali". Si deve pertanto ritenere che gli stranieri non sono destinatari delle norme che attribuiscono diritti e doveri politici,vale a dire quelle situazioni giuridiche soggettive strettamente inerenti alla qualità di cittadino,e quindi il diritto di elettorato attivo e passivo,di associarsi in partiti,di rivolgere petizioni alla Camere ed il dovere di fedeltà alla Repubblica. IL DIRITTO DI ASILO: La Costituzione(art.10,comma III)attribuisce poi allo straniero,al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche,il diritto di asilo nel territorio della Repubblica,secondo le condizioni stabilite dalla legge. Condizione perché lo straniero assuma la qualità di rifugiato politico è che egli non possa di fatto esercitare nel suo Paese le libertà democratiche che la nostra Costituzione garantisce;lo straniero che ottiene l'asilo politico ha poi,a differenza degli altri stranieri,il diritto a soggiornare a tempo indeterminato in Italia:la disposizione è chiaramente una diretta conseguenza del carattere democratico della nostra Repubblica. E' da ricordare infine che,a norma dell'art.10 comma IV Cost. non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Con legge 94 del 2009 è stata data una disciplina organica della condizione giuridica dello straniero extracomunitario o apolide. Allo straniero sono riconosciuti tutti i diritti concernenti la persona umana. Sono riconosciute procedure specifiche per regolare l'immigrazione. Lo straniero può chiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oltre che turistici o di studio; permesso che non può superare la durata massima di 2 anni, salvo rinnovo. Il Presidente del C. dei ministri determina ogni anno la quota di ingresso degli stranieri.

SEZIONE VI- I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E FORMAZIONI SOCIALI

25. L'impegno della Repubblica nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali- La nostra Costituzione(art.2)riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che come partecipe alle formazioni sociali nella quali si svolge la sua personalità. L'impegno costituzionale di riconoscere e garantire tali diritti è assunto quindi non soltanto dallo Stato-apparato,ma dallo Stato-istituzione,comprensivo,oltre che di tutti i minori corpi sociali,anche di tutti gli ordinamenti particolari e ad essi sovraordinato. Il problema che si pone a questo riguardo è quello di stabilire se le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'uomo debbano inserire nel loro ordinamento interno norme di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili o se,nell'ipotesi negativa(o

This document is available free of charge on StuDocu.com

qualora le formazioni sociali non adempiano all'obbligo),il singolo possa ugualmente invocare la tutela delle situazioni soggettivi lese dal potere privato. Ora,non sembra che tale obbligo possa essere imposto dall'esterno,con un intervento dell'apparato autoritario dello Stato,poiché ciò equivarrebbe a comprimere la sfera di autonomia delle formazioni sociali:ogni formazione sociale deve infatti poter essere libera di darsi un ordinamento interno in cui i diritti inviolabili possono essere riconosciuti o non esserlo,garantiti o non garantiti. Il problema allora si sposta,e si tratta quindi di stabilire se l'ordinamento statale possa apprestare il riconoscimento e gli strumenti di garanzia dei diritti inviolabili dei singoli in quanto componenti di una formazione sociale. Così impostato,il problema diventa di valutazioni e scelte politiche;pertanto occorre piuttosto fare riferimento alla Costituzione per accertare quando essa esige che certi valori tutelati nei confronti dei poteri pubblici siano riconosciuti o protetti anche nei confronti del potere privato. L'art.2 a tal proposito si presta ad essere interpretato non esclusivamente nel senso che "i diritti inviolabili dell'uomo" sono soltanto quelli espressamente garantiti da altre disposizioni costituzionali,ma piuttosto nel senso che esso contiene un "elenco aperto",di modo che dottrina e giurisprudenza(e in particolare,la giurisprudenza costituzionale)possono trarne,in via d'interpretazione storico-evolutiva,la garanzia di altre situazioni soggettive inviolabili.

26. Le formazioni sociali a rilevanza costituzionale: Esse sono: le confessioni religiose, la famiglia, la scuola, la comunità del lavoro, i partiti politici, le Regioni, le Province, i Comuni, le minoranze linguistiche. Il rispetto dei valori costituzionali è richiesto quindi anche all'interno di tali formazioni,e nella specie,i diritti fondamentali di libertà ed eguaglianza dovrebbero essere riconosciuti e garantiti ai singoli anche all'interno di esse. A tal fine,la Costituzione dispone espressamente che: le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto ad organizzarsi secondo i propri statuti,purchè questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano(art.8 comma II); il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare(art.29 comma II); la legge,nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali deve assicurare ad esse piena libertà,e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali(art.33 comma IV); è condizione per la registrazione dei sindacati che i loro statuti sanciscano un ordinamento interno a base democratica(art.39 comma III); i cittadini associati in partiti devono concorrere a determinare la politica nazionale con metodo democratico(art.49). La Costituzione ha dunque posto limiti ben precisi all'autonomia delle formazioni sociali,nel senso che impone loro il rispetto del principio di democraticità e del principio di eguaglianza,oltre che,più in generale,dell'ordinamento giuridico statale.

27. Azionabilità dei diritti inviolabili e formazioni sociali- Se questo è il quadro generale,si ci pone a questo punto il problema in merito alla possibilità che i singoli abbiano o meno a disposizione strumenti giuridici atti a far valere i loro "diritti inviolabili"nei confronti del potere privato. Da una parte stanno coloro che

sostengono che l'art.2 Cost. consenta la protezione giurisdizionale del singolo in seno all'associazione invocando l'art.24 Cost.;dall'altra coloro che ammettono l'intervento del giudice purchè rispetti i limiti dell'autonomia privata. Secondo poi un'altra tesi non si può operare una trasposizione meccanica all'interno delle formazioni sociali di tutti i diritti di cui l'individuo gode nell'ordinamento generale;infine è stato sostenuto che l'intervenuto del giudice nelle associazioni,a tutela degli interessi degli associati costituirebbe,più che un fattore limitativo della libertà associativa,un modo di garantire proprio questi valori,nei contenuti e nelle dimensioni che i privati,associandosi spontaneamente,vi hanno dato.

28. Considerazioni finali- Bisogna però anzitutto sottolineare,per meglio inquadrare i complessi problemi posti dalla formulazione dell'art.2,la sostanziale ETEROGENEITA' DELLE FORMAZIONI SOCIALI a rilevanza costituzionale,per cui da un lato abbiamo formazioni NECESSARIE(la famiglia),dall'altro formazioni VOLONTARIE(le confessioni religiose,i partiti ecc.). Inoltre tali associazioni perseguono fini eterogenei(di solidarietà e mutua assistenza la famiglia;religiosi le comunità religiose;di istruzione la scuola;economico-sociali le comunità di lavoro; politici i partiti),rispetto ai quali lo Stato-istituzione può avere un interesse diretto,fino ad enunciarli espressamente nella Costituzione,o un interesse soltanto indiretto,per cui si limita a riconoscere e tutelare le formazioni sociali che li perseguono,ma non ne determina espressamente le finalità né tantomeno le rende obbligatorie. Esistono poi dei limiti "esterni" posti dalla Costituzione all'ordinamento delle formazioni: l'ordinamento giuridico italiano(confessioni religiose acattoliche), l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi(la famiglia), il trattamento scolastico equipollente(la scuola privata), l'ordinamento interno su base democratica(i sindacati), il metodo democratico(i partiti),anche se tutti possono ricondursi ai principi di libertà ed eguaglianza. La diversità di natura,di fini,di limiti esterni ecc. fanno si che non possa corrispondere un ordinamento interno omogeneo alle varie formazioni sociali né tantomeno una parità di trattamento da parte dello Stato. Il legislatore ha tuttavia ritenuto di dover intervenire,dettando una disciplina diretta a tutelare i diritti del lavoratore all'interno dell'impresa(legge n.300 del 1970,c.d."STATUTO DEI LAVORATORI") ed i diritti dei componenti della famiglia legittima(con la riforma del diritto di famiglia).Ma nel primo caso si trattava di dare attuazione al principio secondo il quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà e alla dignità umana(art.41 comma II Cost.),nel secondo di dare attuazione al principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi(art.29 comma II Cost.) e alle norme che prevedono la tutela dei figli all'interno della famiglia(art.30 Cost.).

29. Formazioni sociali, poteri privati e libertà del terzo- Le libertà individuali possono subire minacce all'interno della formazione sociale cui appartengono, ma anche da parte di soggetti terzi rispetto ad essa. L'ordinamento interviene per salvaguardare i diritti contro le sopraffazioni delle formazioni sociali, eliminando alcune immunità proprie della PP.AA. e affermando i principi di libertà, uguaglianza e imparzialità.***30. Il diritto alla riservatezza-*** Nella società tecnologica in cui viviamo, esistono strumenti che non consentono all'uomo di vivere a pieno della sua riservatezza.

This document is available free of charge on StuDocu.com

Le difese che l'ordinamento appresta a fronte di ciò consistono essenzialmente nelle garanzie costituzionali. Anche se parte della dottrina nega che tale diritto sia previsto nella Cost. Sicuramente questo diritto trova tutela negli artt. 2 e 3 Cost.

Capitolo II-LE AUTONOMIE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

1. Costituzione italiana e formazioni sociali- La Costituzione(come peraltro molte altre Carte fondamentali contemporanee nate dal travaglio del secondo conflitto bellico e intente ad operare una ricostruzione della società politica),dà ampio spazio alle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'uomo,e segna,di fatto,il trapasso dal modello politico liberale chiuso nel dualismo Stato – individuo ad un sistema aperto di collegamenti,che proprio nelle formazioni sociali rinviene il più idoneo trait d'union di autorità e libertà. L'intermediazione delle formazioni sociali fra apparato e cittadino dunque,prima ancora che essere un fatto costituzionalmente rilevate,assume il più profondo significato di un diverso moto di concepire ed esercitare la sovranità,per un ordinamento che voglia essere democratico nel senso più autentico e vero del termine. La peculiare nota distintiva rispetto alle democrazie formali dell'Ottocento delle democrazie sostanziali dei regimi attuali sta quindi proprio nella sostituzione della visione liberale della sovranità dall'alto con la concezione di una sovranità dal basso,di cui il pluralismo sociale è appunto componente necessaria.

2. La famiglia. La famiglia è il nucleo essenziale della società,nonché la formazione sociale primigenia in cui si svolge la personalità dell'uomo. Ora,si rivengono specificamente tre articoli (29,30 e 31)relativi alla famiglia,ma anche da altre norme emerge chiaramente l'interesse e l'attenzione dedicativi dal Costituente.
La famiglia quindi,come ogni formazione sociali di rilevanza costituzionale,è stata senza dubbio oggetto di una graduale evoluzione,ma con il divenire storico la famiglia non ha mai cessato di costituire un ideale parametro di riferimento sociale né ha subito uno svuotamento della propria indefettibile funzione nell'ambito di una qualsivoglia comunità. Proprio per questo motivo si riconosce la rilevanza costituzionale della famiglia,intesa come "societas naturalis"(società naturale).
In merito a tale evoluzione storica,il codice civile del '42 offriva ancora una visione di una famiglia patriarcale,fortemente gerarchizzata con al vertice il pater familias. Più ancora che quella dei figli,la posizione della moglie(tenuta a seguire il marito "dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza",così come ex art.144 del vecchio codice,e ad obbedirgli in cambio del mantenimento),era di stampo chiaramente ottocentesco. A porre rimedio a questa situazione patrimonialistica della "donna-res",che sviliva le più profonde qualità spirituali del matrimonio,si è provveduto solo nel 1975 con la RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA,che fa in gran parte dato attuazione alle indicazioni costituzionali.
Fondamento della famiglia è anzitutto il MATRIMONIO,anche se ad oggi va facendosi strada la tendenza a tutelare(soprattutto sotto il profilo economico)le situazioni giuridiche e i rapporti fondati sulla convivenza MORE UXORIO,ossia la c.d."FAMIGLIA DI FATTO".Il vincolo creativo della famiglia ha comunque sia carattere legale,ed è pertanto costituzionalmente rilevante se legittimamente

costituito(c.d."MATRIMONIO CIVILE"),sia se accompagnato sia se privo di riconoscimento religioso. Ci si è chiesti,alla base dei principi costituzionali,se il matrimonio debba essere necessariamente indissolubile. Il riferimento al matrimonio civile(e non anche a quello religioso)indurrebbe a ritenere che non sussistono ostacoli costituzionali all'ammissibilità del divorzio:quest'ultimo è stato introdotto con la legge 1 dicembre 1970 n.808(detta,dal nome dei primi firmatari del progetto,Fortuna-Baslini),ora modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, relativa per l'appunto allo scioglimento del matrimonio civile e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La legge,impugnata innanzi alla Corte costituzionale per contrasto con l'art.7 Cost.è stata fatta salva dalla Corte stessa(sent.n.169 del '71,n.176 del '73 e n.99 del '76)ed ha anche ottenuto il consenso popolare (con il referendum nel 1974,in occasione del quale i NO all'abrogazione della legge superarono il 59%dei voti validi). Ora,il matrimonio è "ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi",con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità famigliare(art.29 comma II). Se è dunque vero che la famiglia è fondata sul matrimonio come comunione spirituale dei coniugi, il matrimonio è a sua volta ordinato dall'esigenza primaria dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,che tollera solo quei limiti predisposti a tutela dell'unità della famiglia. In particolare,quanto all'eguaglianza giuridica,la legge 19 maggio del 1975 n.151 ha ampiamente riformato la disciplina legislativa previgente: sostituendo la POTESTA' MARITALE sui figli con la POTESTA' CONIUGALE; affermando il principio della CONDUZIONE PARITARIA,da parte di entrambi i coniugi,del governo familiare; istituendo il regime patrimoniale della COMUNIONE DEI BENI e ristrutturando il diritto successorio in modo più favorevole al coniuge superstite. Quanto invece all'eguaglianza morale dei coniugi,pure a seguito della riforma,essa necessita ancora di tutela e di effettiva concretizzazione. L'eguaglianza morale mira in primo luogo a proteggere la pari dignità personale dei coniugi,e pertanto ad evitare eventuali tentativi di umiliazione e spersonalizzazione di un coniuge da parte dell'altro,quali purtroppo alle volte si riscontrano,per lo più a carico della donna. La peculiare genericità del relativo precetto costituzionale ne rende tuttavia particolarmente gravosa l'effettiva realizzazione. Nonostante alcuni interventi legislativi,la parità tra uomo e donna non può dirsi ancora pienamente raggiunta,soprattutto per la persistenza di forme di discriminazioni,dirette e indirette. Un passo in avanti in questa direzione è stato però compiuto con le leggi n.125 del 1991 e n.215 del 1992 che hanno introdotto una normativa organica in materia di "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".Tali leggi spostano l'applicazione del principio di parità fra uomo e donna nel lavoro dal terreno dell'uguaglianza formale a quello dell'uguaglianza sostanziale(anche se permangono ancora motivate ragioni di insoddisfazione).Le leggi sono state modificate,tra l'altro,dal D.Lgs 30 maggio 2005 n.145,con il quale è stata data attuazione alla direttiva comunitaria in materia di parità di trattamento tra uomini e donne,per quanto riguarda l'accesso al lavoro,alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. Infine,molte delle disposizioni contenute nelle leggi sopra citate sono state raccolte nel D.Lgs.n.198 del 2006(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). La

This document is available free of charge on StuDocu.com

Costituzione,se da un lato si preoccupa della condizione familiare della donna,non trascura però quella dei figli. A tal proposito,spetta ad entrambi i genitori il diritto-dovere di "mantenere,istruire ed educare i figli,anche se nati fuori del matrimonio"(art.30 comma I). Si tratta di un diritto-dovere sanzionabile penalmente e civilmente in caso di inadempienza,tant'è che la stessa Costituzione assegna alla legge di provvedere "nei casi di incapacità dei genitori a che siano assolti i loro compiti"(art.30 comma II).I genitori peraltro,pur vincolati ad assolvere questi doveri,sono al tempo stesso liberi circa le modalità e i tipi di istruzione ed educazione,ma non possono ad es.venir meno all'impegno,quanto all'istruzione,di assicurare ai figli la frequenza(gratuita)alla scuola dell'obbligo. D'altro canto,la rilevanza sociale di questa disposizione è di immediata evidenza,essendo l'educazione familiare presupposto necessario(e parte integrante)della complessiva educazione civica,che è fonte inesauribile di progresso morale e materiale dello Stato. Inoltre, l'educazione(come istruzione)dei figli deve procedere secondo le naturali inclinazioni di questi ultimi,in modo che essi possano,anche nella famiglia(e quindi nella società in genere)esplicare in pieno la propria personalità e non vedere frustrate le proprie capacità. A proposito invece della prole nata al di fuori del matrimonio(PROLE NATURALE),la Costituzione aggiunge che a quest'ultima è per legge assicurata "ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima"(art.30 comma III).La stessa legge n.151 del 1975 aveva ammesso la possibilità di riconoscimento dei figli naturali,anche se generati in costanza di matrimonio,ed ha inoltre modificato in meglio le norme del codice in materia successoria. Sempre con riguardo alla famiglia,la Repubblica si impegna in definitiva ad agevolare "con misure economiche ed altre provvidenze la formazione stessa della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,con particolare riguardo alle famiglie numerose"(art.31 comma I) e di proteggere "la maternità,l'infanzia e la gioventù,favorendo gli istituti necessari a tal scopo"(art.31 comma II),in modo che sia assicurata alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa(art.36 comma I).

3. La scuola- Direttamente collegata alla famiglia è la formazione sociale scuola;non a caso,nella sistematica costituzionale relativa ai rapporti etico-sociali,essa segue quasi immediatamente la famiglia. Il processo ideale(e cronologico)di formazione intellettuale e spirituale del cittadino infatti si svolge naturalmente dalla famiglia alla scuola. In particolare quest'ultima assolve al compito,fondamentale,di preparare culturalmente l'individuo,in modo tale che questi possa inserirsi con un'idonea preparazione di base nel mondo del lavoro. Proprio nella necessità dell'intermediazione fra famiglia e lavoro deve rinvenirsi la ratio della rilevanza costituzionale di questa formazione:la scuola infatti è innanzitutto un imprescindibile strumento di elevazione spirituale dell'uomo e di progresso civile,nonché produttrice di benefici di natura economica,che derivano,sia pur indirettamente,ad ogni società composta di lavori culturalmente preparati(secondo quella che si configura quindi come una vera e propria FUNZIONE SOCIALE della scuola). Proprio come garanzia di tale funzione sociale va quindi intesa la disposizione contenuta nell'art.34 II comma Cost.,secondo cui l'istruzione inferiore,impartita per almeno 8 anni,è

obbligatoria:questo è infatti il grado minimo d'istruzione socialmente necessario e come tale assolutamente inderogabile. La Costituzione però prevede anche le condizioni per superare questo primo risultato minimo assicurando(con borse di studio,assegni alle famiglie ed altre provvidenze)ai "capaci e meritevoli" il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi anche se privi di mezzi,come sancito dall'art.34 commi III e IV. Pertanto,se è vero che "la scuola è aperta a tutti"(art.34 comma I),dopo il periodo formativo iniziale di istruzione inferiore,per tutti obbligatorio,i capaci e i meritevoli sono messi in condizione di proseguire gli studi per mezzo di provvidenze economiche pubbliche. Il fatto che queste forme di contributi vengano attribuite solo ai capaci e ai meritevoli "privi di mezzi" non costituisce ad ogni modo fonte di discriminazione fra i cittadini,come pure potrebbe sembrare ad una lettura superficiale della disposizione in esame,né dunque costituisce un'implicita violazione del principio di eguaglianza,ma anzi appare come vera e propria specificazione del principio medesimo,essendo dettata proprio dall'esigenza di intervenire a favore di quelle categorie di cittadini di fatto "disuguali" per ripristinare fra essi e l'altra parte dei cittadini condizioni di sostanziale parità anche sotto quest'aspetto. La sola capacità non è sufficiente,giacchè è possibile riscontrare capacità intellettuale anche in capo a persone non bisognose,né allo stesso modo è da solo sufficiente il merito:occorre quindi il cumulo di entrambe le qualità,della capacità(come attributo intellettuale)e del merito(come attributo spirituale). All'art.34 Cost. è stata data attuazione con la legge n.390 del 1991,che prevede inoltre interventi dello Stato,delle Regioni e delle Università in tal senso:in particolare,spetta allo Stato di stabilire l'indirizzo,il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari;alle Regioni di garantire l'accesso ai servizi ed alle provvidenze economiche,di assegnare le borse di studio ecc.;alle Università di concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi LE SCUOLE NON STATALI: In merito alla struttura interna della scuola,ne va anzitutto posta in evidenza la natura sostanzialmente PLURALISTICA: la Costituzione cioè non impone un unico tipo o modello pedagogico,vietando anzi il monopolio statale nel campo dell'istruzione;enti e privati hanno infatti il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato(art.33 comma III),con l'unico obbligo di assicurare un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali(art.33 comma IV),prescrivendo soprattutto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale(art.33 comma V). Peraltro ad oggi l'istituzione di scuole private non è più subordinata ad un'autorizzazione discrezionale(come invece prescriveva la legge del '42,dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale),né sono previsti pubblici finanziamenti a favore di questi istituti,fatto questo che seppure per un certo verso può valere a scoraggiare il pluralismo scolastico,per un altro si giustifica con l'esigenza di salvaguardare in primis la libertà d'insegnamento(art.33 comma I),che risulterebbe in tal modo inevitabilmente compromessa dai controlli pubblici che si accompagnerebbero automaticamente ai finanziamenti. Il pluralismo viene inoltre costituzionalmente favorito con l'attribuzione alle istituzioni di alta cultura,alle

This document is available free of charge on StuDocu.com

università e alle accademie del diritto di farsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato(art.33 ultimo comma).

4. Le confessioni religiose- A norma dell'art.8 comma I Cost.,tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge;si tratta di una norma di rottura nei confronti del passato,in quanto fa fede sull'avvenuto superamento del confessionismo di stampo ottocentesco,sostituito da una concezione del fenomeno religioso costituzionalmente rilevante come tale,senza che si possano discriminare e stabilire gradi diversi di libertà a seconda dei diversi culti. In questo senso,l'art.8 non può essere inteso in tutta la sua portata se non letto in connessione inscindibile con la libertà di religione sancita dall'art.19,con la fondamentale differenza che,mentre l'art.19 riguarda una libertà dell'UOMO come tale,professata sia in forma individuale sia in forma associata,l'art.8 invece concerne l'uguale libertà del GRUPPO CONFESSIONE RELIGIOSA,inteso in senso istituzionale. Dopo l'art.8,la libertà della confessione cattolica non è né può essere qualitativamente diversa dalla libertà delle confessioni acattoliche,anche se indubbiamente il culto cattolico conserva,forte dell'appartenenza ad esso della larga maggioranza degli italiani,una peculiare posizione rispetto agli altri,che tuttavia non vale comunque a giustificare,come ha rilevato la Corte costituzionale in alcune sue pronunce,discriminazioni che si basino soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose. LA CONFESSIONE CATTOLICA: La storia dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica non si è sempre svolta secondo un'identica linea evolutiva:mentre lo Statuto albertino esordiva enunciando solennemente il principio secondo cui "La religione cattolica,apostolica e romana è la sola religione dello Stato,e gli altri culti esistenti sono tollerati conformemente alle leggi",che instaurava inequivocabilmente una situazione di privilegio a favore del culto cattolico e a svantaggio di altri culti(appena tollerati),negli anni immediatamente successivi i rapporti fra autorità politica e Papato si incrinarono notevolmente soprattutto a seguito dell'occupazione di Roma che diede vita alla c.d. "questione romana".Tant'è che le leggi delle guarentigie(1871)con le quali lo Stato italiano pretese di disciplinare unilateralmente le prerogative del Papa e le sue relazioni con la Chiesa non furono mai formalmente accettate dal Pontefice,che anzi manifestò apertamente il proprio dissenso col divieto rivolto ai propri fedeli di partecipare alle elezioni politiche e ad altre pubbliche manifestazioni("NON EXPEDIT").La conciliazione si ebbe poi dopo ben 50 anni di aperti contrasti,con la stipulazione,l'11 febbraio 1929,dei PATTI LATERANENSI,che ancora oggi regolano(seppur modificati)in via esclusiva i rapporti fra Stato e Chiesa. I Patti consistono di un: TRATTATO,con cui si pose fine alla questione romana e si costituì lo Stato Città del Vaticano,che si impegnò a riconoscere il nascente Stato italiano; CONVENZIONE FINANZIARIA,che prevedeva il pagamento,da parte dello Stato italiano,di un indennizzo versato alla Città del Vaticano a titolo di risarcimento per l'occupazione subita con la breccia di Porta Pia; CONCORDATO,ora modificato dall'Accordo fra la Repubblica italiana e la Santa Sede,firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e dal relativo "PROTOCOLLO ADDIZIONALE". Con l'art.1 del Trattato si riconobbe e

riaffermò il principio statutario della religione di Stato,che sarebbe stato definitivamente superato solo con l'avvento della Costituzione repubblica del '48 e precisamente con l'affermazione,solennemente sancita dall'art.8 comma I,della LIBERTA' DI CULTO. La Costituzione infatti,dopo aver affermato che "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,ciascuno nel proprio ordine,INDIPENDENTI e SOVRANI(art.7 comma I),fa rinvio per la disciplina dei loro rapporti ai Patti suddetti,e conclude nel senso che le modifiche dei Patti,accettate dalla due parti,non richiedono procedimento di revisione costituzionale(art.7 comma II). Tale articolo è stato fatto oggetto di numerosissime dispute dottrinali,occasionate anche da alcune decisioni della Corte,che ha tuttavia assunto,nelle sue varie pronunce in merito,una posizione piuttosto ambigua e indecisa,che invece di sciogliere alcuni nodi interpretativi prodotti dalla formulazione letterale di questa norma costituzionale,ne ha anzi creati di nuovi e di ulteriori. In particolare,in un primo tempo l'interpretazione del secondo comma dell'art.7 era orientata nel senso che il rinvio ai Patti,come fonte regolativa dei rapporti fra Stato e Chiesa,valesse come un'implicita COSTITUZIONALIZZAZIONE delle singole norme pattizie. Quest'opinione è stata in seguito abbandonata dalla dottrina,sulla base di molteplici argomentazioni:si è infatti anzitutto obiettato che,giusta la tesi della costituzionalizzazione,assumendola come tale sarebbe stata comunque necessaria per la modifica dei Patti,la revisione costituzionale anche se la modifica fosse stata bilateralmente voluta e accettata. Inoltre,si è fatto presente come non tutte le norme pattizie disciplinino,per loro natura,una materia costituzionale é sembrato quindi preferibile ritenere che l'art.7 contenga una NORMA SULLA PRODUZIONE GIURIDICA,costituzionalizzando così non le singole norme,ma il c.d. PRINCIPIO CONCORDATARIO fra Stato e Chiesa,per il quale lo Stato sarebbe vincolato a disciplinare bilateralmente i propri rapporti con la Chiesa. Qualora invece l'accordo non fosse raggiungibile,la modifica unilaterale delle norme concordatarie richiederebbe il ricorso alla procedura aggravata prevista dal 138,essendo infatti costituzionalmente illegittima per contrasto con quanto disposto dall'art.7 comma II,per cui le modifiche ai patti non richiedono un procedimento di revisione. Dal canto suo, la Corte costituzionale ha riconosciuto la propria competenza a sindacare i Patti sotto il profilo del loro eventuale contrasto con i PRINCIPI SUPREMI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE,fermo restando che le norme pattizie che non siano in contrasto con detti principi non possono essere oggetto del sindacato da parte della Corte in quanto godono appunto della COPERTURA COSTITUZIONALE dell'art.7. Ora,la locuzione "principi supremi dell'ordinamento costituzionale"è alquanto sibillina,dal momento che ancora oggi non risulta chiaramente cosa siano in concreto questi principi e,nella specie,se si debbano unicamente identificare con i principi fondamentali della Costituzione oppure no,dandone una lettura più ampia e aperta. L'occasione per una maggiore chiarezza nei rapporti fra Stato e Chiesa avrebbe potuto rinvenirsi solo in una revisione del Concordato,che di fatto è avvenuta con l'Accordo(e il relativo Protocollo Addizionale)stipulato fra la Repubblica italiana e la Santa Sede il 18 febbraio 1984,Accordo che è stato raggiunto dopo una complessa vicenda protrattasi per 8 anni,nel corso della quale le parti contraenti avevano formulato numero bozze

This document is available free of charge on StuDocu.com

preliminari. Di quest'Accordo può dirsi che di fatto costituisce un nuovo Concordato(come si deduce dall'art.13,a norma del quale "le disposizioni del Concordato non riportate nell'Accordo sono da considerarsi abrogate"),sebbene tale accordo sia stato reso noto come "Modificazioni al Concordato lateranense",formula questa che seppure forse impropria è valsa a contenere l'Accordo nell'ambito dei Patti lateranensi e a sottoporlo alla stessa disciplina di cui tali Patti godono ai sensi dell'art.7 Cost.,di modo che esso ha conservato la copertura costituzionale di cui godeva l'originario Concordato(secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale). LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA: Anche i rapporti fra Stato e culti acattolici non sempre si sono svolti all'insegna della reciproca comprensione,ma si può dire che negli anni si è assistito ad un lento e progressivo processo di liberalizzazione,giunto a termine con l'entrata in vigore dell'attuale Costituzione. Dalla "tolleranza"dello Statuto albertino verso questi culti si è infatti passati all'AMMISSIONE con la legge del 24 giugno 1929,di poco successiva alla stipulazione dei Patti lateranensi ed approvata nel quadro di una generale e complessiva riconsiderazione del fenomeno religioso. Tuttavia,l'uguale libertà fra fede cattolica e confessionismo di ogni altra natura si è avuta solo con il ripudio della struttura rigidamente accentrata e statualista del regime liberale prima,e fascista poi,e l'affermazione dell'ideologia democratica e pluralista. Solo in questa visione infatti può essere compreso appieno il precetto dell'art.8. L'ultimo comma di questo articolo stabilisce infatti che i rapporti delle confessioni diverse da quella cattolica con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Si è molto discusso in dottrina sulla natura giuridica di tali intese;sostanzialmente le soluzioni proposte sono due:alcuni hanno ritenuto che si tratti di convenzioni di diritto interno,altri invece che le intese in questione siano da parificare ai concordati,quali fonti di diritto esterno(sulla base di una concezione del fenomeno religioso come fenomeno istituzionale originario e quindi non derivato dallo Stato). Le due opinioni convergono ad ogni modo nel fare carico al Parlamento dell'obbligo di rispettare l'intesa nel suo contenuto normativo(Mortati),nel senso che il legislatore non può modificare le clausole concordate.

5. La comunità del lavoro- Fra le varie comunità intermedie previste dalla nostra Costituzione e sulle quali si fonda l'ordinamento pluralista dello Stato,particolare rilievo assumono,insieme ai partiti politici,i SINDACATI,per le funzioni che la Costituzione e le leggi successive hanno loro affidato. Il sindacato è innanzitutto una libera organizzazione di lavoratori(subordinati o indipendenti)o di datori di lavoro avente come fine la tutela degli interessi collettivi degli associati. La nascita storica del sindacato si può far risalire alla metà del secolo scorso,quando la lotta per il salario svelò le condizioni drammatiche in cui versavano i lavoratori,umiliati nella loro dignità e normativamente abbandonati in balìa delle leggi del liberismo economico,per cui il sindacato si caratterizzò da principio,e si caratterizza tutt'oggi,soprattutto come associazione di lavoratori subordinati. Il processo di affrancazione dei lavoratori fu lungo e faticoso,e solo di recente la libertà sindacale si è affermata definitivamente. La Costituzione ha poi affermato il principio del

PLURALISMO SINDACALE,consistente nella possibilità che gli appartenenti alla stessa categoria produttiva si organizzino in più sindacati. L'art.39 comma I infatti dispone che l'organizzazione sindacale è libera,riconoscendo pertanto nel sindacato una manifestazione associativa rientrante nella sfera dell'autonomia privata,che non si esaurisce però nel pluralismo sindacale,ma comprende anche il diritto dei singoli di associarsi o di non associarsi sindacalmente,di associarsi ad una piuttosto che ad un'altra organizzazione sindacale e di recedere,una volta iscritti,qualora lo ritengano opportuno. La stessa Costituzione comunque prevede la possibilità che l'organizzazione sindacale assuma anche rilievo pubblicistico nel momento in cui,tramite la registrazione presso uffici locali o centrali,i sindacati acquistano la personalità giuridica;i sindacati registrati possono,rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia vincolante nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto stesso si riferisce. Unico obbligo è che i loro statuti sanciscano un ordinamento interno a base democratica,prescrivendo l'elettività delle cariche,l'adozione del principio di maggioranza per la validità delle deliberazioni,l'approvazione dei bilanci da parte degli iscritti ecc. Dalle associazioni sindacali semplici si distinguono poi le associazioni sindacali complesse,che sono associazioni di associazioni sindacali,confederazioni o federazioni sindacali,aventi il fine di tutelare gli interessi comuni alle varie categorie di lavoratori o di imprenditori che vi aderiscono;le più significative sono,quanto ai lavoratori,la Confederazione generale italiana del lavoro(CGIL),la Confederazione italiana sindacati lavoratori(CISL) e per i datori di lavoro Confindustria,CONFCOMMERCIO e CONFAGRICOLTURA. Accanto a questi sindacati operano da qualche anno a questa parte i c.d."SINDACATI AUTONOMI",a loro volta raggruppati nella CISAL,presenti soprattutto nel settore dei pubblici servizi. Altro fenomeno recente è dato dalla costituzione in alcuni settori dei pubblici servizi,dei COBAS(comitati di base),sorti per svolgere prevalentemente un'azione rivendicativa sul piano del trattamento economico.
Gli strumenti di cui principalmente si avvale il sindacato per raggiungere i propri obiettivi sono il CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO e lo SCIOPERO. Per quanto riguarda i contratti,i contratti stipulati da sindacati registrati hanno diversa efficacia rispetto ai contratti stipulati da sindacati non registrati,obbligatori solo per gli iscritti a detti sindacati. Si pone poi il problema del rapporto in cui si trovano il contratto collettivo e il contratto individuale di lavoro;al riguardo è ammessa la prevalenza delle clausole del primo su quelle del secondo,a meno che quest'ultimo non disponga più favorevolmente per il lavoratore. Quest'eventualità però è alquanto rara a verificarsi,giacchè di fatto i contratti individuali riproducono il contenuto dei contratti collettivi. Il contratto collettivo inoltre dovrebbe essere stipulato,a norma dell'art.39 comma IV Cost.,dai sindacati registrati,rappresentati unitariamente:tuttavia,l'articolo non ha trovato attuazione fino ad opera,ed esistono seri dubbi che possa trovarla in seguito sia per difficoltà di ordine tecnico sia per l'opposizione politica degli stessi sindacati. In questo stato di cose,l'unico contratto collettivo che possa oggi stipularsi è quello c.d. di "DIRITTO COMUNE"(vale a dire secondo le norme contenute nel libro IV delle obbligazioni del codice civile)che ha

This document is available free of charge on StuDocu.com

pertanto efficacia limitata agli iscritti ai sindacati stipulanti,efficacia che tuttavia si estende di fatto anche ai non iscritti. Un particolare regime vige invece per i contratti collettivi per il pubblico impiego(riguardanti il personale civile dello Stato,delle Regioni a Statuto ordinario,delle Province e dei Comuni,degli enti ospedalieri e degli enti parastatali)che,limitatamente ad alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego,e sulla base degli accordi sindacali sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica ed hanno quindi efficacia ERGA OMNES.
IL DIRITTO DI SCIOPERO: Quanto allo sciopero,l'art.40 Cost. dispone che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. La ratio del riconoscimento costituzionale di questo diritto sta nella constatazione che,nel conflitto fra imprenditori e lavoratori,questi ultimi rappresentano la parte economicamente più debole alla quale appunto la Costituzione ha attribuito tale diritto come strumento per ristabilire l'equilibrio nella lotta sindacale. Per "sciopero" si intende quindi ogni astensione collettiva dal lavoro promossa dai sindacati e posta in essere dai lavoratori subordinati,avente per finalità quella di ottenere miglioramenti della situazione economica e delle condizioni di lavoro rispetto a quelle disciplinate nel contratto collettivo.In questo senso,il diritto di sciopero trova fondamento oltre che nell'art.40 anche nell'art.41 comma II,secondo il quale l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà o alla dignità umana".
La dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono che il diritto di sciopero sia un diritto soggettivo immediatamente azionabile ed hanno pertanto rigettato la tesi della programmaticità dell'art.40,interpretando la norma in questione nel senso che le leggi regolatrici dello sciopero potranno disciplinare esclusivamente le MODALITA' di esercizio del diritto. Tuttavia il diritto di sciopero incontra limiti ben precisi nel momento del suo esercizio:nella specie,l'esercizio del diritto di sciopero non è consentito ai militari e alla polizia di Stato,in quanto l'esercizio dello stesso potrebbe pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
In consonanza con lo spirito dell'ordinamento corporativo,vari articoli del codice penale consideravano illecito lo sciopero. La Corte costituzionale ha però dichiarato l'illegittimità dell'art.502 codice penale,che sanciva l'illiceità della serrata e dello sciopero per fini contrattuali. Per SERRATA si intende la temporanea sospensione dal lavoro disposta dal datore di lavoro al fine di fare pressione sui lavoratori per motivi contrattuali o per indurli a rinunciare ad agitazioni promosse per ottenere miglioramenti economici,ed è stata riconosciuta penalmente lecita dalla Corte costituzionale e quindi equiparata,sotto il profilo della garanzia costituzionale,allo sciopero:è però da ritenere che la Costituzione contenga un tacito divieto della serrata e quindi un eventuale intervento del legislatore diretto a sanzionare penalmente la serrata sarebbe costituzionalmente legittimo. La Corte costituzionale ha inoltre tracciato una distinzione tra sciopero e serrata nella sen.n.222 del 1975,con la quale è stato tra l'altro riconosciuto il diritto di sciopero dei pubblici impiegati,compresi i magistrati,con riferimento però più alla loro qualità di pubblici dipendenti che alla funzione da essi esercitata. Infine la Corte ha affermato in un'altra sua pronuncia il principio che,senza in nulla coartare la libertà del lavoratore che abbia inteso

scioperare,è legittimo sostituire temporaneamente i pubblici dipendenti che,scioperando,interrompono un servizio essenziale per la collettività. Quanto poi alle forme c.d."abnormi"di sciopero(bianco,a singhiozzo,a scacchiera ecc.)è da rilevare che la giurisprudenza,dopo un'iniziale posizione contraria,ne ha adesso riconosciuto la legittimità,a condizione che non venga arrecato pregiudizio al diritto alla vita e all'incolumità personale e alla produttività delle aziende. In particolare,l'esercizio del diritto di sciopero è adesso disciplinato dalla legge n.146 del 1990,come modificata dalla legge n.83/2000 per quel che riguarda i servizi pubblici essenziali. L'art.1 di detta legge dispone che sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,costituzionalmente tutelati alla vita,alla salute,alla libertà e alla sicurezza,alla libertà di circolazione,all'assistenza e alla previdenza sociale,all'istruzione e alla libertà di comunicazione. Nell'ambito di questi servizi il diritto di sciopero deve essere esercitato nel rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili,con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro;sono pertanto previste sanzioni disciplinari e amministrative pecuniarie per i lavoratori(pubblici e privati)che,astenendosi dal lavoro,non garantiscono l'erogazione di tali prestazioni. A lungo si è discusso in merito alla legittimità dello SCIOPERO POLITICO. A tal proposito si è assistito ad una notevole evoluzione giurisprudenziale:in passato infatti lo sciopero per fini diversi da quelli economico-contrattuali era stato ritenuto lecito,ma dopo l'"autunno caldo"del 1969 lo sciopero politico è stato considerato,più che una libertà costituzionalmente garantita,un vero e proprio diritto. Dal canto suo,la Corte costituzionale con due importanti pronunce del 1974 ha affermato con la prima la legittimità (ex art.40 Cost.)dello sciopero "non solo quando sia volto a finalità retributive ma anche quando,più in generale,esso venga proclamato in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori,e con la seconda ha dichiarato legittima la punizione dello sciopero politico laddove questo sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale o quando ostacoli il libero esercizio dei diritti e dei poteri nei quali viene ad esprimersi la sovranità popolare. LO STATUTO DEI LAVORATORI(legge 20 maggio 1970,n.300):vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;tutela la salute e l'integrità fisica del lavoratore;attribuisce ai lavoratori studenti il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;vieta la costituzione dei c.d."SINDACATI GIALLI" o "SINDACATI DI COMODO",sostenuti e finanziati dai datori di lavoro al fine di controbattere la libertà sindacale dall'interno della fabbrica;prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore il cui licenziamento sia stato dichiarato inefficace con una sentenza o annullato perché intimato senza giusta causa o giustificato motivo o ancora dichiarato nullo. LA POSIZIONE DEI SINDACATI NEL SISTEMA: La posizione dei sindacati nel sistema rispetto all'originario disegno costituzionale risulta alquanto potenziata,tenuto conto che i sindacati sono andati via via erodendo ambiti di azioni tradizionalmente riservati in via esclusiva ad altri soggetti politici(in primis i partiti politici). Questo stato di cose è stato favorito soprattutto dall'assenza

This document is available free of charge on StuDocu.com

della legge sindacale,prevista dall'art.39 Cost.,alla cui approvazione gli stessi sindacati per primi si sono tenacemente opposti,giacchè tale legge avrebbe comportato controlli statali sulla loro organizzazione interna e quindi,di riflesso,sulla loro attività. Si è dunque assistito ad un graduale inserimento dei sindacati nell'area del potere politico:ciò ha portato ad una linea di politica sindacale che è andata via via sviluppandosi soprattutto a partire dal 1968-69 nella direzione di una visione globale degli interessi della classe lavoratrice.
Questa nuova strategia sindacale ha posto il problema dei rapporti tra sindacati e partiti,che vede i primi tendere ad affermare sempre più la loro autonomia nei confronti dei secondi(basti pensare all'incompatibilità fra cariche sindacali e mandato parlamentare). In merito alla distinzione fra questi organismi e i partiti,va detto che è totalmente diverso il fine istituzionale perseguito:essenzialmente socio-economico per i sindacati,socio-politico per i partiti;in altri termini i sindacati non guardano alla realtà sociale nella sua pluralità e inquadrandola invece soprattutto in una visione economica,i partiti hanno invece di tale realtà una visione globale(che comprende quindi anche le strutture e i rapporti economici,ma che si arresta di fronte alla riserva sindacale di contrattazione collettiva e di sciopero).Sul piano strumentale poi,mentre il programma dei partiti diviene indirizzo politico allorchè essi conquistano e compongono la maggioranza in Parlamento,i sindacati invece non possono gli strumenti giuridici atti per realizzare le loro scelte di politica economica sul piano dello Stato-governo. Tuttavia, l'azione sindacale ha avuto modo di esplicarsi ampiamente sia ricorrendo agli strumenti della contrattazione collettiva e dello sciopero,sia mediante la tessitura di una complessa e fitta rete di rapporti con i poteri dello Stato(basti pensare alla presenza dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale in organi di Stato come il CNEL).

6. I partiti politici- Fra tutte le formazioni sociali che prendono parte attivamente a determinare la realtà politica a livello di Stato-apparato,peculiare e preminente posizione occupa il PARTITO POLITICO come associazione di individui accomunati da una medesima visione "di parte"degli interessi generali di una data comunità statale. Elementi costitutivi del partito sono quindi,in primo luogo,la pluralità di persone,l'organizzazione,il patrimonio e lo scopo(o ideologia in senso lato).In particolare,lo scopo richiede necessariamente l'esistenza di un'organizzazione stabile,idonea al perseguimento e alla realizzazione dello scopo medesimo. Questa caratterizzazione complessa del partito tuttavia non si è sempre storicamente avuta:prescindendo dai periodi storici in cui i partiti erano addirittura considerati illegittimi(come nello Stato di polizia)c'è da dire che durante il regime politico liberale si è avuto un atteggiamento per lo più agnostico,o di mera tolleranza dello Stato nei loro confronti,di modo che i partiti costituirono,a conti fatti,nient'altro che meri raggruppamenti parlamentari(come la Destra e la Sinistra storica in Italia),privi di una reale e costante presenza nel Paese. Quest'ultima si ebbe solo in epoca relativamente recente,a seguito dell'estensione del suffragio e della conseguente trasformazione del partito da associazione elitaria in movimento politico di massa,cui fu coevo il suo riconoscimento costituzionale. Ad oggi bisogna pertanto

distinguere tra una posizione del partito come STRUMENTO "PRIVATISTICO"indispensabile per la determinazione della politica nazionale e al tempo stesso una vera e propria incorporazione del partito nello Stato,che vede l'attribuzione al partito della qualità di organo di determinazione della volontà statale. Questa bipartizione trova grosso modo riscontro a seconda dei regimi politici cui si applica,essendo la prima più tipica degli Stati democratici occidentali,la seconda degli Stati autoritari e socialisti. Infatti mentre nelle democrazie occidentali il sistema politico è fondato sulla molteplicità dei partiti(BIPARTISMO o PLURIPARTITISMO),nei residui Paesi dell'area socialista(e negli Stati autoritari in generale)la natura del partito come organo statale si accompagna ad un sistema monopartitico(c.d."STATI A PARTITO UNICO").Nella specie,negli Stati sostanzialmente bipartitici(Gran Bretagna ed USA)si registra sostanzialmente l'alternanza al potere dei sue partiti numericamente più consistenti(quasi sempre uno conservatore,l'altro progressista),c.d."SWING OF PENDULUM";laddove invece nei regimi pluripartitici è necessaria la formazione di governi di coalizione,a formula compromissoria,che,per ciò solo,non sempre riescono ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Questa situazione,che pure di per sé è già precaria,viene poi ulteriormente aggravata laddove,come in Italia,la proliferazione all'interno dei partiti di numerose fazioni e correnti(c.d."CORRENTISMO")contribuisce a minare ab intra la stabilità delle coalizioni di governo. La disciplina costituzionale dei partiti politici è ufficialmente sancita dall'art.49 Cost.,per la quale tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Tale disposizione costituisce chiaramente un'evidente specificazione dell'art.18(libertà di associazione):non si tratta pertanto di un diritto in senso stretto,ma di una semplice libertà di associazione,di cui godono tutti i cittadini nei confronti dei partiti politici. Non sembra quindi che si possa pretendere l'iscrizione al partito politico,giacchè proprio la caratterizzazione di questo(rispetto alle altre formazioni sociali)quale associazione a scopi generali comporta l'attribuzione al partito della facoltà di operare una selezione fra coloro che chiedono l'iscrizione:per gli stessi motivi,bene può il partito espellere l'iscritto che si dimostri non più in linea ideologica con esso.
Secondo quanto sancito dall'art.98 comma III Cost. inoltre,il legislatore può stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti per alcune categorie di cittadini(i magistrati,i militari di carriera in servizio attivo,i funzionari e gli agenti di polizia,i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero).
Per quanto riguarda il DIRITTO DI CONCORRERE A DETERMINARE LA POLITICA NAZIONALE,bisogna ancora una volta distinguere gli Stati monopartitici,in cui(per l'incorporazione del partito fra gli organi statali,fino al punto che esso costituisce il centro motore di tutte le pubbliche funzioni)effettivamente solo ai cittadini politicamente attivi,in quanto iscritti al partito,è dato determinare l'indirizzo politico. Mentre negli Stati pluripartitici nei quali i partiti conservano la caratteristica di associazioni di fatto,non può essere loro riconosciuto il monopolio della determinazione della politica nazionale. Ma la risposta negativa alla domanda se solo i cittadini iscritti ai partiti determinano la politica nazionale trova la sua più

This document is available free of charge on StuDocu.com

autorevole conferma soprattutto nella specificazione dell'art.49,per cui l'associazionismo politico(pluralismo politico)costituisce un valore costituzionalmente ineliminabile:la tendenza a considerare cittadini pleno iure solo gli iscritti ai partiti di fatti stride con lo spirito del pluralismo politico della nostra Costituzione in maniera vistosa,e viola il diritto dei non iscritti a concorrere anch'essi a determinare la politica nazionale. Per cui hanno diritto a concorrere a determinare la politica nazionale anche altre forze politico-sociali. Questo concorso alla determinazione della politica nazionale deve però avvenire con "METODO DEMOCRATICO":l'applicazione del principio democratico ai partiti acquista quindi non solo una portata esterna(relativamente alla democraticità dell'attività svolta dal partito),ma anche un'interna(relativamente alla democraticità dell'organizzazione interna del partito stesso). Il che introduce il problema dei controlli dello Stato sui partiti,che pure sarebbero necessari ma che di fatto risultano scarsamente efficaci(controllo che non riguarderebbe comunque sia l'ideologia del partito ma appunto la democraticità interna dello stesso),al fine di evitare specialmente il c.d."ESTREMISMO POLITICO". Da molti anni si dibatte in Italia sull'opportunità di stabilire un finanziamento pubblico ai partiti politici:nel 1974 era stata emanata una legge che prevedeva tale finanziamento;tuttavia essa è stata parzialmente abrogata mediante referendum popolare,nel 1993. Nel 1997 era stata approvata un'ulteriore legge,a sua volta abolita da un'ulteriore legge nel '99,che ammette soltanto il rimborso delle spese elettorali(esteso peraltro anche ai comitati promotori di referendum dichiarati ammissibili dalla Corte)ed alcune agevolazioni fiscali. Ad oggi,in Italia persiste una certa reticenza al riconoscimento dei partiti come associazioni di diritto privato,per cui la loro posizione giuridica resta sui generis e non del tutto soggetta alle regole di diritto comune.

7. Le minoranze linguistiche- Fra le formazioni sociali rientrano anche le minoranze linguistiche,che la Repubblica tutela con apposite norme(art.6 Cost.).Tale tutela ha trovato attuazione negli Statuti,nonché nelle relative norme di attuazione,di alcune Regioni in cui vivono gruppi di alloglotti e in particolare negli Statuti del Trentino Alto-Adige(per la tutela delle minoranze di lingua tedesca e ladina),del Friuli(lingua slovena)e della Valle d'Aosta(lingua francese).Le disposizioni più importanti concernono: la tutela della lingua materna(per cui la lingua francese in Valle d'Aosta e la lingua tedesca nel Trentino sono parificate alla lingua italiana);la salvaguardia delle caratteristiche etnico-culturali dei gruppi linguistici e dell'ordinamento scolastico,che prevede l'insegnamento bilingue(nel Trentino anche in ladino). Accanto a queste minoranze esistono tuttavia in Italia altri gruppi alloglotti che non godono di alcuna tutela,in specie le minoranze di lingua albanese(presenti soprattutto in alcune regioni dell'Italia meridionale e insulare),greca,sarda,serbo-croata.

CAPITOLO TERZO- LE AUTONOMIE DEGLI ENTI TERRITORIALI

SEZIONE I- LA FORMAZIONE E LA NATURA GIURIDICA DELLE REGIONI

1. Il problema delle autonomie regionali- Le Regioni sono state istituite in Italia con la Costituzione repubblicana del 27 dicembre 1947,il cui Titolo V della Parte II("Le

Regioni,le Province,i Comuni"),successivamente riformato dalla legge cost.18 dicembre 2001 n.3 disciplina le linee essenziali dell'ordinamento dei nuovi enti e attribuisce alla Sicilia,alla Sardegna,al Trentino-Alto Adige,al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta forme e condizioni particolari di autonomia secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale. A norma dell'art.131 Cost.sono state costituite 20 Regioni autonome,compresa la Regione Molise che,staccata dagli Abruzzi,è stata anch'essa costituita in Regione autonoma con la legge costituzionale 27 dicembre 1963,n.3. L'esigenza di un decentramento dello Stato e quella di assegnare determinate funzioni tradizionalmente appartenenti allo Stato ad enti da questo distinti trovano la loro radice,oltre che in considerazioni di ordine prettamente tecnico-giuridico,in alcuni complessi problemi della società italiana che lo Stato,con la sua amministrazione rigidamente accentrata,non era riuscito a risolvere. La caduta del fascismo e della monarchia e la volontà popolare,espressa formalmente con il voto nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 di dar vita ad un nuovo ordinamento costituzionale,avevano riproposto con rinnovato vigore questi problemi all'attenzione dell'opinione pubblica e dei partiti,per cui l'Assemblea costituente non potè non tenere in conto una realtà che le si imponeva dall'esterno e che occorreva recepire nelle strutture normative dello Stato repubblicano. Gli aspetti di questa realtà erano vari,ma alla base troviamo essenzialmente il fattore geografico(la frammentazione della penisola in realtà locali e territoriali profondamente diverse le une dalle altre)e il fattore storico(le molte vicende politiche che nel corso dei secoli hanno travagliato l'Italia,sottoponendola a dominazioni straniere e spezzettandola in numerosi Stati):questi due fattori erano stati a loro volto causa di notevoli squilibri di natura economica e sociale,che il trascorrere del tempo non era riuscito a sanare(basti ricordare le condizioni dell'Italia meridionale e la "questione meridionale"che interessava milioni di italiana che non riuscivano a trovare nella loro terra la possibilità di condurre un'esistenza libera e dignitosa).
Il problema delle autonomie regionali fu affrontato globalmente dall'Assemblea costituente:nonostante la maggioranza dei partiti in essa rappresentati fosse favorevole alla creazione dei nuovi enti,i dibattiti su questo tema furono spesso vivaci e non mancarono radicali prese di posizione nettamente contrarie. Il compito di redigere un progetto di ordinamento regionale fu affidato in seno alla seconda Sottocommissione dell'Assemblea (costituita nell'ambito della Commissione del 75 alla quale spettava di elaborare lo schema della Costituzione),ad un Comitato di redazione composto da 10 deputati e presieduto dall'onorevole Ambrosini. Il Comitato presentò nella seconda Sottocommissione il progetto elaborato,accompagnato da una relazione che prevedeva la Regione quale ente intermedio fra lo Stato ed i Comuni e le assegnava il compito di valorizzare le forze locali nel quadro e nell'interesse dello Stato in generale. Venne quindi a crearsi la Regione,quale zona intermedia ed indispensabile fra la Nazione e i Comuni.
Al dibattito in Assemblea sull'ordinamento regionale parteciparono deputati di ogni partito e corrente.Alla fine,fra le opposte tesi dei fautori di un semplice decentramento amministrativo e dei sostenitori di un ordinamento federale,si impose la soluzione intermedia dei regionalisti unitari:le norme sull'ordinamento regionale

This document is available free of charge on StuDocu.com

previste nel progetto di Costituzione furono approvate(sia pure con alcuni emendamenti)ed entrarono a comporre il Titolo V della nuova Costituzione repubblicana.

2. I caratteri dell'autonomia regionale- Ai preesistenti enti territoriali,Province e Comuni,si aggiunse in tal modo la Regione,quale ente intermedio fra lo Stato e le collettività minori locali. L'autonomia regionale va ricompresa nel concetto più ampio di autonomia,che sta ad indicare,secondo la classica definizione del Mortati "la libertà di determinazione consentita ad un soggetto". E' tuttavia da precisare che non esiste un concetto unitario di autonomia:il termine infatti si specifica in più concetti. Del resto,l'impiego che di esso fa la Costituzione avvalora questa molteplicità di significati,e infatti nell'art.5 si parla di "autonomie locali";nell'art.33 di "ordinamenti autonomi"(nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato),"delle istituzioni di alta cultura,università ed accademie";nell'art.104 della magistratura come ordine autonomo oltre che indipendente da ogni altro potere;nell'art.114 dei Comuni,delle Province,delle Città metropolitane e delle Regioni come "enti autonomi con propri statuti,poteri e funzioni";nell'art.116 di forme e condizioni particolari di autonomia attribuite alla Regioni a Statuto speciale;nell'art.119 di "autonomia finanziaria"dei Comuni,delle Province,delle Città metropolitane e delle Regioni. Sembra ad ogni modo che i concetti di autonomia possano ricondursi essenzialmente a tre: AUTONOMIA NORMATIVA intesa, secondo la definizione del Giannini,come "potestà attribuita in ordinamenti giuridici statali a enti diversi dallo Stato di emanare norme costitutive dello stesso ordinamento giuridico statale":in questo senso,Regioni,Province e Comuni sono "enti autonomi",anche se non sono gli unici soggetti dotati di un'autonomia normativa(si pensi ai sindacati); AUTONOMIA ORGANIZZATORIA che consente ad alcuni enti di dotarsi di un regime giuridico parzialmente diverso da quello cui sono soggetti altri enti(si pensi all'autonomia delle Università),AUTONOMIA POLITICA intesa come potere di alcuni enti di darsi un indirizzo politico diverso da quello dello Stato. Quanto all'AUTONOMIA FINANZIARIA,non costituisce una figura a sé ma sta ad indicare una qualità dell'autonomia organizzatoria,vale a dire la relativa autosufficienza di alcuni soggetti per quanto riguarda la provvista dei mezzi finanziari necessari allo svolgimento della loro attività:così ad esempio l'art.119 Cost .dispone che le Regioni(insieme ai Comuni,alle Città metropolitane e alle Province)stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Dall'autonomia va distinta l'AUTARCHIA,intesa non secondo il significato etimologico del termine e quindi come possibilità di autogovernarsi,bensì come potere conferito dall'ordinamento giuridico statale ad alcuni enti di emanare provvedimenti concreti ai quali l'ordinamento stesso attribuisce la stessa efficacia,o meglio,la medesima ESECUTORIETA'degli atti amministrativi dello Stato-soggetto. Enti autarchici in tal senso sono appunto le Regioni,le Province e i Comuni. L'autonomia delle Regioni si specifica,nell'ordinamento italiano,come AUTONOMIA NORMATIVA ed ORGANIZZATORIA,nonché come AUTONOMIA POLITICA,vale a dire come facoltà delle Regioni di adottare,entro i limiti istituzionali che le sono propri e con i controlli costituzionalmente stabiliti,un

proprio indirizzo politico,diverso in ipotesi da quello dello Stato,purchè non contrastante con i principi di struttura dell'ordinamento costituzionale. L'autonomia politica sembra intimamente connessa con i motivi che stanno a fondamento della creazione dell'ordinamento regionale e del conseguente decentramento dello Stato:infatti i problemi e gli interessi locali possono avere natura e proporzioni diverse da Regione a Regioni,e pertanto si deve coerentemente ammettere che ciascuna Regione possa adottare un proprio indirizzo politico differenziato rispetto a quello dello Stato,al fine di realizzare quella concordia discors che costituisce,in una comunità statale come quella italiana,la migliore garanzia di un'effettiva unità nazionale. E' lo Stato stesso quindi ad essersi autolimitato attribuendo alle Regioni poteri e funzioni costituzionalmente garantiti che gli erano tradizionalmente propri. In ragione di ciò,la Regione vede riconoscersi una sfera giuridica intangibile ed è legittimata ad adite nei confronti dello Stato medesimo qualora questo violi l'ambito della sua competenza. Riassuntivamente possiamo quindi dire che: le Regioni sono parte in una situazione giuridica ATTIVA nei confronti dello Stato; tale situazione si articola in una serie di facoltà giuridiche riconnesse all'autonomia regionale ed è azionabile dinanzi all'organo della giustizia costituzionale(Corte costituzionale). Da quanto detto risulta che l'autonomia regionale,complessivamente considerata,è più completa e di grado superiore rispetto a quella provinciale e comunale,anche se l'introduzione in Costituzione nel 2001 del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'ha dato nuova dignità all'autonomia comunale posta a fondamento,anche sul piano amministrativo,di tutto il sistema delle autonomie.
La competenza legislativa delle Regioni,molto rafforzata a seguito della riforma del Titolo V,porta al riconoscimento accanto allo Stato-soggetto,di altri enti,appunto le Regioni,sostanzialmente pari ordinate al primo ed attribuisce pertanto alle stesse,per questo aspetto,natura e rilevanza costituzionale quali enti che caratterizzano lo Stato italiano come "STATO REGIONALE".In questo senso si è anche parlato di "FEDERALISMO",che non significa che l'Italia ad oggi possa configurarsi come uno Stato federale in senso stretto,ma che ormai è venuta meno la tradizionale posizione di supremazia dell'ordinamento statale nei confronti degli altri ordinamenti giuridici preesistenti nel territorio,in primis quello regionale. La rilevanza costituzionale dell'ente Regione va tuttavia commisurata al principio supremo dell'UNITA' e della INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA,che ne costituisce la linea di confine. Infatti gli ordinamenti regionali sono derivati e perciò risultano automaticamente delimitati dallo Stato-istituzione(vale a dire la Repubblica),anche se,più che di una subordinazione gerarchica delle fonti regionali a quelle statali,è forse più corretto e appropriato parlare di regime di separazione.

3. Gli elementi costitutivi della regione: a) il territorio- Una definizione più esauriente della Regione porta a considerarla come un ente pubblico a rilevanza costituzionale e rappresentativo di una collettività stanziata su un determinato territorio,dotato di poteri e funzioni propri e di un ordinamento autonomo nei limiti prefissati dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. La Regione è ente territoriale perché(al pari dello Stato,delle Province e dei Comuni,anch'essi enti territoriali)il

This document is available free of charge on StuDocu.com

territorio ne costituisce l'elemento essenziale,non tanto inteso come ambito geografico o fisico,o come sfera spaziale entro la quale le Regioni possono esercitare le loro funzioni,ma come piuttosto il centro di riferimento degli interessi comunitari che in esso trovano la loro localizzazione. Nella stessa Costituzione sono previste peraltro le procedure per la creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni esistenti e per il distacco di Comuni e Province da una Regione per la loro aggregazione ad un'altra. In particolare,per la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni è richiesto(art.132 Cost.comma I): una legge costituzionale(dato che il numero e la denominazione di tutte e 20 le Regioni sono previsti nella Costituzione,art.131); un minimo di 1 milione di abitanti; la richiesta di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate; l'approvazione della proposta con referendum da parte della maggioranza delle popolazioni stesse. Per il distacco di Province e Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad un'altra è richiesto invece(ex art.132 Cost.II comma): una legge ordinaria; la richiesta delle Province o dei Comuni interessati; il parere dei Consigli regionali; l'approvazione della proposta con referendum da parte della maggioranza delle popolazioni interessate.

4. Segue: b) la comunità regionale- La comunità stanziata sul territorio della Regione è destinataria sia di norme regionali sia di norme statali. Spetta ad una parte della comunità regionale,e precisamente a coloro che sono iscritti nelle liste elettorali dei Comuni e che godono,quindi,del diritto elettorale attivo,di eleggere il Consiglio regionale,di richiedere i referendum previsti negli art.123 e 132 Cost.,di presentare proposte di legge e di provvedimenti amministrativi al Consiglio regionale.

5. c) l'apparato autoritario- La Regione è un soggetto di diritto(persona giuridica)dotato di propri poteri e funzioni(art.114 Cost.).Anche la Regione possiede quindi(come ogni altro ente o istituzione)un proprio apparato autoritario,un proprio "governo"in senso lato e la relativa organizzazione. La Regione tuttavia NON E' UN ENTE SOVRANO,sia perché il suo ordinamento non è originario(dipendendo la sua validità dall'ordinamento dello Stato-istituzione)sia perché il suo apparato autoritario è subordinato a quello dello Stato-istituzione. LA DISTINZIONE FRA REGIONE E STATO-MEMBRO: Originariamente si soleva fondare la distinzione fra Regione e Stato-membro dello Stato federale sul carattere derivato della Regione e sulla conseguente subordinazione del suo apparato autoritario. Sennonché la linea di confine non appare più così netta,se si considera che l'originarietà degli Stati membri è limitata essenzialmente alla preesistenza,da un punto di vista prettamente e meramente cronologico,di questi Stati rispetto allo Stato centrale,per cui una volta creato quest'ultimo,essi risultano allo stesso modo subordinati alla Costituzione federale. Oltretutto lo Stato centrale ha,di regola,poteri di controllo e di intervento per quanto riguarda l'adempimento da parte degli Stati membri degli obblighi stabiliti dalla Costituzione federale. Non è su questo piano pertanto che può essere rinvenuta la distinzione fra Stato-membro e Regione,né su quello,puramente formale,della partecipazione(anch'essa limitata)degli Stati-membri al potere di revisione

costituzionale,che non è invece prevista per le Regioni,se non limitatamente alla richiesta del referendum costituzionale. Entrambi gli enti infatti risultano subordinati all'ordinamento dello Stato in cui sono ricompresi,di modo che la distinzione può essere se mai delineata con riferimento ai poteri e alle funzioni attribuite alla Regioni e agli Stati-membri e nella logica secondo la quale è avvenuta tale ripartizione. Lo Stato centrale ha infatti sempre riservato a sé i settori di poteri e di attività che attengono ad esigenze aventi carattere unitario,decentrando agli Stati-membri e alla Regioni quelli residui. Appare evidente quindi come la riserva allo Stato e il trasferimento ai due enti di poteri ed attività siano determinati da valutazioni politiche e non da criteri generali e astratti. Esistono però un potere e un settore di attività che lo Stato unitario a decentramento regionale,a differenza dello Stato federale,ha sempre riservato a sé e,in particolare,il potere giudiziario e l'attività di polizia che ha per fine il mantenimento dell'ordine pubblico. La "logica"di questa riserva va rinvenuta non nella generica considerazione che,essendo il potere giudiziario espressione della sovranità dello Stato,non può essere attribuito alle Regioni,che sovrane non sono,altrimenti non si spiegherebbe il trasferimento alle Regioni del potere legislativo e di quello esecutivo. E' da considerare invece che,per loro stessa natura,il potere giudiziario e la funzione giurisdizionale mal si prestano ad essere suddivisi fra più enti,vista la necessità di adottare e mantenere fermi alcuni criteri formali che assicurino l'unitarietà dell'ordinamento;per cui l'accentramento nello Stato del potere giudiziario e della relativa funzione risponde ad un'esigenza tecnica più che politica.Esigenza che non è al contrario avvertita negli Stati federali,nei quali accanto all'ordinamento giuridico dello Stato centrale sussistono i distinti ordinamenti degli Stati-membri.Nello stesso ordine di idee va considerato il mancato trasferimento alle Regioni del potere di polizia,quale conseguenza della riserva statale nel campo della tutela dell'ordine pubblico.

6. I due tipi di regione- L'ordinamento costituzionale italiano prevede due tipi di Regioni:a STATUTO ORDINARIO ed a STATUTO SPECIALE,a seconda del diverso grado di autonomia ad esse attribuito. I fattori alla base dell'autonomia assumevano infatti in alcune Regioni italiane,a causa della loro peculiarità di carattere geografico,politico ed etnico,maggior rilievo che in altre,per cui si ritenne di dover attribuire a queste regioni,e in particolare alla Sicilia,alla Sardegna,al Trentino-Alto Adige,al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta "forme e condizioni particolari di autonomia". Ne deriva che non tutte le Regioni sono sottoposte allo stesso regime giuridico: le Regioni di diritto comune infatti trovano la loro disciplina uniforme nel Titolo V della Parte II della Costituzione,mentre l'ordinamento delle cinque Regioni alle quali sono state concesse forme e condizioni particolari di autonomia è contenuto in Statuti speciali adottati con legge costituzionale. Questi Statuti possono apportare deroghe alle norme del Titolo V della Costituzione,cioè a quelle disposizioni che valgono come disciplina uniforme per le Regioni di diritto comune.Bisogna notare tuttavia che le norme della Costituzione sono applicabili anche alle Regioni a Statuto speciale ogni qualvolta la materia regolata in queste norme non trovi una sua disciplina giuridica nei loro statuti. Altre norme poi

This document is available free of charge on StuDocu.com

contenute nel Titolo V si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale per la loro specifica funzione,che è quella di salvaguardare il carattere unitario dello Stato. Il III comma dell'art.116(introdotto nel 2001)consente che anche le Regioni di diritto comune acquistino "ulteriore forme e condizioni di autonomia"nelle materie di competenza concorrente ed in quelle riservate allo Stato contemplate dalle lettere : l) limitatamente ai giudici di pace; n)norme generali sull'istruzione; s)tutela dell'ambiente,dell'ecosistema e dei beni culturali. Questi ulteriori accrescimenti della competenza legislativa possono essere effettuati con legge dello Stato,su iniziativa della Regione interessata,sentiti gli enti locali,nel rispetto dei principi dell'autonomia finanziaria contenuti nell'art.119 della Costituzione. Come si vede,la differenza tra Regioni di diritto comune e Regioni a Statuto speciale tende a diventare sempre più sottile. Gli elementi di differenziazione fra le Regioni a Statuto speciale e le Regioni di diritto comune attengono al procedimento di formazione dello Statuto ed alla sfera di competenza legislativa ed amministrativa;inoltre,i sistemi finanziari dei due tipi di Regione sono,per alcuni aspetti,diversi;anche se la "specialità"delle Regioni differenziate stenta ormai a farsi valere,soprattutto per il progressivo livellamento di quest'ultime ad opera di leggi e atti amministrativi dello Stato.

7. Gli Statuti regionali- L'art.123 comma II nella nuova formulazione introdotta dalla legge costituzionale n.1 del 1999 stabilisce che lo Statuto delle Regioni di diritto comune è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,con due deliberazioni successive ad intervallo non minore di due mesi. Il nuovo art.123 prevede che per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto del Commissario del Governo (a seguito dell'entrata in vigore della legge cost.n.3 del 2001 è stato abrogato l'originario testo dell'art.124 Cost.che prevedeva il Commissario del Governo,ed è stato soppresso il meccanismo relativo all'apposizione del "visto"del Commissario nei confronti delle leggi regionali). E' stata inoltre abolita l'approvazione successiva dello Statuto con legge del Parlamento,prevista dall'art.123 Cost. nel suo testo originario. Il venir meno di questo controllo centralistico è stato bilanciato però con la facoltà attribuita al Governo di promuovere,entro trenta giorni dalla pubblicazione degli Statuti stessi,la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.
Al controllo giuridico si affianca il controllo "democratico",costituito dalla sottoposizione dello Statuto a referendum popolare qualora,entro tre mesi dalla sua pubblicazione,ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non viene promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Si tratta di una norma analoga a quella contenuta nel II comma dell'art.138 Cost.,riguardante le leggi di revisione costituzionale:ciò contribuisce a configurare lo Statuto come una sorta di "costituzione in piccolo"in ambito regionale,fornita di rigidità garantita dall'aggravamento della procedura,escluso ogni controllo politico esterno affidato ad organi costituzionali. Gli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata sono invece adottati,secondo l'art.116 della Costituzione,con leggi costituzionali:e infatti gli Statuti della Sardegna,della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige sono stati

adottati con leggi costituzionali(rispettivamente n.3,n.4 e n.5 del 26 febbraio 1948)votate dalla stessa Assemblea costituente e lo Statuto della Sicilia(emanato il 15 maggio del 1946 con decreto legislativo)è stato convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.2,sempre dall'Assemblea costituente nella legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.2. Con la legge costituzionale n.1 del 1963 è stato infine adottato dal Parlamento lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia;lo Statuto del Trentino-Alto Adige è oggi quello che risulta dal testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige emanato con D.P.R.n.670/1972 e successive modificazioni. LE MODIFICHE AGLI STATUTI: Dalla natura di legge costituzionale degli Statuti speciali discende che le loro norme non possono essere modificate se non con la procedura di revisione costituzionale prevista nell'art.138,mentre per modificare lo Statuto di una Regione di diritto comune sarà sufficiente seguire lo stesso procedimento previsto dall'art.123 Cost.per la formazione dello Statuto. N.B.:La legge cost.n.2 del 2001 ha attribuito alle Regioni a Statuto speciale la possibilità di modificare la propria forma di governo con leggi regionali approvate secondo una procedura aggravata,operando in tal modo una "DECOSTITUZIONALIZZAZIONE"di tale importante materia.
IL CONTENUTO DEGLI STATUTI ORDINARI: A norma dello stesso art.123 Cost.,nel testo modificato dalla legge n.1 del 1999,lo Statuto delle Regioni di diritto comune deve contenere: la determinazione della forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento; l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione; la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Tali materie costituiscono il contenuto necessario(ma non esclusivo)degli Statuti.
Tuttavia,se si leggessero gli Statuti delle Regioni di diritto comune sembrerebbe di trovarsi in presenza di tante mini-costituzioni che,interpretando estensivamente l'art.123 Cost.,sono andate ben al di là delle indicazioni in esso contenute,quasi a voler riaffermare la vitalità dell'istituto regionale in una comunità statale la cui costituzione materiale presenta oggi,almeno in alcuni settori,caratteristiche differenti da quelle proprie del periodo in cui furono votati la Costituzione e gli Statuti speciali.
Quanto agli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata essi sono atti dello Stato aventi la forma e l'efficacia della legge costituzionale .Le norme contenute negli Statuti speciali devono considerarsi di DIRITTO ECCEZIONALE rispetto alle norme costituzionali relative alle Regioni di diritto comune. Si deve però ricordare che l'ordinamento delle Regioni a regime differenziato non si esaurisce nelle norme statutarie ma è integrato da quelle norme contenute nel Titolo V che costituiscono dei principi generali comuni ai due tipi di Regione(ad es.l'art.120,che fa divieto alle Regioni di istituire dazi di importazione o esportazione o transito fra le Regioni o di adottare provvedimenti che limitano la pari condizione giuridica di tutti i cittadini).Eventuali lacune statutarie poi possono essere colmate con il ricorso in via di analogia ai principi ricavabili non solo dalla Costituzione ma anche dagli altri Statuti speciali. Dopo la legge cost. n. 1 del 1999, tutte le regioni di dir. comune si sono dotate di nuovi statuto, eccetto la Basilicata in cui i relativi lavori sono avviati.

This document is available free of charge on StuDocu.com

SEZIONE II- L'ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI

8. Il corpo elettorale regionale- Organi direttivi della Regione(sia essa di diritto comune o a regime differenziato)sono: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Regione.Al governo dell'ente partecipa poi anche il CORPO ELETTORALE REGIONALE,vale a dire quella parte dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione e che,usando gli strumenti previsti nella Costituzione e negli Statuti,esercitano(su base locale)la loro sovranità. Il corpo elettorale prende parte attiva al governo della Regione mediante l'esercizio del diritto di voto per la formazione del Consiglio regionale;esso svolge anche un'altra funzione di notevole rilievo mediante il REFERENDUM abrogativo di leggi e di provvedimenti amministrativi della Regione.(Oltre al referendum abrogativo,la Costituzione ha previsto altri tipi di referendum su base regionale:l'art.132 ad esempio dispone che si può,con legge costituzionale,sentiti i Consigli regionali,disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti,quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum della maggioranza delle popolazioni stesse. Sempre a norma dell'art.132 si può,con referendum e con legge della Repubblica,sentiti i Consigli regionali,consentire che Province e Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.)

9.Il Consiglio Regionale- il Consiglio regionale(Assemblea regionale in Sicilia,Consiglio della Valle in Valle d'Aosta)è il massimo organo deliberativo-rappresentativo dell'ente Regione ed è eletto dal corpo elettorale regionale. LA LEGGE ELETTORALE: La legge costituzionale n.1 del 1999 ha modificato l'art.122 Cost.ed ha attribuito alla competenza legislativa regionale,nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali.
In particolare,sul sistema di elezione del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali sono stati stabiliti i seguenti principi: individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranza nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale,se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto; previsione,nel caso in cui la Regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto,di termini temporali tassativi,comunque non superiori a 90 giorni,per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; divieto di mandato imperativo. Inoltre,sempre ai sensi della legge cost.n.1 del 1999,fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi elettorali regionali,l'elezione dei Consigli regionali verrà effettuata secondo la legge ordinaria vigente. Al riparto dei seggi dei Consigli regionali concorrono sia criteri proporzionalistici sia criteri maggioritari:si ci è dunque trovati di fronte ad un SISTEMA MISTO,volto a conseguire: la formazione di maggioranza stabili,senza sacrificare il pluralismo della rappresentanza; l'individuazione del Presidente della

Regione nella persona del capolista della lista regionale maggioritaria. Nelle Regioni a Statuto speciale le norme sui sistemi elettorali sono dettate con legge regionale,in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. In particolare,la legge regionale,approvata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,determina la forma di governo della Regione e,specificatamente,le modalità di elezione del Consiglio regionale,del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale,i rapporti tra gli organi della Regione,la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione,i casi di ineleggibilità e di incompatibilità,nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e la disciplina del referendum regionale abrogativo,propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi,la stessa legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Nei confronti di questa legge regionale il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte costituzionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione(fatta eccezione per la Regione Sicilia,per la quale opera un diverso meccanismo d'impugnazione delle leggi regionali). La legge viene sottoposta a referendum(la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale) qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti del Consiglio regionale;la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge è stata approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio regionale,si fa luogo a referendum soltanto se,entro 3 mesi dalla sua pubblicazione,la richiesta è sottoscritta da 1/30 (Friuli,Sardegna e Sicilia)o da 1/15 (Valle d'Aosta,Province autonome di Trento e Bolzano)degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale. I CASI DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA':Quanto ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità,alcuni sono stabiliti dalla stessa Costituzione(art.104,122 e 135 Cost.:incompatibilità fra l'ufficio di consigliere regionale e quello,rispettivamente,di membro elettivo del CSM,di membro di una delle Camere del Parlamento,del Parlamento europeo o di altro Consiglio regionale o di una Giunta regionale e di membro della Corte costituzionale). Nulla ci dice la Costituzione in ordine al numero dei consiglieri e alla durata in carica del Consiglio. Per quanto riguarda le Regioni di diritto comune,la legge n.108 del 1968 dispone che il Consiglio regionale è composto: di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; di 40 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;di 30 membri nelle altre Regioni. (Tali numeri sono ormai diventati puramente indicativi,data la possibilità di variazione in seguito all'assegnazione del premio di maggioranza.) Quanto alla durata in carica,essa è fissata in 5 anni (art.3 della legge n.108 del 1968 e art.5 della legge n.165 del 2004)per le Regioni di diritto comune,e nello stesso numero di anni per i Consigli delle Regioni a Statuto speciale. Il quinquennio decorre a partire dalla data delle elezioni;i Consigli delle Regioni di diritto comune esercitano le loro funzioni

This document is available free of charge on StuDocu.com

fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione. La legge n.108 del 1968 esclude pertanto la PROROGATIO dei loro poteri,prevista invece per i Consigli delle Regioni a Statuto speciale. A seguito dell'entrata in vigore della legge cost.n.1 del 1999 invece,la Corte costituzionale(sent.n.196 del 2003)ha ritenuto che l'eventuale previsione della PROROGATIO sia rimessa agli Statuti delle Regioni di diritto comune,ai sensi del nuovo art.123 Cost."come parte della disciplina della forma di governo regionale". Il numero dei membri del Consiglio è fisso in Sicilia(90 membri),in Valle d'Aosta(35),in Trentino(70 consiglieri) e in Sardegna(80),mentre nel Friuli è determinato in ragione di 1 ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento. Il Consiglio esercita la potestà legislativa spettante alla Regione,può fare proposte di legge alle Camere ed esercita altre funzioni conferitegli dalla Costituzione.Altre attribuzioni sono invece,secondo la previsione dei vari Statuti: l'approvazione del bilancio preventivo della Regione e del conto consuntivo,del programma economico regionale e dei piani di attuazione; la deliberazione dei tributi regionali; l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali; l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione e ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio dalla Giunta. La maggior parte degli Statuti delle Regioni di diritto comune attribuisce inoltre al Consiglio il potere di determinare l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione,sottolineando in tal modo il ruolo di "organo esecutivo"della Giunta(art.121 comma III Cost.). Spetta infine ai Consigli regionali il potere di AUTOORGANIZZAZIONE proprio di ogni organo collegiale,che trova la sua massima espressione nell'approvazione di un regolamento consiliare che predispone la loro organizzazione interna(prevedendo ad esempio la costituzione dei gruppi e delle commissioni permanenti consiliari)e disciplina i modi di esercizio delle loro funzioni. LO STATUS DI CONSIGLIERE REGIONALE: Lo status di consigliere regionale è disciplinato sia nella Costituzione sia nei singoli Statuti. A norma dell'art.122 comma IV Cost.,i consiglieri regionali(analogamente ai parlamentari)non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;ma i consiglieri regionali non godono delle immunità previste dal II e III comma dell'art.68 Cost.,riservate esclusivamente ai membri del Parlamento nazionale in base al PRINCIPIO DELLA NON ESTENSIBILITA',in via analogica,DELLE NORME ECCEZIONALE(art.14 preleggi). Fondamento costituzionale sembra invece avere il DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO,data la natura politica dell'organo,che è per l'appunto rappresentativo dell'intera comunità regionale. L'art.1 della legge n.108 del 1968 ha disposto infatti che "I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione SENZA VINCOLO DI MANDATO". I consiglieri regionali hanno inoltre diritto ad un'indennità stabilita con legge regionale,il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni svolte in Consiglio. Infine,i Consigli godono di un'autonomia contabile e funzionale,e ad essi è stata estesa la speciale tutela penale prevista per le Camere(art.289 cod.pen.).

10. LA GIUNTA REGIONALE:La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione,ed è composta da un Presidente e da un numero variabile di assessori,secondo i diversi Statuti. Il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Il nuovo testo del V comma dell'art.122 Cost. stabilisce come regola che il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto e che lo stesso nomini e revochi i componenti della Giunta.Gli statuti regionali possono tuttavia deliberare un diverso sistema di elezione sia del Presidente che dei componenti della Giunta.
Il II comma dell'art.126 Cost.,così come modificato dalla legge costituzionale n.1 del 1999,attribuisce al Consiglio regionale la potestà di esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta,mediante mozione motivata,sottoscritta da almeno 1/5 dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti stessi. La mozione non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente,nonché la rimozione,l'impedimento permanente,la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano contestualmente le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Le attribuzioni della Giunta sono indicare negli statuti delle Regioni e per quelle a Statuto speciale,anche nelle norme di attuazione degli statuti stessi.

11. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA: Il Presidente della Giunta regionale è il capo dell'ente Regione. In questa sua qualità,egli rappresenta la Regione all'esterno,dirige la politica della Giunta e ne è responsabile,promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali,indice i referendum previsti dagli Statuti o dalle leggi regionali,rappresenta l'ente in giudizio ed esercita i diritti patrimoniali e non patrimoniali attribuiti alla Regione. Spetta al Presidente della Giunta regionale promuovere dinanzi alla Corte costituzionale,previa deliberazione della Giunta,la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di un'altra Regione che si ritenga abbiano violato la sfera di competenza assegnata alla Regione dalla Costituzione o dallo Statuto speciale. Allo stesso modo è il Presidente della Giunta regionale che ricorre alla Corte costituzionale,sempre in seguito a deliberazione della Giunta,nel caso in cui si ritenga che lo Stato o un'altra Regione abbiano,con un atto non legislativo,invaso la sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione. Come Presidente di un organo collegiale,spetta al Presidente della Giunta convocarla e fissarne l'ordine del giorno. I Presidenti delle Regioni a Statuto speciale partecipano inoltre,per espressa disposizione degli Statuti stessi,al Consiglio dei ministri con voto consultivo quando il Consiglio tratti questioni che riguardano particolarmente la loro Regione.

12. LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE- L'art.123 I comma della Costituzione,nel testo modificato dalla legge costituzionale n.1 del 1999,attribuisce alla potestà statutaria delle Regioni la determinazione della forma di governo regionale stabilito dalla Costituzione del 1947,che imponeva il regime parlamentare

This document is available free of charge on StuDocu.com

“a tendenza assemblare”,caratterizzato dall’elezione del Presidente e dei membri della Giunta da parte del Consiglio regionale tra i suoi componenti e dalla concentrazione dei poteri di indirizzo nel Consiglio,oltre che dall’attribuzione allo stesso della potestà regolamentare,normalmente prerogativa dell’esecutivo nella forma di governo parlamentare classica. La recente revisione costituzionale ha eliminato quest’ultima attribuzione del Consiglio(art.121 II comma nel nuovo testo),contribuendo così a riequilibrare le posizioni dei supremi organi regionali. Salva restando la possibilità delle singole Regioni di scegliere una diversa forma di governo,il “modello delineato nella riforma costituzionale del 1999 è quello c.d.”NEOPARLAMENTARE”. In primo luogo,è previsto che il Presidente sia eletto contestualmente al Consiglio. Allo scopo di assicurare la consonanza tra Consiglio e Presidente,sono candidati alla presidenza i capilista delle liste regionali e viene eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Questa disposizione dovrebbe garantire che il corpo elettorale elegga contemporaneamente un governo e la maggioranza che lo dovrà sostenere;di conseguenza si dovrebbero avere esecutivi stabili,in grado di assicurare la c.d. “governabilità”. Non si è voluto introdurre una separazione rigida tra esecutivo e legislativo,tipica della forma di governo presidenziale perché è stata prevista la possibilità per il Consiglio di esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente,provocando le dimissioni di quest’ultimo,unitamente a quelle della Giunta. La legge costituzionale n.2 del 2001 ha esteso alle Regioni a Statuto speciale,con quale variazione per la Regione Valle d’Aosta e per le Provincia di Bolzano,lo stesso regime previsto dalla legge cost.n.1 del 1999 per le Regioni di diritto comune. A questo punto si può dire che la scelta per la forma di governo “NEOPARLAMENTARE”è,in questo momento storico,predominante per gli enti politici diversi dallo Stato.
Occorre ricordare infine che la Corte costituzionale,con sent.n.2 del 2004,ha dichiarato illegittime alcune norme del nuovo Statuto della Regione Calabria,laddove prevedevano un Vice-Presidente,eletto insieme al Presidente e destinato a sostituire quest’ultimo nell’ipotesi di dimissioni o di fatti accidentali(impedimento,morte ecc.),e che sono state ritenute in contrasto con il principio,costituzionalizzato dalla legge cost.n.1 del 1999,noto come AUT SIMUL STABUNT AUT SIMUL CADENT(con questa espressione si intende dire che il Presidente della Giunta ed il Consiglio regionale sono eletti contestualmente e che il venir meno di uno dei due organi determina la scadenza anticipata dell’altro e il ricorso a nuove elezioni per il rinnovo di entrambi gli organi). La vigenza di tale principio è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con la sent.n.12 del 2006,con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una norma,contenuta nello Statuto della Regione Abruzzo,che prevedeva l’obbligo per il Presidente della Giunta di presentare il programma nella prima seduta successiva alle elezioni e stabiliva che la mancata approvazione del programma producesse gli effetti di una mozione di sfiducia. La Corte ha escluso che si possano inserire negli Statuti norme regolatrici dei rapporti tra Consiglio e Presidente simili al rapporti di fiducia tipico della forma di governo parlamentare,dove il Presidente non è eletto a suffragio universale. E’ stata inoltre

esclusa la possibilità di una mozione di sfiducia individuale ai singoli assessori,per contrasto con l'art.122 comma V Cost.

SEZIONE III- I RACCORDI FRA LO STATO E LE REGIONI

13. IL REGIONALISMO COOPERATIVO -La Costituzione,nel riconoscere lo Stato italiano come "Stato regionale"non ha inteso orientare i rapporti fra l'ente sovrano e gli enti dotati di autonomia politica esclusivamente nel senso di una separazione delle rispettive competenze,ma anche e soprattutto inteso volgere questi stessi rapporti nel senso di una reciproca collaborazione,specie laddove sono maggiormente evidenti i vincoli di interdipendenza fra la dimensione degli interessi locali e quella degli interessi nazionali. Le forme di cooperazione fra Stato e Regioni previste in Costituzione sono state progressivamente arricchite,soprattutto in seguito all'attuazione della riforma del Titolo V della Parte II operata con la legge cost. n. 3 del 2001. E infatti,poiché le Regioni si trovano ormai ad esercitare,nelle materie di loro competenza,buona parte delle funzioni amministrative prima svolte dagli organi dell'amministrazione centrale,si è reso necessario instaurare una serie di raccordi mediante cui le attività svolte dallo Stato a livello nazionale e dalle Regioni a livello locale possano coordinarsi al fine di ottenere una maggiore efficienza nella cura degli interessi pubblici. Inoltre, in base all'art.118 Cost.(dopo la riforma del 2001),la competenza generale sulle funzioni amministrative spetta ai Comuni,salvo che,per assicurarne l'esercizio unitario,le stesse siano conferite a Province,Città metropolitane,Regioni e Stato(secondo i principi di SUSSIDIARIETA',DIFFERENZIAZIONE e ADEGUATEZZA).
E' questo a grandi linee il modello del "REGIONALISMO COOPERATIVO" che tuttavia non ha sempre avuto un'ordinata e coerente applicazione:infatti la cooperazione tra Stato e Regioni si è spesse volte frammentata e spezzettata in molteplici organi,ovvero in procedimenti c.d. "misti". A tale insoddisfacente stato di cose ha posto rimedio,almeno in parte,la legge n.400 del 1988,il cui art.12 ha delegato il Governo ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere,in seguito all'istituzione della CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI FRA LO STATO,LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME,al riordino e all'eventuale soppressione degli organi a composizione mista Stato-Regioni.

14. LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI AD ATTIVITA' DELLO STATO- Le Regioni possono partecipare ad attività dello Stato sia singolarmente sia collettivamente. A norma dell'art.121 comma II della Costituzione,i Consigli regionali possono presentare proposte di legge(ordinaria e costituzionale)alle Camere in materia di interesse regionale,oltre che voti e petizioni. I Consigli sono poi chiamati a esprimere il loro parere sulla fusione di Regioni già esistenti o sulla creazione di nuove Regioni(alle quali si provvede con legge costituzionale)e sulle modifiche territoriali delle Regioni(alle quali si provvede con legge ordinaria)(art.132 Cost.). Il parere del Consiglio è obbligatorio,ma non vincolante,giacchè non incide sulla determinazione della volontà del legislatore statale,che si muove sempre

This document is available free of charge on StuDocu.com

nell'ampia sfera di discrezionalità che gli è propria.
Le Regioni partecipano inoltre alle elezioni del Presidente della Repubblica ciascuna con 3 delegati(1 per la Valle d'Aosta)che vengono a integrare il Parlamento in seduta comune(art.83 Cost.).(L'integrazione del Parlamento in seduta comune è stata disposta per dare al Presidente della Repubblica una base più larga di quella parlamentare,così da evitare che egli possa essere espressione soltanto del partito più numeroso,ma il risultano pratico sembra dubbio,considerato il numero esiguo dei delegati regionali.)
Quanto all'esercizio collettivo di funzioni di partecipazione ad atti dello Stato invece,va anzitutto considerata la richiesta di referendum abrogativo (art.75 Cost.)che può essere avanzata da 5 Consigli regionali ed avrà generalmente ad oggetto una legge ordinaria o un atto avente forza di legge che incidano su interessi comuni a più Regioni(lo stesso dicasi per la richiesta di referendum che si inserisce nel procedimento di revisione costituzionale).
Notevole rilievo assume poi la partecipazione delle Regioni all'elaborazione e all'attuazione del programma economico nazionale,mediante sia l'elaborazione di schemi di sviluppo economico regionale,sia il loro concorso alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica.In sede poi di attuazione del programma,le Regioni possono redigere programmi di intervento,nel quadro delle competenze loro assegnate.

15. LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI FRA LO STATO,LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME- La Conferenza,istituita con l'art.12 della legge n.400 del 1988,è il principale strumento di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale,interregionale e infraregionale. Sono compiti principali della Conferenza: -promuovere e sancire le intese tra Stato,Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; -promuovere e sancire gli accordi tra Governo,Regioni e Pronvice autonome di Trento e Bolzano,in attuazione del PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità,economicità ed efficacia dell'azione amministrativa; -assicurare lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo,le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; -fermo restando quanto previsto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,determinare,nei casi previsti dalla legge,i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza esprime parere obbligatorio,ma non vincolante,su tutti gli schemi di disegno di legge,di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano,oltre che su ogni altro oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporle.

16. LA FUNZIONE STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO: La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni attinenti ad esigenze unitarie risulta riservata allo Stato,anche con riferimento agli obiettivi del

programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. L'esercizio concreto di questa potestà aveva dato origine a forti lamentele da parte delle Regioni,che vi vedevano la sopravvivenza del tradizionale centralismo statalistico. Dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione(ad opera della già citata legge cost.n.3 del 2001)tale funzione è apparsa incompatibile con la logica di un ordinamento regionale che si orienta verso modelli di federalismo. Il dubbio circa la sua sopravvivenza,che aveva inizialmente prodotto vivaci dibattiti dottrinali,sembra oggi rimosso dalla legge n.131 del 2001,che esplicitamente statuisce che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legislazione prima vigente non possono essere adottati nelle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni.

17.IL RAPPRESENTANTE DELLO STATO PER I RAPPORTI CON IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE: Dopo la soppressione del Commissario del Governo,previsto originariamente dall'art.124 Cost. prima della riforma del 2001,è stato introdotto con la legge n.131 del 2001 il RAPPRESENTANTE DELLO STATO PER I RAPPORTI CON IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE,incarnato dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione. Sono di competenza del Rappresentante dello Stato:
-le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione; -la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri degli statuti,delle leggi e degli atti amministrativi regionali,ai fini di eventuali impugnative in via principale davanti alla Corte costituzionale o di proposizione di conflitto di attribuzione davanti alla stessa;
-la promozione dell'attuazione di intese e del coordinamento fra Stato e Regione;
-l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri;
-l'indizione delle elezioni regionali.

18. IL PRINCIPIO DI "LEALE COOPERAZIONE": Il c.d. PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE fra Stato e Regioni risulta inteso a superare alcune formalistiche separazione di competenze fra i due enti affinchè le rispettive funzioni di svolgano nel modo più efficiente e coordinato possibile(anche in vista di un integrale rispetto del principio costituzionale del "buon andamento" della pubblica amministrazione). Esso ha trovato concreta attuazione in alcuni procedimenti di formazione di atti statali,che hanno visto la partecipazione,alle volte addirittura paritaria,delle Regioni. Si tratta di formule sufficientemente ampie ed elastiche,che permettono agli uffici statali e a quelli regionali di adottare svariate misure di raccordo e di coordinamento,come ad esempio le intese,le consultazioni,le richieste di parere,le informazioni reciproche ecc. Ovviamente,in uno Stato unitario a decentramento regionale esso non può spingersi oltre certi limiti,non può porre cioè Stato e Regioni sullo stesso piano(come di regola avviene negli ordinamenti federali,nei quali la partecipazione dello Stato centrale e degli Stati-membri si realizza su base paritaria). Tranne infatti i casi in cui il consenso delle Regioni si renda necessario per tutelare specifici interessi regionali e la loro stessa sfera di

This document is available free of charge on StuDocu.com

autonomia,bene può la decisione ultima essere rimessa unicamente allo Stato,sia pure dopo che le Regioni sono state chiamate a parteciparvi. In altre parole,una collaborazione del tutto paritaria fra Stato e Regione non si armonizzerebbe con il disegno costituzionale,secondo il quale gli ordinamenti regionali non sono originari,bensì derivati da quello statale.

Sezione IV- LE FUNZIONI DELLE REGIONI

Le funzioni normative

19. LO STATUTO:POSIZIONE NEL SISTEMA DELLE FONTI E CONTENUTO

L'autonomia regionale trova la sua maggiore espressione nella potestà assegnata alla Regione di emanare leggi in senso formale e risulta essere,in tal modo,più ampia rispetto a quella degli altri enti territoriali minori,Province e Comuni,che è limitata all'emanazione di fonti secondarie,gli statuti e i regolamenti,e non già estesa anche all'emanazione di fonti primarie(quali appunto le leggi regionali).
Una posizione di preminenza nel sistema delle fonti regionali è assunta dallo Statuto delle Regioni di diritto comune,che è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale con due deliberazioni successivi adottate con intervallo non minore di 2 mesi e sottoponibile a referendum entro 3 mesi dalla sua pubblicazione. La maggiore efficacia dello Statuto rispetto alle altre leggi deriva dal suo essere l'atto fondamentale della Regione,approvato con una procedura aggravata. Ne consegue che la revisione dello Statuto può avvenire soltanto con l'adozione dello stesso procedimento previsto per la sua deliberazione.
A norma dell'art.123 della Costituzione(nel testo modificato ex legge cost.n.1/1999),lo Statuto delle Regioni di diritto comune deve contenere:
-la determinazione della forma di governo(non si tratta di una RISERVA PIENA:lo Statuto può stabilire norme relative alla forma di governo che però non siano già oggetto di coperta costituzionale);
-i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione;
-l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa e di referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. La legge cost.n.3 del 2001 ha stabilito inoltre che in ogni Regione lo Statuto disciplina il CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI,organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. E' questo dunque il contenuto necessario dello Statuto,con i limiti posti dalla Costituzione:entro questi limiti,ciascuna Regione può darsi un'organizzazione interna diversa per adattarla alle proprie condizioni socio-politiche,di modo che fra le fonti statali e la fonte statutaria si ha un regime di separazione delle competenze.
Altra questione è invece quella relativa all'estensione della potestà statutaria a materie non espressamente previste nell'art.123 Cost.:posto che tale articolo indica solo il contenuto necessario degli Statuti(ponendo quindi al riguardo una "riserva di Statuto"),nulla esclude che gli Statuti possano contenere norme di principio o programmatiche.Gli Statuti regionali infatti molto spesso racchiudono contenuti

ulteriori rispetto ai contenuti necessari dello Statuto,e talvolta esprimono una serie di formulazioni avanzate(come nello Statuto della Toscana:tutela delle coppie omofile).La Corte costituzione è perciò stata chiamata a giudicare in merito a tali stessi contenuti ulteriori rispetto a quelli prettamente necessari ex art.123 Cost.: Al riguardo,nelle sentenze n.372,378 e 379 del 2004,la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure di legittimità costituzionale avanzate dallo Stato nei confronti di alcuni articoli dei nuovi Statuti delle Regioni Toscana,Umbria ed Emilia Romagna,contenenti disposizioni di principio sugli obiettivi prioritari dell'attività regionale. La Corte ha ritenuto infatti che tali formulazioni siano espressioni di orientamenti culturali,linee politiche,ma che non siano giuridicamente rilevanti e, come tali, vincolanti. La Corte ha negato che le stesse possano essere assimilate alle c.d.norme programmatiche della Costituzione alle quali è stata riconosciuta invece una funzione di integrazione e interpretazione delle norme vigenti,poiché gli Statuti non sono carte costituzionali,ma solo fonti regionali a competenza riservata e specializzata. Le disposizioni di principio degli Statuti regionali esplicano pertanto,secondo la Corte,una funzione,per così dire,di natura culturale o anche politica,ma certo non normativa. Ergo,la Corte avrebbe potuto rilevare l'illegittimità costituzionale di queste formulazioni,per essersi poste al di là delle competenze attribuite alla legislazione statutaria regionale,ma di fatto ha compiuto una valutazione SOSTANZIALE(non FORMALE),per cui,pur riconoscendo tali formulazioni come estranee alla competenza statutaria,anziché rilevarne l'illegittimità per incompatibilità con l'art.123 Cost. ne stabilisce la non vincolatività giuridica,la non cogenza. N.B.: Il limite alla potestà statutaria regionale è rappresentato in primis dall'art.122 Cost.,che attribuisce alla legge dello Stato la potestà statale(concorrente a quella regionale).

20. LE LEGGI REGIONALI ORDINARIE

A)IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE- Si suddivide,al pari del procedimento di formazione delle leggi statali,in tre fasi: dell'INIZIATIVA,COSTITUTIVA ed INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA. A differenza della legge statale(che è un atto complesso),la legge regionale è un atto semplice,essendo espressione della volontà di un solo organo legislativo. Essa è,ad ogni modo,una LEGGE FORMALE,vale a dire un atto posto in essere da un organo,nell'esercizio della funzione legislativa,secondo un procedimento tipico disciplinato nella Costituzione,negli Statuti regionali e nei regolamenti consiliari. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta,ai singoli consiglieri e agli elettori della Regione(in numero variabile a seconda della Regione).Gli Statuti ordinari l'attribuiscono anche ai Consigli comunali e provinciali(secondo diverse modalità);alcuni statuti poi hanno esteso il potere di iniziativa alle organizzazioni sindacali,ai Consigli di valle o alle comunità montane e prevedono che ogni cittadino,associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio,nei termini stabiliti dal regolamento consiliare,osservazioni o proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.
Ogni progetto di legge,previo esame da parte della commissione legislativa competente per materia,è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con

This document is available free of charge on StuDocu.com

votazione finale. Il procedimento adottato per la formazione delle leggi regionali è quindi quello ordinario(con le commissioni in sede REFERENTE),con abbreviazione dei termini qualora il Consiglio dichiari l'urgenza del progetto. Resta escluso il procedimento decentrato(con le commissioni in sede DELIBERANTE)sia perché l'art.72 comma III Cost.non è estensibile analogicamente all'ordinamento regionale,e sia perché il numero dei componenti delle commissioni consiliari è talmente ridotto che,qualora si demandasse loro l'approvazione delle leggi,il principio della democraticità dell'attività regionale verrebbe ad essere seriamente compromesso. Le leggi regionali sono infine promulgate dal Presidente della Giunta e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e riprodotte(a puro fine conoscitivo)nella Gazzetta Ufficiale della Regione:entrano in vigore non prima di 15 giorni dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

21. B)I LIMITI: L'esercizio della potestà legislativa regionale incontra diversi limiti,che possono complessivamente distinguersi in GENERALI e SPECIALI. Sono limiti GENERALI quelli validi per tutti i tipi di legge regionale,e sono limiti DI LEGITTIMITA'. L'art.117 comma I Cost.(dopo la riforma del 2001)pone dei limiti generali alla legislazione sia dello Stato che delle Regioni:essi sono la Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Esistono poi limiti generali di legittimità propri delle leggi regionali;essi sono dati da alcuni principi costituzionali assolutamente inderogabili da parte delle Regioni,quali:
- il principio del DECENTRAMENTO(che comporta il rispetto da parte delle Regioni dell'autonomia degli enti infraregionali); -il principio della TIPICITA' DELLE FORME(secondo il quale le Regioni non possono seguire,nella formazione dei loro atti,procedimenti diversi da quelli prescritti in Costituzione e negli Statuti speciali,e non possono dare agli atti stessi un contenuto differenti da quello che è da considerare TIPICO(Mortati). Quanto al limite delle MATERIE,va detto che esso contiene in sé un elevato margine di indeterminatezza concettuale,così che nella pratica non è possibile riscontrare un riparto definitivo e immutabile tra Stato e Regioni. Inoltre tale limite non è di per sé sufficiente a determinare la misura della competenza regionale,giacchè anche nelle materie attribuite alla potestà legislativa delle Regioni lo Stato può intervenire con le sue leggi. Altro limite a carattere generale è dato dalla NATURA TERRITORIALE dell'ente,il che comporta che di regola la legge regionale deve esaurire la sua efficacia entro l'ambito del territorio regionale. Il limite di legittimità si specifica nell'art.120 Cost.,a norma del quale la Regione non può istituire dazi d'importazione,di esportazione o transito fra le Regioni,non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose e non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Controversa appare poi l'intensità dei limiti dati dalle RISERVE DI LEGGE e dai RAPPORTI PRIVATI.
Quanto al primo,nulla autorizza a sostenere(come in un primo tempo aveva invece ritenuto la Corte costituzionale)che la Costituzione,quando rinvia la disciplina di una determinata materia puramente e semplicemente alla "legge" ,si riferisca soltanto alla legge dello Stato:infatti,se così fosse,si priverebbe la Regione della potestà legislativa

in materie attribuite alla sua competenza,ma riservate alla legge.Il problema non si pone per quelle riserve di legge che sono sicuramente statali,quali quelle relative alla disciplina dei diritti e dei doveri dei cittadini,del tutto sottratta alla competenza regionale. Per le altre,ha finito con l'essere determinante la giurisprudenza della Corte costituzionale che,abbandonata la posizione rigida,ha ammesso che in alcune materie la riserva di legge non preclude l'intervento del legislatore regionale.Di converso,la Corte ha ritenuto che altre riserve sono sicuramente statali,come ad esempio quella in materia penale,di rapporti di diritto processuale e di attività giurisdizionale. Allo stesso modo,la Corte ha precisato il limite dei rapporti privati,statuendo che la Regione non ha in materia alcuna potestà legislativa.In tempi recenti,la Corte ha attenuato la rigidità della sua posizione tradizionale,ammettendo che la Regione possa adattare la disciplina dei rapporti privatistici nelle materie di sua competenza,nel rispetto del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza. I limiti ***SPECIALI*** valgono ad indicare la misura della potestà legislativa regionale ed a caratterizzarne la tipologia,e sono dati: dai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato; dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali; dagli obblighi internazionali dello Stato e dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

22. 23. C)LA POTESTA' LEGISLATIVA: La potestà legislativa regionale,dopo la riforma introdotta dalla legge cost.n.3 del 2001,si articola in due tipi: PRIMARIA(o ESCLUSIVA)e CONCORRENTE(o RIPARTITA).
La potestà legislativa PRIMARIA appartiene alle Regioni a Statuto ordinario e speciali nelle materie non riservate alla competenza dello Stato e non ricomprese tra quelle di competenza concorrente dall'art.117 comma II e III della Costituzione.Spetta inoltre alle Regioni a Statuto speciale nelle materie elencate nei rispettivi Statuti. La potestà primaria non è però esente da limiti che,in un sistema pluralista di fonti come quello italiano,valgono ad assicurare il principio costituzionale dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica e dunque l'unitarietà dell'ordinamento giuridico. I limiti posti a tale tipo di potestà sono peraltro molto ampi e sono costituiti: dai principi generali dell'ordinamento giuridico(art.12 delle preleggi); dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali (limite dovuto anch'esso all'unità e all'indivisibilità della Repubblica,che verrebbe compromessa se alcune grandi leggi di riforma votare dal Parlamento nazionale non avessero ingresso nelle Regioni); dagli obblighi internazionali dello Stato e dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario(di fatti,nell'esercizio della propria potestà legislativa,le Regioni non possono intaccare gli obblighi e i vincoli assunti dallo Stato sia in campo internazionale che nell'ambito sopranazionale dell'Unione. Tuttavia le Regioni non sono escluse dai processi formativi e attuativi delle norme internazionali e sopranazionale:esse infatti,nelle materie di loro competenza,possono anche concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Gli art.5 e 5 della legge n.131 del 2003 stabiliscono le procedure mediante le quali le Regioni possono realizzare,nelle materie di propria competenza: la partecipazione

This document is available free of charge on StuDocu.com

alla formazione degli atti comunitari; la stipulazione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato; la conclusione di accordi con altri Stati,esecutivi ed applicativi di accordi internazionali già entrati in vigore o accordi di natura tecnico-amministrativa o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire lo sviluppo economico,sociale e culturale delle Regioni stesse; l'esecuzione diretta degli accordi internazionali ratificati. Nell'esercizio di queste competenze internazionali,le Regioni non possono esprimere valutazioni sulla politica estera dello Stato,né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi o oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi di altre Regioni o di Comuni,Province e Città metropolitane. La Regione ha l'obbligo di informare il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri delle eventuali trattative dirette alla formazione di un accordo internazionale. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati. Prima della sottoscrizione dell'accordo,la Regione comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri,il quale,sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo,conferisce i pieni poteri di firma. In assenza del conferimento dei pieni poteri di firma,gli accordi sono nulli. LA POTESTA' RIPARTITA O CONCORRENTE: E' propria sia delle Regioni a Statuto speciale sia delle Regioni ordinarie. E' così definita perché,nelle materie attribuite alla competenza regionale,sono legittimati a legiferare,ma con diversa intensità,sia lo Stato che la Regione:lo Stato,al quale spetta di stabilire per ogni materia i principi fondamentali con leggi proprie(LEGGI CORNICE);la Regione,alla quale spetta,nei limiti di detti principi,di svolgerli. Nelle materie di competenza regionale intervengono quindi due fonti separate:la legge statale per stabilire i principi fondamentali,la legge regionale per svolgere tali principi;ergo né lo Stato può dettare norme di sviluppo e di dettaglio,né la Regione norme di principio. La legislazione statale di dettaglio trova applicazione nel territorio della Regione nel caso in cui manchi,nella materia data,una disciplina regionale,per evitare che si provochi un vuoto legislativo. Se lo Stato omette di emanare leggi-cornice,la Regione può legiferare ugualmente nei limiti dei principi fondamentali,desumibili dalle leggi vigenti. Per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali,il Governo è delegato ad adottare,entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima,su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati,uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie previste dall'art.117 III comma Cost.,attenendosi ai principi di ESCLUSIVITA',ADEGUATEZZA,CHIAREZZA,PROPORZIONALITA'ed OMOGENEITA'. Gli schemi dei decreti in questione devono essere sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni,della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia,che dovrebbero attenuare i rischi di eccessiva discrezionalità da parte del Governo.

24. Le leggi provinciali- Lo Statuto del Trentino-Alto Adige ha attribuito un potere legislativo ed esecutivo autonomo alla Provincia di Bolzano e,conseguentemente,a quella di Trento. E'questo l'unico caso in cui gli organi consiliari di una Provincia esercitano il potere legislativo.

25. LE MATERIE ATTRIBUITE ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE- Nel ripartire la potestà legislativa fra lo Stato e le Regioni,la Costituzione(dopo la riforma del 2001)ha adottato il metodo della enumerazione delle materie di competenza statale(RIPARTIZIONE ORIZZONTALE)integrato con una ripartizione della potestà legislativa fra Stato e Regioni(RIPARTIZIONE VERTICALE). Tutte le materie non riservate allo Stato e non ricomprese nella potestà legislativa concorrente sono quindi di competenza regionale. Si tratta di un metodo tipico degli ordinamenti federali,fondati sul principio di massima espansione degli Stati membri,che cedono allo Stato federale soltanto i poteri necessari ad assicurare la tutela di alcuni beni indivisibili necessari per la comune difesa,la coesione nazionale e la parità di trattamento dei cittadini rispetto ad alcuni diritti ed interessi fondamentali. Il quadro complessivo,che potrebbe apparire abbastanza chiaro nella sua formulazione astratta,in realtà si complica appena si ci trova di fronte all'interpretazione delle espressioni contenute in Costituzione,al fine di determinare i poteri reali sia dello Stato che delle Regioni. Il vecchio testo dell'art.117 Cost.(che enumerava le materie di competenza regionale ed affidava allo Stato tutto il resto)non ha impedito lo sviluppo,nel corso di un cinquantennio,di una legislazione statale e di una giurisprudenza costituzionale volte a creare,con sempre maggior precisione,la DOTTRINA DEL LIMITE GENERALE INTRINSECO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE rappresentato dall'INTERESSE NAZIONALE. Dietro questo concetto indeterminato è transitata una serie nutrita di leggi dello Stato sostanzialmente lesive dell'autonomia regionale,giustificate dall'esigenza di salvaguardare il preminente interesse nazionale mediante discipline di dettaglio che sarebbero in realtà state di competenza delle Regioni.
Anche il trasferimento delle funzioni amministrativi ha subito remore e rallentamenti dovuti alla riluttanza dello Stato a cedere poteri inerenti a interessi rilevanti. Dopo un faticoso cammino di rivendicazione da parte degli enti regionali di margini maggiori di autonomia,si arrivò finalmente ad un gruppo di leggi,che hanno preso il nome del Ministro BASSANINI(legge di delega n.59 del 1997)che realizzavano quello che fu chiamato il "FEDERALISMO A COSTITUZIONE INVARIATA",consistente nell'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative enumerate,e alle Regioni e agli enti locali tutte le altre. Alle Regioni e agli enti locali dovevano quindi essere attribuite tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità,nonché i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori,con la sola eccezione di quei compiti e funzioni amministrative riservate espressamente dalla legge medesima allo Stato(ad es. difesa,forze armate,rapporti con le confessioni religiose,tutela dei beni culturali ecc.).In questo modo si operava un vero e proprio capovolgimento della precedente logica di riparto:prima della legge 59/1997 infatti,la Regione esercitava

This document is available free of charge on StuDocu.com

esclusivamente le funzioni amministrative nelle materie in cui aveva competenza legislativa. Con la riforma Bassanini si realizzava,pertanto,un'interpretazione evolutiva dell'art.118 Cost.,in virtù della quale le funzioni amministrative venivano attribuite in linea di principio,a Regioni ed enti locali anche nelle materie in cui lo Stato aveva la titolarità della funzione legislativa. Sulla base dei principi indicati nella legge delega 1997,sono stati emanati alcuni decreti legislativi che hanno avviato un processo di riorganizzazione dello Stato in senso regionalista e autonomista:questo processo era avviato a "costituzione invariata",e quindi vennero pure avanzati dubbi circa l'effettiva compatibilità delle soluzioni adottate con la disciplina costituzionale. A ciò si aggiungevano le spinte di alcune forze politiche e di correnti di opinioni favorevoli a spostare sul terreno della riforma costituzionale il processo di ristrutturazione dello Stato in senso regionalista e autonomista:tutto ciò ha portato alla riforma del Titolo V.
Con la legge n.59 del 1997 è stato introdotto pure il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA',che parte dalla posizione basilare del Comune,quale ente più vicino alla comunità amministrata,ed ammette il conferimento di funzioni a livello più elevato solo per l'accertata impossibilità di curare in modo adeguato certi interessi nell'ambito del comune stesso. Si è così scalfita l'originaria concezione del "PARALLELISMO DELLE FUNZIONI",per cui nelle materie di competenza legislativa delle Regioni,queste ultime esercitavano anche le funzioni amministrative,mentre in tutte le altre, le funzioni amministrative erano imputate allo Stato,sulla base non soltanto del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'(il livello di governo superiore interviene solo quando l'amministrazione più vicina ai cittadini non possa da sola assolvere al compito),ma anche del PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE(enti dello stesso livello possono avere competenze diverse)e del PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA(le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza). La legge costituzionale n.3 del 2001 ha costituzionalizzato il principio di sussidiarietà,stabilendo che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,per assicurarne l'esercizio unitario,siano da conferire a Province,Regioni e Stato,sulla base dei principi di sussidiarietà,differenziazione e adeguatezza(art.118 comma I Cost.nel testo riformato). Pertanto,a seguito della riforma costituzionale,tutte le funzioni dell'amministrazione pubblica dovrebbero essere tendenzialmente assegnate ad un'AMMINISTRAZIONE LOCALE,salvo che non vi sia l'esigenza di unificarne l'esercizio ad un livello più elevato.
Anche il principio di sussidiarietà è fortemente ambiguo,perché dovrà essere,di volta in volta,determinato quando e perché una certa funzione non può essere esercitata a livello locale:esso è tuttavia molto utile come chiave interpretativa,perché dovrebbe servire da criterio-guida della giurisprudenza costituzionale,seconda una tendenza di massima espansione dell'autonomia locale e di restrizione minimale dell'intervento legislativo e amministrativo dei livelli superiori. Solo l'esperienza potrà dirci quanto la nuova normativa sarà in grado di evitare un rinnovato centralismo;vero è per il momento che,senza un adeguato contrappeso all'interno del potere legislativo dello Stato,le leggi statali potrebbero ricominciare a erodere le competenze regionali,senza

che la Corte costituzionale possa,da sola,impedire tale processo. Si era perciò inizialmente pensato all'introduzione di una "CAMERA DELLE REGIONI E/O DELLE AUTONOMIE"che avrebbe potuto provvedere,di volta in volta,all'esatta determinazione di ciò che può fare lo Stato e di ciò che è invece attribuito alle Regioni,ma tale organo di raccordo non è stato previsto dalla riforma costituzionale del 2001. Attualmente,pertanto,i principali organi di raccordo sono la COMMISSIONE BICAMERALE INTEGRATA e la CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI FRA LO STATO,LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME. La Commissione parlamentare per le questioni regionali è un organo bicamerale previsto dalla Costituzione del '48 per svolgere compiti consultivi,limitati essenzialmente all'ipotesi di scioglimento anticipato dei Consigli regionali. La nuova disciplina introdotta dalla riforma costituzionale del 1999 prevede(art.126 Cost.)che,con decreto motivato del Presidente della Repubblica,e sentita la Commissione bicamerale,siano disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrati alla Costituzioni o gravi violazioni di legge,oppure ancora per ragioni di sicurezza nazionale. Ma è stato l'art.11 legge cost.3/2001 a valorizzare la Commissione,con l'attribuzione di rilevanti funzioni di raccordo tra Stato e Regioni. Esso prevede infatti la partecipazione di rappresentanti della Regione,delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione bicamerale;ma,a diversi anni di distanza,nessun atto attuativo è stato deliberato,e l'ipotesi della Commissione bicamerale integrata sembra ormai del tutto abbandonata.
In ultimo,c'è da dire che la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V ha offerto conferma della fallacia del criterio di ripartizione della competenza legislativa basato sull'elencazione delle materie,anche dopo l'inversione del criterio di riparto a favore delle Regioni. Con visibili intenti di tutela di valori fondamentali,la Corte ha costruito "materie TRASVERSALI"(tutela dell'ambiente,della concorrenza ecc.)nelle quali la linea di confine tra competenza statale e regionale non può essere tracciata a priori,ma solo dopo valutazione sistematica del singolo intervento legislativo in relazione ai beni da tutelare. Con legge cost. n. 1 del 2012, la materia armonizzazione dei bilanci pubblici è stata spostata al comma III dell'art. 117 passando alla competenza esclusiva dello Stato ai fini di coesione economico-finanziaria.

26.LA POSIZIONE DELLA LEGGE REGIONALE NEL SISTEMA DELLE FONTI: La legge regionale è una legge in senso tecnico,cioè un atto avente l'efficacia(formale e sostanziale)ed il valore(vale a dire la sottoponibilità al giudizio di legittimità della Corte costituzionale,ai sensi dell'art.134 Cost.)della legge.Come tale,la legge regionale è subordinata alla Costituzione,sia nel suo contenuto(che non può essere contrario o derogare alle norme costituzionali)sia per il rispetto dei limiti posti dalla Costituzione all'esercizio della potestà legislativa regionale.
Si discute,invece,se la legge regionale sia subordinata o pari ordinata nei confronti della legge dello Stato. Ora,poiché le due fonti sono separate,nel senso che il loro ambito di competenza è tenuto distinto nelle norme costituzionali,sembra che fra loro

This document is available free of charge on StuDocu.com

non possa esserci rapporto di pari ordinazione o di subordinazione. Ciò non toglie,tuttavia,che la legge statale possa condizionare la validità della legge regionale (si pensi alle leggi che stabiliscono i principi fondamentali per ciascuna materia di competenza regionale,alle leggi che pongono le norme delle riforme economico-sociali e alle leggi che danno esecuzione in Italia agli accordi internazionali). Di converso,esistono dei limiti posti dalle norme costituzionali all'operatività delle leggi statali:così la legge statale non può disciplinare le materie attribuite alla competenza primaria delle Regioni;non può contenere norme di sviluppo e di dettaglio nelle materie attribuite alla competenza ripartita(ma soltanto "principi fondamentali appunto). Il rapporto fra la legge statale e quella regionale non appare quindi ordinato secondo il criterio gerarchico,per cui la prima(anche quando fissa il limite dei principi o da esecuzione agli obblighi internazionali)non è sovraordinata alla seconda,con la conseguenza che le eventuali antinomie fra le due fonti vanno risolte non invocando la maggiore FORZA(intesa come efficacia formale)della fonte statale.La delimitazione costituzionale degli ambiti di competenza esclude infatti un rapporto di tipo gerarchico fra queste due fonti.

27. I REGOLAMENTI REGIONALI: La potestà regolamentare è attribuita dagli Statuti alla Giunta regionale nelle regioni ad autonomia speciale,tranne la Valle d'Aosta e la Sardegna,regioni in cui tutti i poteri normativi sono concentrati nel Consiglio. Il principio della separazione delle funzioni era applicato rigidamente invece nelle regioni di diritto comune,nelle quali,secondo il testo costituzionale originario,"Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione" e "La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni"(art.121,II e III comma Cost.).La legge costituzionale n.1 del 1999 ha modificato l'art.121,eliminando la competenza regolamentare del Consiglio:l'attribuzione alla Giunta della potestà regolamentare ha consentito dunque una stretta connessione dei regolamenti con le attribuzioni degli organi esecutivi,oltre che una maggiore speditezza nella loro emanazione.

Le funzioni amministrative

28. Le funzioni amministrative regionali e locali-Il nuovo testo dell'art.118 Cost.,introdotto dalla legge cost. n.3 del 2001,oltre a contenere il principio di sussidiarietà stabilisce che i Comuni,le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale,secondo le rispettive competenze.
La sfera di competenza amministrativa degli enti locali riceve così una garanzia costituzionale,che dovrebbe preservare tali enti dall'accentramento regionale,non meno soffocante di quello statale.
L'art.4,comma 3,della legge n.59 del 1997 disciplina la ripartizione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo(nazionale,regionale e locale),sancendo una serie di principi,alcuni dei quali assumono il rango di principi costituzionali,e precisamente: il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'(art.118 Cost. "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio

unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza."); il PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE,che impone di tener conto delle diverse caratteristiche demografiche,territoriali e strutturali degli enti attributari; il PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA,che implica l'idoneità organizzativa dell'amministrazione attributaria a garantire l'esercizio delle funzione. Il principio di sussidiarietà implica pure che tutti gli enti pubblici,dallo Stato al Comune,devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini,singoli o associati:viene così superata una concezione passiva dello Stato sociale,stimolando l'attivismo dei privati. A norma dell'art.120,comma II,Cost.(nel nuovo testo introdotto dalla legge cost.n.3 del 2001),il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni(nonché delle Città metropolitane e dei Comuni)nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria,oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica o quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica.

29. Il difensore civico. Gli Statuti di molte regioni prevedono l'istituzione di un difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale o provinciale, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini,

SEZIONE V- L'AUTONOMIA FINANZIARIA

30. Principi generali- L'art.119 Cost.(dopo la riforma del 2001)stabilisce che i Comuni,le Province,le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa(autonomia che,secondo la classica espressione del Mortati,è una vera e propria "pietra angolare" dell'autonomia regionale). Dall'art.119 Cost.risulta che la finanzia delle Regioni di diritto comune e degli enti locali si basa sulle seguenti entrate: entrate derivanti dal proprio patrimonio,attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato; tributi propri stabiliti e applicati in armonia con la Costituzione; eventuali risorse aggiuntive derivanti da interventi speciali dello Stato in favore di determinate Regioni o enti locali per promuovere lo sviluppo economico,per rimuovere gli squilibri economici e sociali ecc. (Le Regioni e gli enti locali possono stabilire ed applicare tributi propri "in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario",ai sensi dell'art.119 comma II Cost. Perchè questo disegno costituzionale possa essere attuato è necessario però l'intervento del legislatore nazionale,al quale spetta,secondo la Corte costituzionale,non solo di fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi,ma anche determinare le linee dell'intero sistema tributario,e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva,rispettivamente,di Stato,Regioni ed enti locali. Quella tributaria è insomma una rivoluzione promessa.). Con legge cost. n. 1 del 2012, a decorrere dall'anno finanziario 2014, è stato introdotto il principio di pareggio di bilancio anche per Comuni, Provincie e Regioni, mediante una modifica all'art. 119.

This document is available free of charge on StuDocu.com

31. Il federalismo fiscale ed il fondo perequativo- in Italia esistono vasti dislivelli nella ricchezza, nel reddito e quindi nella capacità fiscale. L'art. 119 al comma III, prevede che venga istituito un fondo perequativo per i territori con meno capacità fiscale per abitante. L'aiuto dello Stato deve, però, essere impiegato responsabilmente e non per spese irragionevoli (cd. Finanza allegra). Sono posti 2 limiti rigorosi: le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento; è esclusa ogni garanzia dello Stato sui loro prestiti. Il Governo è chiamato ad adottare decreti legislativi per attuare l'art. 119 Cost.

SEZIONE VI- I CONTROLLI SUGLI ORGANI DIRETTIVI DELLE REGIONI: Gli organi direttivi delle Regioni(Consiglio,Giunta,Presidente della Giunta)sono sottoposti a controllo ai sensi dell'art.126 Cost.:tale controllo non ha per oggetto un atto,bensì un comportamento o un'attività dell'organo. Al contrario di quanto avviene nel controllo di legittimità sugli atti,manca in questo caso un puntuale paradigma(che nel controllo di legittimità è dato appunto dalla legge)cui raffrontare il comportamento o l'attività dell'organo,con la conseguenza che questo tipo di controllo può essere esercitato secondo un certo margine di discrezionalità politica.

32. Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta-Le misure sanzionatorie previste sono date dallo scioglimento del Consiglio regionale e dalla rimozione del Presidente della Giunta;a norma del nuovo testo dell'art.126 Cost. introdotto dalla legge cost.n.1 del 1999,il Consiglio regionale può essere sciolto e il Presidente della Giunta può essere revocato: -quando abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge; -per ragioni di sicurezza nazionale. Il Consiglio può essere sciolto: -quando sia stata votata una mozione di sfiducia al Presidente della Giunta; per dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri. scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica,sentita una Commissione di deputati e senatori per le questioni regionali. ***33. Il procedimento-*** Il procedimento di scioglimento del Consiglio regionale consta di 2 fasi: una preparatoria ed una costitutiva.

SEZIONE VII-LE PROVINCE,I COMUNI E GLI ALTRI ENTI LOCALI: La Costituzione,oltre a contenere il principio generale della tutela e della promozione delle autonomie locali(art.5 Cost.) che caratterizza lo Stato italiano come Stato decentrato,fa espressa menzione di Province e Comuni nell'art.114 Cost.,a norma del quale "La Repubblica è costituita dai Comuni,dalle Province,dalle Città metropolitane,dalle Regioni e dallo Stato." Nel 2000 è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,che raccoglie in modo organico la vasta legislazione statale in materia.

LA PROVINCIA: E' l'ente locale intermedio tra Comune e Regione,il quale rappresenta la propria comunità,ne cura gli interessi,ne promuove e coordina lo sviluppo. Spettano alla Provincia,a norma degli art.19 e seguenti del T.U.del 2000,le funzioni amministrative di interesse provinciale(difesa del suolo,tutela e

valorizzazione dell'ambiente,prevenzione delle calamità,valorizzazione dei beni culturali,la protezione della flora e della fauna,i parchi e le riserve naturali,la caccia e la pesca nelle acque interne,i servizi sanitari attribuiti dalla legislazione statale e regionale ecc.).Come ente di programmazione,la Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica,territoriale ed ambientale,concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali. ***IL COMUNE***: E' l'ente locale che rappresenta la propria comunità,ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Spettano al Comune,ai sensi degli art.13 e seguenti del T.U.del 2000,tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale nei settori dei servizi alla persona e alla comunità,dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico,salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle legge statale o regionale. Il Comune gestisce inoltre i servizi elettorali,di anagrafe,di stato civile,di statistica e di leva militare;le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo. ***ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA-*** Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco; sono organi della Provincia, il Consiglio, la Giunta e il Presidente. Le elezioni e la durata in carica sono regolati dalla legge. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico- amministrativo. La Giunta comunale e quella provinciale sono composte dal Sindaco e dal Presidente che le presiedono, e dagli assessori. Nei Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti e nelle Province, gli assessori sono nominati dal Sindaco e dal Presidente. Questi ultimi sono eletti con sistema maggioritario a doppio turno e a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni del Consiglio. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non rientrino nella competenza di Consiglio e Presidente o nel comune al segretario e ai funzionari dirigenti. Sindaco e Presidente rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta e il Consiglio. Il Sindaco, il Presidente e le relative Giunte cessano dall'ufficio, in seguito a una mozione di sfiducia da parte del Consiglio, votata a maggioranza assoluta- in tal caso si procede alla nomina di un Commissario.

Il decentramento infracomunale- l'art. 17 del T.U. del 2000, stabilisce che i Comuni con popolazione superiore a 250000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Tale istituzione è facoltativa per i Comuni con popolazione dai 100000 e fino ai 250000 abitanti. Tuttavia, la finanziaria 2010, a fronte della crisi, questi organismi sono stati soppressi.

IL MUTAMENTO DI CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI E COMUNALI: Il distacco di una provincia o di un comune e la sua aggregazione ad un'altra regione sono disposte con legge della Repubblica,sentiti i Consigli regionali e,mediante referendum,le popolazioni interessate(art.132 comma II Cost.). Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con legge della Repubblica,su iniziativa dei Comuni,sentita la stessa Regione(art.133 comma I Cost.).L'istituzione di nuovi comuni nel territorio regionale

This document is available free of charge on StuDocu.com

e la modifica delle circoscrizioni e denominazioni è invece affidata alla legge regionale,sentite le popolazioni interessate(art.133 comma II Cost.).